



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Gli orientamenti delle Sezioni Civili

II

Anno 2024



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO

Rassegna della giurisprudenza di legittimità

Gli orientamenti delle Sezioni Civili

Anno 2024

VOLUME II

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

VOLUME SECONDO

I PRINCIPI DI DIRITTO SOSTANZIALE

PARTE QUARTA

IMPRESA E MERCATO

(Coordinato da Alessandro Farolfi e Cecilia Bernardo)

CAPITOLO XVI

I DIRITTI DI PRIVATIVA E LA CONCORRENZA *(di Paolo Fraulini)*

1. Il marchio.	293
2. Il brevetto.	294
3. Le condotte anticoncorrenziali <i>ex lege</i> 10 ottobre 1990, n. 287.	294
4. La concorrenza sleale.	296
5. I diritti del consumatore.	297
6. Il diritto d'autore.	299

CAPITOLO XVII

IL DIRITTO DELLE SOCIETÀ *(di Cecilia Bernardo, Guido Romano, Aldo Ruggiero)*

1. Le società in generale.	300
1.1. Le vicende modificative ed estintive delle società.	300
1.2. Cessione di partecipazioni societarie.	301
1.3. Profili processuali.	303
2. Le società di persone.	306
2.1. Autonomia sostanziale e processuale della società rispetto ai singoli soci.	306
2.2. Continuazione dell'attività di impresa e scioglimento del rapporto sociale.	307
3. Le società di capitali.	309
3.1. Le azioni e le quote sociali.	309
3.2. Finanziamenti e conferimenti a vario titolo.	309
3.3. Le deliberazioni dell'assemblea.	310
3.4. Il compenso degli amministratori e dei sindaci.	312
3.5. Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.	313
3.6. La responsabilità da direzione e coordinamento.	319
3.7. La revoca dell'amministratore e il recesso del socio.	319
3.8. Le operazioni straordinarie.	320
3.9. I patti parasociali.	321

4. Particolari società di capitali.	322
4.1. Le società cooperative.	322

CAPITOLO XVIII

IL DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI *(di Alessandro Farolfi)*

1. Questioni pregiudiziali.	324
2. Intermediazione finanziaria.	325
3. I rapporti bancari.	328
4. La responsabilità della banca.	331
5. Titoli di credito.	333

CAPITOLO XIX

IL DIRITTO DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA *(di Alessandro Farolfi e Aldo Ruggiero)*

1. Il fallimento dell'imprenditore: i presupposti.	335
1.1. L'estensione del fallimento e le società cancellate.	337
1.2. Il procedimento prefallimentare.	338
1.3. I reclami avverso la sentenza di fallimento.	339
2. Gli organi delle procedure concorsuali.	340
2.1. I reclami endoconcorsuali.	341
3. I pagamenti e le azioni di inefficacia.	342
3.1. Le azioni <i>ex art.</i> 66 l.fall.	342
3.2. Le revocatorie fallimentari.	343
4. I rapporti pendenti.	345
5. La formazione dello stato passivo.	346
5.1. <i>Segue:</i> profili processuali.	351
6. La liquidazione dell'attivo.	353
7. La chiusura del fallimento e l'esdebitazione	355
8. Il concordato fallimentare.	356
9. Il concordato preventivo in generale.	356
9.1. <i>Segue:</i> l'ammissione, la revoca, l'omologa.	359
10. La liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria.	362

APPROFONDIMENTO TEMATICO

IL D.LGS. N. 136 DEL 2024 (C.D. CORRETTIVO) E LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

(di Alessandro Farolfi)

1. Uno sguardo d'insieme.	366
2. La nuova fase di accesso al concordato preventivo: la domanda con riserva.	367

3. Le modifiche alla disciplina della proposta concordataria	370
4. Ulteriori modifiche: in particolare l'omologazione nel caso di ristrutturazione "tra- sversale".	372
5. Entrata in vigore.. . . .	375

PARTE QUINTA

IL DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA

(Coordinato da Antonella Filomena Sarracino)

CAPITOLO XX

IL LAVORO PRIVATO: DIRITTI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ (di Manuel Bianchi)

1. Le fonti.	377
2. Il diritto sindacale.	378
3. La retribuzione.	378
3.1. Il T.F.R..	381
3.2. La progressione economica orizzontale.. . . .	382
3.3. Prescrizione e decadenza.	382
4. I caratteri e l'oggetto della prestazione lavorativa.. . . .	383
4.1. Diligenza, buona fede e fedeltà.	383
4.2. Luogo.	384
4.3. Orario.	384
4.4. Astensione dal lavoro: festività, ferie e permessi.	386
4.4.1. Segue: malattia e periodo di comportamento.	387
4.4.2. Segue: l'esercizio del diritto di sciopero.	388
4.5. Mansioni e demansionamento.	389
5. La tutela <i>ex art.</i> 2087 c.c., le condotte discriminatorie e il <i>mobbing</i>	391
6. La distinzione fra lavoro autonomo e subordinato.	392
7. Il lavoro in apprendistato, a termine, somministrato, intermittente, a progetto.. . . .	393
7.1. La collaborazione nell'impresa familiare.	395
8. Il datore di lavoro: appalto, trasferimento d'azienda, intermediazione di manodopera.	395
9. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore.	398
10. Le rinunzie e transazioni del lavoratore.	398
11. Il contratto di agenzia.	399

CAPITOLO XXI

IL LICENZIAMENTO (di Luigi Di Paola)

1. Potere disciplinare.	401
2. Licenziamento individuale: i rilevanti interventi della Corte costituzionale.. . . .	403
2.1. Onere di comunicazione per iscritto.	404

2.2. La rinnovazione del licenziamento e la violazione di <i>bis in idem</i> .	404
2.3. La revoca del licenziamento.	405
2.4. Licenziamento ritorsivo e discriminatorio.	405
2.5. Giusta causa e giustificato motivo soggettivo di licenziamento.	406
2.6. Giustificato motivo oggettivo di licenziamento.	408
2.7. Periodo di comportamento e licenziamento.	409
2.8. L'impugnazione del licenziamento e le decadenze.	410
2.9. Il licenziamento ingiurioso.	411
2.10. Applicazioni della legge "Fornero".	411
2.11. Le conseguenze del licenziamento illegittimo.	411
2.12. Il preavviso.	412
2.13. Il licenziamento del dirigente.	413
2.14. La risoluzione del rapporto nel lavoro nautico.	413
3. Licenziamenti collettivi.	413

CAPITOLO XXII

IL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO PRIVATIZZATO (di Luca D'addario)

1. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: introduzione.	416
2. I principi generali.	416
3. La costituzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego privatizzato.	418
3.1. Il reclutamento mediante procedure concorsuali: regole ed eccezioni. Le progressioni di carriera.	418
3.2. I contratti di lavoro flessibili.	423
4. Retribuzione e altri trattamenti economici.	424
5. Parità di trattamento.	431
6. Classificazione del personale: categorie qualifiche e mansioni.	431
7. Mobilità.	433
7.1. Comando e distacco.	436
8. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.	437
9. Illeciti disciplinari.	438
9.1. Obblighi vaccinali Covid.	443
10. La cessazione del rapporto di lavoro.	443
11. La dirigenza.	444
12. Il personale scolastico.	450
13. Le azioni di ripetizione del pagamento indebito.	454

CAPITOLO XXIII

LE VICENDE DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA (di Mario De Ioris)

1. L'obbligazione contributiva e i soggetti obbligati.	455
2. La retribuzione imponibile e il minimale retributivo.	457
3. Gli sgravi e i benefici contributivi.	458

4. Totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali..	459
5. Omissione contributiva e posizione del lavoratore..	460
6. Accertamento e riscossione..	462
7. La prescrizione dei crediti contributivi..	462
8. Gli elenchi dei lavoratori agricoli.	464
9. La prosecuzione volontaria del versamento dei contributi.	464

CAPITOLO XXIV

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI *(di Mario De Ioris)*

1. La contribuzione figurativa e le maggiorazioni contributive.	465
2. Le prestazioni pensionistiche.	468
3. Il cumulo dei trattamenti: divieti e facoltà di opzione..	473
4. L'indennità di disoccupazione..	474
5. L'indennità di mobilità.	475
6. L'Assicurazione sociale per l'Impiego (ASpI).	476
7. La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI)	477
8. La Cassa integrazione guadagni..	479
9. Il TFR e le altre prestazioni corrisposte dal Fondo di garanzia <i>ex art. 2 della</i> legge n. 297 del 1982.	479
10. Indennità di buonuscita e trattamenti analoghi..	480
11. L'indebito previdenziale.	481
12. La responsabilità per danni degli enti previdenziali e nei loro confronti.	483

CAPITOLO XXV

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI *(di Mario De Ioris)*

1. Premessa.	485
2. L'invalidità civile..	485
3. Le misure di sostegno previste per l'emergenza pandemica da Covid-19..	486
4. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fruite all'estero..	486
5. Le prestazioni a beneficio delle vittime del dovere e di soggetti assimilati..	487
6. Le prestazioni in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni o emotrasfusioni.	488
7. Le provvidenze a sostegno della natalità.	489

CAPITOLO XXVI

LA TUTELA INAIL *(di Mario De Ioris)*

1. Premessa.	490
2. I soggetti beneficiari dell'assicurazione obbligatoria..	490
3. Le prestazioni erogate dall'INAIL ed i requisiti per il loro riconoscimento.	491
4. L'azione di regresso dell'INAIL.	492

CAPITOLO XXVII

LA PREVIDENZA DI CATEGORIA *(di Mario De Ioris)*

1. Le Casse professionali..	494
2. Geometri..	494
3. Dottori commercialisti..	494
4. Medici..	496
5. Ingegneri e architetti..	496
6. Notai..	497
7. Gli assicurati presso l'ENPAIA..	497

CAPITOLO XXVIII

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA *(di Mario De Ioris)*

1. Finalità della previdenza complementare, natura dei relativi versamenti e mezzi di tutela contro il datore di lavoro insolvente..	498
2. Le forme di previdenza integrativa per il personale del pubblico impiego..	498
3. Alcuni casi controversi di legittimazione passiva..	499

PARTE SESTA

I RAPPORTI CON I PUBBLICI POTERI

(Coordinato da Alessandro Farolfi e Cecilia Bernardo)

CAPITOLO XXIX

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ *(di Giulia Stano)*

1. Premessa..	500
2. Giurisdizione..	500
3. Aspetti processuali..	501
4. Procedimento espropriativo..	501
5. Determinazione delle indennità di espropriazione e occupazione. Altre indennità..	502
6. Opposizione alla stima..	506
7. Ipotesi diverse di acquisizione in capo alla p.a..	507
8. Casi particolari: la facoltà di riacquisizione di aree attribuita ai Consorzi di sviluppo industriale ex art. 63 l. n. 448 del 1998..	507

CAPITOLO XXX

APPALTI PUBBLICI *(di Francesca Della Valle)*

1. Il contratto di appalto..	509
2. L'esecuzione del contratto..	510

3. L'arbitrato negli appalti pubblici.	512
4. Il subappalto.	513

CAPITOLO XXXI

LE SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING *(di Giulia Stano)*

1. Premessa.	514
2. Requisito del cd. controllo analogo congiunto.	514
3. Riparto di giurisdizione e violazione dei limiti esterni della giurisdizione.	515
4. Contratto di collaborazione a progetto e rapporto di lavoro a tempo indeterminato.	516
5. Questioni relative all'affidamento del servizio idrico integrato.	517

CAPITOLO XXXII

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE *(di Olimpia Monaco)*

1. Principi generali, struttura impugnatoria del giudizio di opposizione e regole processuali.	518
2. Giurisdizione.	522
3. Competenza ed incompetenza.	523
4. Cumulo materiale e concorso di persone.	524
5. La responsabilità solidale.	525
6. Prescrizione.	525
7. Sanzioni in ambito bancario e finanziario: profili procedurali e processuali.	526
8. Abuso di informazioni privilegiate.	527
9. Ulteriori pronunce riguardanti le sanzioni in ambito bancario e finanziario.	528
10. Le sanzioni amministrative previste dal codice della strada: modalità di accertamento.	528
11. Il verbale di constatazione delle violazioni al codice della strada: natura, requisiti e notificazione.	529
12. L'opposizione: il rito, la competenza, l'oggetto e gli effetti.	530
13. Le violazioni sanzionate dal codice della strada.	532
14. Le altre sanzioni.	532

CAPITOLO XXXIII

ELEZIONI E GIUDIZI ELETTORALI *(di Giulia Stano)*

1. Premessa.	534
2. Diritto di elettorato passivo.	534
3. Diritto di elettorato attivo e appartenenza di genere.	536
4. Spese elettorali.	537

CAPITOLO XXXIV

I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI *(di Olimpia Monaco - Luca D'Addario)*

1. Premessa.	539
2. La responsabilità disciplinare dei magistrati.	539

2.1. Gli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni.	539
2.2. Concorso formale tra illeciti funzionali.	541
3. Il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio.. . . .	541
4. Il giudizio disciplinare.	541
4.1. Revoca del provvedimento di archiviazione disposto ai sensi dell'art. 16, comma 5- <i>bis</i> , del d. lgs. n. 109 del 2006.	542
4.2. La sospensione dei termini del procedimento disciplinare.	542
4.3. La revoca della misura cautelare e la sospensione cautelare.. . . .	542
4.4. Cessazione del rapporto di servizio e cessazione della materia del contendere.. . . .	543
4.5. L'utilizzo di intercettazioni.	543
4.6. La sanzione della rimozione a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006.. . . .	544
4.7. La revisione della sentenza.. . . .	544
5. La responsabilità disciplinare degli avvocati.. . . .	544
5.1. Gli illeciti disciplinari.	544
5.2. La concreta individuazione delle condotte illecite.	545
5.3. Il Consiglio distrettuale di disciplina, elezione dei componenti e natura del giudizio disciplinare dinanzi al medesimo.. . . .	545
5.4. Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione resa dal Consiglio distrettuale di disciplina.. . . .	546
5.5. L'impugnazione dinanzi alle Sezioni Unite della decisione del Consiglio Nazionale Forense.	546
5.6. La riassunzione del giudizio disciplinare a seguito di cassazione con rinvio della decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense.	546
6. La responsabilità disciplinare dei notai.	547
6.1. Gli illeciti disciplinari.	547
6.2. Il ravvedimento.	548

VOLUME SECONDO

I PRINCIPI DI DIRITTO SOSTANZIALE
(coordinato da Luigi La Battaglia)

PARTE QUARTA

IMPRESA E MERCATO

(coordinata da Alessandro Farolfi)

CAPITOLO XVI

I DIRITTI DI PRIVATIVA E LA CONCORRENZA

(DI PAOLO FRAULINI)

SOMMARIO: 1. Il marchio. - 2. Il brevetto. - 3. Le condotte anticoncorrenziali *ex lege* 10 ottobre 1990, n. 287. - 4. La concorrenza sleale. - 5. I diritti del consumatore. - 6. Il diritto d'autore.

1. Il marchio.

Sul tema della registrabilità del segno, Sez. 1 n. 18683/2024, G. Iofrida, Rv. 671673-02 ha dichiarato invalida la registrazione di un segno come marchio, se essa possa indurre nel pubblico l'erronea convinzione che il prodotto provenga da un'area territoriale nota per le eccellenti qualità di quel prodotto, giacché in tale ipotesi si verifica un effetto distorsivo del mercato, ingenerato dall'inganno subito dai consumatori - portati a credere che il prodotto che viene loro proposto provenga da una certa area geografica e goda dei pregi per cui essa è nota - e ciò a prescindere dall'appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione dell'area geografica in capo a chicchessia e in particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno.

Sul medesimo tema, Sez. 1, n. 5866/2024, G. Iofrida, Rv. 670559-01, ha statuito che la nullità per la registrazione del marchio in malafede *ex art.* 19 c.p.i., concernendo una condotta autonoma che presuppone la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, desumibile, in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto d'interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare, si differenzia dalla nullità per difetto di novità *ex art.* 12 c.p.i., che invece presuppone la valutazione dei requisiti di registrabilità del marchio posteriore alla luce dell'esistenza di anteriori diritti su marchi o altri segni distintivi.

In tema di denominazioni di origine, Sez. 1, n. 10350/2024 G. Iofrida, Rv. 671088-01, ha affermato che l'art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. UE n. 1151 del 2012, essendo finalizzato a tutelare l'origine geografica del prodotto, vieta le condotte evocative che, comunque, ad essa facciano riferimento, non estendendosi all'utilizzo esclusivo di singoli termini non geografici, generici e comuni, sui quali non è consentito un monopolio da parte del soggetto registrante.

In tema di contitolarità dell'uso del marchio, Sez. 1, n. 10637/2024, F. Terrusi, Rv. 670886-01, ha affermato che in caso di comunione sul marchio, il contratto di licenza d'uso del segno distintivo a terzi in via esclusiva richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari, perché la concessione al licenziatario dell'esclusiva priva i contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, assumendo rilievo contrario il disposto dell'art. 1108, commi 1 e 3, c.c., soggiungendo, Rv. 670886-02, che in caso di comunione sul marchio che sia stato concesso in licenza d'uso esclusiva a favore di terzi, con l'accordo di tutti i suoi contitolari, è sempre possibile il venir meno della volontà di prosecuzione di uno dei medesimi, il quale non può ritenersi vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria; tale circostanza implica la necessità di rinegoziare l'atto mediante una nuova concessione, da concordare nuovamente con l'unanimità dei consensi.

A tenore di **Sez. 1, n. 33614/2024, D. Valentino, Rv. 673402-01**, in tema di marchi d'impresa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005, il preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà di esso, o che ne importi una notorietà puramente locale, non esclude la novità del marchio successivo e, quindi, la possibilità che il medesimo sia registrato; tuttavia, il detto preuso locale conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone, senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato.

2. Il brevetto.

Sul tema delle limitazioni all'uso del brevetto farmacologico, **Sez. 1, n. 18372/2024, G. Iofrida, Rv. 671668-01**, ha sancito che la c.d. "*Bolar clause*" o "esenzione Bolar", secondo cui sono consentite le attività di sperimentazione di un farmaco coperto da altrui brevetto finalizzate all'ottenimento di un'autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio del farmaco dopo la scadenza del brevetto altrui, persegue il fine di agevolare il tempestivo ingresso sul mercato dei farmaci generici per non prolungare, di fatto, la durata della privativa, consentendo ai produttori genericisti di iniziare le attività amministrative e di sperimentazione prodromiche all'ottenimento di un'AIC (autorizzazione immissione in commercio), pur in costanza del brevetto di riferimento; conseguentemente, tale esenzione può essere invocata anche dal terzo che produce il principio attivo del farmaco brevettato per finalità registrative non proprie, ma di terzi genericisti non attrezzati a produrre in proprio, ma intenzionati ad entrare nel mercato alla scadenza dell'esclusiva del titolo brevettuale, a condizione che - oltre alla preventiva richiesta da parte del genericista - tale finalità registrativa sia indicata a livello negoziale quale limite di utilizzo, come previsione dell'impegno all'uso del principio attivo secondo le finalità Bolar.

In tema di forma dei contratti di licenza d'uso, **Sez. 2, n. 17157/2024, A. Mondini, Rv. 671375-01**, ha affermato che il contratto di licenza d'uso di una banca dati non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, la prova della sua stipulazione può essere data anche mediante presunzioni vertenti sull'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo.

Sui brevetti agricoli, **Sez. 1, n. 9429/2024, E. Campese, Rv. 670722-01**, ha statuito che è nulla, per contrarietà all'ordine pubblico, stante la violazione dell'art. 13, punti 2 e 3, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la clausola contrattuale che attribuisce al titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui coltivati brevettati anche il potere di individuare i soggetti ai quali spetterà in via esclusiva la distribuzione dei frutti ottenuti dal produttore precedentemente autorizzato all'utilizzo dei costituenti varietali della varietà protetta da cui quei frutti siano stati prodotti, ove questi ultimi siano inutilizzabili come materiale di moltiplicazione.

A tenore di **Sez. 1, n. 31995/2024, M. Falabella, Rv. 673233-01**, in tema di controversie sulla validità e contraffazione del brevetto, la trasformazione, a norma dell'art. 58, comma 2, c.p.i., in modello di utilità, del brevetto europeo che sia stato revocato, costituisce fattispecie diversa dalla conversione giudiziale disciplinata dalla norma di cui all'art. 76, comma 3, c.p.i. e, pertanto, non giustifica, a seguito del maturarsi nel giudizio delle preclusioni assertive, alcuna immutazione del thema decidendum della causa.

3. Le condotte anticoncorrenziali ex lege 10 ottobre 1990, n. 287

In ambito di abuso di posizione dominante, **Sez. 3, n. 3052/2024, Rossetti, Rv. 670081-02**, ha affermato che la definizione del mercato rilevante di un prodotto o servizio, quando

si tratti di stabilire se una clausola contrattuale sia o meno il frutto di una imposizione abusiva, deve essere condotta avuto riguardo a sei criteri indefettibili: a) l'area geografica di diffusione del prodotto o servizio; b) la sostituibilità del prodotto da parte di chi lo domanda; c) la sostituibilità del prodotto da parte di chi lo offre; d) l'esistenza di pressioni concorrenziali; e) la possibilità di interferenza con altri mercati; f) la struttura del mercato.

Sul medesimo tema, **Sez. 1, n. 9/2024, Reggiani, Rv. 669815-01**, ha statuito che l'abuso escludente, che rientra nell'ambito della fattispecie di abuso della posizione dominante, sussiste, come chiarito da CGUE, Sentenza n. 377 del 12/05/2022, in causa C-719/2022, quando la pratica realizzata da un'impresa in posizione dominante sia idonea a produrre un effetto escludente e sia basata sull'utilizzo di mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza normale, ossia fondata sul merito, tali essendo quelli per i quali non vi è alcun interesse economico se non quello di eliminare i concorrenti per poter poi rialzare i prezzi, traendo profitto dalla situazione di monopolio, sì da pregiudicare la penetrazione o il mantenimento sul mercato di imprese concorrenti in ragione del merito. In presenza di tali due condizioni, l'impresa in posizione dominante può sottrarsi al divieto di cui all'art. 102 TFUE, purché dimostri che la pratica in questione era obiettivamente giustificata da circostanze ad essa esterne o dall'interesse dei consumatori, e proporzionata a tale giustificazione oppure controbilanciata, se non superata, da vantaggi in termini di efficienza che vanno a beneficio anche dei consumatori.

In tema di intese restrittive, **Sez. 3, n. 7834/2024, Gorgoni, Rv. 670712-02**, ha affermato che la legittimazione a far valere la violazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza spetta non solo agli imprenditori, ma a tutti i soggetti del mercato che hanno subito un danno dal comportamento anticoncorrenziale.

Sulla medesima questione, **Sez. 3, n. 12007/2024, Tatangelo, Rv. 670868-01**, ha statuito che i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati "in applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE. La sentenza ha, inoltre, precisato, **Rv. 670868-03**, che le predette clausole contrattuali possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza, essendo, a tal fine, necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse. In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento.

Sul regime della nullità dei contratti c.d. “a valle” di pratiche concorrenziali vietate, **Sez. 3, n. 6685/2024, Gorgoni, Rv. 670549-01**, ha rilevato che la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza.

Sul medesimo tema, **Sez. 1, n. 21841/2024, Marulli, Rv. 671967-01**, ha precisato che la natura anticoncorrenziale, riconosciuta dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono, perciò, anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.

Sul tema del danno risarcibile, **Sez. 3, n. 17108/2024, Ambrosi, Rv. 671526-01**, ha affermato che il risarcimento spetta con riguardo a tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se siano stati conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato, a condizione che l'intesa sia stata posta in essere prima del negozio denunciato come nullo.

A tenore di **Sez. 3, n. 29292/2024, Iannello, Rv. 672881-01**, qualora la nullità della fideiussione a valle di un'intesa anticoncorrenziale sia fatta valere in via di azione, sussiste la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, senza che sia necessario verificare la sussistenza dell'interesse effettivo della parte ad ottenere un accertamento con efficacia di giudicato, anche in eventuali diverse liti.

4. La concorrenza sleale.

In tema di competenza delle Sezioni specializzate, **Sez. 1, n. 22453/2024, Tricomi, Rv. 672172-01**, afferma che il criterio concorrente del *forum commissi delicti* di cui all'art. 120, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2005, può essere applicato solo ove sia prospettato un fatto lesivo di un diritto del titolare della privativa e non quando sia domandato il solo accertamento negativo della contraffazione, perché in tal caso l'attore non si pone come preteso danneggiato, ma richiede unicamente l'accertamento della non lesività della propria condotta rispetto al diritto del convenuto, restando in tal caso applicabile il foro del domicilio eletto dal convenuto titolare di un brevetto o di una registrazione - di cui all'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005, in combinato disposto con il comma 6 *bis* della stessa disposizione - che prevale, ove vi sia stata elezione di domicilio, sui primi tre fori elencati dal comma 2.

Secondo **Sez. U, n. 18623/2024, Carrato, Rv. 671743-01**, l'esercizio delle attività facenti capo al servizio idrico integrato può essere affidato in via diretta alle società “in house” (interamente partecipate dagli enti pubblici e ricadenti nell'ambito territoriale ottimale), senza che ciò determini violazione del principio comunitario di concorrenza, dal momento che tali società, pur essendo dotate di autonoma personalità giuridica, sono equiparabili a un'articolazione interna dell'ente pubblico che le ha costituite, con la conseguente necessità di rispettare i principi che informano la correttezza e la legittimità dell'attività amministrativa, in vista della tutela del peculiare interesse pubblico a cui sono preposte.

Sui presupposti della fattispecie è intervenuta, nell'anno in rassegna, **Sez. 1, n. 14944/2024, Falabella, Rv. 671467-01**, affermando che il cd. “storno vietato” di dipendenti non ricorre

ove l'imprenditore avvii una collaborazione professionale con il prestatore d'opera, che abbia posto fine al precedente rapporto di lavoro, disattendendo l'obbligo di preavviso o il divieto di concorrenza contratti con il vecchio datore di lavoro, poiché l'imprenditore che recluti il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che inerivano al precedente rapporto e l'assunzione in tali circostanze non implica necessariamente una condotta disgregatrice dell'altrui impresa, salvo dimostrare che tale comportamento è univocamente finalizzato all'intenzionale scomposizione dell'organizzazione e della funzionalità dell'unità concorrente, così da menomarne la vitalità economica.

5. I diritti del consumatore.

In tema di competenza delle Sezioni specializzate, **Sez. U, n. 15364/2024, Criscuolo, Rv. 671517-01**, ha affermato che il consumatore che, convenuto in giudizio da un professionista, eccepisce tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito, invocando la sua qualità ed il suo domicilio in altro Stato membro, non ha l'onere di dedurre espressamente ed immediatamente nelle sue difese, ai fini dell'art. 17, comma 1, lett. c), Reg. UE n. 1215 del 2012, che le attività dell'attore sono dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del proprio domicilio, dovendo il giudice verificare la ricorrenza degli elementi fondanti la propria competenza internazionale sulla base degli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituenti.

Sul medesimo tema, **Sez. 3, n. 15699/2024, Moscarini, Rv. 671259-01**, ha rilevato che la competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), Codice del consumo, si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria.

Secondo **Sez. 1, n. 28987/2024, Iofrida, Rv. 673056-01**, in tema di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, la connessione qualificata, prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, non sussiste tra la domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo e del relativo precetto e quella di accertamento della nullità della garanzia fideiussoria accessoria, per violazione della normativa antitrust, le quali se cumulativamente proposte, vanno separate, poiché solo la seconda rientra nella competenza della sezione specializzata.

Sez. 3, n. 29392/2024, Spaziani, Rv. 672883-02, ha affermato che il foro speciale del consumatore si applica alle domande direttamente scaturenti dal contratto di consumo e non, invece, alle domande scaturenti da una fattispecie complessa, nella quale il contratto tra consumatore e professionista è soltanto uno degli elementi costitutivi e che, **Rv. 672883-01**, l'attore che ha adito il giudice del luogo di sua residenza, così oggettivamente avvalendosi del foro del consumatore, pur senza farne espressa menzione, è legittimato ad impugnare, con riferimento alle norme che disciplinano detto foro, il provvedimento con cui il giudice abbia erroneamente declinato la propria competenza in favore dei fori ordinari, poiché, nei contratti tra professionista e consumatore, il luogo di residenza o di domicilio di quest'ultimo è un criterio di collegamento ai fini della determinazione della competenza per territorio, sicché il consumatore non ha l'onere di indicarlo nell'atto introduttivo, né la mancata indicazione può equivalere a rinuncia.

Secondo **Sez. 3, n. 21153/2024, Cirillo, Rv. 671912-01**, il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, costituisce foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale) - è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come

stabilito dall'art. 47 c.c., sicché non ha rilevanza l'individuazione del domicilio effettivo del consumatore in base al luogo di svolgimento della sua attività lavorativa.

Sez. 1, n. 23112/2024, Mercolino, Rv. 672351-01, ha affermato che lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa non può verificarsi in qualsiasi ipotesi di connessione fra domande, ma solo nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., come si verifica nel caso in cui la domanda di accertamento della nullità del contratto di fideiussione o di sue singole clausole, per contrasto con la normativa antitrust (legge n. 287 del 1990), sia proposta unitamente a quelle aventi a oggetto la nullità del contratto di conto corrente da cui deriva il credito della banca e la rideterminazione delle somme effettivamente dovute, stante il vincolo di accessorietà della garanzia - che favorisce il *simultaneous process* - e l'unitarietà del bene della vita perseguito dagli attori nel giudizio, rappresentato dalla esclusione o rideterminazione del loro debito. Sempre in ambito processuale, **Sez. 3, n. 17055/2024, Valle, Rv. 671446-01**, ha statuito che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, se l'esecuzione è fondata su un decreto ingiuntivo non opposto e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, ma entro il limite dell'avvenuta vendita del bene (o dell'assegnazione del credito) pignorato, non potendo opporsi all'aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Sulla nozione di consumatore, **Sez. U, n. 25954/2024, Scarpa, Rv. 672392-01**, hanno affermato che la nozione di consumatore, secondo il diritto dell'Unione Europea, presuppone che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla propria sfera professionale e rivolta alla soddisfazione delle proprie esigenze di consumo privato, restando irrilevante l'eventuale possesso di specifiche competenze e conoscenze nel settore di riferimento. Sul medesimo tema è intervenuta **Sez. 3, n. 26292/2024, Rv. 672630-01**, affermando che, ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, non assume rilevanza l'aspirazione futura a esercitare una professione, dovendosi considerare la qualità del contraente al momento della stipula del contratto.

In tema di strumenti a tutela del consumatore quale parte "debole" del contratto, si segnala **Sez. 3, n. 4140/2024, S. Tassone, Rv. 670530-02**, secondo cui, in tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista, l'applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto.

Sulla vessatorietà delle clausole è intervenuta **Sez. 2, n. 12315/2024, Cavallino, Rv. 671490-01**, secondo cui, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, si presumono vessatorie le clausole che individuano come foro competente località diverse da quella della residenza e del domicilio elettivo, cosicché il domicilio a cui fa riferimento l'attuale previsione dell'art. 66-*bis* è necessariamente quello elettivo.

Sui singoli contratti oggetto di tutela, si segnalano: **Sez. 1, n. 5936/2024, Iofrida, Rv. 670473-02**, secondo cui, nel confronto tra la disciplina generale sull'arbitrato e quella speciale derogatoria dettata a tutela del consumatore, il giudice nazionale, sulla base dell'applicazione dei principi euro-unitari posti a tutela dei diritti dei consumatori, deve procedere alla disapplicazione, per contrarietà alla legislazione comunitaria, della normativa interna laddove essa prevede che

l'impugnazione per nullità del lodo, fondata sull'invalidità della convenzione d'arbitrato dovuta a mancanza di trattativa individuale sulla relativa clausola compromissoria, non è ammessa se non è stata eccepita nel corso del procedimento arbitrale; **Sez. 3, n. 1261/2024, Condello, Rv. 669795-01**, secondo cui, nel contratto di assicurazione sulla vita, la clausola che esclude la copertura per l'evento morte dovuto a determinate cause, preventivamente individuate, delimitando il rischio garantito, attiene all'oggetto del contratto, e non è una clausola limitativa della responsabilità, con la conseguenza che non deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., e che non rientra nell'ambito della tutela del consumatore contro le clausole abusive, perché l'art. 34 del Codice del Consumo esclude che la valutazione del carattere vessatorio della clausola possa essere riferita all'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo; **Sez. 2, n. 23238/2024, Oliva, Rv. 672180-01**, secondo cui, in tema di vendita di beni di consumo, il rimedio ripristinatorio previsto dall'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 spetta anche in caso di successive vicende traslative del bene perché la protezione non concerne il bene in sé ma si riferisce alla posizione "debole" del consumatore, nell'ambito del rapporto di consumo ed il danno, non avendo il contratto in oggetto finalità speculative, non si identifica con la perdita di valore della cosa; **Sez. 3, n. 14410/2024, Moscarini, Rv. 671172-01**, secondo cui al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale; **Sez. 2, n. 785/2024, Giannaccari, Rv. 669927-01**, secondo cui, in tema di mediazione, la clausola predisposta unilateralmente dal mediatore - che prevede il diritto del compenso provvigionale, dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, da parte di un soggetto che si sia avvalso della sua attività qualora l'affare sia stato successivamente concluso da un familiare, società o persona "riconducibile" - è vessatoria ed abusiva, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33 del Codice del consumo, in quanto determina un significativo squilibrio a carico del consumatore, obbligato ad una prestazione in favore del professionista indipendentemente da ogni accertamento, anche in via presuntiva, del preventivo accordo con il soggetto che ha concluso l'affare o di ogni altra circostanza concreta da cui risulti che l'affare sia stato agevolato in ragione dei rapporti familiari o personali tra le parti.

6. Il diritto d'autore.

Sez. 1, n. 11413/2024, Caiazza, Rv. 670974-01, ha affermato che il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di *industrial design* non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.

Secondo **Sez. 1, n. 33599/2024, Valentino, Rv. 673514-01**, il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è incentrato nella capacità creativa dell'autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare e nella realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata, mentre non fruiscono di protezione quelle fotografie che non richiedono alcun apporto creativo, poiché si limitano a riprodurre fedelmente la realtà, senza alcuna personale rielaborazione dell'autore.

CAPITOLO XVII

IL DIRITTO DELLE SOCIETÀ

(DI CECILIA BERNARDO, GUIDO ROMANO, ALDO RUGGIERO)¹

SOMMARIO: 1. Le società in generale. - 1.1. Le vicende modificative ed estintive delle società. - 1.2. Cessione di partecipazioni societarie. - 1.3. Profili processuali. - 2. Le società di persone. - 2.1. Autonomia sostanziale e processuale della società rispetto ai singoli soci - 2.2. Continuazione dell'attività di impresa e scioglimento del rapporto sociale. 3. Le società di capitali. - 3.1. Le azioni e le quote sociali. - 3.2. Finanziamenti e conferimenti a vario titolo. - 3.3. Le deliberazioni dell'assemblea. - 3.4. Il compenso degli amministratori. - 3.5. Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. - 3.6. La responsabilità da direzione e coordinamento. - 3.7. La revoca dell'amministratore e il recesso del socio. - 3.8. Le operazioni straordinarie. - 3.9. I patti parasociali. - 4. Particolari società di capitali. - 4.1. Le società cooperative.

1. Le società in generale.

Nel corso del 2024 la Suprema Corte ha adottato pronunce che hanno interessato in generale la materia societaria, in particolare esaminando le caratteristiche delle vicende modificative ed estintive delle società e della cessione di partecipazioni sociali; le società di persone; la figura degli amministratori e dei sindaci e le rispettive responsabilità; le delibere assembleari e le relative impugnazioni e, infine, le operazioni straordinarie.

Vengono di seguito riportate le decisioni che hanno approfondito le tematiche appena menzionate, unitamente a quelle adottate sulle medesime questioni, o su questioni connesse, ma riferite ai singoli tipi societari, in modo da evidenziarne gli aspetti comuni e le differenze.

1.1. Le vicende modificative ed estintive delle società.

È, ormai, consolidato il principio affermato da **Sez. U, n. 06070/2013, Rordorf, Rv. 625323-01**, secondo cui, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, con la cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue, determinandosi un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale tutti i rapporti attivi e passivi ancora in essere si trasferiscono ai soci della società estinta.

Nell'anno in rassegna, infatti, la Suprema Corte ha affermato vari principi di diritto che conseguono e specificano quello suindicato.

In primo luogo, merita menzione **Sez. U, n. 29812/2024, Scotti, Rv. 672860-01**, con la quale è stato affermato che, in tema di giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica), intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato. Il problema si era posto poiché, il legislatore non ha previsto una specifica disciplina per le ipotesi in cui l'evento interruttivo si verifichi tra un grado e l'altro del giudizio, non essendo chiaro se alla parte deceduta possa essere validamente notificata la sentenza presso il suo difensore, al fine di far decorrere il termine breve per impugnare; se l'impugna-

(1) I paragrafi 2, 2.2 e 2.3 sono stati redatti da Aldo Ruggiero, i restanti da Cecilia Bernardo e Guido Romano.

zione possa essere notificata alla parte deceduta presso il suo procuratore nel precedente grado di giudizio; se il procuratore della parte deceduta o divenuta incapace sia legittimato a proporre l'impugnazione per la parte stessa. Per individuare le possibili soluzioni, la suindicata pronuncia ha ritenuto di partire dalle tre pronunce delle Sezioni Unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, in tema di effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, e dal successivo intervento delle Sez. U., n. 15295/2014, Spirito, Rv. 631467-01, in tema di ultrattività del mandato difensivo. Entrambe le pronunce, infatti, prendono in considerazione l'ipotesi di impugnazione notificata al difensore della parte colpita da evento interruttivo non dichiarato nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza impugnata, ma, mentre la pronuncia del 2013 ha dichiarato inammissibile il ricorso, nel 2014 l'impugnazione è stata, al contrario, ritenuta ammissibile, in virtù dell'ultrattività del mandato. Il Collegio ha, pertanto, ritenuto di procedere, nel solco della pronuncia del 2014, sulla strada della piena equiparazione tra ricorrente e resistente, osservando, infine, che la soluzione non responsabilizza oltremisura il difensore, il quale, secondo la lettera e lo spirito della sentenza n. 15295 del 2014, una volta appreso l'evento sopravvenuto, ha il dovere di informare e coordinarsi con i successori della parte colpita.

In linea di continuità con la citata Sez. U, n. 06070/2013, Rordorf, Rv. 625323-01, si pone **Sez. 3, n. 11411/2024, Cirillo F., Rv. 670798-01**, secondo cui, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società (di persone o di capitali), conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Il principio è stato affermato in un caso in cui la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio in virtù della menzionata vicenda estintiva.

1.2. Cessione di partecipazioni societarie.

Nell'anno in rassegna, la S.C. è intervenuta con varie pronunce sulle questioni attinenti al trasferimento delle partecipazioni sociali.

Innanzitutto, **Sez. 1, n. 18891/2024, Catallozzi, Rv. 671679-01**, in tema di società a responsabilità limitata, ha affermato che è valida ed efficace la clausola statutaria che individui una specifica situazione al ricorrere della quale il socio è obbligato all'alienazione della quota di partecipazione al capitale della società senza una previa manifestazione di volontà da parte dell'assemblea, non potendo tale decisione essere parificata all'ipotesi di esclusione di cui all'art. 2473-bis c.c. che, invece, richiede, sia pure non espressamente, la

decisione dei soci. Il principio è stato enunciato in un caso, in cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato valida ed efficace una clausola contenuta nello statuto di una s.r.l., che prevedeva l'obbligo dei soci di minoranza, alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività lavorativa per le società controllate o collegate, di offrire in acquisto agli altri soci le proprie quote di partecipazione al capitale della società.

Con riferimento al pegno della partecipazione sociale, **Sez. 1, n. 16047/2024, Fraulini, Rv. 671537-01**, ha affermato che il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio, atteso che dal combinato disposto degli artt. 2471-*bis* e 2352 c.c. si evince che il socio, la cui quota sia stata oggetto di pegno, perde il solo diritto di voto in assemblea ma conserva, in difetto di diversa pattuizione, tutti gli altri diritti amministrativi connessi alla relativa qualità, ivi compreso quello di impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo. A tal riguardo, giova ricordare che, con risalente pronuncia, **Sez. 1, n. 02053/1999, Verucci, Rv. 523993-01**, aveva già in passato affermato che, ai fini del raggiungimento del *quorum* costitutivo dell'assemblea di una società per azioni, sono legittimamente computabili le azioni del socio datore di pegno, quand'anche questi risulti titolare di gran parte del capitale sociale, considerato che, a differenza di quanto sancito in tema di esercizio del diritto di voto da parte del socio in conflitto di interessi con la società, l'art. 2352 c.c. prevede espressamente la possibilità di stabilire, con apposita convenzione, che il diritto di voto sia esercitato dal socio datore di pegno, anziché dal creditore pignoratizio.

Sez. 3, n. 24859/2024, Condello, Rv. 672218-01, è intervenuta in tema di espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata, affermando che essa è un bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto al pubblico registro e che, ove sia intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939, l'espropriazione non si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, bensì, ai sensi dell'art. 2471, comma 1, c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), mediante notificazione alla società a cui la quota stessa si riferisce e alla società (fiduciaria) che ne ha l'intestazione formale, nonché tramite successiva iscrizione del vincolo nel registro delle imprese, generando l'intestazione fiduciaria un fenomeno di dissociazione tra la situazione di "proprietà sostanziale" (che resta in capo al fiduciante) e la "proprietà formale" (che ricade in capo alla fiduciaria), per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. A tal riguardo, giova ricordare che, in caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, **Sez. U., n. 13143/2022, Rv. 664654-02**, hanno affermato che lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell'art. 2055 c.c. con quella dell'organo chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico). La questione era stata anche affrontata da **Sez. 3, n. 22361/2009, Vivaldi, Rv. 610613-01**, secondo cui la quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 c.c., per cui ad

essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813, ultima parte, c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, poiché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti, con la conseguenza che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di pignoramento nei confronti del socio che ne è titolare, a nulla rilevando il fallimento della società, che è terzo rispetto al processo esecutivo, cui pertanto non si applica l'art. 51 l.fall.

Infine, in ambito tributario, **Sez. T, n. 34872/2024, Di Pisa, Rv. 673545-02**, ha affermato che le riserve, a seguito del trasferimento di quote sociali come forma di distribuzione di dividendi e riserve secondo valori corrispondenti, costituiscono, quale sovrapprezzo, un ulteriore versamento di capitale effettuato dall'azionista/acquirente rispetto a quello rappresentato dal valore nominale della partecipazione, da cui deriva un incremento del patrimonio o un aumento di capitale, disciplinato dalla lettera a) dell'art. 4 della tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e compiuto mediante l'assegnazione di cui alla lettera d) dello stesso articolo, che soggiace a tassazione fissa.

1.3. Profili processuali.

Nell'anno in rassegna, varie sono le pronunce che hanno affrontato profili processuali nell'ambito della materia societaria.

Con riferimento alla legittimazione ad impugnare, **Sez. 3, n. 17192/2024, Condello, Rv. 671567-01**, ha affermato che, in caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso del giudizio, essa spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la legittimazione ad impugnare del ricorrente, sul rilievo che, nell'atto d'appello, egli aveva indicato di agire come socio e legale rappresentante e non come socio succeduto alla s.a.s. cancellata dal registro delle imprese. Sempre in tema di legittimazione all'impugnazione, **Sez. 3, n. 34373/2023, Condello, Rv. 669489-01**, ha affermato che il soggetto che non sia stato parte nel grado precedente, il quale proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria *legitimatio ad causam* per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione, per non avere l'impugnante adempiuto l'onere di allegazione rispetto all'asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari.

Con riferimento alla competenza, **Sez. 1, n. 10325/2024, Caiazzo, Rv. 671162-01**, ha affermato che la controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, a seguito della trasformazione della società, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello *status socii*

e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota, che non ne costituisce una condizione sospensiva ma una conseguenza stabilita dalla legge. Al riguardo, giova ricordare che Sez. 6-2, n. 20365/2021, Dongiacomo, Rv. 662243-01, ha affermato che, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di parte del prezzo di cessione della quota di partecipazioni sociali, fosse di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, in quanto afferente anche a diritti sociali, posto che le parti avevano condizionato il potere di vendita delle quote sociali, di modifica statutaria e di delibera dell'aumento del capitale sociale, all'integrale pagamento del prezzo della cessione. In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, è stato anche affermato che, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" a queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del *petitum* sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della *causa petendi*, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Nella specie, la S.C. aveva ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad una vicenda successoria ove l'azione era diretta all'accertamento della natura simulata o effettiva dell'intestazione dell'azienda appartenente al *de cuius* ad uno dei figli, ai fini del calcolo dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario e non, invece, della partecipazione societaria o del trasferimento delle quote societarie (Sez. 6, n. 22149/2020, Criscuolo, Rv. 659401-01).

Quanto ai profili processuali in caso di fusione tra società, Sez. 1, n. 09955/2024, Perrino, Rv. 670725-01, ha affermato che l'ex amministratore della società precedentemente fusa per incorporazione in altra società ha interesse a proporre in proprio e non già quale organo della società estinta, ai sensi dell'art. 18 l.fall., reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società incorporante, essendo tale impugnazione finalizzata ad elidere gli effetti negativi personali che da tale provvedimento possono derivargli, sia sul piano morale, in relazione ad eventuali contestazioni di reati, sia su quello patrimoniale, in relazione ad eventuali azioni di responsabilità. Tale pronuncia rappresenta una specificazione del principio affermato da Sez. 1, n. 07190/2019, Vella, Rv. 653110-01, secondo cui l'amministratore di società di capitali è legittimato *iure proprio* a proporre opposizione alla dichiarazione di fallimento della società, considerata l'ampia formula dell'art. 18 l. fall., che estende la legittimazione a "qualunque interessato", essendo l'opposizione volta a rimuovere gli effetti riflessi, individuabili nelle responsabilità penale e civile, che possono derivare a suo danno dal fallimento. Nel caso concreto, era stata affermata la legittimazione a proporre reclamo da parte dell'amministratore che, prima della dichiarazione di fallimento, era già cessato dalla carica ed era stato destinatario del provvedimento di sequestro penale in prevenzione delle quote societarie.

Sempre con riferimento al caso in cui la fusione per incorporazione si verifichi in corso di causa, **Sez. T, n. 07700/2024, Balsamo, Rv. 670618-02**, ha affermato che la incorporata, ove la incorporante rimanga estranea al processo, può impugnare la decisione o anche ricevere la notifica dell'impugnazione dalla controparte, a mezzo dello stesso difensore per effetto della procura estesa a tutti i gradi di giudizio, fermo restando il principio che tutti i rapporti sostanziali e processuali continuano nell'ambito della società incorporante o di quella nata dalla fusione paritaria. A tal riguardo, giova ricordare che **Sez. U., n. 21970/2021, Nazzicone, Rv. 661864-01**, avevano statuito che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa *ex lege* dall'art. 2504-bis c.c.

Sempre in tema di fusione, **Sez. 3, n. 07711/2024, Gorgoni, Rv. 670694-01**, ha statuito che la società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio, che sia anche conferitaria di un ramo d'azienda, è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado e cedente del ramo d'azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione ma anche per effetto della cessione, assumendo così una duplice legittimazione, quella di successore a titolo universale (che le deriva dalla fusione) e quella di successore a titolo particolare (che le deriva dalla cessione di ramo d'azienda) con la conseguenza che, ove si qualifichi come cessionaria del ramo d'azienda, può limitarsi ad allegare tale titolo, specificandolo nell'intestazione dell'impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile.

Infine, **Sez. 1, n. 30409/2024, Valentino, Rv. 673086-01**, ha affermato che il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo avverso la decisione del tribunale, in tema di accertamento di una causa di scioglimento della società, non è ricorribile per cassazione *ex art. 111 Cost.*, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione privo di carattere decisorio, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario e ottenerne la rimozione, previa dimostrazione dell'insussistenza della causa di scioglimento. A tal riguardo, giova ricordare che, secondo **Sez. 6-1, n. 15070/2011, Rordorf, Rv. 618602-01**, il decreto emesso dalla corte d'appello, che abbia negato la reclamabilità del decreto del tribunale, avente ad oggetto la nomina del liquidatore di società personale, non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un'indagine sommaria e condotta *incidenter tantum*, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti. Né tale principio viene meno allorché il giudice (nella specie la Corte d'appello) si sia pronunciato su di un profilo processuale, atteso che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può pertanto avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito.

2. Le società di persone.

La Suprema Corte, nell'anno in rassegna, si è pronunciata più volte in materia di autonomia della società di persone rispetto ai soci, soprattutto con riferimento alla estinzione della società ed allo scioglimento del rapporto sociale, fondandosi sui consolidati principi della personalità autonoma della società e della responsabilità illimitata dei soci.

2.1. Autonomia sostanziale e processuale della società rispetto ai singoli soci.

In tema di società di fatto, realizzata da soggetti che gestiscono una o più società nell'interesse proprio, usandole come schermo e superando la autonomia della impresa collettiva, **Sez. 1, n. 00204/2024, Dongiacomo, Rv. 67055-01**, ha affermato che l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nell'interesse proprio, benché costituisca in astratto un indizio contrario all'esistenza della c.d. supersocietà di fatto e favorevole, piuttosto, alla individuazione di una *holding* di fatto, non esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale *affectio* tra le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi, l'esercizio di un abuso sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo.

Sempre in tema di società di fatto, **Sez. 1, n. 00074/2024, Fidanzia A., Rv. 670212-01**, ha stabilito che l'abuso di una società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato, che è compatibile con l'accordo, iniziale o successivo, rispetto al quale la società si fa carico dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli utili, mentre le persone fisiche simmetricamente assumono debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti, ove l'abuso non è stato programmato sin dal momento in cui i soggetti hanno iniziato ad interagire, ma è solo il frutto della violazione dei principi di corretta gestione da parte di chi, tra gli originari partecipi del rapporto, era in condizione di farlo. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza di una supersocietà di fatto per la mancanza dell'elemento della *affectio societatis*, senza indagare se lo stesso fosse carente sin dall'origine ovvero fosse venuto meno successivamente, in forza di una modifica ed evoluzione in concreto degli originari accordi.

A seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, che ha comportato il venir meno dell'iniziativa ufficiosa, ed ai suoi riflessi nell'ambito societario, **Sez. 1, n. 17546/2024, Perrino, Rv. 671554-01**, ha statuito che i creditori che hanno proposto il ricorso per la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel successivo procedimento di fallimento in estensione *ex artt. 15 e 147 l.fall.*, promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore, e neanche nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione, proposto dal socio illimitatamente responsabile cui il fallimento sia stato esteso, poiché l'oggetto della sentenza di fallimento in estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società. Secondo la S.C., quindi, le procedure rimangono distinte ed autonome, per come comprovato dall'assenza di un interesse dei creditori del fallimento sociale che, ciononostante, si trovano esposti a una domanda di risarcimento per danni derivante dall'iniziativa ulteriore da loro non desiderata ma promossa da altri. Inoltre, sottolinea la

S.C., i creditori istanti per il fallimento sociale potrebbero anche avere interesse contrario all'estensione, qualora, per esempio, dispongano di una garanzia personale, poiché si troverebbero esposti alla concorrenza sul patrimonio personale di tutti i creditori sociali.

2.2. Continuazione dell'attività di impresa e scioglimento del rapporto sociale.

In tema di successione ereditaria nella quota di un socio defunto, **Sez. 1, n. 13163/2024, D'Orazio, Rv. 671455-01**, ha affermato che nelle società di persone la morte di uno dei soci, determinando lo scioglimento del suo rapporto particolare con la società e l'acquisto, da parte degli eredi, del diritto alla liquidazione della sua quota, secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., comporta in capo ad essi un diritto di credito nei confronti della società, che non si divide automaticamente in ragione delle rispettive quote, ma entra a far parte della comunione ereditaria e può essere fatto valere, nella sua interezza, da ciascuno dei partecipanti singolarmente, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri. Gli eredi, infatti, non acquistano in automatico la posizione di socio, ma solo un diritto di credito consistente nella liquidazione della quota, salvo diversa volontà di continuazione dell'attività sociale con gli stessi.

In tema di successione tra società e soci a seguito della estinzione della prima, **Sez. 3, n. 11411/2024, Cirillo, Rv. 670798-01** ha affermato che, con l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene meno ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, per cui si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, erano limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi ha rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che ai soci di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva.

Sotto il profilo processuale, la vicenda estintiva di una società di persona ha dato luogo alla pronuncia di **Sez. 2, n. 31130/2024, Trapuzzano, Rv. 673045-01**, per la quale la citazione notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta. Tuttavia, detto vizio, rilevabile di ufficio, è sanato dalla costituzione in giudizio del successore dell'ente, nella specie il socio accomandatario, il quale, riconoscendosi come convenuto, indipendentemente dalle difese processuali svolte, dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto introduttivo. Pertanto, la S.C. ha stabilito che la costituzione volontaria del socio comporta che l'atto ha comunque raggiunto lo scopo *ex art. 156, comma 3, c.p.c.*

Sullo stesso tema processuale, **Sez. 3, n. 17192/2024, Condello, Rv. 671567-01**, ha affermato che, in caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile

d'ufficio. In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la legittimazione ad impugnare del ricorrente, sul rilievo che, nell'atto d'appello, a livello di prospettazione difensiva, egli aveva indicato di agire come socio e legale rappresentante e non come socio succeduto alla s.a.s. cancellata dal registro delle imprese, omettendo del tutto di fare menzione della intervenuta successione. La cancellazione della società, infatti, ha come effetto il venir meno del potere di rappresentanza degli organi della liquidazione, trattandosi di qualità giuridicamente impossibile in dipendenza dell'avvenuta cancellazione. Pertanto, il soggetto che propone la impugnazione ovvero vi resiste nella qualità di successore di una società estinta deve allegare la propria *legitimatio ad causam* e ne deve fornire la prova ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.

In tema di valutazione della quota sociale del socio uscente, **Sez. 1, n. 13290/2024, D'Orazio, Rv. 671458-01**, ha statuito che l'art. 2289 c.c., nel fare riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale, con la conseguenza che, ai fini della quantificazione della somma dovuta, occorre tenere conto anche dell'avviamento, ossia dell'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi da quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono. Ciò comporta che la valutazione economica di detto avviamento va operata con una stima ragionevolmente prudentiale, seguendo uno dei metodi di calcolo, patrimoniali, reddituali o misti, la cui scelta è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. La stessa S.C. ha precisato a supporto del proprio *decisum* che la molteplicità dei criteri che, sul piano pratico, vengono proposti per la determinazione del valore di avviamento, non obbliga il giudice del merito a chiarire le ragioni della scelta dell'uno piuttosto che dell'altro, procedendo ad una preventiva e astratta comparazione fra i diversi metodi, perché, versandosi in materia di apprezzamenti eminentemente discrezionali, sottratti per loro natura al sindacato di legittimità in quanto non inficiati da vizi logici e giuridici, egli assolve al dovere giuridico di una sufficiente motivazione solo se fonda l'anzidetto giudizio su considerazioni atte a dimostrare che il metodo di indagine tecnica concretamente seguito ha condotto a risultati convincenti e accettabili.

Sez. 1, n. 11342/2024, Dongiacomo, Rv. 671017-01, ai fini della assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone in conseguenza del fallimento della società, ha stabilito che non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell'operatività di un patto sociale ma basta la prova di un comportamento del socio tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento. In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito la assoggettabilità al fallimento del terzo, che, pur non essendo più socio, aveva nondimeno acconsentito al mantenimento del proprio nome nella ragione sociale. Infatti, secondo la S.C. l'inserimento del nominativo del socio accomandante nella ragione sociale (art. 2314, comma 2, c.c.), al pari dell'inserimento nella ragione sociale del nome del socio accomandatario cessato (artt. 2314, comma 1, e 2292, comma 2, c.c.), comportano, per previsione normativa, la responsabilità illimitata per le obbligazioni della società esclusivamente in ragione del contenuto oggettivo della ragione sociale e della oggettiva confusione conseguentemente ingenerata sul ruolo da lui (ancora) svolto nella società, con esclusione in tale valutazione di ogni considerazione relativa ad elementi estrinseci all'aspetto formale della ragione sociale.

La S.C. si è pronunciata anche in tema di riscossione a seguito della estinzione della società. **Sez. T, n. 17404/2024, Condello, Rv. 671613-01**, ha affermato che il preavviso di

iscrizione ipotecaria intestato a società di persone o di capitali estinta, avendo la funzione di consentire al debitore di presentare osservazioni, compulsandone l'adempimento, è valido ed efficace anche se notificato agli *ex* soci, i quali, in virtù del fenomeno successorio conseguente all'estinzione dell'ente, subentrano nelle relative obbligazioni inadempite, illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seconda del regime giuridico dei debiti sociali *pendente societate*.

3. Le società di capitali.

Vengono di seguito riportate le decisioni adottate dalla Corte di cassazione, nel corso del 2024, con specifico riferimento alle società di capitali. Trattano, in particolare, di azioni, di finanziamenti e i conferimenti a vario titolo da parte dei soci, delle deliberazioni assembleari, dell'amministrazione e delle azioni di responsabilità. In alcuni casi, la Corte di cassazione ha affrontato le singole questioni, riferendosi in generale alle società di capitali, mentre, in altri casi, come di volta in volta precisato, ha esaminato in particolare la disciplina propria delle s.p.a. o delle s.r.l.

3.1. Le azioni e le quote sociali.

Con una prima decisione, la S.C. è intervenuta in tema di acquisto di azioni proprie. Secondo Sez. 1, n. 23557/2024, Falabella, Rv. 672356-01, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c., come modificato dal d.lgs. n. 224 del 2010, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo sia del *quorum* costitutivo che di quello deliberativo. La pronuncia si pone in linea di continuità con il precedente della Sez. 1, n. 23950/2018, Nazzicone, Rv. 650822-01.

In ambito tributario, Sez. T, n. 11152/2024, A. Napolitano, Rv. 671159-02, ha affermato che, nel caso in cui la quota sociale di una società a responsabilità limitata sia costituita in usufrutto, le somme ricavate dalla liquidazione volontaria della società - che costituiscono, ai sensi dell'art. 47, comma 7, TUIR, un utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote - spettano all'usufruttuario, con la conseguenza che il rapporto d'imposta avente ad oggetto tale utile sorge, ad ogni effetto, tra l'amministrazione e l'usufruttuario.

3.2. Finanziamenti e conferimenti a vario titolo.

Nell'ambito delle erogazioni che possono garantire un beneficio finanziario alla società ricevente, i soci possono effettuare apporti fuori capitale (effettuati *causa societatis* e senza obbligo di rimborso), oppure veri e propri prestiti, da cui deriva un obbligo di rimborso a carico della società. Qualora il finanziamento sia stato erogato in una situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, il diritto del socio al suo rimborso sorge postergato, ai sensi dell'art. 2467 c.c. Come precisato da Sez. 1, n. 12994/2019, Nazzicone, Rv. 654252-01, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma. Di conseguenza, la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente non solo al momento della concessione del finanziamento, ma anche a quello della richiesta di rimborso, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio.

Nell'anno in rassegna, è stata precisata la nozione di postergazione. In particolare, **Sez. 1, n. 15196/2024, Campese, Rv. 671470-03**, in tema di finanziamenti dei soci in favore della società, ha affermato che la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta. Sempre con la stessa pronuncia, **Rv. 671470-02**, la S.C. ha anche affermato che l'azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso, percepito entro l'anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell'indebitto, bensì di revocatoria di carattere speciale, poiché l'art. 2467, comma 1, c.c. (*ratione temporis* applicabile) delinea un'inefficacia *ex lege* del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della *scientia decotiois*. Al riguardo, giova ricordare che, in tema di insinuazione allo stato passivo, il credito derivante dal finanziamento alla società fallita in qualunque forma effettuato dal socio, in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ai sensi dell'art. 2467 c.c., va ammesso al concorso con il rango postergato non essendo equiparabile ad un credito chirografario (Sez. 1, n. 20649/2019, Fidanzia, Rv. 654671-01).

3.3. Le deliberazioni dell'assemblea.

Nell'anno in rassegna, la S.C. ha adottato alcune significative pronunce relative alle deliberazioni assembleari.

È stato, in primo luogo, affermato da **Sez. 1, n. 10873/2024, Catallozzi, Rv. 671101-01**, che, in tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ove sia contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate, la parte impugnante ha l'onere di dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità e l'erroneità delle stesse, mentre, se sia contestata la violazione del principio di chiarezza, è sufficiente la produzione in giudizio del bilancio medesimo e della documentazione accompagnatoria allegata, dalla quale emerga l'inosservanza di tale principio. A tal riguardo, giova ricordare che, come affermato da Sez. 1, n. 21238/2021, Iofrida, Rv. 661976-01, l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio deve essere valutato alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a lamentare la mancanza di una corretta informazione - secondo le prescrizioni di legge - sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, senza dedurre alcun danno economico; non esclude, pertanto, l'interesse ad agire la perdita dell'intero capitale sociale e il conseguente azzeramento del valore economico della partecipazione, poiché quest'ultima costituisce pur sempre un bene compreso nel patrimonio del socio, al quale non va negato il diritto di essere messo a conoscenza dei fatti che, nel corso dell'esercizio, hanno inciso sul patrimonio e sull'andamento economico della società. In precedenza, era stato anche affermato che (Sez. 1, n. 03946/2018, M. Di Marzio, Rv. 647060-01), in tema di impugnazione della deliberazione assunta da una società di capitali, l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità della stessa grava su chi la impugna. In particolare, la S.C. aveva cassato con rinvio la sentenza resa dalla corte d'appello, la quale aveva annullato la delibera di aumento del capitale sociale di una società a responsabilità limitata, sul presupposto che la società convenuta non avesse dimostrato la veridicità della situazione patrimoniale su cui si fondava l'aumento deliberato.

Sempre in tema di giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per azioni, **Sez. 1, n. 10521/2024, Scotti, Rv. 670882-01**, ha affermato che l'avvenuta riassunzione a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale, non

preclude alla parte la facoltà di dedurre in sede di riassunzione un vizio di nullità inizialmente non dedotto, atteso che l'art. 2434-*bis* c.c., nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che tale preclusione si estende all'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante, posto che il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima di tale evento. A tal riguardo, giova ricordare che Sez. 1, n. 14338/2023, Amatore, Rv. 667923-01, aveva affermato che le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci *medio tempore* chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 2434-*bis*, comma 3, c.c., l'amministratore deve non solo tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità nella predisposizione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, ma anche correggere i bilanci seguenti a quello impugnato, con la conseguenza che la mancata impugnazione di questi ultimi non priva dell'interesse ad agire il socio impugnante.

Altra importante pronuncia è quella di Sez. 1, n. 04034/2024, Perrino, Rv. 670224-01, secondo cui, in materia societaria, sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera assembleare che ne costituisca applicazione, qualora il voto espresso non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento dell'interesse della società - in quanto volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure ove sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva valorizzato, quale forma di abuso della maggioranza assembleare, la circostanza che quest'ultima avesse disposto la soppressione della clausola statutaria contenente il diritto di prelazione interna, appena diciotto giorni prima della cessione di quote intercorsa fra altri due soci. Appare opportuno ricordare che, secondo Sez. 1, n. 01361/2011, Rordorf, Rv. 616237-01, l'abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare, quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Infine, in ambito tributario, Sez. T, n. 17387/2024, Macagno, Rv. 671611-01, ha affermato che il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti; tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la necessità dell'istanza di verifica, attribuendo al disconoscimento del verbale di approvazione del bilancio finale di liquidazione la natura di generica contestazione non

circostanziata e, quindi, opponibile al socio in mancanza di tempestiva impugnazione. La pronuncia si pone in linea di continuità con il precedente di cui a Sez. 1, n. 33233/2019, Fidanzia, Rv. 656579-01.

3.4. Il compenso degli amministratori e dei sindaci.

Anche il tema del compenso degli organi di gestione e di controllo della società è stato interessato, nell'annualità in rassegna, da alcune pronunce della Suprema Corte.

Innanzitutto, Sez. 1, n. 10889/2024, Catallozzi, Rv. 671102-01, ha affermato che, nelle società di capitali, la delibera di quantificazione del compenso all'amministratore non è invalida per conflitto di interessi, ancorché adottata con il voto determinante dell'amministratore stesso, che abbia partecipato all'assemblea in veste di socio, poiché essa, pur consentendogli di conseguire un suo interesse personale, non comporta, di per sé, un pregiudizio all'interesse sociale. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nonostante il voto determinante del socio-amministratore, non aveva ravvisato alcuna incompatibilità tra l'interesse personale e quello della società, trattandosi di delibera che aveva ridotto il suo compenso a causa delle difficoltà economiche della società. In tema di annullamento per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2373 c.c., della delibera assembleare, nella specie determinativa del compenso degli amministratori, Sez. 1, n. 28748/2008, Rordorf, Rv. 605917-01, aveva affermato che il vizio ricorre quando essa è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società, senza che risulti condizionante in sé - ai fini del conflitto di interessi ovvero anche dell'eccesso di potere - la decisività del voto da parte dell'amministratore (beneficiario dell'atto) che sia anche socio, con la conseguenza che la accertata irragionevolezza della misura del compenso (valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa, da rapportare all'impegno chiesto per la sua gestione) può risultare anche quando la delibera attua un patto parasociale, in precedenza stipulato sotto forma di transazione fra i soci, compresi gli impugnanti soci di minoranza, che sono legittimati all'impugnazione in quanto dissenzienti e nonostante la partecipazione al predetto accordo.

Quanto al compenso dei sindaci, Sez. 1, n. 33910/2024, Caprioli, Rv. 673446-01, ha affermato che, nelle società per azioni, è nullo l'atto transattivo riguardante l'importo del compenso spettante al componente del collegio sindacale, ove sottoscritto dall'amministratore delegato in assenza di autorizzazione o successiva ratifica da parte dell'assemblea dei soci.

Merita, infine, segnalazione in ambito tributario, Sez. T, n. 20613/2024, Gori, Rv. 672027-01, alla cui stregua la disciplina sul compenso degli amministratori di cui agli artt. 2389, comma 1, e 2364, comma 1, n. 3, c.c., è dettata anche nell'interesse pubblico, al fine del regolare svolgimento dell'attività economica, e ha natura imperativa ai fini dell'art. 1418, comma 1, c.c., non potendo essere derogata attraverso la stipulazione di contratti di consulenza a titolo oneroso, aventi ad oggetto la prestazione intellettuale resa dagli amministratori in favore della società di capitali da loro amministrata, senza il rispetto delle prescritte formalità e la previa determinazione dell'assemblea dei soci. In precedenza, Sez. T, n. 24471/2022, Nonno, Rv. 665800-01, aveva affermato che la disciplina sul funzionamento delle società, che, dettata anche nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, ha natura imperativa ed inderogabile, contiene una distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione del compenso di modo che, ai fini della deducibilità del compenso degli amministratori di società di capitali, è necessario che ne risulti la quantificazione nello statuto, ovvero in una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione del bilancio contenente

la posta relativa al compenso, salvo che l'assemblea, convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia anche discusso ed approvato espressamente la proposta di determinazione dello stesso.

3.5. Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Numerose sono le pronunce, adottate dalla Suprema Corte nel 2024, che hanno precisato i contorni delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi di gestione di società di capitali.

Come è noto, per giurisprudenza costante (risalente a Sez. 1, n. 03652/1997, Rordorf, Rv. 503948-01, seguita, in tempi più recenti, da Sez. 1, n. 28718/2020, Campese, Rv. 660020-01), all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità *ex art. 2392 c.c.* di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

Nell'anno in rassegna, con la medesima pronuncia sono stati affermati tre importanti principi in tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento. In particolare, **Sez. 1, n. 08069/2024, Nazzicone, Rv. 670860-01**, ha affermato che colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile l'amministratore delegato di una società fallita per avere proseguito l'attività d'impresa pur in presenza della perdita del capitale sociale, non avendo il convenuto fornito la prova che gli atti compiuti fossero finalizzati alla liquidazione della società o alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio. A tal riguardo, in una precedente pronuncia, Sez. 1, n. 00198/2022, Fidanzia, Rv. 663554-01, aveva affermato che colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali

atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

In secondo luogo, con **Sez. 1, n. 08069/2024, Nazzicone, Rv. 670860-02**, è stato affermato che, in tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma.

Con riferimento al meccanismo di liquidazione del differenziale dei netti patrimoniali, giova menzionare anche **Sez. 1, n. 05252/2024, Terrusi, Rv. 670275-01**, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare *ex art. 146 l.fall.* nei confronti dell'amministratore, il meccanismo di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, dal momento che stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto. A tal riguardo, giova ricordare il precedente di cui a **Sez. 1, n. 04347/2022, Vanucci, Rv. 664310-02**, secondo cui, nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare *ex art. 146 l.fall.* nei confronti dell'amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale (così come previsto dall'art. 2449 c.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, *ratione temporis* applicabile al caso di specie), il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, indicandone le ragioni ed a condizione che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore.

Infine, **Sez. 1, n. 08069/2024, Nazzicone, Rv. 670860-03**, in tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, ha affermato che il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (*cd. business judgement rule*) (le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società) non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie. A tal riguardo, merita ricordare che, in precedenza, **Sez. 1, n. 02172/2023, Fidanzia, Rv. 666986-01**, aveva affermato che, in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle

scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi *ex ante* secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. Nella specie, la S.C. aveva rigettato il ricorso avverso la decisione d'appello che aveva qualificato come atto di *mala gestio* l'acquisto di un ramo d'azienda gravemente indebitato e dissestato, in quanto non accompagnato dalla contestuale adozione di adeguate risposte organizzative idonee a consentirne il rilancio.

Sempre in tema di *business judgement rule*, Sez. 1, n. 10742/2024, Dongiacomo, Rv. 671098-01, ha affermato che, in tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da valutarsi *ex ante* secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto dell'eventuale mancata adozione da parte degli amministratori delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per quel tipo di scelta e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, di talché, una volta verificatane l'irragionevolezza, gli amministratori rispondono dei danni conseguenti alla cagionata insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni del ceto creditorio. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, come atto irragionevole e fonte di danno risarcibile, la decisione degli amministratori di ottenere il controllo di altra società, acquisendone un ramo d'azienda gravemente indebitato.

Infine, anche la Sez. 1, n. 10413/2024, Catallozzi, Rv. 671095-01, si è occupata della responsabilità degli amministratori in presenza di una causa di scioglimento della società, affermando che essi sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: da un lato, per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, a seguito del ritardo o dell'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e, dall'altro lato, per i danni arrecati a tali soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la società se non a fini conservativi. A tal riguardo, giova menzionare anche il precedente di Sez. 1, n. 06893/2023, Vannucci, Rv. 667213-01, secondo cui la responsabilità degli amministratori verso il creditore di società a responsabilità limitata - per il compimento di atti gestori non funzionali alla conservazione del patrimonio sociale dopo il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4), c.c. - è disciplinata nel successivo art. 2486 c.c. e, pur avendo natura extracontrattuale, non è suscettibile di essere ricondotta allo schema generale dell'art. 2043 c.c., non venendo in evidenza un "fatto illecito" nel senso postulato da detta norma, in quanto gli amministratori agiscono nel compimento delle operazioni pregiudizievoli non in proprio ma in qualità di organi investiti della rappresentanza dell'ente.

Nell'anno in rassegna, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi anche sulla figura dell'amministratore di fatto, con Sez. 3, n. 07864/2024, Gorgoni, Rv. 670713-01, secondo cui coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, possono esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità degli atti compiuti dal gestore alla società gerita, non è necessaria la ratifica. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso fosse necessaria una ratifica della società gerita allo scopo di renderle opponibile

il verbale di accettazione senza riserve di un'opera commissionata, sottoscritto dall'amministratore di fatto. A tal riguardo, giova ricordare che l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l'azione di responsabilità (così Sez. 1, n. 21730/2020, Falabella, Rv. 659274-01).

In tre occasioni, la Suprema Corte si è occupata della responsabilità degli amministratori privi di deleghe. In primo luogo, **Sez. 1, n. 10739/2024, Dongiacomo, Rv. 671097-01**, ha affermato che, in tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe che, pur a fronte di segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori non esecutivi, i quali, nonostante la mancata trasmissione delle relazioni informative periodiche, avevano negligenemente omesso di chiedere chiarimenti ai delegati, denunciando il loro inadempimento ed attivando i rimedi più adeguati, come la revoca della delega gestoria o dell'amministratore delegato, l'avocazione al consiglio delle operazioni rientranti nella delega, la proposizione delle necessarie iniziative giudiziali. A tal riguardo, va menzionato il precedente di Sez. 1, n. 02038/2018, Nazzicone, Rv. 647054-01, secondo cui la responsabilità solidale degli amministratori della s.r.l. per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società non costituisce una forma di responsabilità oggettiva, posto che l'esonero da responsabilità previsto dall'art. 2476 c.c. non è ancorato al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in occasione del consiglio di amministrazione deliberante ma all'effettiva mancanza di qualsiasi profilo di colpa.

Inoltre, in linea di continuità con Sez. 1, n. 17441/2016, M. Di Marzio, Rv. 641165-01, la **Sez. 1, n. 15054/2024, Crolla, Rv. 671469-01**, ha affermato che, in tema di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati *ex art. 2381 c.c.*, rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori privi di deleghe, per non aver acquisito, dagli amministratori operativi o dal collegio sindacale, informazioni al fine di verificare la congruità del valore di un conferimento di azienda, sebbene la società, nei due anni successivi ad esso, aveva riportato ingenti perdite, in contrasto con il business plan in base al quale l'esperto aveva effettuato la stima, che prevedeva il conseguimento di utili per entrambe le annualità.

Infine, **Sez. 2, n. 32010/2024, Guida, Rv. 673452-01**, in tema di sanzioni amministrative *ex art. 144 TUB*, ha affermato che l'obbligo di "agire in modo informato", previsto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c., comporta che il consigliere di amministrazione non

esecutivo risponda non dell'inadempimento degli specifici doveri gravanti sui titolari della gestione o delle funzioni di controllo, ma dell'inosservanza di quelli che incombono sui componenti del consiglio di amministrazione, anche in base alla normativa secondaria di settore, come quello di approntare strumenti organizzativi valevoli ad assicurare che le informazioni rilevanti raggiungano sempre il consiglio e quello di adoperarsi in concreto per garantire la completezza, veridicità ed efficacia dei sistemi informativi, configurandosi, in caso di violazione, una responsabilità contrattuale verso i soci della banca e di tipo pubblicistico verso l'autorità di vigilanza.

In tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza; dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza (in termini analoghi si era già espressa Sez. 2, n. 19556/2020, Cosentino, Rv. 659134-01).

Con riferimento alla responsabilità del collegio sindacale, **Sez. 1, n. 02343/2024, Terrusi, Rv. 671473-01**, ha affermato che, a fronte dell'opposizione con la quale il sindaco di una società fallita si dolga della mancata ammissione allo stato passivo del credito relativo al compenso maturato nei confronti dell'ente, la procedura fallimentare può sollevare l'eccezione di inadempimento del sindaco stesso ai propri obblighi contrattuali; tuttavia, nel caso in cui sia dedotta una fattispecie di responsabilità concorrente dei sindaci *ex art. 2407 c.c.*, il curatore ha l'onere di proporre detta eccezione in maniera specifica, dando la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la omessa vigilanza da parte dell'organo di controllo. Analogo principio era stato affermato con riferimento alla posizione dell'amministratore da Sez. 1, n. 29252/2021, Vella, Rv. 662907-01, secondo cui, in tema di compenso spettante all'amministratore di società a responsabilità limitata, la società può far valere quale eccezione riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli obblighi assunti dall'amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, la cui violazione integra la responsabilità *ex art. 2476*, comma 1, c.c., venendo in rilievo non il rapporto di immedesimazione organica, bensì il nesso sinallagmatico di tipo contrattuale tra adempimento dei doveri e diritto al compenso.

L'eccezione di inadempimento del sindaco può essere sollevata anche dal curatore del fallimento, a fronte della domanda di insinuazione allo stato passivo del suo credito professionale, assumendo che l'istante sia incorso nella responsabilità concorrente e solidale prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c.: a tal riguardo, la **Sez. 1, n. 03922/2024, Crolla, Rv. 670221-02**, ha affermato che, il curatore deve fornire la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibile dal sindaco e, solo una volta fornita la prova di tali fatti, non semplicemente descritti, può limitarsi a

dedurre il difetto di vigilanza dell'organo di controllo. Tale pronuncia rappresenta una specificazione del principio affermato dalla Sez. 6-1, n. 25584/2018, Nazzicone, Rv. 650915-01, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore *ex art. 1460 c.c.*. Il principio era stato affermato nell'ambito di un'opposizione allo stato passivo, in cui la S.C. aveva rigettato il ricorso contro l'esclusione di un credito, relativo a compensi derivanti dalla carica di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società fallita, in virtù della prova fornita in relazione all'eccezione di inadempimento, spiegata dal fallimento, dei doveri inerenti alla carica.

Sempre in tema di azioni di responsabilità verso l'organo sindacale, **Sez. 1, n. 02350/2024, Dongiacomo, Rv. 670237-01**, ha affermato che spetta all'attore allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso; una volta assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di dimostrare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la prevista gamma di atti (sollecitazioni, richieste, richiami, indagini) sino alle denunce alle autorità civile e penale. A tal riguardo, merita ricordare che, come già affermato da Sez. 1, n. 18770/2019, Nazzicone, Rv. 654662-01, ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi - secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale - se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione *ex art. 2403-bis c.c.*, la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata *ex artt. 2377 ss. c.c.*, la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'*art. 2406 c.c.*, il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite *ex artt. 2446-2447 c.c.*, il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'*art. 2487 c.c.*, la denuncia al tribunale *ex art. 2409 c.c.*, ed ogni altra attività possibile ed utile.

Infine, in linea di continuità con quanto affermato da Sez. 1, n. 18770/2019, Nazzicone, Rv. 654662-02, si è posta la già citata **Sez. 1, n. 03922/2024, Crolla, Rv. 670221-01**, secondo cui, in tema di responsabilità dei componenti dell'organo di controllo delle società, non è sufficiente, al fine di escludere l'inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo la realizzazione dei fatti dannosi, ove i soggetti nominati abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.

Sulla scia del precedente di cui a Sez. 1, n. 32397/2019, Fidanzia, Rv. 656128-01, **Sez. 1, n. 27789/2024, Catallozzi, Rv. 673352-01**, ha statuito che la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'*art. 2407, comma 2, c.c.* non richiede

l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, essendo sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate. Nella specie, la S.C., ha confermato la decisione di condanna al risarcimento del danno pronunciata in favore del fallimento, nei confronti del componente del collegio sindacale di una s.r.l. che aveva disatteso i doveri derivanti dalla sua carica, omettendo la convocazione dell'assemblea *ex art.* 2406 c.c., la denuncia al Tribunale *ex art.* 2409 c.c., nonché l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità *ex art.* 2393, comma 3, c.c., pur a fronte di gravi irregolarità.

3.6. La responsabilità da direzione e coordinamento.

In una occasione, la S.C. ha avuto modo di affrontare la responsabilità risarcitoria prevista dall'art. 2497 c.c. a carico delle società o degli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento.

In particolare, in tema di gruppi societari, Sez. 1, n. 15196/2024, Campese, Rv. 671470-01, ha affermato che la società eterodiretta non è legittimata ad esperire direttamente l'azione di responsabilità nei confronti della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, poiché l'art. 2497, comma 3, c.c., nel riconoscere tale legittimazione ai soci ed ai creditori della controllata, offre un sistema di tutela completo, garantendo, ai primi, il risarcimento del pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione e, ai secondi, la difesa dell'integrità del patrimonio sociale ed evitando inammissibili duplicazioni, sicché, in caso di fallimento della società eterodiretta, il curatore è legittimato ad esercitare soltanto l'azione già spettante ai creditori sociali, non essendogli riconosciuto un generalizzato potere di rappresentanza. A tal riguardo, giova ricordare che, secondo Sez. 1, n. 29139/2017, Nazzicone, Rv. 646486-01, l'art. 2497, comma 3, c.c. non prevede una condizione di procedibilità dell'azione di responsabilità - promossa dal socio o dal creditore sociale nei confronti della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento - consistente nella infruttuosa escussione del patrimonio della controllata o nella previa formale richiesta risarcitoria ad essa rivolta, avendo il legislatore posto unicamente in capo alla società capogruppo l'obbligo di risarcire i soci e i creditori sociali danneggiati dall'abuso dell'attività di direzione e coordinamento.

3.7. La revoca dell'amministratore e il recesso del socio.

Nell'anno in rassegna, meritano nota due interventi della Suprema Corte in tema, rispettivamente, di revoca dell'amministratore e di recesso del socio.

Il primo di essi riguarda le società per azioni partecipate da un ente pubblico, con riferimento alle quali Sez. 1, n. 31994/2024, Falabella, Rv. 673238-01, ha affermato che la revoca dell'amministratore da parte dello Stato o dell'ente pubblico che lo ha nominato, ai sensi dell'art. 2449, comma 2, c.c., è un atto di diritto privato da imputarsi alla società partecipata, sicché della sua eventuale illegittimità (nella specie, perché adottata senza giusta causa) risponde la sola società e non anche lo Stato o l'ente titolare della relativa partecipazione. Sul tema, appare utile menzionare l'arresto delle Sez. U., n. 07799/2005, Elefante, Rv. 580283-01, secondo cui la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il Comune ne possieda, in tutto o in parte, le azioni: il rapporto tra società ed ente

locale è di assoluta autonomia, al Comune non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento di provvedimenti comunali di non approvazione del bilancio e conseguente revoca degli amministratori di società per azioni di cui il Comune sia unico socio, costituendo gli atti impugnati espressione non di potestà amministrativa ma dei poteri conferiti al Comune dagli artt. 2383, 2458 e 2459 cod. civ., nella specie trasfusi nello statuto della società per azioni, e quindi manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, cosicché la posizione soggettiva degli amministratori revocati - che non svolgono né esercitano un pubblico servizio - è configurabile in termini di diritto soggettivo, dovendo inoltre escludersi la riconducibilità di detta controversia nel novero di quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

Quanto al secondo profilo, **Sez. 1, n. 02629/2024, Nazzicone, Rv. 670257-01**, ha affermato che, nell'ambito delle società per azioni, che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è lecita la clausola statutaria che, ai sensi dell'art. 2437, comma 4, c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società *ad nutum* con un termine congruo di preavviso. Sul medesimo tema, può essere utile ricordare che, secondo **Sez. 1, n. 04716/2020, Iofrida, Rv. 657081-01**, è escluso il diritto di recesso *ad nutum* del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al 2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall'art. 2437, comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società e dovendo anche escludersi l'estensione della disciplina prevista dall'art. 2285 c.c. per le società di persone, ove prevale l'*intuitus personae*, ostandovi esigenze di certezza e di tutela dell'interesse dei creditori delle società per azioni al mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest'ultimo offerta, a differenza dei creditori delle società di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili.

3.8. Le operazioni straordinarie.

Nell'anno in rassegna, vanno menzionate talune pronunce in tema di operazioni straordinarie, cioè quelle operazioni di riorganizzazione della società che si riflettono sul patrimonio sociale e sulla posizione dei soci.

Innanzitutto, in linea di continuità con la precedente **Sez. 1, n. 06324/2023, Abete, Rv. 667131-01, Sez. 1, n. 14414/2024, Vella, Rv. 671464-01**, ha affermato che la fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata, che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, in ragione della norma speciale di cui all'art 10 l.fall.

Con riferimento alla scissione societaria, **Sez. 3, n. 02457/2024, Condello, Rv. 670066-01**, ha affermato che la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506-*quater* c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impu-

gnazione, ad un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali. A tal riguardo, giova menzionare il precedente della Sez. 6-2, n. 36690/2021, Dongiacomo, Rv. 662935-01, secondo cui, in tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-*bis*, comma 2 e 2506-*quater*, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova.

Infine, in ambito tributario, Sez. T, n. 14465/2024, Picardi, Rv. 671429-01, ha affermato che, in tema di imposta di registro, la trasformazione eterogenea regressiva è soggetta all'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. c), della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, integrando l'ultima modifica statutaria della società, non riconducibile al successivo art. 9 della stessa tariffa, che ha natura residuale e si applica solo agli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con previsione di un corrispettivo, non ravvisabile ove una società di capitali si trasformi in società non lucrativa o ente non societario. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto correttamente corrisposta l'imposta in misura fissa, poiché nella trasformazione di una società in fondazione il capitale sociale resta impiegato, sia pure con modalità e fini diversi, e non viene restituito ai soci a titolo di corrispettivo.

3.9. I patti parasociali.

In due pronunce, la Suprema Corte si è occupata di patti parasociali.

In particolare, in tema di società di capitali, Sez. 1, n. 13561/2024, Fraulini, Rv. 671334-01, ha affermato che i patti parasociali, anche a seguito della tipizzazione operata dall'art. 2341-*bis* c.c., possono avere un contenuto diverso da quello previsto dalla citata norma, quale espressione della libertà contrattuale riconosciuta ai soci, purché detti accordi siano finalizzati a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all'interno della società, nell'esercizio della funzione organica che essi svolgono per effetto della qualità rivestita, secondo una delle tre finalità codificate dalla predetta disposizione. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva qualificato come patto parasociale una convenzione con cui il socio uscente aveva pattuito che la cessione della quota ad un terzo era condizionata all'assunzione della garanzia, da parte del cedente, del pagamento pro quota di un mutuo precedentemente contratto nell'interesse della società, accertando che tale assetto di interessi nulla aveva a che vedere con le finalità previste dall'art. 2341-*bis* c.c.. Sempre in tema di patti parasociali, Sez. 1, n. 22375/2023, Fraulini, Rv. 668462-01, la clausola cd. *russian roulette*, contenuta in un patto parasociale, è valida, in quanto soddisfa l'interesse dei soci paciscenti ad evitare la possibile paralisi del funzionamento dell'assemblea derivante dalla contrapposizione del loro paritetico peso nell'esercizio del diritto di voto, sicché deve negarsi che la determinazione del suo contenuto sia rimessa all'unilaterale arbitrio di un socio a danno dell'altro.

In secondo luogo, Sez. 1, n. 27283/2024, Fraulini, Rv. 672775-01, ha affermato che la clausola, inserita in un contratto di permuta azionaria, volta ad indennizzare il beneficiario in caso di perdita del valore di mercato delle partecipazioni permutate, garantendone la redditività, configura un patto parasociale, che non viola il divieto di patto leonino, ove non comporti uno stravolgimento totale e costante del ruolo del socio e sia

meritevole di tutela, risultando funzionale non solo al tipo di operazione concretamente identificata, ma anche al raggiungimento degli interessi identificati dalle parti nel contratto di permuta medesimo. A tal riguardo, può risultare utile menzionare il precedente di Sez. 1, n. 17498/2018, Nazzicone, Rv. 649519-01, secondo cui è lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. *put*) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società.

4. Particolari società di capitali.

Vengono di seguito riportate le pronunce della S.C. che hanno esaminato società regolate da una disciplina del tutto speciale, con particolare riferimento alle società cooperative. A tali figure devono essere affiancate le società a partecipazione pubblica, comprese le società *in house*, a cui, proprio per l'accentuata specificità, viene dedicato un autonomo capitolo, nella parte riservata ai rapporti con i pubblici poteri, cui si rinvia.

4.1. Le società cooperative.

Nell'anno in rassegna, la Suprema Corte è tornata ad occuparsi di questioni relative alla particolare natura del rapporto del socio all'interno della cooperativa. Come è noto, infatti, con la partecipazione ad una società cooperativa, il singolo realizza due tipi di rapporti: quello mutualistico (che ha riflessi sul piano patrimoniale) e quello sociale (che attribuisce al socio dei poteri all'interno dell'organizzazione).

Secondo Sez. 1, n. 16231/2024, Falabella, Rv. 671541-01, il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti, l'uno - di carattere associativo - che direttamente discende dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. Pertanto, in caso di controversia sulla legittimità di contribuzioni poste dalla società a carico del socio nelle cooperative edilizie - in cui l'acquisto da parte dei soci della proprietà dell'alloggio - per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito - passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio in cui la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente - occorre verificare se gli apporti richiesti al socio incidano sul rapporto di scambio, traducendosi in oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo della vendita (nel qual caso si è in presenza di atti della società inidonei ad incidere sui diritti derivanti dal contratto di cessione dell'alloggio e perciò privi di effetti nei confronti del socio), o sul rapporto associativo, da cui discende l'obbligo di effettuare i conferimenti e le contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione previsti dallo statuto. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza chiarire a quale dei due rapporti sopra descritti si riferisse, aveva ritenuto legittima una delibera di spesa che richiedeva a ciascun socio, ben dopo l'assegnazione dell'alloggio, un contributo finanziario per il pagamento del mutuo contratto dalla cooperativa per la costruzione del complesso edilizio oggetto del rapporto sociale. La pronuncia si pone in linea di continuità con la Sez. 1, n. 07646/2007, Gilardi, Rv. 596020-01.

Sempre in tema di società cooperative, Sez. 1, n. 14850/2024, Campese, Rv. 671344-01, ha ribadito che il principio in base al quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale non sono utilizzabili nell'ambito dei contratti societari, in quanto caratterizzati dalla comunione di scopo, non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio da parte del socio si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione alla vita sociale e non è caratterizzato dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra le prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. Il principio è stato affermato in una controversia tra socio e società cooperativa agricola e zootecnica, in cui il conferimento del prodotto agricolo da parte del primo è stato qualificato come l'adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario, sebbene originata all'interno di una relazione di natura associativa ed in base ad accordi negoziali, aventi come fonte anche il contratto sociale. La pronuncia si pone in linea di continuità con il precedente della Sez. 2, n. 23606/2023, Varrone, Rv. 668409-01, ma risulta difforme rispetto al precedente della Sez. 3, n. 24242/2023, Condello, Rv. 668646-01, secondo cui i conferimenti annuali di prodotti, eseguiti dal socio imprenditore agricolo alla cooperativa agricola di conferimento o di trasformazione, trovano titolo nel contratto sociale che prevede la relativa obbligazione e non costituiscono oggetto di una prestazione accessoria *ex art. 2345 c.c.*, con la conseguenza che la consegna dei prodotti non determina l'operatività del principio di corrispettività e non fa sorgere in capo al socio il diritto a un corrispettivo, ma una mera aspettativa alla remunerazione del proprio conferimento, che può anche mancare e che è integrata dall'attribuzione *pro quota* ai soci del profitto conseguito dalla cooperativa tramite l'attività di impresa. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il diritto alla remunerazione del conferimento di latte effettuato da un socio a una cooperativa agricola a r.l., che, a causa di una grave crisi del settore lattiero-caesario, aveva subito una perdita di esercizio.

CAPITOLO XVIII

IL DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI

(DI ALESSANDRO FAROLFI)

SOMMARIO: 1. Questioni pregiudiziali. - 2. Intermediazione finanziaria. - 3. I rapporti bancari. - 4. La responsabilità della banca. - 5. Titoli di credito.

1. Questioni pregiudiziali.

Va innanzitutto evidenziato, in questa materia, che alcune questioni originate da rinvio pregiudiziale *ex art. 363 bis c.p.c.*, sono state decise nel corso del presente anno dalle Sezioni unite. In particolare:

a) il decreto della Prima Presidente del 06/09/2023, su rinvio del Trib. di Salerno, in tema di mutuo con ammortamento alla francese di cui sia indicato il TAN e l'importo delle rate, domandandosi se occorra l'indicazione del regime composto degli interessi ai fini del rispetto di determinatezza e determinabilità dell'oggetto contrattuale, nonché ai fini della possibile applicazione della nullità di cui all'art. 117 comma 4 TUB, per violazione dei principi di trasparenza contrattuale, ha portato alla decisione di **Sez. U, n. 15130/2024, Rv. 671092-02**, massimata nei seguenti termini in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti;

b) quanto al decreto della Prima Presidente del 18/09/2023, su rinvio del Trib. di Milano, sul valore del titolo esecutivo giudiziale di condanna e, in particolare, nella parte in cui rinvia agli interessi legali, se questi ultimi debbano ritenersi esclusivamente quelli di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., ovvero se possa ritenersi implicito il richiamo al maggior tasso (c.d. super-interesse) di cui al quarto comma della stessa disposizione, **Sez. U, n. 12449/2024, Rv. 670951-02**, ha stabilito che se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (*ex art. 1284, comma 4, c.c.*), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo;

c) l'ulteriore decreto presidenziale, emesso sempre in data 18/09/2023, circa i rapporti fra l'art. 1284, comma 4, c.c. e l'art. 429 c.p.c. in tema di crediti di lavoro, relativo alla questione se quest'ultima disposizione abbia natura speciale o sia destinata ad integrarsi con la prima, ha portato ad una decisione di inammissibilità sopravvenuta della questione, in dipendenza di quanto deciso dalle stesse S.U. con la pronuncia appena richiamata n. 12449/2024 (si tratta di **Sez. U., n. 12974/2024**, non massimata).

Da notare che nel corso dell'anno in rassegna una nuova questione pregiudiziale, ancora una volta in materia di mutuo ed a testimonianza di un dialogo fecondo fra merito e legittimità, è stata assegnata alle Sezioni Unite con decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione del 10 ottobre 2024. Si tratta della questione “se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l'intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, la configurabilità a carico del medesimo mutuatario di una obbligazione attuale di restituzione della somma - per gli effetti di cui all'art. 474, comma I, c.p.c. - imponga inderogabilmente che l'importo erogato sia stato successivamente svincolato in favore del mutuatario ovvero se, al contrario, possano prospettarsi regolamenti contrattuali idonei a determinare l'insorgenza di un obbligo restitutorio. Conseguentemente, se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l'intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, il contratto così stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. contro il mutuatario solo allorché nelle medesime forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata sia attestato lo svincolo delle somme già mutate e ritrasferite alla mutuante ovvero se, al contrario, un siffatto contratto concluso nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. anche in assenza di attestazione dello svincolo effettuata secondo le modalità previste da tale ultima disposizione, allorché il regolamento contrattuale sia idoneo a determinare l'insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima del detto svincolo”.

2. Intermediazione finanziaria.

La S.C. ha, nel corso del 2024, affrontato molti nodi problematici relativi all'intermediazione finanziaria ed ai doveri degli intermediari con relative responsabilità connesse.

Si può iniziare col ricordare che la S.C. ha stabilito come il termine prescrizione decennale per l'esercizio da parte del cliente dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione di un “contratto quadro” stipulato con il primo, inizi a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (**Sez. 1, n. 32226/2024, Campese, Rv. 673234-01**). La medesima decisione ha altresì precisato che ai detti fini, l'indagine, incentrata sull'accertamento della manifestazione in concreto per il cliente medesimo del pregiudizio patrimoniale, deve necessariamente tenere conto, tra l'altro, della natura peculiare dei beni oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare i quali, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili nonché del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile non può essere provocato dal normale andamento del valore o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto la fluttuazione del titolo stesso è ontologicamente connaturata alla

natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari, soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari, essendo necessario, invece, un “quid pluris”, se del caso anche un evento “anomalo”, che disveli il rischio taciuto dall’intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale.

Peraltro, secondo **Sez. 3, n. 28952/2024, Spaziani, Rv. 672891-01**, la responsabilità solidale dell’intermediario, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di una condotta anomala dell’investitore, idonei ad evidenziarne la collusione oppure la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, il cui apprezzamento costituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità (nella specie, la S.C. ha affermato l’inammissibilità della censura volta a contestare l’argomentato giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito circa l’inidoneità ad escludere la responsabilità solidale dell’intermediario dell’incauto affidamento da parte dell’investitore delle credenziali per operare sul proprio conto corrente). La medesima decisione (Rv. 672891 - 02) ha altresì osservato che la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dal promotore allorquando, accertata la sussistenza del rapporto di preposizione ed il carattere illecito, doloso o colposo del fatto dannoso, ricorre un nesso di occasionalità necessaria tra quest’ultimo e l’esecuzione delle incombenze affidate al preposto, per la cui ricorrenza non è necessario che il fatto dannoso derivi dall’esercizio delle incombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo sia esposto all’ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cui quest’ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l’incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso.

Sez. 1, n. 16097/2024, Fraulini, Rv. 671538-01, ha invece stabilito che il diritto di recesso di cui all’art. 30, comma 6, d. lgs. n. 58 del 1998, non trova applicazione qualora l’investimento sia inserito in una più complessa operazione economica, tale che possa presumersi una pianificazione complessiva dell’intera operazione, sì da escludere l’effetto di “sorpresa” che il legislatore ha inteso neutralizzare mediante la previsione dello *ius poenitendi*.

Da considerare, in tema di nullità relative alle forme contrattuali, la precisazione compiuta da **Sez. 1, n. 9331/2024, Lamorgese, Rv. 670720-01**, per cui il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma, ai sensi dell’art. 23 T.U.F., senza necessità di indagare se la partecipazione dell’altro (la cui firma è risultata apocrita) sia stata essenziale, in quanto tale negozio non è qualificabile come contratto plurilaterale, ai sensi dell’art. 1420 c.c., bensì come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa, derivandone il conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi i clienti. Mentre **Sez. 1, n. 7315/2024, Perrino, Rv. 670646-01**, ha stabilito che laddove sia convenuto fra le parti che l’oggetto dell’investimento debba individuarsi in titoli a basso rischio, il modo dell’esecuzione del mandato ricevuto non può rientrare nella discrezionalità dell’intermediario finanziario, costituendo piuttosto il contenuto dell’obbligazione che grava sul medesimo quale mandatario dell’investitore, così che ai sensi dell’art. 1711 c.c. restano a sua carico gli atti esorbitanti dal mandato ricevuto, dovendo pertanto rispondere dei danni arrecati in conseguenza della negoziazione di titoli ad alto rischio od acquistati su ordinativi contenenti la firma apocrita dell’investitore, nei limiti delle perdite subite dal cliente per effetto dell’eccesso del mandato. A sua volta, invece, **Sez. 1, n. 6343/2024, Catallozzi, Rv. 670476-01**, ha affermato che l’estensione degli obblighi di forma per la conclusione dei contratti, ai sensi dell’art. 25 del

d.lgs. n. 58 del 1998, anche ai servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche, nonché, in quanto compatibili, dalle imprese di assicurazione, voluta dall'art. 11 l. n. 262 del 2005 con l'introduzione dell'art. 25-*bis* del predetto d.lgs., va riguardata in uno con il perdurante potere della Consob di prevedere, con regolamento, che gli stessi possano o debbano essere stipulati in altra forma (in applicazione del citato principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità di un contratto assicurativo finanziario per difetto del requisito di forma scritta, senza considerare che la Consob, con la delibera del 30 maggio 2007, n. 15691, applicabile *ratione temporis*, aveva esteso l'esclusione del requisito della forma scritta per i prodotti finanziari emessi dalle banche anche agli omologhi prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione).

In tema di raccolta di informazioni dal cliente, **Sez. 1, n. 7412/2024, Falabella, Rv. 670561-01**, ha affermato che la compilazione, al momento della conclusione del contratto quadro, del questionario diretto a far conoscere la propensione al rischio del cliente ed i suoi obiettivi di investimento, non vale ad integrare la dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, del reg. Consob n. 11522 del 1998, che esige un'espressa attestazione sulla specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, al fine di rendere edotto l'intermediario della volontà dell'investitore di rinunciare ad una serie di diritti, altrimenti spettantegli, non ricavabile dalle generiche indicazioni raccolte a norma dell'art. 28 del citato regolamento (fattispecie in tema di *interest rate swap*).

Si è invece stabilito, in tema di offerta al pubblico di prodotti finanziari, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto informativo, ai sensi dell'art. 34-*ter* del Regolamento Emittenti Consob, la locuzione "medesimo prodotto finanziario" non indica strumenti finanziari semplicemente appartenenti al medesimo genere, ma allude a strumenti finanziari omogenei, perché si riferiscono a un medesimo affare o condividono un identico ed unico rischio, connesso all'investimento del capitale (**Sez. 2, n. 33255/2024, Guida, Rv. 673505-02**). La stessa decisione (Rv. 673505-01) ha altresì precisato che l'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo viene meno in presenza dei presupposti di esenzione *ex art. 34-ter* del Regolamento Emittenti Consob e, cioè, quando i prodotti offerti provengono da soggetti giuridici distinti senza superare, per ciascuno di essi, la soglia di cinque milioni di euro nell'arco di dodici mesi e, al contempo, sotto il profilo oggettivo, vi è diversità dei prodotti offerti, trattandosi di patrimoni destinati *ex art. 2447-bis c.c.*, costituiti ciascuno per uno specifico affare.

Sulla questione relativa alla distinzione fra polizze previdenziali ed investimenti speculativi, **Sez. 1, n. 9418/2024, Perrino, Rv. 670878-02**, ha invece affermato che in tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze *guaranteed unit linked*, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle *partial guaranteed unit linked*, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze *unit linked* cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la natura assicurativo - previdenziale della polizza

stipulata, escludendone la qualità di strumento finanziario, dal momento che essa garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote se maggiore, con un incremento dell'1%, al momento della morte del contraente assicurato).

3. I rapporti bancari.

Iniziando da una prospettiva processuale e, per così dire, di carattere pregiudiziale, si è affermato che in tema di competenza per valore, la domanda di consegna della documentazione bancaria, formulata ai sensi dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, è di valore indeterminabile, a nulla rilevando il valore dei costi di produzione delle copie, poiché tale attività è meramente strumentale a soddisfare il diritto del cliente ad ottenere la consegna dei documenti relativi al rapporto, anche a fini di acquisizione della prova. (Sez. 1, n. 29272/2024, Iofrida, Rv. 673027-01). Mente con riferimento al recupero dei crediti bancari oggetto di "cartolarizzazione", Sez. 3, n. 7243/2024, Fanticini, Rv. 670579-01, ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.

Sez. 2, n. 23866/2024, Amato, Rv. 672283-01, ha affermato che nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel qualificare un contratto di prestito di denaro concluso tra persone fisiche, aveva erroneamente interpretato le categorie ministeriali e le Istruzioni della Banca d'Italia, così facendo rientrare la scrittura privata nella categoria "altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine", benché la stessa, sostenuta da garanzie personali, fosse stata sottoscritta da un soggetto diverso dalle banche e dagli intermediari non bancari).

Nell'anno in rassegna si riscontrano diverse pronunce in tema di conto corrente bancario. Sez. 1, n. 15177/2024, Scotti, Rv. 671348-01, ha affermato che l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tempestiva la contestazione della posta corrispondente al saldo negativo di un conto secondario, formulata solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis vigente, poiché la banca non aveva prodotto anteriormente, né in sede monitoria né con la comparsa di risposta o con la prima memoria, l'estratto del conto principale, da cui risultava la confluenza dei saldi negativi dei conti secondari).

Sez. 1, n. 13586/2024, Marulli, Rv. 671460-01, ha a propria volta precisato che in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebitato *ex art. 2033 c.c.* anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebitato da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebitato può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate. Collegata a tale pronuncia la decisione, di poco precedente, resa da **Sez. 1, n. 4214/2024, Fidanzia, Rv. 670268-01**, per la quale l'azione di ripetizione dell'indebitato *ex art. 2033 c.c.* è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebitato pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria.

Da ricordare che, secondo **Sez. 1, n. 11735/2024, Caiazza, Rv. 671118-01**, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato; che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale; che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile).

Per il caso di conto corrente per il quale manchino una parte degli estratti conto, **Sez. 1, n. 1763/2024, Campese, Rv. 669907-04**, ha così ricostruito la distribuzione degli oneri probatori delle parti: ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda; a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi

intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile; b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda; b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale; in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.

Si è già ricordato (retro § 1) che in materia è intervenuta la importante decisione resa da **Sez. U, n. 15130/2024, Lamorgese, Rv. 671092-02**, secondo cui in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

Sempre in tema di interessi, **Sez. 1, n. 5282/2024, Falabella, Rv. 670278-01**, ha affermato che in tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 - e della delib. CICR del 9 febbraio 2000.

4. La responsabilità della banca.

In tema di responsabilità della banca, **Sez. L, n. 31844/2024, Cavallaro, Rv. 673297-01**, ha affermato che in caso di pagamento da parte della banca dei ratei di pensione, una volta deceduto il beneficiario, al soggetto delegato alla riscossione, la responsabilità dell'istituto di credito verso l'INPS, pur in assenza tra le predette parti di un contratto, è di natura contrattuale, in ragione dello speciale affidamento che chiunque si avvale di un intermediario bancario per effettuare un pagamento è legittimato a riporre nell'adozione, da parte dell'intermediario medesimo, di tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione del beneficiario, vieppiù in considerazione della qualità professionale del banchiere che gli impone uno sforzo maggiore in termini di correttezza e protezione dell'affidamento, rispetto a quello che si può attendere dal *quisque de populo*.

Mentre, secondo **Sez. 3, n. 29831/2024, Gorgoni, Rv. 672934-01**, in tema di deposito amministrato di azioni, il mandato irrevocabile a vendere titoli conferito a un istituto bancario a garanzia di un concesso affidamento esclude, pur in presenza di un significativo scarto tra valore della garanzia e debito garantito, l'obbligo della banca di procedere alla vendita, ma non la esonera dall'agire in buona fede, nell'esecuzione del contratto, per la gestione prudentiale dei titoli e la loro eventuale dismissione, anche in assenza di un ordine esplicito (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria di due correntisti limitandosi ad escludere l'esistenza di un danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di vendere i titoli senza valutare la sussistenza di un danno per violazione, da parte della banca, dell'obbligo di comportarsi in buona fede nell'esecuzione del contratto, provvedendo alla vendita delle azioni in via di deterioramento, anche in assenza di un ordine impartito in tal senso dai clienti).

Diverse le pronunce massimate in tema di pagamento di assegno a soggetto non legittimato. Per **Sez. 1, n. 26972/2024, Fraulini, Rv. 672514-01**, in tema di responsabilità della banca negoziatrice, per aver consentito l'incasso di un assegno di traenza a persona non legittimata, il giudizio di diligenza professionale, compiuto dal giudice di merito per integrare la clausola generale ed elastica dell'art. 1176, comma 2, c.c., costituisce attività di interpretazione della norma, non limitata al mero profilo di ricostruzione fattuale, e, trattandosi di giudizio di diritto, è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ove si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di Poste italiane s.p.a., per aver consentito l'incasso di un assegno di traenza da parte di cliente non abituale, identificato attraverso la patente di guida ed il codice fiscale, sebbene questi fossero documenti d'identità ed il titolo non presentasse segni di alterazione o contraffazione). A sua volta, **Sez. 1, n. 25888/2024, Terrusi, Rv. 672481-01**, ha stabilito che la responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, prevista dall'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, ha natura contrattuale, ragion per cui la banca è sempre ammessa a fornire la prova liberatoria della non imputabilità a sé dell'erronea identificazione. La stessa decisione ha affermato che, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice nell'identificazione del prenditore, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., non configurandosi detta responsabilità in senso meramente oggettivo.

Nel caso di prelievi abusivi effettuati dal promotore finanziario infedele, la S.C. ha precisato che incombe sul cliente danneggiato l'onere di provare la distrazione delle somme dal proprio conto corrente, mentre spetta alla banca provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa risarcitoria, costituito dall'accreditamento della somma derivante dagli investimenti effettuati dal promotore su altri conti correnti nella giuridica disponibilità del cliente (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato la banca al risarcimento del danno, non avendo provato che le somme sottratte erano tornate nella disponibilità del cliente rimasto vittima delle falsificazioni degli ordini di bonifico: così **Sez. 3, n. 25855/2024, Tassone, Rv. 672263-01**).

Sempre nell'anno in rassegna, la S.C. ha invece affermato che a seguito di risoluzione della Banca delle Marche s.p.a., disposta dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di "passività" richiede che il

debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento; ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio. (**Sez. 1, n. 22115/2024, Marulli, Rv. 672273-01**).

Sez. 1, n. 21105/2024, Caiazza, Rv. 672086-01, ha affermato che, in tema di pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario, l'art. 25 del d.lgs. n. 11 del 2010 - di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno - attribuisce all'IBAN la funzione di filtro per determinare i casi in cui la responsabilità della mancata o inesatta esecuzione è attribuibile all'utente e quelli in cui occorre accertare quale degli intermediari coinvolti nel procedimento abbia causato il malfunzionamento dell'operazione, con la conseguenza che, se un pagamento risulta eseguito secondo un IBAN erroneamente indicato dal solvens, non sussiste responsabilità degli intermediari che hanno partecipato all'operazione (pur avendo gli stessi l'obbligo di attivarsi e collaborare per il recupero delle somme), indipendentemente dal fatto che l'ordine contenga ulteriori informazioni per individuare il beneficiario e/o il suo conto di accredito. Nella medesima materia, **Sez. 1, n. 17415/2024, Campese, Rv. 671553-01**, ha invece stabilito che la responsabilità della banca in caso di pagamento mediante bonifico, da eseguirsi in favore di beneficiario sprovvisto di conto di accredito presso l'istituto intermediario, osserva la disciplina del diritto comune, sicché, ove il beneficiario sia rimasto insoddisfatto a causa dell'inesatta indicazione del codice Iban, grava sull'intermediario, responsabile secondo la teoria del contatto sociale qualificato, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie per scongiurare il rischio di erronea individuazione o, quanto meno, di essersi adoperato per consentire all'ordinante di individuare il soggetto concretamente beneficiato anche comunicando, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.

A dimostrazione della diffusività del fenomeno, anche **Sez. 3, n. 3780/2024, Moscarini, Rv. 670096-01**, è intervenuta in argomento, stabilendo che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente (nella specie, la S.C. in applicazione del detto principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto gravante su Poste Italiane S.p.a., ai fini della non riferibilità al cliente delle operazioni fraudolente eseguite con la sua carta Postepay, la dimostrazione della previa adozione di mezzi di prevenzione dell'uso illecito dei sistemi elettronici di pagamento, quali, ad esempio, l'invio al titolare della carta di appositi sms alert di conferma di ogni singola operazione).

In termini più ampi si è affermato (**Sez. 1, n. 3350/2024, Marulli, Rv. 669961-01**) che la responsabilità contrattuale da contatto sociale - che, alla stregua dell'art. 1173 c.c., è ascrivibile all'operato delle autorità di vigilanza per il fatto commesso dal proprio dipendente o dal proprio funzionario allorché, per la posizione di protezione rispettivamente rivestita, siano in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell'illecito - postula che il danno sia derivato da una precisa regola di condotta che, quantunque avente portata generale, sia indirizzata verso quei soli soggetti che, in relazione al contesto sociale di riferimento e al contatto determinato in quel contesto, siano individuabili come portatori di uno specifico interesse meritevole di tutela (nella specie, la S.C. ha escluso che gli organi di controllo di un istituto di mutualità in dissesto, quali il Mise o Confcooperative, la Banca d'Italia e il Ministero per lo sviluppo economico, fossero venuti meno ad un obbligo di protezione specifica nei confronti dei titolari di libretti e certificati

di deposito emessi dal medesimo istituto, in quanto gli scopi da ciascuno di essi perseguiti mirano a tutelare interessi riguardanti la generalità dei consociati e non quelli specifici dei reclamanti, tutelabili, in difetto del presupposto del contatto sociale, solo nell'ambito del *neminem laedere ex art. 2043 c.c.*).

5. Titoli di credito.

In termini generali, **Sez. 3, n. 29476/2024, Pellecchia, Rv. 672840-01**, ha affermato che l'art. 1994 c.c. - il quale prevede che chiunque ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito in conformità alle sue leggi di circolazione non è soggetto ad azione di rivendicazione - si applica esclusivamente ad ipotesi in cui un soggetto acquista il titolo da un altro soggetto che non ne era proprietario (un terzo, quindi, rispetto al proprietario spogliato), non potendosi invece applicare ai rapporti diretti *inter partes*, i quali restano soggetti alle norme generali, perché la norma mira, da un lato, ad impedire la circolazione di un titolo di credito ma non gli incassi avvenuti in forza di esso e, dall'altro, ad evitare che di quel medesimo titolo vi sia un successivo acquisto da parte di terzo con relativo possesso di buona fede (nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità della norma e confermato la sentenza di accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo in relazione al versamento di una somma, a mezzo assegni bancari, in favore della ricorrente in carenza di causa di giustificazione, non essendo intercorso tra le parti alcun rapporto contrattuale).

Sez. 1, n. 25910/2024, Terrusi, Rv. 672499-01, ha invece stabilito che requisiti per la valida assunzione di un'obbligazione cambiaria in nome altrui sono, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1669 del 1933, non solo l'esistenza di una procura o di un potere *ex lege*, ma anche l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri, come nel caso di collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società, sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente, con la conseguenza che a questo ultimo deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l'eccezione, proponibile soltanto dal rappresentato, del difetto o eccesso di rappresentanza del sottoscrittore (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la levata del protesto nei confronti del sottoscrittore - per mancanza di fondi sul suo conto personale - piuttosto che della società rappresentata, a causa della mancata indicazione della qualità di amministratore, nonostante l'assegno recasse la ragione sociale e gli altri elementi identificativi della società accanto alla firma di traente).

In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, si è invece precisato che la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno, cui consegue l'inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa, non ammette equipollenti e, onde evitare accordi fraudolenti dell'obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento, rappresentando il rispetto di detto termine condizione per l'operare dell'esenzione da responsabilità; tale prova va pertanto fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto esclusivamente nelle forme previste dall'art. 8, della l. n. 386 del 1990 e, cioè, mediante quietanza con firma autenticata del portatore, ovvero con attestazione dell'istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell'importo dovuto. (**Sez. 1, n. 22850/2024, Caiazza, Rv. 672350-01**). In tema anche **Sez. 3, n. 20738/2024, Spaziani, Rv. 671961-01**, secondo cui in caso di omesso pagamento di assegno bancario e in mancanza della levata del protesto nei confronti del traente, il portatore non può esercitare l'azione di regresso contro gli obbligati cambiari, ma mantiene i suoi diritti contro l'emittente del titolo, che non dispone di azione di regresso e,

dunque, non è portatore di un interesse tutelato dalla legge al tempestivo protesto (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente escluso i presupposti per l'esercizio dell'azione causale di regresso - esercitata, con ricorso monitorio, da parte del portatore degli assegni nei confronti dei giranti e del traente -, senza considerare che quattro dei dieci titoli azionati erano stati protestati e che l'emittente doveva ritenersi obbligato per l'intero importo indicato da tutti i titoli, a prescindere dal protesto).

Sez. 3, n. 8793/2024, Rossi, Rv. 670766-01, ha affermato che, in caso di espropriazione presso terzi, il decorso del termine triennale di prescrizione per l'incasso dell'assegno circolare emesso da una banca, quale terzo pignorato, per ottemperare all'ordinanza di assegnazione, comporta il venir meno di ogni possibile azione nei riguardi dell'emittente da parte del creditore procedente, beneficiario dell'assegno, il quale non può ottenere, in un autonomo giudizio di cognizione, la condanna dell'istituto di credito alla riemissione dell'assegno o al pagamento della relativa provvista, essendosi estinta ogni obbligazione cartolare, ed essendo, di regola, carente di interesse ad agire sulla base del rapporto causale sottostante l'emissione dell'assegno, salva l'allegazione della specifica utilità, giuridicamente apprezzabile, ottenibile dal giudizio di cognizione e diversa da quella offerta dal titolo esecutivo di cui è già munito, integrato dall'ordinanza di assegnazione.

Si è altresì precisato (Sez. 1, n. 1633/2024, Terrusi, Rv. 670235-01) che il pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto cambiario deve necessariamente avvenire tramite moneta, non potendo, di contro, risolversi nella consegna di assegni bancari (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che detta consegna avesse avuto effetto solutorio, in un caso in cui il pubblico ufficiale aveva a sua volta illegittimamente restituito le cambiali al debitore ed incassato gli assegni trattenendone l'importo).

CAPITOLO XIX

IL DIRITTO DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

(DI ALESSANDRO FAROLFI E ALDO RUGGIERO)¹

SOMMARIO: 1. Il fallimento dell'imprenditore: i presupposti. - 1.1. L'estensione del fallimento e le società cancellate. - 1.2. Il procedimento prefallimentare. - 1.3. I reclami avverso la sentenza di fallimento e il decreto di rigetto. - 2. Gli organi delle procedure concorsuali. - 2.1. I reclami endoconcorsuali. - 3. I pagamenti e le azioni di inefficacia. - 3.1. Le azioni *ex art. 66 l.fall.* - 3.2. Le revocatorie fallimentari. - 4. I rapporti pendenti. - 5. La formazione dello stato passivo - 5.1. Segue: profili processuali - 6. La liquidazione dell'attivo - 7. La chiusura del fallimento e l'esdebitazione - 8. Il concordato fallimentare. - 9. Il concordato preventivo in generale. - 9.1. Segue: l'ammissione, la revoca, l'omologa. - 10. La liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria.

1. Il fallimento dell'imprenditore: i presupposti.

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è stato approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, 14, ma, dopo essere stato più volte modificato, è entrato in vigore il 15 luglio 2022, abrogando la legge fallimentare e sostituendo il fallimento con una procedura sostanzialmente analoga, denominata liquidazione giudiziale.

Il Codice è stato poi oggetto di un successivo restyling ad opera del d.lgs. n. 136/2024, entrato in vigore lo scorso 28 settembre 2024. Tale ultimo correttivo ha, in effetti, modificato molteplici disposizioni del codice, soprattutto correggendo difetti di formulazione e/o coordinamento, ovvero cercando di meglio esprimere principi che avevano dato luogo a contrasto nell'ambito della giurisprudenza di merito. Fortemente incisa, inoltre, è stata la disciplina del sovraindebitamento e dell'esdebitazione dell'incapiente.

L'art. 121 del c.c.i.i., peraltro, conferma la linea di continuità fra liquidazione giudiziale e fallimento, stabilendo che "le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza". I requisiti di cui all'art. 2 cit., riguardano: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Sono stati perciò, di fatto, riconfermati i parametri dimensionali già utilizzati dal precedente art. 1, comma 2, l.fall.

Anche per il presupposto oggettivo, caratterizzato dallo stato di insolvenza, va ricordato che l'art. 5, comma 2, l.fall. lo individua, stabilendo che "lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". La stessa definizione, va subito

(1) I paragrafi 5, 5.1, 6, 7, 8, 9, 9.1 e 10 sono stati redatti da Aldo Ruggiero. I restanti da Alessandro Farolfi.

aggiunto, è stata testualmente ripresa e, quindi, confermata dall'art. 2, comma 1, lett. b) del nuovo Codice, sì che su questo punto l'elaborazione giurisprudenziale relativa appare destinata a mantenere la sua attualità.

In attesa che le nuove disposizioni codicistiche siano oggetto dell'interpretazione nomofilattica della S.C., continuano - in forza della norma transitoria di cui all'art. 390 c.c.i.i. - ad applicarsi le norme previgenti della legge fallimentare alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi. Questo spiega perché le decisioni che saranno di seguito richiamate continuino ad applicare, appunto, le norme previgenti.

Posta tale premessa, occorre subito aggiungere che diverse sono state le decisioni che nel corso di quest'anno si sono occupate di fallimento e dei suoi presupposti, ponendosi certamente in linea con gli orientamenti ormai acquisiti.

Per quanto riguarda i presupposti dimensionali, **Sez. 1, n. 25159/2024, Pazzi, Rv. 672406-01**, ha stabilito che il debito assunto da un terzo nei confronti dell'imprenditore mediante il c.d. "accollo interno" va computato nella verifica del superamento della soglia di fallibilità, prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., atteso che in esso il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.

Per **Sez. 3, n. 34075/2024, Fanticini, Rv. 673170-03**, ha stabilito che il *trust* non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto; pertanto, dopo aver affermato in motivazione che esso non è litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, provvedendo successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, la decisione riportata ha precisato che il *trust*, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società dall'art. 73, comma 1, TUIR (come modificato dall'art. 1, comma 74, della l. n. 296 del 2006), non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal *trustee* nell'interesse di uno o più beneficiari; ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotato altresì di legittimazione processuale - è solo il *trustee*.

In tema di valutazione dell'insolvenza delle società in liquidazione, si è precisato che gli effetti della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento dell'iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese, con la conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (**Sez. 1, n. 12156/2024, Amatore Rv. 671452-01**).

Sez. 1, n. 11342/2024, Dongiacomo, Rv. 671017-01, ha invece affermato che ai fini della assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone, in conseguenza del fallimento della società, non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell'operatività di un patto sociale, ma basta la prova di un comportamento del socio tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento.

Da sottolineare, altresì, che **Sez. 1, n. 204/2024, Dongiacomo, Rv. 670553-01**, ha stabilito che l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nell'interesse proprio, benché costituisca in astratto un indizio contrario all'esistenza della c.d. supersocietà di fatto e favorevole, piuttosto, alla individuazione di una *holding* di fatto, non esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale *affectio* tra le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi, l'esercizio di un abuso sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo. Nella stessa linea di pensiero, **Sez. 1, n. 74/2024, Fidanzia, Rv. 670212-01**, ha affermato che, in tema di supersocietà di fatto, l'abuso di una società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato, che è compatibile con l'accordo, iniziale o successivo, che la società si faccia carico dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli utili, mentre le persone fisiche simmetricamente assumano debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti, ove l'abuso non sia stato programmato sin dal momento in cui i soggetti hanno iniziato ad interagire, ma sia solo il frutto della violazione dei principi di corretta gestione da parte di chi, tra gli originari partecipi del rapporto, era in condizione di farlo (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza di una supersocietà di fatto per la mancanza dell'elemento della *affectio societatis*, senza indagare se esso fosse carente sin dall'origine ovvero fosse successivamente venuto meno, in forza di una modifica ed evoluzione in concreto degli originari accordi).

Sempre in ordine al presupposto soggettivo, **Sez. 1, n. 1587/2024, Vella, Rv. 670234-01**, ha stabilito che l'esenzione delle *start up* innovative dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste in tema di sovraindebitamento, prevista dall'art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica in modo automatico al momento del decorso dei termini stabiliti nell'art. 25, commi 2 e 3, del medesimo decreto, senza che rilevino né il termine di sessanta giorni previsto per l'adempimento delle formalità amministrative di cancellazione dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta.

1.1. L'estensione del fallimento e le società cancellate.

Si interseca con il tema in oggetto, affrontando altresì il ruolo del Curatore la seguente decisione, resa da **Sez. 1, n. 32531/2024, Pazzi, Rv. 673512-01**, secondo cui, in tema di contenuto ed efficacia probatoria della relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l.fall., rientra fra i compiti del curatore quello di raccogliere informazioni rivolgendosi, ai sensi dell'art. 49 l.fall., all'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento o a chi abbia motivo di ritenere che abbia rivestito di fatto tale ruolo, ai fini della puntuale ricostruzione della dinamica dell'impresa dichiarata fallita e della conseguente assunzione delle più opportune iniziative nella gestione della procedura fallimentare, con la conseguenza

che tali dichiarazioni, che sono liberamente rese, dall'interrogato, senza alcun obbligo di essere preventivamente ammonito né alcun conseguente dovere di rispondere, una volta rese, sono pienamente utilizzabili e valutabili a fini probatori, anche in sede di richiesta di estensione del fallimento nei confronti del dichiarante.

Con una precisazione di rilievo, si è affermato che, a seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007 - che ha comportato il venir meno dell'iniziativa ufficiosa - i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel successivo procedimento di fallimento in estensione *ex artt. 15 e 147 l.fall.*, promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore, e neanche nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione, proposto dal socio illimitatamente responsabile cui il fallimento sia stato esteso, poiché l'oggetto della sentenza di fallimento in estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società. (**Sez. 1, n. 17546/2024, Perrino, Rv. 671554-01**).

Ai fini della notifica del ricorso in estensione, **Sez. 1, ord. n. 12134/2024, Amatore, Rv. 672398-01**, ha stabilito che l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita).

Nel corso dell'anno in rassegna **Sez. 1, n. 14414/2024, Vella, Rv. 671464-01**, ha affermato che la fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata, che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, in ragione della norma speciale di cui all'art 10 l.fall.

1.2. Il procedimento prefallimentare.

Affrontando il delicato tema della segnalazione dello stato di insolvenza, si è affermato che quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell'art. 7 l.fall., la trasmissione degli atti al P.M., affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice, di cui all'art. 111 Cost., per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell'imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice (**Sez. 1, n. 27560/2024, Pazzi, Rv. 672785-01**).

Sez. 1, n. 27611/2024, Pazzi, Rv. 672787-01, ha invece precisato che la risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento dinanzi al tribunale ritenuto competente, presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietà

del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art. 9-*bis* della l.fall., (introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2006), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente. Sempre in tema di competenza, **Sez. 1, n. 12131/2024, Amatore, Rv. 670978-01**, ha stabilito che in tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio *ex art. 9 l.fall.* deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, secondo quanto previsto dall'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare; conseguentemente, l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento deve ritenersi tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.

Ancora una volta in tema di fusione per incorporazione, **Sez. 1, n. 18261/2024, Crolla, Rv. 671666-01**, ha affrontato il tema della legittimazione passiva, stabilendo che in tema di fallimento, la fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 10 l.fall. di talché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio *ex art. 15 l.fall.*, il soggetto debitore destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nella società incorporata che, pur se estinta, conserva la propria identità ai fini dell'eventuale dichiarazione di fallimento, potendo peraltro la società incorporante intervenire nel giudizio prefallimentare e proporre reclamo, nella qualità di soggetto interessato, avverso l'eventuale sentenza di fallimento dell'incorporata medesima.

Il tema del coordinamento fra diverse procedura concorsuali pendenti è stato affrontato stabilendo che in tema di ammissione al concordato preventivo in pendenza del giudizio per la dichiarazione di fallimento, al termine concesso per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 162, comma 1, l.fall., avente natura perentoria, non si applica la sospensione feriale, essendo prevalenti le esigenze di celerità sottese alla discussione dell'istanza di fallimento (**Sez. 1, n. 14196/2024, Perrino, Rv. 671463-01**).

1.3. I reclami avverso la sentenza di fallimento.

In questo ambito, **Sez. 1, n. 27525 del 23/10/2024, Vella, Rv. 672782-01**, ha affermato che il decreto con cui la corte d'appello, in accoglimento del reclamo *ex art. 22, comma 4, l.fall.*, rimette gli atti al tribunale per la declaratoria del fallimento, avendo natura interinale e non decisoria, non deve contenere alcuna statuizione sulle spese e sulla responsabilità processuale aggravata *ex art. 96 c.p.c.*, prevista invece solo nel caso di rigetto.

Con una importante precisazione, si è stabilito che il reclamo avverso la sentenza di fallimento *ex art. 18 l.fall.* non rientra tra quelli esentati, in forza dell'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, dal pagamento del contributo unificato sicché, in ipotesi di rigetto di detta impugnazione, risulta dovuto il raddoppio del contributo medesimo (**Sez. 1, n. 15533/2024, Amatore, Rv. 671349-01**).

Sez. 1, n. 14985/2024, Fidanzia, Rv. 671468-01, ha invece affermato che, in tema di notifiche a mezzo p.e.c., la notificazione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è validamente effettuata, ove il messaggio ecceda la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, attraverso l'invio di una pluralità di buste, una principale e le altre complementari, purché gli invii siano coevi, cioè strettamente consecutivi, ed

eseguiti entro la fine del giorno di scadenza (nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto irrituale la notificazione a mezzo p.e.c. del reclamo, avvenuta mediante più messaggi consegnati nello stesso giorno nell'arco di un breve intervallo temporale).

Circa gli effetti della desistenza, si è operata una importante distinzione: in tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove sia prodotta soltanto in sede di reclamo; al contrario, la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva respinto il reclamo del fallito, escludendo che una transazione contenente un accollo liberatorio, priva di data certa, prodotta dinanzi al giudice d'appello, potesse incidere sulla legittimazione del creditore istante travolgendo la sentenza di apertura della procedura concorsuale) (**Sez. 1, n. 11495/2024, Dongiacomo, Rv. 670976-01**).

Sez. 1, n. 922/2024, Pazzi, Rv. 670213-01, ha affermato che la Corte d'appello, in sede di reclamo avverso una statuizione del tribunale che abbia ritenuto inammissibile in rito una domanda concordataria dichiarando poi il fallimento, ove ritenga di accogliere l'impugnazione, deve rimettere la causa al tribunale medesimo per l'esame nel merito della domanda di concordato, non potendo prenderla direttamente in esame.

2. Gli organi delle procedure concorsuali.

Sul ruolo del curatore, **Sez. 1, n. 27288/2024, Pazzi, Rv. 673506-01**, ha affermato che, in tema di determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni che rimane disponibile per il fallito, il giudice delegato non esercita un potere pienamente discrezionale, ma deve compiere una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito da destinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, tenendo conto che è onere del curatore richiedere preventivamente l'emissione del decreto di cui all'art. 46, comma 2, l.fall., al fine di documentare l'eventuale eccedenza dei pagamenti, ed è onere del fallito, che intenda trattenere quanto percepito a titolo di reddito o pensione, allegare e dimostrare le condizioni personali in cui versa e le particolari esigenze a cui egli deve sopperire a tal fine.

Il comportamento del curatore può, talora, rilevare al fine di riconoscere una perdurante legittimazione processuale del fallimento. In argomento si è affermato che in tema di fallimento, la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell'atto impositivo, con riferimento ai rapporti d'imposta i cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori ad impugnare l'atto. (**Sez. T, n. 21333/2024, Leuzzi, Rv. 671651-02**).

Sez. 1, n. 18116/2024, Dongiacomo, Rv. 671662-02, ha invece affermato che il consulente di parte nominato dal curatore fallimentare nell'ambito di un processo civile svolge attività di natura squisitamente difensiva, ancorché di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita, con la conseguenza che il suo compenso deve essere determinato avendo riguardo, in

ragione della qualità dell'opera prestata, alle relative tariffe professionali e, nei limiti dell'importo domandato, al valore della pratica ivi previsto, mentre non è possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio. La stessa decisione ha altresì precisato che l'opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'art. 32, comma 2, l.fall. e s'inquadra, piuttosto, in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale.

In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale (**Sez. 1, n. 6642/2024, Caiazza, Rv. 670477-01**).

Con riferimento al ruolo ed ai poteri del giudice delegato, **Sez. U, n. 7337/2024, Terrusi, Rv. 670507-01**, ha affermato che l'art. 108, comma 2, l.fall. prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo (disciplinata nella sezione II del capo VI della medesima normativa) secondo le alternative indicate nell'art. 107 l.fall., perché in essa il curatore esercita la sua funzione secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; al contrario, va escluso che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisce, *ex art. 72, ult. comma, l.fall.* quale semplice sostituto del fallito nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito con cui era stato autorizzato il curatore, subentrato al fallito nel preliminare di compravendita trascritto anteriormente all'apertura del fallimento, a stipulare il contratto definitivo, cancellando altresì l'ipoteca gravante sull'immobile, destinato ad abitazione principale del promissario acquirente).

2.1. I reclami endoconcorsuali.

Il tema è stato affrontato da **Sez. 1, n. 28509/2024, Pazzi, Rv. 672877-01**, secondo cui il decreto emesso dal giudice delegato di immediata liberazione dell'immobile trasferito, assoggettato a procedura concorsuale, può essere impugnato esclusivamente mediante il reclamo *ex art. 26 l.fall.* e non attraverso il rimedio dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* (la fattispecie riguardava una locazione a canone vile non opponibile all'aggiudicatario *ex art. 2923 c.c.*).

Da ricordare anche **Sez. 1, n. 18019/2024, Amatore, Rv. 671661-01**, che ha affermato come la parte rimasta insoddisfatta dal provvedimento reso ai sensi dell'art. 169-*bis* l.fall., anche in sede di reclamo, avente a oggetto la sorte dei contratti pendenti stipulati dall'imprenditore ammesso alla procedura, possa far valere l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o sospensione, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano, mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattere amministrativo e non giurisdizionale dell'oggetto del predetto provvedimento, che resta tale anche nell'ipotesi in cui il concordato sia stato omologato, non sussistendo in tale ipotesi alcuna preclusione da giudicato impeditiva della proponibilità dell'azione.

Sez. 2, n. 17879/2024, Grasso, Rv. 671715-01 ha, invece, affermato che l'opera prestata dai professionisti a favore del fallimento viene liquidata dal giudice delegato con decreto impugnabile esclusivamente con il rimedio del reclamo *ex art.* 26 l.fall.; tale principio non soffre eccezioni quanto al decreto di liquidazione dei compensi del difensore di un fallimento ammesso al gratuito patrocinio in un processo tributario, come si desume *ex art.* 144 del d.P.R. n. 115 del 2002 che devolve al giudice delegato, e non alle Commissioni del patrocinio a spese dello Stato, tutte le funzioni di vigilanza.

In questa materia si rinviene, altresì, una delle primissime applicazioni del nuovo Codice della crisi: si tratta di Sez. 1, n. 12523/2024, Pazzi, Rv. 670980-01, la quale ha affermato che il reclamo previsto dall'art. 124 del d. lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), a differenza delle norme contenute negli artt. da 40 a 53 dello stesso codice, che regolano in linea generale il procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, riguarda la procedura di liquidazione giudiziale e non può essere esteso o applicato in via analogica a procedure di diversa natura, in mancanza di uno specifico richiamo normativo.

3. I pagamenti e le azioni di inefficacia.

In tema di azione di inefficacia *ex art.* 64 l.fall., Sez. 1, n. 20886/2024, Pazzi, Rv. 671964-01, ha stabilito che deve ritenersi che il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito integri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del *solvens*; tuttavia, detta prova ben può essere rappresentata dalla circostanza che il pagamento abbia riguardato un debito di pertinenza di un soggetto creditore del *solvens*, in quanto ciò soddisfa, di per sé, un interesse mediato e indiretto di quest'ultimo, correlato all'automatico operare della compensazione legale (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, al fine di dimostrare il carattere oneroso della prestazione, il fatto che il pagamento fosse avvenuto per estinguere un debito di altra società, appartenente al medesimo gruppo, a sua volta creditrice del *solvens*).

Da menzionare anche Sez. 1, n. 15196/2024, Campese, Rv. 671470-02, secondo cui in tema di finanziamenti dei soci in favore della società, l'azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso, percepito entro l'anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell'indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, poiché l'art. 2467, comma 1, c.c. (*ratione temporis* applicabile) delinea un'inefficacia *ex lege* del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della *scientia decotionis*.

3.1. Le azioni *ex art.* 66 l.fall.

In argomento, si segnala Sez. 3, n. 7201/2024, Tassone, Rv. 670439-01, la quale ha affermato che il commissario liquidatore è assimilabile, per natura e funzioni, al curatore fallimentare e, come questo, nell'azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla società posta in liquidazione, ha l'onere di provare a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; conseguentemente, la sussistenza dell'*eventus damni* può ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre i predetti elementi emerge che, per effetto dell'atto pregiudizievole, è divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito (in misura eccedente la

normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori) e il requisito soggettivo della *scientia damni* va ravvisato nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria.

3.2. Le revocatorie fallimentari.

Nel corso dell'anno in rassegna si segnala, anzitutto, una decisione che si è occupata della natura dell'obbligazione restitutoria discendente dall'accoglimento della revocatoria fallimentare. **Sez. 1, n. 31652/2024, Vella, Rv. 673511-01**, ha stabilito che in esito al positivo esperimento da parte del curatore dell'azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione restitutoria dell'*accipiens* soccombente, attesa la natura costitutiva della relativa sentenza, ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, con la conseguenza che gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e, in difetto di sua proposizione, dalla data della sentenza di accoglimento.

Sez. 1, n. 30124/2024, Dongiacomo, Rv. 673205-01, ha invece affermato che è inammissibile l'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, esperita nei confronti di un fallimento, trattandosi di un'azione costitutiva che modifica *ex post* una situazione giuridica preesistente ed operando il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso in funzione di tutela della massa dei creditori (nel caso di specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'azione revocatoria fallimentare esperita dal terzo acquirente, a sua volta fallito, successivamente all'apertura della procedura concorsuale nei confronti del fallito alienante avente per oggetto la risoluzione unilaterale del contratto di cessione d'azienda per inadempimento della cessionaria e conseguente retrocessione del compendio aziendale, in quanto proposta dopo l'apertura del fallimento della cedente, rilevando che, mentre l'azione costitutiva non è esperibile per le anzidette ragioni, il curatore del fallito cessionario potrà, comunque, insinuarsi al passivo del fallimento del cedente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione dal momento che, oggetto della revocatoria, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori).

Sez. 1, n. 30252/2024, Vella, Rv. 673191-01, ha affermato che in tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa (si veda anche **Sez. 1, n. 25166/2024, Abete, Rv. 672487-01**). Contestualmente, **Sez. 1, n. 30254/2024, Dongiacomo, Rv. 673085-01**, ha stabilito che, in tema di revocatoria fallimentare, la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del solo fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientra tra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro; ne consegue che non può certamente ritenersi tale il pagamento eseguito da un terzo, su ordine o indicazione del debitore delegante, poi fallito, con denaro di quest'ultimo, non rilevando, per contro, la convinzione del creditore circa l'utilizzazione da parte del *solvens* di denaro proprio.

Sez. 1, n. 30130/2024, Dongiacomo, Rv. 673509-01, ha pure affermato che, in tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione di una precedente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal fine utilizzati, secondo lo schema del collegamento negoziale, conferisce all'operazione complessivamente realizzata, e all'atto terminale di estinzione del debito, carattere di anormalità (nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che la riscossione da parte della banca appellante dei crediti oggetto di due mandati all'incasso ad essa conferiti dalla società poi fallita costituisce un atto di pagamento che aveva estinto, con mezzi anormali, il debito assunto nei suoi confronti dalla mandante alla restituzione delle somme alla stessa erogate dalla banca mandataria a titolo di anticipazione su crediti IVA).

Con altra pronuncia contestuale (**Sez. 1, n. 30127/2024, Dongiacomo, Rv. 673138-01**) il S.C. ha altresì precisato che l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, i quali seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'operatività dell'esenzione, poiché la brevità del rapporto tra le parti era incompatibile con la formazione di una prassi commerciale stabile, senza effettuare alcuna valutazione con riferimento alle condizioni contrattualmente pattuite).

Per **Sez. 1, n. 12754/2024, Crolla, Rv. 671393-01**, invece, l'atto con il quale il contraente non inadempiente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, risolve unilateralmente il contratto stipulato con il contraente inadempiente poi fallito non è annoverabile tra gli "atti a titolo oneroso" e quindi non è revocabile ai sensi dell'art. 67 l.fall., in quanto il contraente inadempiente, che in seguito sia sottoposto a fallimento, non vi ha in alcun modo partecipato o cooperato, subendone solo gli effetti in posizione di soggezione.

Sempre in tema di esenzione da revocatoria, **Sez. 1, n. 10039/2024, Crolla, Rv. 671084-01**, ha affermato che, in tema di cartolarizzazione ex l. n. 130 del 1999, l'esenzione di carattere soggettivo all'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, prevista dall'art. 4, comma 3, della citata normativa, essendo finalizzata a non ledere l'interesse e le aspettative degli investitori che hanno sottoscritto le obbligazioni della cessionaria, opera a condizione che la cartolarizzazione venga completata, con l'emissione degli strumenti finanziari necessari per il pagamento dell'operazione di cessione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva disconosciuto l'esenzione, perché la banca aveva fornito solo la prova della cessione in blocco dei crediti, ma non dell'emissione dei titoli incorporanti e della loro collocazione sul mercato). Invece **Sez. 1, n. 8900/2024, Pazzi, Rv. 671093-01**, ha stabilito che l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. non si applica al compenso dell'avvocato, poiché il rapporto intercorrente con il cliente non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo.

4. I rapporti pendenti.

Nel corso dell'anno in rassegna, le S.U. si sono occupate degli effetti del subentro del curatore nel contratto preliminare trascritto, nonché dei poteri "purgativi" spettanti al giudice delegato *ex art.* 108 l.f.

Si è già menzionata **Sez. U, n. 7337 del 19/03/2024, Terrusi, Rv. 670507-01**, secondo cui l'art. 108, comma 2, l.fall. prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo (disciplinata nella sezione II del capo VI della medesima normativa) secondo le alternative indicate nell'art. 107 l.fall., dovendosi escludere che la norma possa essere applicata nei diversi casi in cui il curatore agisce, *ex art.* 72, ult. comma, l.fall. quale semplice sostituto del fallito nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita. La medesima decisione ha, altresì, precisato a tal riguardo che la soluzione accolta dall'art. 173, comma 4, del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza si pone in discontinuità rispetto alla regolamentazione contenuta nella legge fallimentare e non può, pertanto, essere utilizzata al fine di estendere detto potere purgativo al di là delle ipotesi di liquidazione dell'attivo fallimentare ivi previste, considerato altresì che l'interpretazione di una disposizione di legge, anche ove intesa in senso evolutivo, non può che trovare un limite nel significante testuale della disposizione normativa che il legislatore ha posto.

Sez. L, n. 5316/2024, Patti, Rv. 670158-01, ha invece affermato, in una materia al crocevia fra appalto e rapporti di lavoro, che le prestazioni accessorie rese dalla società datrice di lavoro, *ex art.* 2345 c.c., a favore di altra società, in quanto socia della stessa, ed aventi contenuto omogeneo a quello delle prestazioni di lavoro rese dai dipendenti a favore della prima, non hanno rilevanza nei confronti dei lavoratori, in quanto essi sono terzi rispetto al rapporto societario, sicché tra la società datrice di lavoro e la s.p.a. è configurabile, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto di servizi; ne consegue che il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, *ex art.* 29 del d.lgs. 276 del 2003, per cui deve escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società (nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, pur avendo qualificato il rapporto tra le due società alla stregua di un appalto di servizi, aveva dichiarato improcedibile l'azione diretta intentata nei confronti della committente dai dipendenti della società posta in liquidazione coatta amministrativa).

Sez. 1, n. 28955/2024, Dongiacomo, Rv. 673508-01, ha affermato che nel contratto di conto corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza che, quando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre fare esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire nel suddetto conto ed ormai perfezionatesi, a nulla rilevando la mancata annotazione di dette operazioni (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un caso di anticipi su fatture appostate sul conto anticipi, aveva rigettato la domanda di ammissione al passivo della banca creditrice

sul presupposto che dette somme erano state addebitate sul conto corrente bancario del debitore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, senza indagare, in forza del regime giuridico relativo a dette operazioni, sull'avvenuto perfezionamento o meno delle stesse a prescindere dalla loro annotazione sul conto corrente bancario).

5. La formazione dello stato passivo.

La formazione dello stato passivo costituisce uno dei passaggi essenziale per addivenire alla soddisfazione dei creditori, atteso che ognuno di loro, al fine di ottenere il pagamento del proprio credito, è tenuto all'insinuazione nello stato passivo, con la conseguente ammissione del giudice delegato o del tribunale, in ossequio al principio della *par condicio creditorum*. Lo stato passivo è attraversato da diversi passaggi, avendo una preliminare fase di presentazione delle domande di ammissione, una fase di accertamento ed ammissione o meno del credito da parte del giudice delegato ed una fase di opposizione concernente la contestazione del credito per il quale è stata chiesta la ammissione. La disciplina dello stato passivo consente anche la presentazione di domande tardive e di domande ultratardive, soggette sempre alla fase contenziosa in caso di mancata ammissione per motivi di rito o di merito del credito.

Nell'anno in rassegna, **Sez. 3, n. 24806/2024, Porreca, Rv. 672217-01**, ha affermato che la pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiedere l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore. Ciò conferma la permanenza dell'esclusività e della necessità della insinuazione di ogni credito nello stato passivo, atteso che la S.C. ha ribadito che la pendenza di un procedimento diretto all'accertamento di un credito non esonera il creditore dal presentare la domanda di ammissione nello stato passivo, onere che non può mai ricadere sul curatore, pur nella conoscenza della pendenza del giudizio di merito.

Sempre con riferimento allo stesso principio della necessaria insinuazione del credito nello stato passivo, la **Sez. 3, n. 17154/2024, Spaziani, Rv. 671566-01**, ha affermato che il creditore - che ottiene prima della apertura della procedura concorsuale nei confronti del debitore una sentenza di condanna di quest'ultimo (o una sentenza di accertamento del credito, pure se emessa in reiezione di un'azione di accertamento negativo esperita dal debitore) - deve essere ammesso al passivo con riserva, ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 3, della l. fall., sulla base di tale pronuncia, ancorché soggetta ad impugnazione, ed il curatore ha la facoltà di proporre l'impugnazione o proseguirla se era già stata proposta dalla parte *in bonis*, non determinandosi, pertanto, l'improcedibilità della domanda. La S.C., pertanto, in applicazione della citata norma, ha affermato che il curatore ha la possibilità, una volta ammesso con riserva il credito, di impugnare il titolo ottenuto dal creditore ovvero di proseguire il giudizio avviato dal debitore-fallito.

Quanto alla formazione del titolo anteriormente alla pronuncia di fallimento, **Sez. 1, n. 08260/2024, Crolla, Rv. 670568-01**, ha statuito che l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto decorre dalla data di emissione del provvedimento di esecutorietà, di cui all'art. 647 c.p.c., atteso che con esso il giudice compie un'attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale del decreto medesimo, restando privi di rilievo disfunzioni dell'ufficio o ritardi nell'emissione del relativo provvedimento. Peraltro, la stessa S.C. ha statuito che, in difetto di quanto

sopra, ogni credito, pur se fondato su un decreto ingiuntivo, tuttavia privo di dette connotazioni, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 l.fall., coerentemente con il principio della cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della sua declaratoria e con un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici patrimoniali delle parti, garantendo, comunque, il procedimento di verifica del passivo, anche attraverso l'appendice oppositiva *ex art.* 98 l.fall., la pienezza del contraddittorio processuale e l'esercizio del diritto di difesa in relazione al credito vantato.

Tra i titoli previsti ai fini dell'ammissione con riserva ovvero della semplice ammissione poiché già passati in giudicato anteriormente alla pronuncia di fallimento, **Sez. 1, n. 04593/2024, Amatore, Rv. 670556-01**, ha affermato che il credito fondato su una ordinanza *ex art.* 186-*ter* c.p.c., successivamente revocata per l'improcedibilità del giudizio a seguito dell'intervenuto fallimento, non è suscettibile di essere ammesso con riserva, ai sensi dell'art. 96, comma 2, della l.fall., non potendo considerarsi né un credito condizionato né, tanto meno, un credito accertato con sentenza non ancora passata in giudicato al momento dell'apertura della procedura concorsuale, perdendo detto titolo ogni rilevanza.

Nell'esame dell'anno in rassegna, in tema di accertamento, assume rilevanza anche la natura del credito per ottenere eventualmente una soddisfazione prioritaria del credito rispetto a tutti gli altri creditori, ove caratterizzato da un titolo privilegiato che lo connota in tal senso. Ai fini della formazione dello stato passivo, una volta accertato il credito, ove richiesto dal creditore con l'insinuazione, il giudice fallimentare deve anche valutare la natura del credito, privilegiato o meno, che attribuisce una priorità in sede di riparto, in via generale o su singoli beni su cui insiste il vincolo.

Detta peculiarità sussiste non solo in sede sostanziale, connotando la natura del credito, ai fini di una ammissione prioritaria in sede di stato passivo e conseguentemente in sede distributiva, ma anche in sede processuale. **Sez. 1, n. 22914/2024, Crolla, Rv. 672278-01**, in tale contesto, ha affermato che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, poiché ancora in vigore in quanto non attinto dalla riforma, sia quando il debitore esecutato è sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia quando sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui ai successivi artt. 268 e ss., così da trattare in modo analogo dette procedure, ormai avvinte da una comunanza di disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai creditori fondiari. La S.C. riconduce così l'art. 150 del CCII all'art. 51 l.fall., ponendo in rilievo la permanenza, in entrambe le norme, della possibilità di deroghe, previste dalla legge, alla regola generale del divieto di azioni esecutive o cautelari in corso di procedura.

La S.C. nell'anno in rassegna è intervenuta anche in materia di consecuzione tra procedure concorsuali. **Sez. 1, n. 22772/2024, Abete, Rv. 672275-01**, ha affermato che la prededuzione prevista dall'art. 182-*quinquies* l.fall. non si proietta al di là del soggetto a cui essa è stata riconosciuta nella procedura medesima, anche se il piano concordatario eventualmente contempla o riflette una correlazione, convenzionale o legale, con altro imprenditore, sicché essa non transita né circola in dipendenza del trasferimento del credito cui si connette, né perdura o persiste in caso di vicende modificative del lato passivo dell'obbligazione. La pronuncia si fonda sul distinguo tra prededuzione, di ordine processuale, e privilegio, di natura sostanziale, per statuire che la prima non segue il trasferimento del credito poiché opera nell'ambito della procedura e solo nei confronti del soggetto verso la quale è riconosciuta. Ciò è tanto vero che il credito prededucibile è sottoponibile ad un diverso grado di priorità in presenza dei privilegi che, ove riconosciuti, possono attribuirgli

preferenza, in sede di distribuzione, al cospetto di più crediti prededucibili. Non va dimenticato, infatti, che anche questi ultimi devono trovare soddisfazione attraverso l'insinuazione nello stato passivo.

Nell'ambito della rilevanza soggettiva del creditore, si è pronunciata la **Sez. 2, n. 17879/2024, Grasso, Rv. 671715-01**, per la quale l'opera prestata dai professionisti a favore del fallimento è liquidata dal giudice delegato con decreto impugnabile esclusivamente con il rimedio del reclamo *ex art. 26 l.fall.* Secondo tale statuizione il principio non soffre eccezioni quanto al decreto di liquidazione dei compensi del difensore di un fallimento ammesso al gratuito patrocinio in un processo tributario, come si desume *ex art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002*, che devolve al giudice delegato (e non alle Commissioni del patrocinio a spese dello Stato) tutte le funzioni di vigilanza. La S.C. introduce una deroga ad un principio affermato in via generale con la pronuncia di **Sez. 2, n. 3027/2023, Criscuolo, Rv. 666844-01**, secondo la quale spetta al giudice ordinario la cognizione dell'opposizione, proposta *ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011*, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata nell'interesse di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario.

Sempre con riguardo ai professionisti di cui si avvale una procedura concorsuale e della loro soddisfazione in via prioritaria, **Sez. 1, n. 17248/2024, Dongiacomo, Rv. 671552-01**, ha statuito che il credito del professionista che ha assistito in sede stragiudiziale il debitore poi fallito, gode della prededuzione *cd. funzionale ex art. 111, comma 2, della l.fall.*, quando risulta che le relative prestazioni sono teleologicamente coerenti con l'interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale, appropriato alla reale consistenza dell'impresa e alle effettive possibilità di gestione dell'insolvenza e, quindi, valutabili, secondo un giudizio *ex ante* che prescinde dal risultato effettivamente conseguito, come funzionali o alla presentazione della relativa istanza ed alla predisposizione dei documenti a tal fine necessari ovvero alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa.

In tema di crediti bancari da valutarsi in sede di ammissione nello stato passivo, soprattutto sotto il profilo di eventuali compensazioni onde evitare che il creditore e debitore nello stesso tempo si trovi a dover pagare integralmente un proprio debito, avendo a soddisfazione del proprio credito invece solo una percentuale in moneta fallimentare, la **Sez. 1, n. 15825/2024, Dongiacomo, Rv. 671535-01**, ha affermato che, ove la banca sia stata ammessa al passivo per l'intero suo credito verso il fallito derivante dal saldo debitore dei conti correnti e dei conti collegati di anticipazione salvo buon fine, ed abbia proposto opposizione avverso il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento della compensazione tra tale credito e quello vantato dal fallito nei suoi confronti, a titolo di restituzione degli importi ad essa versati dai singoli debitori dei crediti oggetto dell'anticipazione, senza che il curatore abbia, a sua volta, autonomamente impugnato il decreto di ammissione, il giudice dell'opposizione non può nuovamente esaminare la questione relativa all'opponibilità verso la massa delle singole operazioni di anticipazione in base ad una rivalutazione dei fatti che sono stati o avrebbero dovuto essere oggetto di quel provvedimento, essendo l'ammissione coperta dal predetto giudicato. In tal caso, quindi, l'opponibilità del documento contrattuale e delle conseguenti anticipazioni comporta il dovere del giudice di accertare l'esistenza della clausola di compensazione, che deroga al principio di cristallizzazione dei crediti, indipendentemente dal fatto che il credito ed il correlativo debito siano, rispettivamente, anteriore e posteriore rispetto all'ammissione della correntista alla procedura concorsuale.

Sempre in tema di compensazione, la Sez. 3, n. 13345/2024, Gorgoni, Rv. 671151-01, ha affermato che, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice, per ottenerne il rigetto totale o parziale. La stessa Corte ha chiarito che, invece, trova applicazione il rito speciale previsto per l'accertamento del passivo dagli artt. 93 e ss. l. fall. solo in caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. Nel contenzioso esaminato, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile - qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale - la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere l'equo compenso, previsto dal contratto di *leasing* in caso di inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto.

In tema di eccezioni in sede di verifica di stato passivo, Sez. 1, n. 03459/2024, Dongiacomo, Rv. 670262-01 ha affermato che l'opposizione, con la quale il sindaco di una società fallita si duole della mancata ammissione allo stato passivo del credito da compenso maturato nei confronti dell'ente, è contrastabile dalla procedura fallimentare mediante eccezione di totale o parziale inadempimento o d'inesatto adempimento da parte del sindaco stesso ai propri obblighi contrattuali. A fronte del mero onere del curatore di allegare, in relazione alle circostanze di fatto, l'inadempimento dell'organo istante al dovere di vigilanza sull'attività di gestione sociale, viene in rilievo, in capo all'opponente, l'onere di provare di aver esattamente adempiuto, ossia di avere adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri-doveri inerenti alla carica. La pronuncia si inserisce nella normale dialettica processuale dell'onere della prova a carico delle parti contrattuali per dimostrare il corretto adempimento o il mancato o inesatto adempimento, soprattutto nel caso del sindaco di una società che non abbia vigilato ai fini dello scioglimento della stessa società per la perdita del capitale.

La Sez. 1, n. 03922/2024, Crolla, Rv. 670221-02, ha ulteriormente sviluppato la tematica, specificando che il curatore del fallimento che solleva l'eccezione di inadempimento del sindaco, a fronte della domanda di insinuazione allo stato passivo del suo credito professionale, assumendo che l'istante sia incorso nella responsabilità concorrente e solidale prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., deve fornire la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibile dal sindaco e, solo una volta fornita la prova di tali fatti (non semplicemente descritti), può limitarsi a dedurre il difetto di vigilanza dell'organo di controllo.

Ancora nello stesso solco si pone la già menzionata Sez. 1, n. 02343/2024, Terrusi, Rv. 671473-01, per la quale, a fronte dell'opposizione con la quale il sindaco di una società fallita si duole della mancata ammissione allo stato passivo del credito relativo al compenso maturato nei confronti dell'ente, la procedura fallimentare può sollevare l'eccezione di inadempimento del sindaco stesso ai propri obblighi contrattuali; tuttavia, nel caso in cui sia dedotta una fattispecie di responsabilità concorrente dei sindaci ex art. 2407 c.c., il curatore ha l'onere di proporre detta eccezione in maniera specifica,

dando la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la omessa vigilanza da parte dell'organo di controllo.

Quanto alla natura dei crediti esaminati dalla S.C., **Sez. 1, n. 06760/2024, Amatore, Rv. 670635-01**, ha affermato che l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento. In sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, pertanto, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio.

Con riguardo agli accessori che possono accompagnare l'ammissione del credito, la cui natura può condizionare sia l'*an* che il *quantum* degli stessi, **Sez. 1, n. 04403/2024, Fidanzia, Rv. 670271-01**, ha affermato che, alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito è dovuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 55, comma 1, della l.f., sono dovuti, senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo.

Quanto alla documentazione da presentare a corredo della domanda di insinuazione di un credito in sede di accertamento del passivo, **Sez. 1, n. 03839/2024, Fidanzia, Rv. 670220-01**, ha affermato che la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito così insinuato, non altrimenti surrogabile da parte del richiedente l'ammissione. Infatti, secondo la interpretazione della S.C., l'iscrizione dell'ipoteca, e quindi, la sua esistenza, non può che essere provata con la nota di iscrizione ipotecaria non potendosi dedurre, logicamente, da altra e diversa documentazione l'effettiva iscrizione di tale diritto reale di garanzia, nonché le sue modalità e gli accessori da riconoscere, ai sensi dell'art. 2855 c.c., soprattutto in considerazione della sua natura costitutiva.

Sempre con riferimento alla produzione documentale, ai fini dell'ammissione di un credito nello stato passivo relativo al settore bancario, **Sez. 1, n. 03462/2024, Terrusi, Rv. 670263-01**, ha affermato che, in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del limite di finanziabilità non comporta l'inefficacia delle garanzie reali e personali che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice ha ottenuto dal terzo a salvaguardia dell'adempimento del credito restitutorio. La pronuncia si pone in linea con l'orientamento dettato dalle S.U., per cui il limite di finanziabilità *ex art. 38 del T.U.B.* non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto, ma solo un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale fissato dall'autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "*vigilanza prudenziale*", in forza di una norma di natura non imperativa (S.U., n. 33719/22, Lamorgese, Rv. 666194-02). In conseguenza di ciò nessuna rilevanza può avere il limite di finanziabilità, soprattutto quando non viene in discussione il beneficio fondiario, ma le garanzie prestate da terzi.

Quanto agli effetti derivanti dalla consecuzione delle procedure, in tema di insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. *omisso medio*, **Sez. 1, n. 15862/2024, Rv. 671536-01**, ha statuito che, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possi-

bile la risoluzione *ex art.* 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario, l'effetto esdebitatorio - parziale - non viene meno laddove il fallimento sia stato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del concordato omologato era già scaduto.

Invece, **Sez. 1, n. 35087/2024, Dongiacomo, Rv. 673398-01**, ha precisato che in tema di scissione societaria, il creditore munito di ipoteca concessa a garanzia di un debito della società scissa può, in via alternativa, far valere il diritto di ipoteca sull'immobile nei confronti della società che ne sia stata assegnataria, ovvero il suo diritto di credito nei confronti di ciascuna delle società partecipanti all'operazione straordinaria, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato; conseguentemente, qualora la società assegnataria sia stata assoggettata a fallimento, nel primo caso il creditore ipotecario può limitarsi a intervenire nel procedimento fallimentare onde partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene compreso nella procedura e ipotecato in suo favore, mentre, ove faccia valere il diritto di credito sussidiario, ha l'onere di insinuarsi al passivo della relativa procedura, partecipando - nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla società fallita - alla distribuzione dell'intero attivo concorsuale.

5.1. Segue: profili processuali.

La verifica dello stato passivo segue una procedura delineata dal legislatore, di natura endoconcorsuale, senza attitudine ad un giudicato esterno, che deve essere utilizzata da ogni creditore ai fini dell'ammissione del proprio credito per poter partecipare al riparto dell'attivo. Occorre, infatti, da parte del creditore proporre una domanda di insinuazione del credito da sottoporre al giudice delegato, soggetta ad opposizione in caso di diniego totale o parziale, con competenza a decidere del Tribunale.

Nell'ambito della procedura di verifica trovano applicazione, pertanto, sia le regole generali che governano i procedimenti in generale sia le regole particolari dettate appositamente per l'accertamento dei crediti.

In particolare, con riferimento alla composizione del collegio giudicante, **Sez. 1, n. 25251/2024, Vella, Rv. 672413-01**, in tema di incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio chiamato a decidere sul giudizio di opposizione *ex art.* 98 l.f., ha affermato, in applicazione dell'art. 99, comma 10, l.fall. che, alla parte cui un vizio procedurale ha impedito di conoscere preventivamente i componenti del collegio e che, conseguentemente, non ha esercitato il potere di riconsunzione nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. per l'ipotesi di mancata astensione, non è preclusa la denuncia della nullità del decreto decisorio emesso dal collegio così composto, quando essa si correla alla specifica individuazione della causa di riconsunzione, in precedenza non rilevabile e riverberatasi nella nullità della decisione assunta. In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il decreto decisorio emesso dal Tribunale composto dal giudice delegato non astenutosi, avendo l'opponente avuto contezza dell'effettiva composizione del collegio, i cui componenti non erano indicati nel fascicolo digitale, solo al momento della comunicazione del decreto decisorio, atteso che i verbali di udienza attestavano unicamente la presenza del giudice relatore - poi risultato anche presidente ed estensore del decreto impugnato - ed il ruolo cartaceo affisso sulla porta

dell'aula di udienza indicava solo il nome del giudice relatore. La pronuncia appare così coerente anche con il principio del “*giusto processo*” espresso dall'art. 111, comma 2, della Costituzione, che trova nell'art. 6, par. 1, della CEDU il suo fondamento.

In punto di legittimazione attiva o passiva, **Sez. 1, n. 24375/2024, Dongiacomo, Rv. 672362-01**, ha affermato che, in tema di opposizione allo stato passivo, le questioni inerenti alla titolarità attiva o passiva rispetto al rapporto controverso dedotto in giudizio dall'attore hanno natura di mere difese, sicché esse non sono soggette al termine di decadenza previsto dall'art. 99, commi 6 e 7, l.fall., ma possono essere fatte valere anche oltre il termine dettato dalle dette disposizioni e rilevate in ogni caso d'ufficio dal giudice.

Con riguardo alla specialità del rito, **Sez. 1, n. 18760/2024, Terrusi, Rv. 671675-01**, ha statuito che, ai fini dell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria, devono essere osservate, ai sensi dell'art. 111-*bis* l.fall., le modalità del capo V della stessa legge, senza alcuna rilevanza della distinzione tra insinuazioni tempestive e tardive, concettualmente incompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza del credito. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda di insinuazione, viene in rilievo l'art. 101 l.fall., che esprime un principio generale, attuativo della ragionevole durata del procedimento del processo e declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole secondo una valutazione affidata al giudice del merito, caso per caso e secondo il suo prudente apprezzamento, con motivazione che non è sindacabile in sede di legittimità.

Sempre in ordine al rito ed alla sua specialità, **Sez. 1, n. 07772/2024, Vella, Rv. 670650-01**, ha statuito che la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non possono dare luogo ad alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato *ex art. 2909 c.c.*, il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare *ex art. 96, comma 6, l.fall.* In quest'ultimo, infatti, viene in rilievo non tanto il diritto di credito, quanto il diritto al concorso, o comunque il diritto di credito nella sua declinazione concorsuale: una sorta di diritto sostanziale “*a tempo*”, precisa la S.C., destinato indissolubilmente e *ab origine* ad essere realizzato, nel concorso con gli altri creditori, all'interno della procedura fallimentare, attraverso la partecipazione ai riparti.

In ambito probatorio nel procedimento di verifica dello stato passivo, **Sez. 1, n. 07753/2024, Crolla, Rv. 670649-01**, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, ha affermato che il giudice di merito, chiamato a valutare la prova del momento in cui il negozio è stato concluso e la parte onerata ha dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c., ha il compito di accertare, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità di detto fatto per stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità. La S.C., in applicazione di tale statuizione, ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto non consentito dimostrare la data certa dei contratti di appalto invocati dall'opponente, mediante l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di imprese, formato con atto avente data certa; l'estratto conto dei finanziamenti; il verbale di assemblea straordinaria dell'insolvente ed altra analoga documentazione antecedente alla dichiarazione di fallimento.

Sempre con riferimento alla specialità del procedimento di verifica dello stato passivo, con riguardo alla pronuncia sulle spese, **Sez. 1, n. 10047/2024, Fidanzia, Rv. 671085-01**, ha affermato che l'opposizione allo stato passivo, avendo natura di procedimento contenzioso a cognizione piena (sia pure non assimilabile all'appello) e non di volontaria giurisdizione, è regolato, quanto alle spese di lite, dall'applicazione dei parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.

6. La liquidazione dell'attivo.

La liquidazione dell'attivo rappresenta l'altro profilo funzionale di una procedura concorsuale. Da un lato, infatti, una volta accertata la insolvenza, si accertano tutti i crediti al fine di assicurare la soddisfazione dei creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*, riconoscendo eventuali privilegi; dall'altro, si opera per recuperare e gestire l'attivo ai fini della liquidazione di quanto acquisito per soddisfare i creditori attraverso il riparto.

Tra gli strumenti che la legge fallimentare assicura al curatore per il recupero dell'attivo, vi è l'azione revocatoria, di natura costitutiva, diretta a far dichiarare la inefficacia relativa di un atto nei confronti della procedura concorsuale per la successiva liquidazione. **Sez. 1, n. 15196/2024, Campese, Rv. 671470-02**, ha affermato, in tema di finanziamenti dei soci in favore della società, che l'azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso, percepito entro l'anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell'indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, poiché l'art. 2467, comma 1, c.c. (*ratione temporis* applicabile) delinea un'inefficacia *ex lege* del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della *scientia decoctionis*. Precisa la S.C. che, a conferma della correttezza della soluzione ermeneutica, il CCII ha abrogato, all'interno dell'art. 2467 c.c. (e, quindi, anche dell'art. 2497-*quinquies* c.c.), la regola di diritto concorsuale, ponendola nell'ambito dell'art. 164 CCII, rubricato "*Pagamenti di crediti non scaduti e postergati*". Pertanto, la norma risulta inserita nell'ambito della disciplina dell'azione revocatoria, equiparandola a quella relativa ai pagamenti di crediti non scaduti, superando così ogni dubbio interpretativo rispetto alla tesi contrapposta della ripetizione dell'indebito. Risulta, altresì, a seguito della innovazione normativa, ampliato il periodo preso in considerazione, che decorre non più dall'apertura della procedura, ma dal deposito della domanda e ricomprende l'anno anteriore a quest'ultimo nonché il periodo intercorrente tra il deposito della domanda e l'apertura della procedura concorsuale.

Sempre in tema di revocatoria, **Sez. 1, n. 12754/2024, Crolla, Rv. 671393-01**, ha affermato che l'atto con il quale il contraente non inadempiente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, risolve unilateralmente il contratto stipulato con il contraente inadempiente, poi fallito, non è annoverabile tra gli "*atti a titolo oneroso*" e quindi non è revocabile, ai sensi dell'art. 67 l.fall., in quanto il contraente inadempiente, che in seguito sia sottoposto a fallimento, non vi ha in alcun modo partecipato o cooperato, subendone solo gli effetti in posizione di soggezione. La pronuncia, in particolare, ha specificato che l'atto oneroso revocabile non può consistere in una dichiarazione produttiva di effetti giuridici proveniente da un terzo, avente una obiettiva capacità di alterazione del patrimonio, quando manca in radice qualsiasi comportamento da parte del fallito, che si pone come atto dispositivo tale da incidere negativamente sul patrimonio acquisibile dalla esecuzione concorsuale. Richiama, pertanto, l'orientamento già espresso sulla domanda di risoluzione giudiziale del contratto (Sez. 1, n. 04045/1983, Gualtieri, Rv. 428994-01), fondato sul presupposto che la revocatoria non può avere ad oggetto atti processuali e, quindi, anche stragiudiziali che il fallito subisce.

La pendenza della procedura concorsuale non è poi una condizione di proseguibilità dell'azione revocatoria fallimentare, secondo la statuizione di **Sez. 1, n. 10893/2024, Dongiacomo, Rv. 671103-01**, quando il fallimento è stato chiuso per ripartizione finale dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, l.fall., dal momento che la norma consente la chiusura nonostante la presenza di giudizi pendenti, rispetto ai quali il curatore conserva la legittimazione processuale nei successivi stati e gradi.

Sempre ai fini della ricostruzione dell'attivo da liquidare in tema di revocatoria fallimentare, **Sez. 1, n. 10719/2024, Dongiacomo, Rv. 671096-01**, ha affermato che i pagamenti eseguiti tramite intermediari specializzati sono revocabili nei confronti del beneficiario finale della prestazione dovuta dal debitore, poi fallito, e non nei confronti dell'intermediario *accipiens*, solo quando quest'ultimo ha utilizzato la provvista precostituita dall'ordinante in favore dell'effettivo destinatario e non quando, a fronte di preesistenti debiti del *solvens* nei confronti dell'*accipiens*, risulta che i versamenti hanno avuto una funzione solutoria, poiché, in tal caso, la funzione di intermediazione nel pagamento è assorbita da una funzione creditizia.

In tema di gruppi societari, ai fini della legittimazione del curatore per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi societari, **Sez. 1, n. 15196/2024, Campese, Rv. 671470-01**, ha affermato che la società eterodiretta non è legittimata ad esperire direttamente l'azione di responsabilità nei confronti della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, poiché l'art. 2497, comma 3, c.c., nel riconoscere tale legittimazione ai soci ed ai creditori della controllata, offre un sistema di tutela completo, garantendo, ai primi, il risarcimento del pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione e, ai secondi, la difesa dell'integrità del patrimonio sociale ed evitando inammissibili duplicazioni, sicché, in caso di fallimento della società eterodiretta, il curatore è legittimato ad esercitare soltanto l'azione già spettante ai creditori sociali, non essendogli riconosciuto un generalizzato potere di rappresentanza.

Tuttavia, il nostro legislatore ha previsto anche la possibilità di esenzione dall'azione revocatoria per la salvaguardia di interessi ritenuti prevalenti, quali quelli considerati dalla previsione di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005, riguardante gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire. **Sez. 1, n. 10769/2024, Dongiacomo, Rv. 671099-01**, ha affermato che detta disciplina, introducendo una diversa ed innovativa disciplina rispetto a quella previgente, non può retroagire fino ad applicarsi a contratti stipulati e ad insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inapplicabile l'esenzione, trattandosi di contratto stipulato prima della sua entrata in vigore ed essendo irrilevante che avesse ad oggetto una costruzione non ancora ultimata.

In sede di liquidazione del patrimonio acquisito dalla procedura concorsuale e, soprattutto con riferimento agli adempimenti dovuti in esito alla vendita di beni ed alla cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato ex art. 108, comma 2, l.fall. (*ratione temporis* applicabile), **S.U., n. 07337/2024, Terrusi, Rv. 670507-02** hanno affermato che la soluzione accolta dall'art. 173, comma 4, del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza si pone in discontinuità rispetto alla regolamentazione contenuta nella legge fallimentare e non può, pertanto, essere utilizzata al fine di estendere detto potere purgativo al di là delle ipotesi di liquidazione dell'attivo fallimentare ivi previste, considerato altresì che l'interpretazione di una disposizione di legge, anche ove intesa in senso evolutivo, non può che trovare un limite nel significato testuale della disposizione normativa che il legislatore ha posto. La questione controversa esaminata dalla S.C. riguardava il fatto se potesse o meno

considerarsi come vendita concorsuale, ai fini dell'art. 108 l.fall. e delle conseguenze da esso stabilite, la modalità dell'alienazione che si realizza in esito al subentro *ex lege* del curatore fallimentare nel contratto preliminare di vendita di un immobile da adibire ad abitazione principale del promissario, trascritto ai sensi dell'art. 2645-*bis* c.c. (nel caso di specie si trattava del contratto preliminare di assegnazione del bene al socio di una cooperativa edilizia). Il principio cui è pervenuta la S.C. è quello per cui, nel sistema della legge fallimentare, l'art. 108, comma 2, della l.f. prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell'art. 107 della stessa legge, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati a tal fine; mentre è da escludere l'applicazione della norma - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisca nell'ambito dell'art. 72, ultimo comma, l.fall. quale semplice sostituto del fallito, nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita. In applicazione del principio, la S.C. ha, pertanto, cassato la decisione di merito con cui era stato autorizzato il curatore, subentrato al fallito nel preliminare di compravendita trascritto anteriormente all'apertura del fallimento, a stipulare il contratto definitivo, cancellando altresì l'ipoteca gravante sull'immobile, destinato ad abitazione principale del promissario acquirente.

7. La chiusura del fallimento e l'esdebitazione.

A seguito della distribuzione delle somme acquisite dalla liquidazione dell'attivo a favore dei creditori ammessi nello stato passivo, oltre al pagamento delle spese processuali, la procedura viene definita secondo quanto previsto dall'art. 118 l.fall.

La molteplicità degli adempimenti da svolgere e, soprattutto, l'attivazione di contenziosi, causa spesso un notevole prolungamento delle procedure concorsuali, tanto da dare luogo a richieste risarcitorie per l'eccessiva durata della procedura.

Sez. 2, n. 04601/2024, Fortunato, Rv. 670371-01, ha affermato, al riguardo, che il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello - ovvero, per le procedure soggette alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, da quello del definitivo rigetto del reclamo, ove esperito, quale momento in cui detto decreto acquista carattere di definitività; non rileva, invece, il riparto (quand'anche integralmente satisfattivo), in quanto, mentre il termine *ex art. 4 della l. n. 89 del 2001* ha natura processuale e viene in rilievo per accertare la tempestività della domanda, la data di integrale soddisfacimento del creditore, avente natura sostanziale, rileva solo per stabilire la durata della procedura fallimentare e l'entità del danno indennizzabile.

Quanto alla esdebitazione in seguito alla chiusura della procedura fallimentare, quale istituto diretta alla liberazione del debitore dal pagamento dei debiti residui all'esito della procedura concorsuale, **Sez. 1, n. 25946/2024, Vella, Rv. 672508-01**, ha affermato che la valutazione del presupposto oggettivo relativo al soddisfacimento "*almeno parziale*" dei creditori è effettuata tenendo conto dell'intero contesto della procedura, in relazione al quale vanno considerati anche l'entità dell'attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l'ammontare dei costi prededucibili, senza arrestarsi a rilevare la "*irrisorietà*" della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali. La pronuncia appare fondata sull'individuazione di quella parziale soddisfazione secondo un'interpretazione coerente con il "*favor debitoris*" che ispira la norma interna, a cui si è

aggiunto anche il “*favor*” per l’omologo istituto unionale del *discharge of debts* di cui al Tit. III della citata direttiva *Insolvency*, che ha indotto il legislatore nazionale ad eliminare il “*requisito oggettivo*” dalle “*condizioni per l’esdebitazione*” di cui all’art. 280 del CCII.

Nello stesso senso si è pronunciata nell’anno in rassegna anche Sez. 1, n. 28505/2024, Crolla, Rv. 672876-01.

Nella stessa direzione appare orientata ancora la stessa Sez. 1, n. 27562/2024, Vella, Rv. 672786-01, per la quale l’esdebitazione è concessa, in conformità alla lettera dell’art. 142 l.fall. e allo spirito dell’istituto, al ricorrere del requisito della “*meritevolezza*”, escludendosi solo quando il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulta meramente simbolico, e, pertanto, il debitore, ritenuto meritevole, non può essere escluso dal beneficio per ragioni meramente quantitative, indipendenti dalle sue condotte, se, valutate tutte le circostanze concrete della procedura, risulta sussistente un soddisfacimento dei creditori.

8. Il concordato fallimentare.

Nell’ambito delle possibili definizioni della procedura concorsuale, vi rientra anche quella del concordato fallimentare, posto su una linea di confine tra attività liquidatoria e modalità di chiusura della procedura. La Sez. 1, n. 06435/2024, Vella, Rv. 670633-01, che si è pronunciata nel corso dell’anno in tema di concordato fallimentare, ha affermato che, quando a seguito di reclamo ex art. 131 l.fall. la Corte d’Appello ha statuito l’inammissibilità della proposta omologata, che costituiva solo una di quelle contemporaneamente sottoposte ai creditori, queste ultime sono suscettibili di essere riproposte al vaglio di costoro, mediante rimessione al tribunale per il rinnovo delle operazioni di voto.

Il principio dettato dalla S.C. si fonda sul principio di economia processuale e di conservazione degli atti del processo in applicazione dei quali le residue proposte, esclusa quella ritenuta inammissibile, meritano di essere sottoposte nuovamente al vaglio dei creditori nell’ambito di un quadro comparativo depurato dalla proposta ritenuta inammissibile.

9. Il concordato preventivo in generale.

La S.C. ha emesso diverse pronunce nel corso dell’anno anche con riferimento alla diversa procedura concorsuale del concordato preventivo, la quale ha avuto una rivitalizzazione a seguito delle modifiche normative intervenute dalla riforma della Legge fallimentare del 1942 al Codice della crisi di impresa e successive modificazioni, sino ad arrivare al recente d.lgs. n. 136 del 2024 (quest’ultimo applicabile a partire dal 28 settembre 2024).

Con riferimento alle modalità di proposta del concordato preventivo e, in particolare, al concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis, l.fall., Sez. 1, n. 22169/2024, Amatore, Rv. 672168-01, ha affermato che l’eventuale eccedenza finanziaria determinata dalla prosecuzione dell’attività di impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, con la conseguenza che, rientrando nell’oggetto della garanzia generica del credito prevista dall’art. 2740 c.c., la stessa non è liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione. Infatti, l’art. 160, comma 2, l.fall., nel prescrivere che “*il trattamento stabilito per ciascun classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione*” deve essere inteso come trasposizione della cd. *absolute priority rule*, nel senso che una classe di grado inferiore non può ricevere alcun soddisfacimento se quella di grado superiore non è stata integralmente soddisfatta, in conformità a quanto già espresso dalla Sez. 1, n. 17155/2022, Vella, Rv. n. 665089-01. Peraltro, la S.C. con la pronuncia in commento ha definito anche il significato di “*surplus concordatario*”, affermando che, con tale termine, può ragionevol-

mente intendersi non già ogni utilità frutto della prosecuzione dell'attività, bensì soltanto quella parte di essa che eccede la somma destinata al pagamento dei creditori, secondo il piano concordatario, qualificabile come bene futuro assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.

Sotto il profilo della tutela dei creditori nei confronti dei quali pende un contenzioso per l'accertamento della relativa pretesa, **Sez. 1, n. 21431/2024 Rv. 672088-01**) ha affermato che la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento - ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura, che il tribunale deve assolvere direttamente - ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, *ex art. 176 l.fall.*, con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale); dall'altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto. La stessa pronuncia ha statuito, inoltre, che, in tema di omologazione della proposta di concordato preventivo *ex art. 180 l.fall.*, il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili al fine di disporre i relativi accantonamenti, fatti salvi i crediti tributari, oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all'art 90 del d.P.R. n. 602 del 1973, rispetto ai quali il suindicato accantonamento è obbligatorio, essendo rimesso al tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità.

Con riguardo agli effetti del concordato preventivo, **Sez. 1, n. 18019/2024, Amatore, Rv. 671661-01**, ha affermato che la parte rimasta insoddisfatta dal provvedimento - reso ai sensi dell'art. 169-*bis* l.fall., anche in sede di reclamo, e avente ad oggetto la sorte dei contratti pendenti stipulati dall'imprenditore ammesso alla procedura - può far valere l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o sospensione, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano, mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattere amministrativo e non giurisdizionale dell'oggetto del predetto provvedimento, che resta tale anche nell'ipotesi in cui il concordato sia stato omologato, non sussistendo in tale ipotesi alcuna preclusione da giudicato impeditiva della proponibilità dell'azione. Una delle conseguenze di detta impostazione è che i provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 169 *bis* l.fall., anche in sede di reclamo, sulla richiesta di autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso, non sono impugnabili *ex art. 111, comma 7, Cost.*

Sempre nell'ambito dei rapporti pendenti, **Sez. T, n. 12174/2024, Lume, Rv. 670924-01**, in pendenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ha statuito che la riscossione dei tributi sulla base di una rateazione in corso, prevista dall'art. 3 *bis* del d.lgs. n. 462 del 1997, è sospesa, non potendo il contribuente eseguire pagamenti al di fuori del concorso di tutti i creditori, senza che ciò comporti la decadenza dal beneficio e la irrogazione delle conseguenti sanzioni. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il pieno recupero di sanzioni ed interessi a seguito della decadenza dalla rateazione per omesso versamento nei termini della terza rata, in pendenza della apertura della procedura di concordato preventivo.

In una fattispecie concernente la rinuncia alla domanda di concordato preventivo seguita dalla dichiarazione di fallimento, **Sez. 1, n. 17962/2024, Amatore, Rv. 671660-01**, ha sta-

tuito che il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura non può essere considerato prededucibile nel successivo e consecutivo fallimento, quando non vi è stata l'ammissione alla procedura minore, atteso che tale circostanza elide quel nesso di funzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettivi della procedura alternativa al fallimento, che costituisce il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità del credito. La S.C. ha posto a fondamento della decisione il principio per il quale il riconoscimento del rango della prededuzione anche nel successivo e consecutivo fallimento è condizionato all'esistenza dell'elemento della funzionalità delle prestazioni professionali agli obiettivi della procedura di concordato, individuabili nella salvaguardia dell'integrità patrimoniale del debitore e nell'eventuale accrescimento del valore del patrimonio destinato al soddisfacimento dei crediti concorsuali.

Sempre sotto il profilo degli effetti in generale del concordato preventivo in un'ottica di salvaguardia dell'impresa, **Sez. 1, n. 09522/2024, Catallozzi, Rv. 670723-01**, ha affermato che l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, per come desumibile dal disposto dell'art. 168 l.fall., comporta che il debitore - sussistendo detta causa legale di sospensione - si trova in una situazione idonea a determinare la regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi dell'art. 5, lett. b), del d.m. 24 ottobre 2007. La S.C., sulla scorta di tale interpretazione, ha confermato la decisione di merito che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ad erogare i contributi all'editoria in favore della società cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa dopo un procedimento di concordato preventivo, essendo esentata quest'ultima, in forza del ricordato principio, dal dovere di produrre l'attestazione di regolarità contributiva (c.d. DURC).

In tema di *consecutio* tra le procedure, **Sez. 1, n. 05279/2024, Vella, Rv. 670277-01**, ha statuito che, quando la domanda di concordato preventivo "*con riserva*" ex art. 161, comma 6, l.fall., viene dichiarata inammissibile ex art. 162 l.fall., con conseguente dichiarazione di fallimento, è sufficiente, ai fini dell'opponibilità a quest'ultimo del decreto ingiuntivo, l'apposizione del visto di esecutorietà, di cui all'art. 647 c.p.c., anteriormente alla declaratoria fallimentare, ma non anche alla domanda di concordato, atteso che il principio dell'unitarietà fra concordato preventivo e fallimento consecutivo è applicabile, quanto agli effetti del secondo all'apertura del primo, solo in relazione alle ipotesi in cui ciò sia specificamente previsto.

Sempre in sede di consecuzione tra procedure concorsuali, **Sez. 1, n. 26159/2024, Vella, Rv. 672512-01**, ha stabilito che la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno di collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 *bis* l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale, non essendo all'uopo decisivo l'intervallo temporale in sé tra la chiusura della procedura minore e il successivo fallimento, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure.

Sempre in tema di consecuzione tra procedure e degli effetti che ne conseguono nel passaggio dall'una all'altra, la stessa **Sez. 1, n. 26159/2024, Vella, Rv. 672512-02**, con la stessa pronuncia da ultimo indicata, ha statuito che la prededuzione, per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine, *ivi* inclusa l'area preparatoria, sopravvive in una procedura concorsuale diversa che segue la precedente quando sussiste una consecuzione fra le stesse, in quanto la precedenza di pagamento così riservata al credito di massa permane anche al di fuori del perimetro procedurale d'insorgenza, se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplina un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo.

La S.C. si è pronunciata anche con riguardo al recupero dell'attivo in sede concordataria, operando un parallelismo con il curatore fallimentare. **Sez. 3, n. 07201/2024, Tassone, Rv. 670439-01**, ha affermato che il commissario liquidatore è assimilabile, per natura e funzioni, al curatore fallimentare e, come questo, nell'azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla società posta in liquidazione, ha l'onere di provare a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. La sussistenza dell'*eventus damni*, di conseguenza, può ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre i predetti elementi emerge che, per effetto dell'atto pregiudizievole, è divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito (in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori) e il requisito soggettivo della *scientia damni* va ravvisato nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria.

In tema di compensi ai professionisti per l'opera prestata in sede di ammissione al concordato preventivo, **Sez. 1, n. 20059/2024, Abete, Rv. 671691-01** ha affermato che il professionista, designato ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.fall. non è in possesso dei requisiti di indipendenza ex artt. 67, comma 3, lett. d), l.fall. e 2399 c.c., quando ha intrattenuto con il debitore un qualsivoglia rapporto, di durata o destinato a definirsi nel tempo di compimento di prestazione d'opera autonoma, in essere alla proposizione della domanda di concordato, ovvero esauritosi in epoca precedente, svoltosi nel quinquennio antecedente alla data di conferimento dell'incarico. Applicando tale principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che, circoscrivendo la presunzione di non indipendenza ai casi di attività continuativa svolta in favore dell'imprenditore istante, aveva ritenuto irrilevante l'incarico anteriormente conferito all'attestatore di redigere una perizia giurata, trattandosi di prestazione d'opera *una tantum*.

9.1. Segue: l'ammissione, la revoca, l'omologa.

In ordine al rimedio impugnatorio del reclamo in sede di ammissione al concordato preventivo, **Sez. 1, n. 18826/2024 Pazzi, Rv. 671677-01** ha affermato che il provvedimento che decide sul reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta concorrente presentata ai sensi dell'art. 161, comma 4, l.fall. non è ricorribile per cassazione, avendo natura temporanea e non definitiva, essendo revocabile e modificabile in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze, ben potendo il proponente far valere ogni eventuale profilo di illegittimità del decreto mediante l'opposizione all'omologazione della proposta del debitore. Inoltre, secondo la S.C., nulla impedisce al proponente di presentare una nuova proposta ove ancora in termini.

Peraltro, rispetto ai termini previsti per la presentazione di una nuova proposta per l'ammissione al concordato preventivo, **Sez. 1, n. 14196/2024, Perrino, Rv. 671463-01**, ha statuito che, in pendenza del giudizio per la dichiarazione di fallimento, al termine concesso per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 162, comma 1, l.fall., avente natura perentoria, non si applica la sospensione feriale, essendo prevalenti le esigenze di celerità sottese alla discussione dell'istanza di fallimento.

In tema di omologazione del concordato preventivo, con particolare riferimento alla adesione dei creditori alla proposta concordataria, nell'anno in rassegna, **Sez. 1, 24527/2024, Abete, Rv. 672363-02** ha affermato che l'art. 180, comma 4, l.fall., laddove consente al tribu-

nale, ai fini dell'omologazione, di surrogarsi all'amministrazione finanziaria ovvero agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie in caso di loro mancata adesione alla proposta concordataria, ha natura di norma eccezionale e, stante la sua conseguente stretta interpretazione, non si applica a ragioni di credito diverse da quelle propriamente spettanti ai predetti enti. In applicazione di detto principio la S.C. ha, pertanto, confermato la decisione impugnata che aveva escluso, nel novero delle ragioni di credito cui trovava applicazione la disciplina dell'art. 180, comma 4, ultima parte, l.fall., le controversie in cui si discuteva degli oneri di riscossione (c.d. "*aggio*"), poiché questi riguardavano il rapporto tra l'ente impositore e l'ente strumentale alla riscossione e non il contribuente.

La stessa pronuncia ha, altresì, affermato la natura perentoria del termine di venti giorni, previsto dall'art. 178, comma 4, l.fall., entro il quale i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire la loro manifestazione di voto successivamente alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori.

La stessa Sez. 1, n. 27782/2024, Dongiacomo, Rv. 672759-01, ha affermato che l'art. 180, comma 4, l.fall., nel testo introdotto dal d.l. n. 125 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 159 del 2020, laddove consente al tribunale di procedere all'omologazione nonostante la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (c.d. *cram down*), trova applicazione - nella ricorrenza degli altri presupposti richiesti - non solo nel caso in cui l'amministrazione non abbia espresso alcun voto sulla proposta concordataria, ma anche nel caso in cui il creditore pubblico abbia manifestato espressamente il proprio dissenso.

Appare collegabile con le pronunce da ultimo richiamate quella di S.U., n. 20036/2024, Crucitti, Rv. 671760-01, la quale ha affermato che la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell'Agenzia delle entrate, a causa del voto negativo dalla stessa manifestato nei confronti della proposta di trattamento falciato prevista in un concordato preventivo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'espressione del voto non può neppure astrattamente ricondursi al novero degli atti amministrativi, sicché la posizione giuridica soggettiva fatta valere da parte attrice non interferisce con l'esercizio dell'attività autoritativa della pubblica amministrazione. Ha precisato, in tale occasione, la S.C. che la pubblica amministrazione, nell'esprimere il proprio voto nel concordato preventivo, opera come qualsiasi altro creditore sicché tale manifestazione di voto non si annovera nell'ambito dei provvedimenti amministrativi; peraltro, tale voto non è indispensabile se è altrimenti raggiunta la maggioranza, sicché, anche a voler ammettere il contrario, esso non potrebbe essere disapplicato, ove ritenuto illegittimo.

Sempre in materia fiscale, Sez. 1, n. 01033/2024, Vella, Rv. 670214-01, ha affermato che l'istituto del c.d. *cram down* fiscale, disciplinato nell'art. 180, comma 4, l.fall., non dà luogo ad un *tertium genus* di giudizio di homologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 l.fall. ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3, l.fall.) a seconda che siano proposte o meno opposizioni. La S.C. ha precisato, in motivazione, che, a differenza del *cram-down* ordinario - che origina dalla specifica contestazione della convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente (ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, di creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto) - il *cram-down* fiscale attinge al segmento precedente dell'approvazione della proposta, poiché realizza, per una sorta di *fictio*, il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 177, comma 1, l.fall. anche nel caso in cui esse non fossero state raggiunte per la mancata adesione determinante dell'amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie),

purché il tribunale ritenga - in questo caso, a prescindere da una specifica contestazione, essendo già sufficiente la mancata adesione - che la proposta sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Ha concluso, pertanto, affermando che possono aversi casi nei quali il *cram-down* fiscale opera in costanza di opposizioni (con applicazione del regime procedurale ordinario) e casi in cui, nonostante la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), essa opera in assenza di opposizioni (restando l'amministrazione pubblica libera di proporla o meno), con conseguente applicazione del regime procedurale semplificato, che non ammette gravame.

In caso di modifica della proposta di concordato preventivo, **Sez. 1, n. 12137/2024, Crolla, Rv. 671451-01**, ha affermato che, quando intervengono modifiche della proposta che vanno ad incidere sull'impianto soddisfacente del ceto creditorio ovvero mutano la natura dell'accordo o la logica di superamento della situazione di crisi o insolvenza in cui si trova il debitore, i creditori che hanno espresso voto favorevole prima delle modifiche, devono ricevere appropriate ed aggiornate informazioni circa la necessità di una rinnovazione della manifestazione del consenso; ne consegue che, in caso di omesso avviso ed in assenza di ulteriore manifestazione di volontà dei creditori già votanti, gli organi della procedura non possono annullare i voti precedentemente espressi a favore del concordato e deliberare sulla proposta, ma devono procedere alla rinnovazione delle operazioni di voto fornendo ai creditori precise informazioni. Applicando detta statuizione, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, laddove aveva erroneamente qualificato il comportamento inerte serbato dai creditori, dopo la modifica della proposta concordataria consistente nell'allocatione di risorse sopravvenute a beneficio dei creditori erariali in origine degradati, come revoca tacita della dichiarazione di assenso, così da ritenere non approvato il concordato, nonostante agli stessi creditori non fosse stata data alcuna comunicazione della ritenuta inefficacia del loro suffragio e della necessità di procedere alla rinnovazione delle operazioni di voto.

Sempre in tema di voto, **Sez. 1, n. 34807/2024, D'Aquino, Rv. 673365-01**, ha stabilito che l'esclusione dal voto della società controllante prevista dall'art. 177, comma 4, l.fall., non si applica al caso in cui la società controllante, al momento in cui eserciti il diritto di voto, sia stata assoggettata a procedura concorsuale, posto che il conflitto di interessi che caratterizza tale disposizione opera nell'ipotesi in cui l'interesse del votante - proprio del socio - sia funzionale a contrastare l'interesse comune dei creditori alla massimizzazione del sacrificio patrimoniale del debitore che, al contrario, non sussiste in caso di procedura concorsuale, il cui fine è quello del miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, come tale concorrente con quello degli altri creditori ammessi al voto.

Ai fini dell'opposizione alla omologa del concordato preventivo, **Sez. 1, n. 16932/2024, Crolla, Rv. 671551-01**, ha affermato che il creditore che non ha proposto opposizione nell'ambito del giudizio *ex art. 180 l.fall.* non è legittimato ad impugnare, quale terzo, il decreto di omologazione, adducendo il suo interesse a vedere respinta la proposta di concordato, sorto solo successivamente all'instaurazione del suddetto procedimento, atteso che lo stesso interesse può essere tutelato mediante ricorso ai diversi rimedi previsti dall'art. 186 l.fall., il quale prevede la risoluzione e l'annullamento del concordato preventivo. La pronuncia appare rilevante nella misura in cui la fattispecie esaminata attiene all'esito negativo della rottamazione *-ter* cui aveva aderito il debitore, proponente il concordato.

Sempre ai fini della impugnazione dell'omologazione del concordato preventivo, **Sez. 1, n. 01393/2024, Crolla, Rv. 670233-01**, ha statuito che il termine di dieci giorni prima

dell'udienza, fissato dall'art. 180, comma 2, l.fall., per la costituzione delle parti, non ha natura perentoria, non potendo invocarsi, in mancanza di una continuità di disciplina, la previsione di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 14 del 2019 (cd. "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*"), che detta perentorietà contempla espressamente solo per le procedure aperte sotto la sua vigenza. Infatti, continua la S.C., l'omessa previsione della perentorietà del termine fissato per la costituzione delle parti nel giudizio di omologazione del concordato preventivo osta alla sua qualificazione come termine perentorio, tali essendo solo i termini processuali così espressamente dichiarati dal legislatore, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile la costituzione avvenuta oltre detto termine. Si tratta di un principio generale affermato in più settori dell'ordinamento e fondato sul disposto dell'art. 152, comma 2, c.p.c., secondo il quale il termine ha natura ordinatoria se la legge non lo qualifica espressamente come perentorio.

In caso di esito positivo della impugnazione del provvedimento di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, con conseguente dichiarazione di fallimento, **Sez. 1, n. 00922/2024, Pazzi, Rv. 670213-01**, ha affermato che la Corte d'appello deve rimettere la causa al tribunale per l'esame nel merito della domanda di concordato, non potendo prenderla direttamente in esame secondo la normativa fallimentare.

In ogni caso, **Sez. 3, n. 26560/2024, Pellicchia, Rv. 672531-01** ha affermato che il provvedimento di omologazione del concordato preventivo, pur se adottato a seguito di opposizione del creditore dissenziente e successivo reclamo *ex art.* 183 l.fall., per le particolari caratteristiche della procedura concorsuale concordataria, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere deliberativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta; conseguentemente, il provvedimento di omologazione non esclude la facoltà del creditore di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste.

10. La liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria.

In tema di accertamento dell'insolvenza nella procedura di amministrazione straordinaria, **Sez. 1, n. 27338/2024, Cristiano, Rv. 672777-01**, ha stabilito che la sentenza che, a norma dell'art. 8 del d.lgs. n. 270 del 1999, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa che può accedere all'amministrazione straordinaria, in quanto soggetta alle disposizioni sul fallimento e, dunque, necessariamente esercente attività commerciale, è suscettibile di passare in giudicato, anche per ciò che riguarda l'accertamento dello *status* di impresa commerciale, e resta ferma, mantenendo tutti i suoi effetti, salvo che non ne intervenga la revoca con sentenza non più impugnabile.

In tema di liquidazione coatta amministrativa e della sua fase del riparto, **Sez. 1, n. 20862/2024, Pazzi, Rv. 671963-01**, dopo avere operato una distinzione tra la concessione di un acconto ed il riparto parziale - sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima della realizzazione di tutte le attività e l'accertamento di tutte le passività - evidenziando la provvisorietà del primo e la definitività del secondo, ha affermato che i riparti parziali sono impugnabili sulla base dell'applicazione analogica della procedura prevista per il riparto finale, secondo le modalità previste dall'art. 213, comma 3, l.fall., mentre nella liquidazione coatta amministrativa in materia di assicurazioni i riparti parziali sono impugnabili secondo le

modalità previste dagli artt. 98 e 99 l.fall., in ragione del combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (vigente *ratione temporis*).

Sempre in materia di accertamento del passivo nella procedura da ultimo citata, la **Sez. 1, n. 18522/2024 Vella, Rv. 671671-01**, ha affermato che l'avviso ai creditori per la verifica, previsto dall'art. 207 l.fall., costituisce un atto dovuto a carico del commissario, destinato ad una mera *provocatio ad agendum* verso coloro che risultano creditori in base alle scritture contabili del debitore, così che essi siano informati della pendenza della procedura e possano fare valere i propri diritti in concorso; ne consegue che, con tale avviso, il commissario non esprime alcun giudizio preventivo sull'eventuale futura ammissione al passivo né compie una ricognizione del credito. Ciò risulta confermato dalla circostanza che il silenzio mantenuto dal commissario liquidatore in ordine alle richieste formulate dal creditore e il mancato inserimento del credito nell'elenco previsto dall'art. 209, comma 1, l.fall. assume valore implicito di rigetto, contro il quale, per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l.fall.

Sez. 1, n. 17272/2024, Terrusi, Rv. 672498-01, ha affermato che, in tema di liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. in l. n. 212 del 2017, costituisce effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimo d.l. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo *pro tempore*) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, la configurabilità dell'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento. Ne consegue che il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal citato d.l. n. 99 del 2017 prima dell'apertura della l.c.a. non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 l.fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione. La pronuncia si pone in contrasto con un precedente orientamento del giudice di legittimità per il quale la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio di cassazione. Ciò in quanto in materia bancaria rileva la norma speciale di cui all'art. 83, comma 3, del T.u.b., la quale esclude che contro la banca in liquidazione coatta possa essere promossa o seguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3, in tema di opposizioni allo stato passivo. Lo stesso art. 83, comma 2, sancisce, quale conseguenza della messa in liquidazione coatta dell'istituto bancario, gli effetti previsti dagli artt. 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della l. fall., tra cui per l'appunto l'art. 52; mentre l'art. 96, comma 2, n. 3, della medesima legge, relativo all'ammissione con riserva dei crediti accertati con sentenza del giudice ordinario non passata in giudicato, pronunciata prima dell'apertura del procedimento, non è richiamato all'interno della previsione suddetta (**Sez. 1, n. 9461/2020, Scotti, Rv. 657683-01**). La pronuncia dell'anno in rassegna, giunge a conclusione diversa, facendo leva sull'istituto dell'ammissione con riserva come punto di equilibrio tra le esigenze della concorsualità e quelle di tutela giurisdizionale dei diritti. Essa ha, così, affermato che, dinanzi alla liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al citato d.l. n. 99 del 2017, opera

sì il rinvio (art. 2) alle norme del T.u.b., fermo restando la disciplina che tali norme a loro volta rinviavano (cfr. art. 80 nel testo *pro tempore*) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto. Posto che l'istituto dell'ammissione con riserva non è disciplinato dal suddetto d.l. n. 99 del 2017, la pronuncia ha affermato che esso deve trovare un completamento mediante l'estensione della normativa generale nelle disposizioni costì richiamate, tra cui quelle sull'ammissione dei crediti con riserva, nei medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento.

L'interruzione della prescrizione, derivante dalla ammissione del credito allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è stato oggetto di una pronuncia della **Sez. 1, n. 16166/2024, Pazzi, Rv. 671540-01**, la quale ha affermato il suo effetto permanente per tutta la durata della procedura solo a seguito dell'ammissione allo stato passivo della procedura del relativo credito, di talché non può essere riconosciuto effetto analogo alla mera presentazione da parte del creditore dell'istanza di ammissione al passivo, non assimilabile alla proposizione della domanda giudiziale. In applicazione di tale principio, la S.C. ha stabilito che la mera richiesta di ammissione al passivo aveva prodotto, di per sé, un mero effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, in quanto la richiesta non era stata seguita né dal deposito da parte dei Commissari dell'elenco dei creditori ammessi, né - non avendo il creditore istante proposto opposizione - da un provvedimento di ammissione del tribunale, risultando poi irrilevante che all'amministrazione straordinaria avesse fatto seguito l'apertura della procedura fallimentare.

Nell'ambito della ammissione dei crediti e della necessaria verifica in sede di ammissione allo stato passivo, **Sez. 1, n. 04322/2024, Amatore, Rv. 670555-01**, ha statuito che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 e 209 l. fall., anche nella procedura di formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, l'opponente, nel giudizio di opposizione, a pena di decadenza *ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall.*, è tenuto solo a menzionare, seppure in termini specifici, i documenti di cui intende avvalersi che sono già stati prodotti nel corso della verifica amministrativa dei crediti innanzi al commissario liquidatore, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale, in presenza di detto richiamo non generico, deve disporre l'acquisizione dalla documentazione già detenuta dal commissario liquidatore in relazione alla precedente fase di accertamento e al relativo procedimento. Infatti, secondo detta statuizione, è sufficiente che il ricorrente opponente *ex art. 99 l. fall.* si limiti anche solo a valorizzare, nel quadro del ricorso in opposizione, quelli che, tra i documenti già prodotti, appaiono maggiormente idonei a sostenere la propria prospettazione, in quanto, una volta allegati all'originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell'ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in tale fase.

Ai fini della qualificazione del credito da ammettere allo stato passivo, **Sez. 1, n. 28147/2024, Amatore, Rv. 672796-01**, ha affermato che il requisito soggettivo dell'appartenenza alla categoria delle "*piccole e medie imprese*", in relazione al riconoscimento della prededuzione prevista dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, è richiesto per le prestazioni "*necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali*", e non anche per le prestazioni relative "*al risanamento ambientale, alla sicurezza e agli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute*" previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014.

In tema di accertamento dei crediti proponibile al di fuori della procedura, **Sez. L, n. 27796/2024, Bellè, Rv. 672600-01**, ha stabilito che, nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo.

APPROFONDIMENTO TEMATICO

IL D.LGS. N. 136 DEL 2024 (C.D. CORRETTIVO) E LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

(DI ALESSANDRO FAROLFI)

SOMMARIO: 1. Uno sguardo d'insieme. - 2. La nuova fase di accesso al concordato preventivo: la domanda con riserva. - 3. Le modifiche alla disciplina della proposta concordataria. - 4. Ulteriori modifiche: in particolare l'omologazione nel caso di ristrutturazione "trasversale". - 5. Entrata in vigore.

1. Uno sguardo d'insieme.

Prosegue la "tormentata" vicenda della disciplina contenuta nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Come è noto, infatti, il 15 luglio 2022, dopo oltre due anni di rinvii, è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e più volte modificato, prima con il c.d. Correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147), poi con il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 1023.

Ora, il Legislatore torna nuovamente a correggere ed integrare molte disposizioni del Codice con un nuovo intervento Correttivo (da taluni definito "Correttivo ter"), rappresentato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato sulla G.U. n. 227 del 27 settembre 2024 e entrato in vigore il giorno successivo.

Il nuovo intervento normativo è finalizzato, da un lato, a correggere ed emendare talune disposizioni che avevano dato adito a dubbi nella prima giurisprudenza di merito applicativa o che erano apparsi comunque portatori di una formulazione lessicalmente migliorabile.

Dall'altro, l'intervento si muove lungo la direttrice di fornire maggiore coerenza complessiva alla disciplina, tenendo altresì conto degli obiettivi del PNRR nel frattempo perseguiti dal nostro ordinamento.

Sono pertanto certamente rafforzati alcuni principi generali, quali il dovere di buona fede e di leale collaborazione che, già applicabili al debitore che si accinge alla ristrutturazione della propria posizione debitoria ed ai suoi creditori, viene esteso anche ai terzi comunque interessati dall'operazione di ristrutturazione. Al tempo stesso, anche la direttrice dell'emersione tempestiva della crisi viene percorsa, in coerenza con le scelte unionali, attribuendo un potere di segnalazione (c.d. allerta interna) anche ai professionisti che operano la revisione contabile nell'impresa, il che colma una obiettiva lacuna rispetto a quelle imprese di dimensioni contenute per le quali non era obbligatoria la costituzione dell'organo di controllo.

Vi è poi una revisione dell'art. 6 in tema di prededuzione, come pure di talune disposizioni della composizione negoziata, essenzialmente rivolta a potenziarne l'utilizzo ed a chiarire che l'accesso a tale percorso negoziato di concertazione della soluzione della crisi fra imprenditore e suoi creditori non è escluso da situazioni di insolvenza che siano, tuttavia, ancora suscettibili di una ragionevole evoluzione, positiva (c.d. insolvenza reversibile).

In tale contesto, poi, vengono certamente potenziati i diversi strumenti di regolazione della crisi, anche attraverso una diversa modulazione dell'istituto della transazione fiscale,

mentre anche la materia del sovraindebitamento ha subito diverse modifiche al fine di meglio razionalizzare la disciplina, tenendo conto del fatto che essa ha perso la sua matrice extracodicistica (in precedenza rappresentata dalla l. n. 3 del 2012 e successive modificazioni) per trovare un più coerente accoglimento all'interno del Codice, con una maggiore necessità di coordinamento con gli istituti previsti per le imprese "maggiori" (si pensi, solo per fare un esempio, al rapporto fra concordato minore e concordato preventivo o al pressoché totale apparentamento che la liquidazione controllata ha subito rispetto alla "sorella maggiore" liquidazione giudiziale).

Si tratta, perciò, certamente di un intervento ambizioso che, in questa sede, per evidenti ragioni di spazio, verrà affrontato unicamente con riguardo alle modifiche apportate alla disciplina del più importante fra gli strumenti regolatori, cioè al concordato preventivo. Naturalmente, le definizioni e gli aspetti non oggetti di modifiche, sono altresì dati per presupposti.

2. La nuova fase di accesso al concordato preventivo: la domanda con riserva.

Solo apparentemente marginali, ma in realtà dense di portata applicativa, sono le modifiche e le integrazioni che il d.lgs. n. 136/2024 introduce nell'istituto del concordato preventivo.

In primo luogo, appare evidente l'attenzione del legislatore per la fase di accesso a questo strumento che, molto spesso, nella pratica avviene attraverso la richiesta di concessione di un termine per poter poi depositare il piano e la proposta concordataria vera e propria. Si tratta della domanda o accesso con riserva di cui all'art. 44 c.c.i.i., che ha preso il posto, fin dal 15 luglio 2022, del vecchio "concordato in bianco".

Le modifiche riguardano quindi l'art. 44 c.c.i.i. in primis, ma anche il suo collegamento con il successivo art. 46, che diverse difficoltà interpretative avevano sollevato.

Vale la pena riportare il nuovo testo dell'art. 44, a confronto con la precedente "ver-

Testo iniziale

Art. 44. Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione

1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la

Testo modificato

Art. 44. Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione

1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazio-

domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).

ne di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi *e autorizza il commissario al compimento delle attività di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f);*

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione *sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria* che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) idem

1-bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o

perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi del comma 1.

1-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore può chiedere di giovare del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto. [...]

sione”, proprio per l'importanza della disposizione (in grassetto-corsivo le novità).

Le novità richiamate ruotano essenzialmente su tre profili¹:

a) l'art. 44 viene limitato alla fase “prenotativa”, nella quale non vi è stato ancora il deposito del piano e della proposta e, a ben vedere, non è neppure necessaria una scelta definitiva dello strumento utilizzabile, posto che la domanda con riserva potrebbe sfociare, sia nella richiesta di ammissione al concordato preventivo “pieno” (cioè integrato dalla documentazione inizialmente mancante), sia nella richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, sia, come noto, nella richiesta di ammissione al c.d. PRO (piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione); al contempo l'art. 46 resta a disciplinare la gestione dell'impresa e le autorizzazioni nella fase di concordato preventivo “pieno”;

b) viene assegnato un ruolo centrale al progetto di regolazione della crisi e dell'insol-

(1) La relazione tecnica di accompagnamento afferma che “si allinea la lettera a) del comma 1, alle modifiche apportate all'articolo 46, dal quale è stato espunto il riferimento alla domanda prenotativa per le ragioni, di natura sistematica di cui si dirà di seguito. L'allineamento avviene inserendo la puntualizzazione sugli effetti connessi al deposito della domanda prenotativa nell'ambito di una fase del procedimento unitario che non necessariamente conduce al concordato preventivo e contemporaneamente chiarendo che l'articolo 46 è norma di per sé destinata a operare solo con riferimento alla domanda “piena” che sia volta a ottenere l'apertura della procedura di concordato. In questo modo, se il debitore, proponendo la domanda ex articolo 40 con riserva di presentare la proposta, il piano e gli accordi (la “domanda ex articolo 44”, infatti, come tale non esiste, essendo la medesima domanda che si propone col ricorso previsto all'articolo 40, senza il deposito della documentazione completa), non sceglie lo strumento, il regime applicabile è quello, più rigido, del concordato preventivo”.

venza ai fini della possibilità di proroga del termine inizialmente concesso (nella pratica quasi sempre nella misura massima di 60 gg., prorogabili appunto sino a complessivi 120 gg.); nulla vieta, peraltro, che detto progetto venga presentato sin dall'inizio e non soltanto al momento della proroga, così da operare una sorta di *discovery* anticipata delle intenzioni del debitore; del resto, occorre notare, se un simile progetto - che sottintende una cultura di programmazione e di tempestiva adozione delle iniziative per fronteggiare la crisi o l'insolvenza da parte dell'imprenditore - è richiesto anche nella composizione negoziata, non è fuori luogo pretendere la redazione anche in questa sede, quantomeno al fine di comprovare il progresso delle iniziative prescelte per operare il *turnaround* aziendale;

c) viene altresì previsto un regime autorizzatorio e di gestione dell'impresa durante l'accesso con riserva, coerente con lo strumento che si è scelto di utilizzare conformemente al progetto depositato; se, infatti, il nuovo comma 1-*ter* delinea un regime ordinario coerente con una proposta di tipo concordatario, prevedendo l'inefficacia degli atti non autorizzati e, in tal caso, la revoca del decreto di assegnazione del termine, il successivo comma consente al debitore di "scegliere" un diverso regime gestorio - più libero - qualora proponga l'utilizzo di uno strumento giudiziario meno "invasivo", quale l'accordo di ristrutturazione o il PRO (nel primo caso fruendo di fatto di una piena capacità, paragonabile all'imprenditore *in bonis*, nel secondo potendo operare liberamente ma con possibilità di opposizione del commissario giudiziale ad atti di straordinaria amministrazione incoerenti con la soluzione della crisi o, peggio, dannosi per i creditori); naturalmente, si dovrà accertare in concreto che la nuova facoltà introdotta dal comma 1-*quater* non venga utilizzata in modo abusivo, così come l'eventuale verificarsi di situazioni limite, caratterizzate da "ripensamenti" contraddittori, pure astrattamente possibili, fra strumenti eterogenei o, ancora, passaggi da gestioni "libere" a situazioni di spossessamento minore, che dovranno essere governati tenendo ben presente il principio di buona fede ed i doveri più generali imposti dall'art. 4 c.c.i.i.².

3. Le modifiche alla disciplina della proposta concordataria.

Le novità apportate dall'ultimo Correttivo riguardano, ancora, una norma centrale come l'art. 47 c.c.i.i. in tema di ammissione allo strumento concordatario. In questo caso, il legislatore del correttivo si preoccupa di chiarire che il vaglio del tribunale deve riguardare, sin da subito, "la corretta formazione delle classi"; aspetto che rileva con particolare riguardo al concordato in continuità, nel quale il Codice della crisi impone il classamento di tutti i creditori quale adempimento preliminare non solo ai fini della loro votazione, ma anche allo scopo di consentire quella che la Direttiva 1023/2019 definisce *cross class cram down*, ossia la ristrutturazione trasversale richiesta quando, nella tipologia concordataria in continuità, manchi l'adesione della totalità delle classi (su tale aspetto di ritornerà in relazione all'art. 112 c.c.i.i.). Sempre nell'art. 47 si chiarisce che l'obbligo di rendicontazione mensile che il debitore deve fornire, a tutela

(2) Il d.lgs. n. 136/2024 ha inteso generalizzare i doveri di collaborazione e di buona fede previsti dall'art. 4, estendendoli a tutti i soggetti comunque interessati dalla ristrutturazione. Il primo comma, così come modificato, prevede, infatti, che "Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza". Del pari, anche l'ultimo comma dell'art. 4 è divenuto "4. I creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6".

dell'interesse dei creditori e al fine di consentire di verificare l'eventuale distonia fra realtà ed assunzioni del piano industriale, prosegue anche a seguito dell'ammissione allo strumento e non nella sola fase con riserva.

Anche una norma come l'art. 84 c.c.i.i., nel quale troviamo "scolpita" la distinzione fra concordato in continuità (diretta o indiretta) e concordato liquidatorio, oltre che con assuntore, non è andata esente da modifiche. Al comma 1 si inserisce l'espressione "anche con cessione dei beni", per chiarire che tale modalità è pur sempre una forma di liquidazione del patrimonio. La novità di maggiore interesse è data però dalla riscrittura del comma 6, così come segue.

Testo iniziale

6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Testo modificato

6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.

La novità si apprezza ponendola in relazione con la definizione di valore di liquidazione di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), che sino ad ora aveva dato luogo a divergenze interpretative. Si tratta di un concetto che, come intuibile, risulta molto rilevante nel "nuovo" concordato preventivo, in quanto ad esso si ricollega non soltanto una generica valutazione di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, rilevando esso anche ai fini della legittimità del trattamento riservato ai creditori nelle ipotesi in cui il tribunale debba procedere al *cram down* ovvero verificare la modalità di distribuzione del c.d. "surplus" concordatario, nel caso in cui il debitore scelga di offrire un trattamento basato sul principio della *relative priority rule*.

La nuova definizione di valore di liquidazione, contenuta al cit. art. 87, fa riferimento "al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese".

Tale inserimento persegue essenzialmente una finalità di chiarezza³: si stabilisce infatti che in tale valore rientra quanto è ragionevolmente ottenibile con le azioni esperibili

(3) La relazione tecnica di accompagnamento afferma che (si) "sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 al fine di inserire, come anticipato, la definizione di valore di liquidazione. Tale valore viene individuato come quello realizzabile, nell'ambito della liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti e si precisa altresì che in esso debba essere ricompreso anche il maggior valore economico, realizzabile sempre in sede di liquidazione giudiziale, collegato

dal curatore (si pensi ad un'azione di responsabilità verso i sindaci e gli amministratori, oppure all'esito ragionevolmente favorevole di una o più revocatorie...). Più complesso il riferimento al valore dell'azienda in esercizio, laddove il *going concern* sia stato definitivamente perduto e la soluzione concordataria non possa che passare, in tutto o in parte, attraverso uno smembramento dell'azienda e - quantomeno in parte - per una cessione atomistica di beni strumentali e merci di magazzino. Il valore di liquidazione è destinato a rilevare anche per l'attestazione resa dal professionista indipendente, sotto molteplici profili (ad es. nel concordato con continuità aziendale, "che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale" ex art. 87 co. 3; oppure l'attestazione specifica di cui all'art. 88 in caso di transazione fiscale).

Da notare anche la nuova previsione, nell'art. 85 dedicato alla formazione delle classi, circa l'obbligo di classare separatamente "le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta". Pur essendo la modifica in astratto molto rilevante, in quanto è palese il riferimento dimensionale alla definizione unionale delle P.M.I., la struttura tradizionalmente "polverizzata" ed a base familiare delle imprese italiane fa sì che, in concreto, l'esigenza di classamento separato delle imprese creditrici di dimensioni superiori rispetto a quelle "minori" (come a contrario si ricava dalla norma) non sia così frequente.

4. Ulteriori modifiche: in particolare l'omologazione nel caso di ristrutturazione "trasversale".

Tralasciando in questa sede ulteriori emende ad errori materiali, così come lo spostamento di disposizioni per migliorare l'aspetto formale-sistematico del codice, si vuole qui portare l'attenzione su tre ulteriori novità apportate dall'ultimo Correttivo.

La prima, attraverso l'introduzione di un nuovo art. 93 c.c.i.i., intende chiarire che anche i decreti del giudice delegato e del tribunale, adottati nell'ambito del concordato preventivo, sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124, mentre gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito all'espressione "curatore" quella di "commissario" o "liquidatore giudiziale"⁴.

La seconda riguarda una modifica all'art. 112 c.c.i.i. in tema di ristrutturazione trasversale che, come già accennato, aveva interrogato gli operatori.

alla cessione dell'azienda in esercizio, laddove possibile. Si chiarisce infine che, nel determinare il valore di liquidazione, occorre tener conto anche del possibile e ragionevole esito positivo di azioni recuperatorie o risarcitorie collegate alla liquidazione giudiziale (come, ad esempio, le azioni revocatorie e le azioni di responsabilità promosse dal curatore), al netto delle relative spese".

(4) Il dubbio era stato sollevato, fra l'altro, da Sez. 1, ord. n. 12523 del 08/05/2024, Rv. 670980 – 01, ove aveva stabilito che il reclamo previsto dall'art. 124 del d. lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), a differenza delle norme contenute negli artt. da 40 a 53 dello stesso codice, che regolano in linea generale il procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, riguarda la procedura di liquidazione giudiziale e non può essere esteso o applicato in via analogica a procedure di diversa natura, in mancanza di uno specifico richiamo normativo.

Testo iniziale

2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Testo modificato

2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Il chiarimento principale riguarda il significato da attribuire all'espressione "in mancanza", che non dovrebbe essere collegato - come qualcuno aveva sostenuto a fronte di un testo suscettibile di più letture possibili - all'ipotesi in cui non sia raggiunta l'unanimità delle classi favorevoli, bensì al caso di mancato raggiungimento della maggioranza delle classi favorevoli, ciò che renderebbe possibile l'approvazione della proposta concordataria con il solo voto favorevole di una classe, pur se variamente qualificata. Si tratta di un aspetto di rilievo, già oggetto nella prassi di diversificate soluzioni, in quanto una diversa lettura della disposizione in esame è tale spostare l'ago della bilancia della nuova ristrutturazione concordataria fra effettiva (e tradizionale) base convenzionale, oppure puramente legale, così come ridisegnata dal Codice della crisi.

La terza modifica di rilievo riguarda l'inserimento di un nuovo art. 118-*bis* che consente modificazioni del piano successivamente alla omologazione, secondo un modello procedimentale già applicato agli accordi di ristrutturazione dei debiti (vds. art. 58 co. 2 c.c.i.i. e, in precedenza, art. 182-*bis* co. 8 come novellato dal d.l. n. 118/2021, conv. con modd. dalla l. n. 147/2021). Tali modifiche del piano si caratterizzano per essere: a) necessarie; b) sostanziali; c) funzionalmente rivolte all'adempimento della proposta iniziale. La modifica che si vuole apportare deve, inoltre, essere accompagnata da una relazione di attestazione di un professionista indipendente, (la norma parla di "rinnovo" dell'attestazione) ed il meccanismo di approvazione è basato su una sorta di silenzio-assenso procedimentale, che non richiede la ripetizione delle votazioni, in quanto la modifica, una volta pubblicata sul registro delle imprese, può essere opposta dai creditori entro 30 gg., dopo di che è sottoposta al vaglio del tribunale nelle forme dell'art. 48 c.c.i.i.).

Alcuni interventi non secondari sono stati apportati anche all'art. 88 c.c.i.i., in primo luogo chiarendo, con un *incipit* meno ambiguo, che la transazione fiscale è compatibile anche con il concordato preventivo in continuità. A riprova di ciò il comma 2 specifica che "l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale".

Viene poi distinta l'operatività del *cram down* a seconda della natura, liquidatoria o in continuità del piano concordatario.

Nel primo caso, "il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza e assicurazioni obbligatorie quando" a) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1; b) il trattamento è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Nel caso di concordato in continuità, invece, il tribunale omologa se a) "ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2"; b) il trattamento non è deteriore rispetto a quello ritraibile dal creditore erariale nell'alternativa della liquidazione giudiziale.

Si specifica poi, superando una diatriba formatasi nella giurisprudenza di merito, che, nel caso di ristrutturazione trasversale di cui all'art. 112, comma 2 c.c.i.i., per potersi applicare il *cram down* l'adesione della parte pubblica deve essere determinante al fine di raggiungere la maggioranza delle classi aderenti alla proposta di concordato, mentre nell'ipotesi alternativa dell'omologazione "trasversale" con una sola classe privilegiata aderente, il *cram down* non può surrogare tale condizione ed il voto favorevole dell'erario deve essere comunque espresso⁵.

(5) Nella giurisprudenza di merito può ricordarsi Trib. Genova, 17 giugno 2024, secondo cui "con riferimento alla avvenuta approvazione di un concordato in continuità aziendale da parte di tutte le classi, come richiesta dall'art. 109, comma 5, C.C.I. a fini omologatori, le due ipotesi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 112 C.C.I. per potersi, in mancanza, comunque addivenire, qualora ricorrano le altre condizioni previste dalle lettere a), b) e c), all'omologazione eteronima di detto concordato da parte dell'autorità giudiziaria (lettera che recita: "la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione"), come ben argomentato dal Tribunale di Bergamo, 11 aprile 2023, sono chiaramente alternative fra loro e il caso della classe "svantaggiata" (o "interessata" a secondo dell'orientamento) permette proprio di intervenire, in una ideale graduazione, quando anche la maggioranza non è raggiunta, in quanto fornisce una soluzione per detta ipotesi che permette di non dover ricorrere all'applicazione estensiva di uno strumento che trae le proprie origini nel contesto del concordato liquidatorio, tutto incentrato sul

5. Entrata in vigore.

Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, intitolato “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14”, è stato, come noto, pubblicato sulla G.U. n. 227 del 27 settembre 2024 ed è entrato in vigore il giorno successivo, 28 settembre 2024.

Il Correttivo contiene una disposizione volta a regolare i profili di diritto intertemporale relativi alla sua applicabilità, problematica certamente particolarmente sentita nella pratica, soprattutto con riguardo ai procedimenti ed alle procedure concorsuali pendenti.

L’art. 56 afferma, in primo luogo, la regola generale dell’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (e quindi dal 28 settembre 2024).

Contiene poi alcune disposizioni più specifiche.

I commi 2 e 3 riguardano, in particolare, la composizione negoziata, laddove affermano che “le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del presente decreto si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6, 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4, del presente decreto si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore”.

Aggiunge poi la norma che “salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.

La lettura apparentemente piana della norma, nel senso dell’immediata operatività delle nuove disposizioni anche “in corsa”, nell’ambito di procedimenti già pendenti, ha però sollevato taluni interrogativi.

Mentre il rilievo circa il mancato richiamo alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ed al concordato minore potrebbe essere superabile, nel caso in cui si ritenga che detti istituti rientrino nella più generale categoria degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, l’immediata applicabilità delle nuove disposizioni porta con sé un possibile dubbio circa l’applicabilità retroattiva delle nuove norme anche a segmenti procedurali già compiuti nel vigore delle disposizioni ante-correttivo, ovvero relativi alla prevalenza del principio del *tempus regit actum*, con l’ulteriore esigenza, in tal caso, di distinguere fra norme processuali e disciplina sostanziale dei diversi istituti⁶.

prevalere della maggioranza, laddove il concordato in continuità dovrebbe appunto caratterizzarsi per l’unanimità delle classi, ragion per cui non può essere accolta la tesi secondo la quale il cram down fiscale e previdenziale, come previsto dall’art. 88, comma 2 bis, C.C.I., potrebbe servire a realizzare i presupposti della c.d. ristrutturazione trasversale e, quindi, a consentire l’omologazione del concordato in continuità aziendale anche in presenza dell’approvazione da parte di una sola classe di creditori”.

(6) Si può ricordare come il S.C. abbia cercato di risolvere, recentissimamente, un analogo dubbio in relazione alle modifiche che l’ordinamento aveva apportato alla legge n. 3/2012 – in tema di sovraindebitamento – attraverso l’entrata in vigore della legge n. 176/2020, di conversione del c.d. d.l. Ristori. Cass. Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34133, in corso di massimazione, ha affermato che “Le modifiche apportate alla legge n. 3 del 2012, in virtù dell’art. 4-ter, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176 del 2020, si applicano anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti alla data del 25 dicembre 2020; tuttavia, la possibilità accordata al debitore di

Va peraltro segnalato che, subito dopo l'entrata in vigore del nuovo Correttivo, il legislatore è nuovamente intervenuto, proprio con riferimento all'art. 56 cit., con una disposizione di interpretazione autentica.

Il d.l. 29 novembre 2024, n. 178, ha così disposto - con l'art. 8, comma 1 - che "l'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati".

presentare, nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo, può essere esercitata unicamente fino all'udienza ex art. 10 della legge n. 3 cit., sicché, ove tale udienza sia stata già tenuta, la presentazione di detta istanza non è ammissibile". La decisione si segnala in quanto cerca di temperare l'immediata operatività delle nuove disposizioni con la consumazione di facoltà processuali previste dalle nuove norme.

PARTE QUINTA

IL DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA

(Coordinata da Antonella Filomena Sarracino)

CAPITOLO XX

IL LAVORO PRIVATO: DIRITTI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ

(DI MANUEL BIANCHI)

SOMMARIO: 1. Le fonti. - 2. Il diritto sindacale. - 3. La retribuzione. - 3.1. Il T.F.R. - 3.2. La progressione economica orizzontale. - 3.3. Prescrizione e decadenza. - 4. I caratteri e l'oggetto della prestazione lavorativa. - 4.1. Diligenza, buona fede e fedeltà. - 4.2. Luogo. - 4.3. Orario. - 4.4. Astensione dal lavoro: festività, ferie e permessi. - 4.4.1. Segue: malattia e periodo di comporto. - 4.4.2. Segue: l'esercizio del diritto di sciopero. - 4.5. Mansioni e demansionamento. - 5. La tutela *ex art.* 2087, il mobbing e le condotte discriminatorie. - 6. La distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato. - 7. Il lavoro in apprendistato, a termine, somministrato, intermittente, a progetto. - 7.1. La collaborazione nell'impresa familiare. - 8. Il datore di lavoro: appalto, trasferimento d'azienda, intermediazione di manodopera. - 9. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore. - 10. Le rinunzie e transazioni del lavoratore. - 11. Il contratto di agenzia.

1. Le fonti.

In tema di fonti, nell'anno in rassegna, la S.C. ha in particolare rivolto la propria attenzione all'ambito temporale e alla sfera di efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune.

Quanto al primo aspetto, si è affermato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazioni dell'autonomia collettiva, operano entro l'ambito temporale concordato dagli stipulanti, ai quali è rimessa la scelta di pattuire eventuali clausole di ultrattività - come quella di perdurante vigenza del contratto fino al rinnovo contrattuale - che devono essere intese come apposizione di un termine, stante l'incertezza solo nel *quando* e non anche nell'*an* dell'evento futuro: ne consegue che la disdetta del contratto collettivo vigente intimata dal singolo datore di lavoro deve considerarsi illegittima e, quindi, priva di effetti. Così **Sez. L, 26666/2024, Boghetich, Rv. 672594-01**, cui si deve anche la seguente massima (**Rv. 672594-02**): la comunicazione con cui il singolo datore di lavoro si impegna a proseguire l'applicazione del contratto collettivo vigente - a seguito di illegittima disdetta, intimata unilateralmente dal medesimo datore - costituisce mero atto unilaterale recettizio, produttivo di effetti dal momento in cui perviene a conoscenza delle organizzazioni sindacali destinatarie, e la successiva revoca di detta comunicazione non è idonea - in mancanza di adesione di tali organizzazioni - ad elidere gli effetti già prodotti e può valere, al più, come proposta di stipula di un nuovo contratto con differente contenuto, né può essere interpretata alla luce della comune intenzione delle parti desumibile dal comportamento del destinatario della dichiarazione, in quanto anch'essa costituente atto unilaterale e quindi apprezzabile esclusivamente alla luce dell'intento del suo autore.

Il principio è stato affermato in relazione al c.c.n.l. Sanità privata del 19.1.2005, avente scadenza al 31.12.2005 e ultrattivo fino all'8.10.2020, sottoscritto da associazione sindacale cui il datore di lavoro, al momento della cessazione dell'ultrattività, non era più iscritto.

Sul perimetro soggettivo di applicazione del contratto collettivo, è di rilievo **Sez. L, 07203/2024, Rivero, Rv. 670442-01**, le cui affermazioni sono state così compendiate: la sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente; conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost.

2. Il diritto sindacale.

Il Giudice di legittimità è intervenuto anche sulla disciplina delle attività sindacali e dei comportamenti datoriali rilevanti *ex art. 28 st.lav.* A questo proposito, meritano di essere segnalate:

- **Sez. L, 24595/2024, Leone, Rv. 672247-01**, così massimata: l'attività di proselitismo sindacale con diffusione di comunicati sindacali nei luoghi di lavoro - nella specie a mezzo volantaggio - è legittima se svolta entro gli "spazi comunicativi" messi a disposizione dal datore e, comunque, in modo tale da non recare pregiudizio al normale svolgimento della vita aziendale sotto il profilo funzionale e produttivo; nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la legittimità del volantaggio realizzato dal c.d. "uomo *sandwich*", con affissione di un comunicato sindacale su petto e schiena del lavoratore per l'intera giornata lavorativa, in quanto avvenuto fuori degli spazi consentiti e fonte di costante disturbo per l'attività lavorativa;

- **Sez. L, 06876/2024, Bellè, Rv. 670440-01**, in cui si afferma che ai fini dell'integrazione, da parte del datore di lavoro, dell'attività antisindacale, a norma dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, rileva l'idoneità della condotta a produrre l'effetto che la disposizione intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale, sicché anche una condotta lecita nella sua obiettività configura un comportamento antisindacale ove presenti i caratteri dell'abuso del diritto. Nella specie, la S.C. ha quindi confermato la sentenza di merito nella quale era stato affermato che l'avere l'amministrazione datrice di lavoro - in presenza di una disposizione dell'accordo quadro per le elezioni delle RSU che prevedeva, in ipotesi di decadenza della RSU, la sottoscrizione dei contratti integrativi da parte dei componenti rimasti in carica - inteso trattare e, poi, stipulare un accordo con una RSU incompleta - integrata da un solo membro su tre -, avesse comunque alterato la normalità delle relazioni sindacali, non essendovi ragioni di necessità od urgenza, in quanto il contratto integrativo precedente si era rinnovato ed era dunque efficace.

3. La retribuzione.

In materia di retribuzione, assumono particolare rilievo le pronunce che si occupano dell'interpretazione delle norme poste direttamente a presidio del principio costituzionale della giusta e sufficiente retribuzione (art. 36 Cost.).

In quest'ottica, fra quelle pubblicate dalla S.C. nell'anno 2024, si segnala senz'altro **Sez. L, 09136/2024, Rivero, Rv. 670602-01**, secondo cui, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, senza che si possa considerare come definitivamente acquisito un diritto

derivante da una norma collettiva caducata o sostituita da altra successiva, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento concorrente con la fonte individuale, ferma restando la facoltà del lavoratore di rinunciare validamente al trattamento economico individuale che non riguardi l'applicazione di disposizioni inderogabili stabilite dalla legge o dai contratti collettivi, né diritti indisponibili *ex art.* 2113 c.c.. Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'*art.* 2077 c.c. e dei diritti retributivi del lavoratore da parte di un accordo sindacale aziendale che, nell'operare un complessivo riordino del sistema retributivo, ha accorpato alcune indennità accessorie di derivazione collettiva in due nuovi emolumenti condizionati alla presenza in servizio, subordinandone il riconoscimento, per i dipendenti titolari di superminimo pattuito con accordo individuale, alla scelta di rinunciare a questo con accordo sottoscritto ai sensi dell'*art.* 2113, ultimo comma, c.c.

Quanto ai rapporti tra la retribuzione e gli accordi *ex art.* 2113 c.c. di modifica delle mansioni e del livello di inquadramento si segnala **Sez. L, 26320/2024, Micheli, Rv. 672588-01**, la quale ha statuito che la disciplina di cui all'*art.* 2103 c.c., come modificato dall'*art.* 3 del d.lgs. n. 81 del 2015 - secondo la quale accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione possono essere stipulati, a pena di nullità, alle condizioni da esso previste e nelle sedi di cui all'*art.* 2113 c.c. - si applica a tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche se non ricorre un mutamento di mansioni o di livello di inquadramento. In tal modo, la Corte è pervenuta ad un assetto parzialmente divergente da quello delineato in *Sez. L, 19092/2017, Garri, Rv. 645267-01*, alla cui stregua, la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa.

Accostandosi ora al versante della determinazione del *quantum* della retribuzione, vanno ricordate una serie di variegate pronunce.

Menzione prioritaria meritano le statuizioni che conferiscono al riconoscimento di una giusta e sufficiente retribuzione una funzione di garanzia contro la violazione del diritto costituzionale al riposo (*art.* 36, comma 3, Cost.).

In questi termini, si è ad esempio espressa **Sez. L, 13932/2024, Micheli, Rv. 671413-01**, pronuncia alla cui stregua la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo *status* personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile (l'incidenza di tale effetto dissuasivo dovendo essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale).

Nel medesimo segno si colloca anche **Sez. L, 25840/2024, Caso, Rv. 672477-01**, statuendo che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'*art.* 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni ed è correlato allo *status* personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunciare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo.

A ribadire l'inesistenza di un principio di parità di trattamento retributivo, quanto al confronto tra rapporti di lavoro a tempo indeterminato e quelli di formazione lavoro, poi trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, è intervenuta **Sez. L, 12300/2024, Patti, Rv. 670930-01**, così massimata: non integrano violazione dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio. Nella fattispecie giunta alla sua attenzione la S.C. ha conseguentemente affermato che legittimamente i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dell'ATAC s.p.a. erano stati esclusi dalla fruizione dell'elemento di riordino del sistema retributivo - cd. E.R.S. -, in quanto emolumento non correlato all'anzianità di servizio. Sull'identificazione dei comportamenti datoriali discriminatori si v. *infra* il par. 5.

Sempre in ordine alle voci retributive spettanti ai lavoratori dei trasporti pubblici si è poi espressa **Sez. L, 24830/2024, Leone, Rv. 672466-01**, affermando che, nel settore degli autoferrotranvieri, in caso di accertamento giudiziale dello svolgimento in fatto delle superiori mansioni di quadro - ai sensi dell'art. 1 dell'accordo nazionale del 2 giugno 1987 (istitutivo della categoria), nonché dell'art. 2, nn. 8 e 16, lett. b), dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000 - al dipendente compete, oltre al superiore inquadramento, anche l'indennità di funzione.

Il giudice di legittimità ha avuto anche occasione di precisare la natura di spettanze retributive degli importi percepiti dal lavoratore, in caso di illegittima cessione di azienda, nel caso di offerta della prestazione lavorativa rifiutata dal cedente.

Il riferimento è a **Sez. L, 14712/2024, Panariello, Rv. 671215-01**, il cui principio di diritto è stato così enucleato da questo Ufficio: nel caso di illegittima cessione d'azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della *mora credendi*, sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto *ex art. 2126 c.c.*, sia perché *l'aliunde perceptum* attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni. Nella medesima pronuncia si affronta altresì (**Rv. 671215-02**) il tema della distinzione tra cessione di ramo d'azienda e appalto illecito, che sarà esaminato nel paragrafo 8.

Occorre infine dar conto, per completezza, di una serie di pronunce intervenute per dirimere questioni peculiari e fra loro non collegate, del pari collegate al tema qui in esame della retribuzione.

Sez. L, 18405/2024, Rivero, Rv. 671866-01, si è occupata del diritto alla retribuzione delle festività lavorate, ed ha affermato che l'art. 59 del CCNL cooperative sociali stabilisce che il lavoratore, se ha prestato la propria opera nelle giornate festive, ha diritto alla retribuzione delle ore lavorate oppure ad un corrispondente riposo da fruire entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, precisando altresì che tale disciplina prevede una regolamentazione specifica ed è incompatibile con quella del sistema della compensazione con la banca ore, prevista dall'art. 52 del medesimo CCNL, che è tarato, invece, su un periodo di tempo più lungo, attraverso un sistema di com-

pensazione che arriva fino a dicembre, allorché il monte ore accumulato, se non compensato con riposi e/o permessi *ad hoc*, va liquidato con una maggiorazione retributiva.

Sulla cessione del quinto dello stipendio è invece intervenuta **Sez. L, 22361/2024, Patti, Rv. 672266-01**, affermando che, nell'ipotesi in cui il lavoratore ricorra alla cessione del quinto dello stipendio, il trattenimento - da parte del datore di lavoro - di somme pari ai costi funzionali al buon esito della cessione è legittimo solo se l'operazione comporta costi aggiuntivi di contabilizzazione e gestione amministrativa insostenibili in rapporto all'organizzazione aziendale, e l'onere della prova di tale sproporzionata gravosità ricade sul datore di lavoro.

Si segnala anche una pronuncia sulle voci retributive dei docenti di scuole gestite da enti privati (nella specie, la Fondazione Maria Ida Vaglini per la cultura musicale), ai quali, secondo l'orientamento espresso da **Sez. L, 18736/2024, Bellè, Rv. 671928-01**, non spetta l'indennità di bilinguismo, di cui all'art. 1 l.r. Valle d'Aosta n. 63 del 1988 (norma efficace fino all'entrata in vigore della contrattazione collettiva a seguito della privatizzazione), posto che tali istituti scolastici non sono ricompresi nelle categorie di quelle "dipendenti" dalla Regione, a nulla rilevando la ricezione di finanziamenti regionali o il collegamento tra gli organi regionali e quelli della scuola privata.

3.1. Il T.F.R.

Quanto al computo della retribuzione differita, o trattamento di fine rapporto (T.F.R.), premesso che il criterio codificato dal legislatore è quello della "non occasionalità" (art. 2120, comma 2, c.c.) - requisito meno rigoroso rispetto a quello della "continuità", viceversa previsto per la previgente indennità di anzianità e, ancor oggi, per l'indennità sostitutiva del preavviso (art. 2121 c.c.) - va ricordato, in primo luogo l'insegnamento di **Sez. L, 14242/2024, Ponterio, Rv. 671208-01**, che si è occupata dei cc.dd. incentivi, affermando il seguente principio di diritto: nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto possono essere ricompresi gli emolumenti incentivanti che, pur presentando in astratto il carattere dell'incertezza, sono erogati ai dipendenti con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente *ex post*, l'avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escluderne il carattere occasionale, senza che rilevi il fatto che l'ammissione al sistema incentivante dipende da una decisione datoriale. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito di includere nel T.F.R. la retribuzione incentivante percepita dal lavoratore nel corso di sei anni consecutivi e legata ad elementi che, essendo rigorosamente collegati allo svolgimento del rapporto di lavoro, non potevano considerarsi connotati da aleatorietà e imprevedibilità.

Sempre in tema di T.F.R., deve segnalarsi **Sez. L, 20938/2024, Michelini, Rv. 671944-02**, che afferma che poiché il controvalore in denaro dell'uso e della disponibilità, anche per fini personali, dell'autovettura aziendale concessa al lavoratore come beneficio in natura, pattiziamente inserito nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro, ha natura retributiva, deve essere computato nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

In applicazione del principio la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva computato il valore dell'auto parametrando al suo costo, ai chilometri annualmente percorsi, ai rimborsi sostenuti per carburante e pedaggi autostradali, ed alle spese di manutenzione e assicurazione poste a carico del datore di lavoro, anziché all'importo forfettizzato indicato in busta paga, per il quale non erano state fornite spiegazioni sulla relativa base di calcolo.

Dal computo del T.F.R. è stata, invece, esclusa l'indennità di mensa, con il limite di una diversa previsione inserita nel contratto collettivo.

Sez. L, 08090/2024, **Michelini**, Rv. 670537-01, ha infatti statuito che, nella disciplina dettata dall'art. 6, comma 3, d.l. n. 333 del 1992, conv. con modific. dalla l. n. 359 del 1992, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione, che consideri il servizio mensa come retribuzione in natura, da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto.

Nel medesimo segno si colloca l'anteriore Sez. L, 07181/2024, **Ponterio**, Rv. 670441-01, che, del pari, rimarca come nella disciplina dettata dall'art. 6, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992, l'indennità di mensa, salva diversa previsione dei contratti collettivi, non costituisce base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto in ragione della sua natura non retributiva, a nulla rilevando la continuativa erogazione e la mancata istituzione del servizio mensa in azienda.

3.2. La progressione economica orizzontale.

Vertente sul tema specifico di cui in rubrica, va rammentata Sez. L, 12036/2024, **Boghetich**, Rv. 670987-01, il cui principio di diritto è stato così enucleato: il personale della riabilitazione a cui si applica *ratione temporis* la disciplina contenuta nel c.c.n.l. 2002-2005 per i dipendenti delle Strutture Associate AIOP, ARIS e Fondazione Gnocchi può conseguire la progressione orizzontale dalla posizione economica D a quella D1 in diverse modalità: alla data di stipulazione di detto c.c.n.l. (24.11.2004), per avere maturato 25 anni di anzianità di servizio nella stessa qualifica e nella stessa struttura sanitaria; successivamente e a regime, per avere maturato 20 anni di anzianità di servizio nella stessa qualifica e nella stessa struttura sanitaria, ovvero - a prescindere dall'anzianità - sulla base dei percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio di cui all'art. 47 del medesimo c.c.n.l.

3.3. Prescrizione e decadenza.

Da ultimo, a chiusura del cerchio tematico, va dato conto di alcune pronunce che hanno affrontato lo snodo classico della prescrizione e della decadenza rispetto alla rivendicazione dei crediti nascenti dal contratto di lavoro.

Al corrispettivo del patto di non concorrenza, secondo quanto stabilito dalla S.C., si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c., trattandosi di convenzione che presuppone e trova causa nella cessazione del rapporto di lavoro, avendo la funzione di far permanere convenzionalmente a carico dell'ex dipendente l'obbligo di fedeltà previsto durante il rapporto di lavoro dall'art. 2105 c.c. (Sez. L, 10680/2024, **Panariello**, Rv. 670871-01).

In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, poi, secondo quanto chiarito da Sez. L, 17484/2024, **Marotta**, Rv. 671593-01, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di *metus* (pronuncia in linea con altra precedente a firma della medesima Relatrice, Sez. L, 27340/2019, **Marotta**, Rv. 655518-01, la quale aveva concluso che, in tema di lavoro car-

cerario, la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione).

Sul tema affine della decadenza, ha stabilito infine **Sez. L, 15219/2024, Leone, Rv. 671224-01**, che la decadenza convenzionalmente stabilita dall'art. 35 del c.c.n.l. per l'industria edile - il quale prevede che qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro devono essere presentati dall'operaio entro il termine perentorio di sei mesi dalla sua cessazione - è validamente impedita dalla tempestiva richiesta del tentativo di conciliazione, il cui espletamento integra il contenuto e la *ratio* della norma contrattuale, dovendosi detta richiesta intendere come vera ed inequivocabile manifestazione di volontà di far valere il proprio diritto, intervenuta la quale saranno operativi i soli ordinari principi in tema di prescrizione.

4. I caratteri e l'oggetto della prestazione lavorativa.

4.1. Diligenza, buona fede e fedeltà.

Sul dovere di diligenza e buona fede del prestatore di lavoro, nell'anno 2024, è intervenuta **Sez. L, 30080/2024, Amendola, Rv. 673066-01**, chiarendo che la valutazione della buona fede del lavoratore - che giustifica il rifiuto di rendere la prestazione *ex art. 1460*, comma 2, c.c. - deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto anche della gravità dell'inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto e della concreta incidenza di detto inadempimento sulle fondamentali esigenze di vita personali e familiari del prestatore, con indispensabile valutazione, quindi, anche dell'attivazione o meno da parte del datore degli accomodamenti ragionevoli, di cui all'art. 3, comma 3 *bis*, del d.lgs. n. 216 del 2003, nei confronti delle persone con disabilità. Nella specie, la S.C. ha, quindi, cassato con rinvio la sentenza di merito che - senza alcuna verifica circa l'attivazione o meno di accomodamenti ragionevoli da parte dell'imprenditore - aveva ritenuto contrario a buona fede il rifiuto del lavoratore oncologico, invalido totale e con handicap grave, di riprendere servizio nella sede di lavoro, a seguito del diniego di trasferimento in sede più vicina alla famiglia.

Sempre a firma del medesimo Estensore, merita menzione anche **Sez. L, 26181/2024, Amendola, Rv. 672655-01**, alla cui stregua, dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede *ex artt. 1175 e 1375 c.c.* deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (fattispecie relativa a dirigente di azienda speciale, istituita presso la locale camera di commercio per la salvaguardia di interessi pubblici, che aveva assunto la carica di consigliere delegato, con poteri di rappresentanza legale, di impresa privata di cui era anche socio).

Al tema dei doveri del lavoratore si lega quello dei mezzi per controllarne l'osservanza: a questo proposito, **Sez. L, 23985/2024, Amendola, Rv. 672269-01**, ha affermato che, in tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, la nozione di patrimonio aziendale tutelabile ai sensi dell'art. 4, comma 1, st.lav., come modificato dall'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 151 del 2015, va intesa in accezione estesa e riguarda la difesa datoriale sia da condotte di appropriazione di denaro, danneggiamento o sottrazione di beni, che giustificano la

protezione da aggressioni di esterni e anche dei dipendenti, sia dalla lesione all'immagine e al patrimonio reputazionale dell'azienda; nella specie, è stata confermata l'integrale utilizzabilità dei filmati, estratti dall'impianto di videosorveglianza aziendale autorizzato con accordo sindacale, che avevano registrato le operazioni di emissione biglietti e incasso e avevano consentito di accertare condotte fraudolente di un dipendente a danno dei clienti, ritenute idonee a pregiudicare l'immagine dell'impresa.

La riconferma della natura privatistica del lavoro degli esperti linguistici impiegati dalle università ha offerto alla Corte di legittimità l'occasione di evidenziare che il prestatore di lavoro è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. (**Sez. L, 13490/2024, Di Paolantonio, Rv. 671187-01**, per l'esame completo della quale si fa rinvio al paragrafo 8 del capitolo sul pubblico impiego contrattualizzato).

4.2. Luogo.

In ordine alla necessaria riassegnazione del prestatore alla propria sede lavorativa a seguito di provvedimento di reintegrazione da parte del datore di lavoro, si ricorda **Sez. L, 18892/2024, Rivero, Rv. 671919-01** (per il compiuto esame della quale si fa rinvio al par. 2.11. del capitolo sul licenziamento).

Quanto ai rapporti fra luogo di lavoro e tutela assistenziale, si registra anche **Sez. L, 00047/2024, Ponterio, Rv. 669690-01**, la quale ha affermato che, in tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

4.3. Orario.

In tema di durata della prestazione lavorativa, è stato ribadito che la mancata fruizione del riposo giornaliero o settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di un danno non patrimoniale che deve ritenersi presunto, perché l'interesse leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost. (**Sez. L, 18390/2024, Rivero, Rv. 672094-02**).

Riveste poi senz'altro un ruolo di primo piano, passando ora alle questioni in ordine alla determinazione dell'orario di lavoro, la giurisprudenza sul contratto a tempo parziale.

Preliminarmente e in generale, con una pronuncia del giugno dell'anno in rassegna, la S.C. (**Sez. L, 17419/2024, Panariello, Rv. 671591-01**) ha ribadito che il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto *part-time* nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno; tuttavia, il datore di lavoro può provare l'esistenza di sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni.

Sez. L, 28657/2024, Caso, Rv. 672689-01, ha poi statuito che anche nella vigenza della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui agli artt. 4-12 del d.lgs. n. 81 del 2015, la modifica unilaterale da parte del datore di lavoro della collocazione temporale della prestazione lavorativa pattuita nel contratto di lavoro *part-time*, in ragione della sua necessaria determi-

nazione convenzionale ed in assenza di clausole elastiche, costituisce inadempimento contrattuale, a maggior ragione per i lavoratori assunti ai sensi della l. n. 68 del 1999, potendo tale modifica risultare incompatibile con le loro minorazioni e conseguenti peculiari esigenze di recupero delle energie psico-fisiche.

Sempre in tema di integrazione del regolamento contrattuale del lavoro *part-time*, **Sez. L, 11333/2024, Rverso, Rv. 671006-02**, ha precisato che il dovere del giudice di determinare (*ex art. 10, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 ed ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000*) le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, in caso di omessa indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario, trova applicazione anche in caso di mancata puntuale indicazione della collocazione dei turni di lavoro, senza che ciò determini alcuna lesione dell'autonomia negoziale.

Nella medesima pronunzia - **Sez. L, 11333/2024, Rverso, Rv. 671006-01** - si afferma altresì, quanto al lavoro parziale organizzato in turni, che è necessaria la puntuale indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario della prestazione lavorativa, con riferimento a giorno, settimana, mese ed anno, non essendo consentito al datore di lavoro, nemmeno in base all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015, derogare a tale esigenza e indicare l'orario di lavoro su turni successivamente alla conclusione del contratto, in assenza di clausole flessibili ed elastiche. Nella specie, la S.C. ha escluso che una tale facoltà fosse legittimata dagli articoli 3 e 9 del c.c.n.l. per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionarie di Autostrade e Trafori, non potendo essi interpretarsi nel senso di autorizzare una comunicazione al lavoratore *part-time* con cadenza annuale o mensile dei turni non indicati nel contratto di lavoro.

In generale, poi, della determinazione del tempo lavorativo, si è occupata **Sez. L, 15332/2024, Boghetich, Rv. 671227-01**, precisando che il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro non può, in via generale, considerarsi esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo; esso, tuttavia, rientra nell'attività lavorativa vera e propria allorché sia lo strumento necessario per l'esecuzione della prestazione, ovvero si tratta di tempo del quale il lavoratore non può liberamente disporre o che caratterizza intrinsecamente la qualità dell'attività, svolta in assenza di un luogo di lavoro fisso o abituale.

Ispirandosi ad analoga *ratio*, **Sez. L, 14843/2024, Rverso, Rv. 671303-01**, ha stabilito che, ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, sicché deve considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi o non assoggettato al potere gerarchico. Nel caso sottoposto alla sua cognizione, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva considerato eterodirette ed obbligatorie l'effettuazione del tragitto dall'ingresso alla postazione informatica e ogni altra attività preliminare ai fini del *log in* e del *log out*, poiché frutto delle decisioni del datore di lavoro riguardanti la struttura della propria sede, la collocazione della postazione di lavoro ed il percorso per raggiungerla, l'assegnazione di mansioni eseguibili solo tramite postazione telematica, la scelta del tipo di computer, la determinazione della procedura di sua accensione, l'orario esatto di inizio turno dinanzi alla postazione già inizializzata ed avviata all'uso.

Dei rapporti fra le fonti di regolazione della durata della prestazione lavorativa si è occupata **Sez. L, 15815/2024, Bellè, Rv. 671434-02**, da cui si è appreso che, nei casi in cui è

applicabile il Regolamento CE n. 561 del 2006, come interpretato dalla sentenza CGUE del 9 novembre 2023 in causa C-477/2022, la disciplina dei tempi di lavoro e riposo per gli autisti di linea è quella di miglior tutela di cui agli artt. 6-9 del predetto Regolamento, ferme le ulteriori regole previste dalla Direttiva 2002/15/CE e dalle normative nazionali (come il d.lgs. n. 234 del 2007) di attuazione di quella sovranazionale, dovendosi in ogni caso escludere un raddoppio della protezione. Nella stessa pronunzia si afferma che, in tema di servizi di trasporto di persone con veicoli adibiti al trasferimento di più di nove individui compreso il conducente, la nozione di “percorso superiore ai cinquanta chilometri” - di cui al Regolamento CE n. 561 del 2006, come interpretato dalla sentenza della CGUE del 9 novembre 2023, in causa C-477/2022 - va intesa come itinerario di linea che il mezzo deve percorrere per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo nell’ambito del servizio regolare, restando irrilevanti il percorso di guida giornaliero del singolo autista o la distanza ulteriore coperta dal veicolo ed altresì ininfluenti, ai fini del calcolo del “periodo di guida” accumulato dal singolo conducente nel periodo di due settimane consecutive (presupposto per la tutela di cui all’art. 6, paragrafo 3, del medesimo Regolamento), le mansioni accessorie o comunque le altre attività svolte dal lavoratore diverse dalla guida o anche la stessa attività di guida, se di veicoli diversi da quelli a cui è applicabile la normativa (Rv. 671434-01).

Doveroso, a questo punto, richiamare anche Sez. L, 18401/2024, **Riverso**, Rv. 671865-01, a mente della quale, in tema di rapporto di lavoro del personale ferroviario, ai fini della diversa quantificazione dell’indennità di utilizzazione di cui all’art. 31 del Contratto aziendale di Gruppo FS, la contrattazione collettiva qualifica come “condotta continuativa ed effettiva” esclusivamente l’attività nel corso della quale il lavoratore PDM (personale di macchina) è responsabile della guida del treno e come “lavoro” le attività accessorie e complementari da eseguire prima della partenza e dopo l’arrivo dei treni, mentre rientra nella nozione di “condotta continuativa” l’attività che ricomprende due periodi di guida del treno senza intervalli di pausa o con intervalli di pausa inferiori ai 15 minuti netti ovvero con fermate di servizio inferiori ai 30 minuti, sicché le eventuali operazioni accessorie o complementari restano in essa assorbite.

Sez. L, 08626/2024, **Patti**, Rv. 670611-01, ha, dal canto suo, statuito che, nel caso di mancato godimento della pausa retribuita prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2003 e, per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, disciplinata dall’art. 74 del c.c.n.l. del 2 maggio 2006 e dell’8 aprile 2013, poiché questo prevede il diritto ad un riposo compensativo per l’impossibilità di fruizione della pausa durante il turno lavorativo, anche con le modalità alternative ivi contemplate, il lavoratore che agisce per il riconoscimento di tale diritto ha l’onere di allegare e provare, quale fatto costitutivo, la prestazione di un’attività giornaliera superiore a sei ore consecutive senza aver goduto della pausa retribuita, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare il fatto estintivo dell’avvenuto godimento di questa secondo le predette modalità alternative o dei riposi compensativi previsti in sostituzione.

4.4. Astensione dal lavoro: festività, ferie e permessi.

Fra i diritti del lavoratore di diretta derivazione costituzionale, vanno ora presi in esame il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 36, comma 3, Cost.).

A tale riguardo, la S.C., nell’anno 2024, è tornata ad affermare che il diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dal lavoro in corrispondenza delle festività infrasettimanali non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro e può formare oggetto di rinuncia solo sulla base di uno specifico accordo fra datore di lavoro e lavoratore o di accordi stipulati da organizzazioni sindacali a cui quest’ultimo abbia conferito esplicito mandato. Nella specie, Sez. L,

14904/2024, Ponterio, Rv. 671220-01, ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato la possibilità, per un datore di lavoro del settore terziario, di far godere ai dipendenti il riposo compensativo del lavoro prestato nel giorno di domenica, normalmente destinato al riposo settimanale, in coincidenza con i giorni di festività infrasettimanale, fondandola unicamente sull'inesistenza nei contratti integrativi aziendali di un divieto in tal senso, e purché tali giorni fossero considerati nella programmazione trimestrale aziendale come giorni di apertura del negozio.

In un ambito più circoscritto, **Sez. L, 13481/2024, Solaini, Rv. 671201-01**, si è così pronunciata: l'art. 48 del c.c.n.l. del 19 luglio 2001, che prevede, per piloti di elicottero, il diritto a fruire di un periodo di ferie annuali della durata di 26 giorni, non può essere letto in modo da ricomprendere le ferie nelle giornate di riposo, in quanto tale interpretazione contrasterebbe con gli artt. 36, comma 3, Cost. e 2109 c.c., in virtù dei quali il diritto alle ferie annuali è irrinunciabile, e con la disciplina nazionale ed europea, che non consente alcuna sovrapposizione tra riposi e ferie.

Tematica affine è quella dei permessi retribuiti: a tal proposito, alla stregua di **Sez. L, 30628/2024, Boghetich, Rv. 673116-01**, il diritto ai permessi previsti dall'art. 33 della l. n. 104 del 1992 sorge a seguito di domanda amministrativa e, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, si configura come obbligazione di durata, la quale, quindi, permane sino all'accertamento di eventuale sopravvenuta modifica delle predette condizioni.

Per **Sez. L, 26417/2024, Michelini, Rv. 672590-01**, il diritto del lavoratore ai permessi di cui all'art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 si pone in relazione diretta con le esigenze di assistenza alla persona disabile, per lo svolgimento di tutte le attività che essa non è in condizioni di compiere autonomamente, senza che il datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sociali, possa sindacare la scelta dei giorni in cui fruire di tali permessi, rimessa esclusivamente al lavoratore e soggetta solo ad obbligo di comunicazione, o contestare la prestazione dell'assistenza in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, la quale pertanto non costituisce abuso del diritto.

Specifici aspetti sono stati affrontati, poi, da **Sez. L, 04264/2024, Tricomi I., Rv. 670048-01**, la quale ha affermato che i periodi di congedo non retribuito richiesti ex art. 4 l. n. 53 del 2000 dal figlio convivente di persona con handicap grave possono essere riqualeficati come permessi retribuiti ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, se fruiti anteriormente alla pronuncia della Corte cost. n. 19 del 2009, in quanto con detta pronuncia è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 42, comma 5, nella parte in cui non includeva nel novero dei legittimati anche il figlio convivente; nonché da **Sez. L, 03998/2024, Caso, Rv. 670046-01**, secondo cui, la fruizione di permessi retribuiti da parte dei lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche presso le Amministrazioni locali, ai sensi dell'art. 20 l.r. Sicilia n. 30 del 2000, deve essere funzionale all'espletamento del mandato ed adeguatamente giustificata, né a tali regole fanno eccezione i permessi orari di cui al comma 4 del citato art. 20, in relazione ai quali è consentito al datore di controllare che il godimento risponda alle causali autodichiarate dal lavoratore.

4.4.1. Segue: malattia e periodo di comportamento.

Altre importanti precisazioni sono state operate in tema di computo del periodo di comportamento.

A tenore di **Sez. L, 15747/2024, Pagetta, Rv. 672165-01**, i periodi di integrazione salariale non possono essere computati ai fini della durata del comportamento, in quanto quest'ultimo, come limite temporale al potere datoriale di recedere dal rapporto di lavoro in mancanza della controprestazione, presuppone l'attualità dell'obbligo di rendere la prestazione

lavorativa ed incide quindi in concreto sul sinallagma contrattuale, mentre la situazione che genera il trattamento di cassa integrazione costituisce ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto estraneo al lavoratore, sicché rende priva di rilievo la contemporanea situazione di malattia dello stesso.

Quanto al periodo di comporto in caso di lavoro a tempo parziale è poi intervenuta, **Sez. L, 11865/2024, Patti, Rv. 671012-01**, con cui è stato precisato che il riproporzionamento del periodo di comporto in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa necessita di previsione da parte della contrattazione collettiva, in quanto l'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 demanda ad essa la possibilità di modulare la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e di infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro, derogando alla regola generale del riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale.

In tema di periodo di comporto e accesso al pronto soccorso va rammentata anche **Sez. L, 15845/2024, Ponterio, Rv. 671278-01**, esaminata nel paragrafo 2.7 dedicato al licenziamento cui si fa rinvio, unitamente a **Sez. L, 12487/2024, Garri, Rv. 670892-01**, che tocca il diverso tema del significato da attribuire al termine di ventiquattro mesi contenuto nella contrattazione collettiva.

Sempre in tema di accertamento della malattia, ma questa volta ai fini della fruizione del periodo di aspettativa non retribuito di cui all'art. 26.9 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va pure ricordato che il lavoratore ha l'onere di produrre previamente, a sostegno della richiesta, certificazione medica con indicazione della data di inizio e di fine della malattia, la quale costituisce titolo per l'assenza, dovendo essere commisurata la concessione del beneficio alla patologia sofferta (così **Sez. L, 06466/2024, Amendola, Rv. 670352-01**).

4.4.2. Segue: l'esercizio del diritto di sciopero.

Nel corso dell'anno in rassegna, due pronunce sono intervenute anche in tema di diritto di sciopero (art. 40 Cost.).

Sez. L, 06787/2024, Michelini, Rv. 670446-01, ha enunciato il seguente principio: il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 Cost.) e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvergono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale, nonché la libertà dell'iniziativa economica, cioè dell'attività imprenditoriale, che con la produttività delle aziende è concreto strumento di realizzazione del diritto costituzionale al lavoro per tutti i cittadini; pertanto, l'esercizio del predetto diritto deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione, ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione.

Sez. L, 24473/2024, Leone, Rv. 672434-01, ha inoltre affermato che gli elementi che qualificano l'astensione dal lavoro come sciopero legittimo sono rappresentati dalla natura collettiva dell'interesse da tutelare e dalla preventiva deliberazione, collettivamente assunta, per la sua adozione, in quanto funzionale a dar conto della diffusività dell'interesse sotteso all'azione dimostrativa collettiva intrapresa, anche se riferito solo ad un gruppo di lavoratori addetti ad una singola funzione.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha quindi confermato la sentenza di appello con la quale è stata ritenuta illegittima l'astensione dal lavoro attuata da alcuni lavoratori, addetti ad un casello autostradale, in assenza di una deliberazione di natura collettiva della sua indizione e solo successivamente comunicata ai rappresentanti sindacali.

4.5. Mansioni e demansionamento.

Va posta attenzione, poi, alla vasta tematica dell'assegnazione del lavoratore alle mansioni di competenza. Come noto, l'individuazione delle corrette mansioni cui adibire il prestatore di lavoro è rilevante già a partire dal momento dell'assunzione. A tale principio fa da contraltare il cd. *ius variandi* datoriale ed i correlativi limiti al suo esercizio.

A tal proposito, con specifico riguardo all'acquisizione di superiori mansioni, giova rammentare quanto precisato da **Sez. L, 21224/2024, Amirante, Rv. 672098-01**, cui si deve l'affermazione che, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., è necessario che l'assegnazione a mansioni superiori sia stata piena, effettiva e continuativa e che l'inquadramento del lavoratore venga ad essere operato sulla base delle mansioni previste dal contratto collettivo raffrontandole con quelle in concreto espletate dal dipendente interessato, non rilevando invece che la qualifica superiore corrispondente alle mansioni attribuite sia classificata dal c.c.n.l. come "ad esaurimento". In virtù di detto principio di diritto, nella vicenda scrutinata dalla S.C., il diritto all'acquisizione *ex art. 2103 c.c.* della superiore qualifica di educatore professionale, di cui al c.c.n.l. AIOP-ARIS 1988-1990, non poteva essere negata al lavoratore assegnato a tali mansioni in ragione del mancato possesso del titolo previsto dal d.m. n. 520 del 1998, poiché tale contratto prevede anche il profilo dell'educatore professionale senza titolo, qualificandolo come figura "ad esaurimento", per la quale non è richiesto detto titolo abilitante.

Per la vicinanza agli argomenti trattati va qui rammentata anche **Sez. L, 18744/2024, Caso, Rv. 671999-01**, secondo cui, in tema di mobilità verticale, l'art. 1, punto C), paragrafo II, lett. c), del Titolo II del c.c.n.l. Industria Metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008 deve essere interpretato - alla luce delle regole di ermeneutica negoziale contenute negli artt. 1362 e ss. c.c. - nel senso che il passaggio dalla seconda alla terza categoria consegue all'accertamento in concreto (compiuto attraverso la sperimentazione di almeno un mese in compiti di livelli superiori, a seguito dell'espletamento per almeno 18 mesi delle funzioni della seconda categoria) della capacità di svolgere funzioni di livello superiore.

In tema di mansioni, una disciplina di speciale garanzia è dettata per i lavoratori disabili, così come puntualizzato da **Sez. L, 10744/2024, Garri, Rv. 670999-01**, per cui, in ipotesi di richiesta di avviamento di detti lavoratori, il rifiuto dell'assunzione può essere giustificato solo a fronte di un'incompatibilità assoluta tra l'invalidità del lavoratore avviato e tutte le mansioni disponibili in azienda, che il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in ragione dell'obbligatorietà dell'assunzione di lavoratori invalidi e della tipicità dei casi di esonero *ex art. 5 l. n. 68 del 1999*. Alla stregua di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, non avendo essa né provato l'inesistenza di mansioni incompatibili con le minorazioni dei disabili avviati, né presentato domanda per l'esonero *ex art. 5, comma 3, l. n. 68 del 1999*.

Infine, in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, secondo **Sez. L, 10391/2024, Garri, Rv. 670801-01**, nel regime di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive del prestatore assente può anche non essere destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore rimpiazzato, perché la sostituzione deve essere funzionale alle esigenze dell'impresa, con la conseguenza che l'imprenditore - nell'esercizio del proprio potere di organizzazione - ha la facoltà di disporre

l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine assunto per ragioni sostitutive, attraverso gli spostamenti interni che ritenga più opportuni alla migliore performance aziendale e, quindi, anche attraverso un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, ferma, però, la necessità della correlazione tra assenza ed assunzione a termine, dovendo la seconda essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'impresa per effetto della prima.

Venendo ora al versante dei poteri datoriali, ai limiti al loro esercizio, ai correlativi obblighi e alle responsabilità conseguenti in caso di loro violazione, **Sez. L, 11870/2024, Panariello, Rv. 671037-02**, ha specificato che, in tema di limiti all'esercizio dello *ius variandi* del datore di lavoro, l'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, di modifica dell'art. 2103 c.c., stabilisce il principio della fungibilità delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale, il quale deve intendersi nel senso che, se il c.c.n.l. articola una medesima categoria legale in più livelli professionali, lo *ius variandi* è legittimamente esercitato solo se le nuove mansioni appartengono, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti; se invece il c.c.n.l. non prevede più livelli professionali, ma solo livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, detto potere sarà ugualmente esercitabile a condizione che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale.

La stessa pronuncia (**Sez. L, 11870/2024, Panariello, Rv. 671037-01**) ha altresì evidenziato che, in tema di demansionamento illegittimo, la protrazione nel tempo della condotta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori costituisce un illecito di natura permanente, cosicché, se essa persiste anche dopo la modifica dell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, occorre valutare se le mansioni assegnate sono ancora qualificabili come "inferiori" alla luce della nuova disciplina; in caso negativo, la connotazione di illiceità di detta condotta viene meno limitatamente alla frazione della stessa successiva all'entrata in vigore della novella, che si applica *ex nunc* (cioè, dal 24/06/2015).

Quando poi il lavoratore allegghi un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è sull'imprenditore che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori è giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (**Sez. L, 00048/2024, Ponterio, Rv. 669700-01**).

Peraltro, sempre in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, **Sez. L, 21527/2024, Tricomi I., Rv. 671947-01**, ha precisato che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare [a]reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno; tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova *ex art. 2697 c.c.* del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.

Sui rapporti fra clausola penale e demansionamento, si segnala infine **Sez. L, 14706/2024, Panariello, Rv. 671308-01**, in cui si è affermato il seguente principio di diritto: per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindere da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una penale pattuita a titolo di anticipata liquidazione del danno da demansionamento, ne aveva negato la riduzione senza valutare la circostanza del pensionamento del lavoratore a distanza di pochi mesi dalla modifica *in peius* delle mansioni.

5. La tutela ex art. 2087 c.c., le condotte discriminatorie e il *mobbing*.

Accostandosi ora, più propriamente, alla tutela globale apprestata dall'art. 2087 c.c., una pronuncia significativa sul tema è quella resa da **Sez. L, n. 26390/2024, Amirante, Rv. 672589-01**, secondo cui la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. è volta a sanzionare l'omessa predisposizione di misure atte a preservare la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della possibilità di venire a conoscenza e d'indagare l'esistenza di fattori di rischio in un dato momento storico; pertanto, qualora sia accertato che il danno alla salute è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione a polveri di amianto, la cui pericolosità era conosciuta al tempo di svolgimento della stessa, il datore di lavoro ha l'onere di provare, pur in assenza di una specifica disposizione preventiva, l'adozione di misure generiche di prudenza necessarie a preservare dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo, non rilevando che il rapporto di lavoro si sia svolto prima dell'introduzione di specifiche norme per il trattamento dell'amianto, quali quelle del d.lgs. n. 277 del 1991.

Si tenga inoltre presente che, come statuito da **Sez. L, 29157/2024, Ciriello, Rv. 673017-01**, in tema di infortuni e malattie professionali, il committente che affida lavori in appalto all'interno dell'azienda, mantenendo nella propria disponibilità l'ambiente di lavoro, è obbligato - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e, quindi, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 626 del 1994 - ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice. Nella specie la S.C. ha affermato che la circostanza che il committente ILVA, oggi Fintecna, non si sia ingerito nell'esecuzione e nell'organizzazione dell'attività dell'appaltatore non è sufficiente ad escluderne la responsabilità, se il nocumento è cagionato da fattori di rischio presenti nello stabilimento di Taranto.

In materia di discriminazione nel settore privato, si registrano invece, nell'anno in rassegna, due significative pronunce.

Alla stregua della prima, costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 198 del 2006, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che, pur non illecito o intrinsecamente discriminatorio, metta, di fatto, i lavoratori di un determinato sesso in posizione di particolare svantaggio rispetto a quelli dell'altro, rilevando, ai fini dell'applicazione della norma citata, il solo effetto discriminatorio finale sul piano della realtà sociale. In applicazione di tale principio, **Sez. L, 04313/2024, Zuliani, Rv. 670126-01**, ha affermato, in ragione dell'accertata preponderanza statistica delle donne tra i lavoratori in *part-time*, che costituisce discriminazione indiretta ai fini delle progressioni economiche orizzontali, l'attribuzione di un punteggio ridotto ai lavoratori a tempo parziale, rispetto a quelli a tempo pieno.

La seconda, più recente, è Sez. L, 33746/2024, Bellè, Rv. 673310-01, la quale, sul tema delle discriminazioni di genere, ha stabilito che se la persona vittima di offese a connotazione sessuale denuncia i fatti, la contestazione disciplinare elevata nei suoi confronti, per l'asserita infondatezza della denuncia, può a sua volta rivestire carattere discriminatorio, anche se non seguita dall'applicazione di alcuna sanzione ma comunque formulata in assenza delle condizioni per un uso legittimo del potere disciplinare (che postula quantomeno la colpa grave del denunciante), in quanto condotta di vittimizzazione secondaria, da ritenersi vietata dalle convenzioni internazionali perché fonte di effetti umilianti e inibitori rispetto alla proposizione di ulteriori ed analoghe denunce.

Viceversa, più d'una sono le pronunce intervenute in tema di *mobbing*: ad esempio, secondo Sez. L, 05061/2024, Zuliani, Rv. 670164-01, l'accertata insussistenza degli estremi del *mobbing* in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo.

Dal canto suo, Sez. L, 04664/2024, Marotta, Rv. 670128-01, ha chiarito che la nozione di *mobbing* - come quella di *straining* - è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro; pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul *quantum* del risarcimento, ma non sull'*an* dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale. In applicazione di tale assunto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento da *mobbing* per l'assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, senza verificare se le condotte datoriali avevano generato un ambiente logorante e "stressogeno" per il dipendente.

6. La distinzione fra lavoro autonomo e subordinato.

Il fondamentale tema dell'interpretazione del rapporto fra le parti come di natura autonoma o, piuttosto, subordinata, nell'anno 2024, ha registrato una significativa presa di posizione da parte di Sez. L, 28274/2024, Ponterio, Rv. 673163-01, 673163-02, 673163-03, che ha affermato i tre principi di seguito enucleati:

- allo scopo di qualificare come autonome o subordinate le prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale, la subordinazione deve essere verificata alla luce dell'intensità dell'etero-organizzazione della prestazione e stabilire se essa è funzionale al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio oppure se eccede le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio; nella fattispecie - riguardante un avvocato presso uno studio legale multidisciplinare, strutturato in associazione professionale della quale egli non era socio - la subordinazione è stata esclusa, essendosi accertato che al legale era lasciato spazio per il libero esercizio della professione, nei suoi contenuti tecnici e nelle sue modalità temporali e gestionali, pur in presenza di regole necessarie al coordinamento della sua attività con quella dello studio (Rv. 673163-01);

- il principio di indisponibilità del tipo negoziale, ribadito più volte dalla Corte costituzionale, preclude al legislatore di negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura ove da ciò derivi l'inapplicabilità di norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato (Rv. 673163-02);

- la scelta legislativa di escludere le "collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali" (nella specie, di avvocato) dal novero dei rapporti di collaborazione ai quali si applica la disciplina del lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientra nei limiti del potere discrezionale attribuito al legislatore, trattandosi di opzione conforme ai canoni di ragionevolezza (stante il possesso da parte del professionista di un potere contrattuale tale da renderlo immune da pratiche elusive e di sfruttamento a cui il legislatore ha voluto porre rimedio) e di uguaglianza (trattandosi di categoria disomogenea rispetto a quelle prive di un simile statuto professionale) (Rv. 673163-03).

Va qui ricordata *in limine*, sui rapporti fra accertamento della natura del rapporto e termini decadenziali, Sez. L, 18210/2024, Amendola, Rv. 671998-01, che ha invece chiarito che nel caso di domanda di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro avente veste formale di contratto di lavoro autonomo, non trova applicazione il regime decadenziale *ex art.* 32 l. n. 183 del 2010, in quanto la riqualificazione operata dal giudice si caratterizza come ricostruzione della realtà del rapporto, con l'effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primo come nei successivi contratti di collaborazione autonoma.

7. Il lavoro in apprendistato, a termine, somministrato, intermittente, a progetto.

Approcciando ora la galassia delle prestazioni che non rientrano nello schema classico del lavoro subordinato a tempo indeterminato, può cominciarsi segnalando una pronuncia in tema di contratto di apprendistato: qui, il requisito della forma scritta, previsto *ratione temporis* dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 167 del 2011, va inteso in senso funzionale, in quanto prescritto a pena di nullità "di protezione" di una delle parti contrattuali, sicché esso è rispettato solo quando è redatto per iscritto anche il piano formativo individuale (così massimata è Sez. L, 06704/2024, Caso, Rv. 670355-01).

Sui fondamenti giustificativi del ricorso al contratto di lavoro a termine è invece intervenuta Sez. L, 22869/2024, Amirante, Rv. 672334-01, cui si deve l'affermazione che, nei contratti di lavoro a tempo determinato, soddisfa il requisito di specificità la causale giustificativa che faccia riferimento a "picchi produttivi", ossia all'intensificazione dell'attività, quando sia accompagnata da altri dati di conoscenza che consentano la individuazione della ragione organizzativa ed il controllo della sua effettività, nonché del rapporto di causalità con l'assunzione. Nel caso sottoposto al suo vaglio, la S.C. ha quindi confermato la sentenza di appello che aveva accertato l'illegittimità di due contratti per prestazioni di lavoro a termine - uno interinale per prestazione di lavoro temporaneo, l'altro di somministrazione di lavoro, entrambi prorogati e aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni di portalettere - rilevando che l'utilizzatrice, Poste Italiane s.p.a., non aveva dato prova né dell'effettiva sussistenza delle ragioni giustificative legittimanti il ricorso a detti contratti, né del nesso causale tra tali ragioni giustificative e l'assunzione del dipendente.

Analogamente, secondo Sez. L, 04634/2024, Ponterio, Rv. 670052-01, in tema di contratti a termine, una volta dedotto dal lavoratore il superamento della percentuale di contingimento, grava sul datore di lavoro la prova del rispetto del previsto limite percentuale, in applicazione del principio di "vicinanza della prova", atteso che il prestatore non è nella disponibilità dei dati (lavoratori occupati nell'impresa) necessari ai fini del controllo.

Per **Sez. L, 19348/2024, Patti, Rv. 671868-01**, poi, in tema di esercizio del diritto di precedenza di cui all'art. 5, comma 4-*quater*, d.lgs. n. 368 del 2001, *ratione temporis* vigente, il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare - manifestando la propria volontà al datore, entro un anno dalla cessazione del rapporto ed anche nel corso dello stesso, in carenza di uno specifico termine a quo nella normativa - il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal proprio datore nei dodici mesi successivi alla manifestazione della volontà di avvalersi della precedenza.

Quanto invece ai contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di attività stagionali, secondo quanto deciso da **Sez. L, 09444/2024, Amendola, Rv. 670681-01**, la mancata indicazione nell'atto scritto del diritto del dipendente ad essere assunto a tempo indeterminato con precedenza rispetto ad altri lavoratori che il datore intenda assumere nell'anno successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, impedisce al datore di lavoro di opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi della precedenza e, se vi è stata l'assunzione di altri lavoratori, lo obbliga al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Va ricordata, a questo punto, anche **Sez. L, 02764/2024, Cinque, Rv. 670031-01**: in tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la deroga - prevista dall'abrogato art. 5, comma 4-*ter*, del d.lgs. n. 368 del 2001, *ratione temporis* applicabile - al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata cumulativa dei contratti, riguardante attività stagionali, ossia preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione), presuppone, ai fini della sua operatività, che la contrattazione collettiva, in attuazione della delega conferitale dalla citata disposizione normativa, elenchi specificatamente le predette attività; in applicazione di tale principio, nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto operante la deroga, sul rilievo che l'art. 128, comma 1, del c.c.n.l. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 25 marzo 2010 definiva plausibilmente come lavoro stagionale anche quello di addetto alla manutenzione e all'esercizio delle opere e degli impianti consorziali, sebbene si trattasse di attività parzialmente difforme dalle ipotesi previste al n. 13 dell'allegato all'articolo unico del d.P.R. n. 1525 del 1963.

Una significativa precisazione, quanto ai rapporti tra lavoro a termine e somministrato, è giunta da **Sez. L, 20505/2024, Caso, Rv. 672072-01**, secondo cui, il cumulo del periodo di lavoro a tempo determinato con quello di lavoro somministrato, *ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015*, rileva solo ai fini del rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi stabilito per la successione di tali contratti e non di quello previsto per la proroga o il rinnovo acasuale dei rapporti a tempo determinato.

In tema di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato **Sez. L, 00378/2024, Gnani, Rv. 669692-01**, ha statuito poi che la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione *ratione temporis* vigente, non comporta una nullità parziale del contratto *ex art. 1419, comma 2, c.c.*, ma una nullità cui consegue, in assenza di diversa previsione di legge, l'effetto caducatorio non retroattivo ai sensi dell'art. 2126 c.c., cosicché deve escludersi la sua conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche ai soli effetti del rapporto previdenziale, non rinvenendosi disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale e per quello di lavoro.

In materia di contratto di lavoro a progetto, **Sez. L, 28112/2024, Michelini, Rv. 672603-01**, ha poi affermato che l'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall'art. 24-bis, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, *ratione temporis* vigente, ha introdotto - in relazione al settore delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso *call center outbound* - una disciplina la cui specialità va rinvenuta nella delega alla contrattazione collettiva nazionale per l'individuazione della base del corrispettivo, ma non in una deroga alle regole che consentono l'utilizzo di tale tipologia contrattuale, comprensive del collegamento funzionale a un risultato finale e della specificità del progetto.

7.1. La collaborazione nell'impresa familiare.

In tema di impresa familiare, si è per altro verso precisato che i diritti di partecipazione del collaboratore sui beni acquistati dal titolare con gli utili non ripartiti hanno natura obbligatoria e non reale, in coerenza: a) con la natura individuale dell'impresa e, quindi, con l'alterità del soggetto collaboratore rispetto alla stessa; b) con l'autonomia operativa dell'azienda familiare, non armonizzabile con l'assoggettamento alle normali regole della comunione; c) con le esigenze di tutela dei terzi, in quanto la contitolarità comporterebbe la sottrazione di detti beni al rischio imprenditoriale (**Sez. L, 15810/2024, Pagetta, Rv. 671276-01**).

8. Il datore di lavoro: appalto, trasferimento d'azienda, intermediazione di manodopera.

Al fine di identificare il soggetto responsabile degli obblighi retributivi e protettivi discendenti dal contratto di lavoro è fondamentale esaminare le vicende modificative che coinvolgono la parte datoriale.

A tale riguardo, **Sez. L, 27607/2024, Boghetich, Rv. 672701-01**, ha chiarito che, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2009, come novellato dall'art. 30 della l. n. 122 del 2016, in caso di subentro di un nuovo appaltatore dotato di una propria struttura organizzativa e operativa, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto non integra l'ipotesi di trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti dal subentrante è caratterizzato da profili di novità tali da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.

In tema di trasferimento di azienda, da parte di **Sez. L, 15740/2024, Panariello, Rv. 671275-01**, si è precisato che la revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa cedente, allo svolgimento dell'attività bancaria non incide sul requisito dell'autonomia del compendio aziendale, presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 2112 c.c., in quanto l'autorizzazione non è un bene immateriale, né un elemento costitutivo dell'attività economica organizzata, bensì l'esito della verifica preliminare sulla sussistenza di tutte le condizioni tecniche e finanziarie per l'esercizio, da parte di un determinato soggetto, dell'impresa bancaria, come tale insuscettibile di cessione.

Delle fattispecie di cambiamento dell'armatore della nave e dell'esercente il velivolo *ex artt. 343 e 917 c.n.*, si occupa **Sez. L, 10748/2024, Leone, Rv. 671016-01**, che specifica che in dette ipotesi non è configurabile un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., in quanto esse si riferiscono ad un singolo elemento dell'azienda (la nave e l'aeromobile) e ai contratti di arruolamento su navi e aeromobili determinati.

Questioni peculiari sono state invece affrontate, nell'ordine:

- da **Sez. L, 05316/2024, Patti, Rv. 670158-01**, la cui massima giova qui riportare: le prestazioni accessorie rese dalla società datrice di lavoro, *ex art. 2345 c.c.*, a favore di altra società, in

quanto socia della stessa, ed aventi contenuto omogeneo a quello delle prestazioni di lavoro rese dai dipendenti a favore della prima, non hanno rilevanza nei confronti dei lavoratori, in quanto essi sono terzi rispetto al rapporto societario, sicché tra la società datrice di lavoro e la s.p.a. è configurabile, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto di servizi; ne consegue che il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, *ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003*, per cui deve escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società: nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, pur avendo qualificato il rapporto tra le due società alla stregua di un appalto di servizi, aveva dichiarato improcedibile l'azione diretta intentata nei confronti della committente dai dipendenti della società posta in liquidazione coatta amministrativa;

- nonché da **Sez. L, 26881/2024, Cinque, Rv. 672596-01**, che - in relazione al contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in forza del quale il titolare dell'impresa cede la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altro soggetto, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest'ultimo - ha affermato che è applicabile il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione *ratione temporis* vigente, se dall'analisi del regolamento contrattuale, intesa a verificare l'interesse economico concreto che sorregge l'operazione, è possibile evincere un'ipotesi di decentramento e dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa.

Sulle problematiche inerenti al trasferimento d'azienda, **Sez. L, 11816/2024, Boghetich, Rv. 671011-01**, ha affermato che, in tema di trasferimento d'azienda, l'inosservanza dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 47 l. n. 428 del 1990 non determina l'invalidità della cessione, ma costituisce comportamento contrario agli obblighi di buona fede e correttezza, il cui inadempimento rileva come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 l. n. 300 del 1970; di conseguenza, la carenza o la falsità delle informazioni fornite non può essere fatta valere dai singoli lavoratori ma solo dalle organizzazioni sindacali, poiché è nell'interesse del sindacato a sviluppare la propria azione di tutela che è stata prevista la procedura di informazione e consultazione dettata dall'anzidetto articolo 47, il quale va interpretato in conformità alla distinzione tra i diritti dei lavoratori e quelli delle organizzazioni sindacali operata dalla Direttiva 2001/23/CE.

A margine di ciò, va anche ricordato che, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto aziendale o dall'uso aziendale in essere presso la cedente ed avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione, però, alcuna contrattazione di pari livello (**Sez. L, 10120/2024, Ponterio, Rv. 670692-01**).

Meritano menzione, a questo punto, tre pronunce intervenute sul tema sempre attuale del cd. "cambio appalto":

- secondo **Sez. L, 18114/2024, Michelini, Rv. 671856-01**, in ipotesi di cambio di gestione dell'appalto, con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, la cd. clausola sociale di cui all'art. 16-*bis* del c.c.n.l. del 20 luglio 2012 sulla mobilità dei lavoratori occupati nelle attività ferroviarie consente all'appaltatore subentrante di assumere solamente una quota del personale già impiegato nel servizio appaltato, in ragione delle ridotte necessità di servizio, a condizione che siano rispettati specifici vincoli procedurali, a garanzia dell'adozione di criteri di selezione trasparenti e riguardanti l'intera platea dei lavoratori già impiegati;

- per Sez. L, 24334/2024, Panariello, Rv. 672437-01, in tema di cambio di gestione dell'appalto e di applicazione della c.d. clausola sociale, gli artt. 331 e 335 del c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi del 20/2/2010 vanno interpretati nel senso che il requisito dell'iscrizione da almeno tre mesi nei libri paga e matricola dell'impresa uscente va verificato mediante il calcolo a ritroso a decorrere dal momento di effettivo e concreto subentro della nuova impresa nell'attività oggetto del contratto.

- Sez. L, 27140/2024, Rivero, Rv. 673538-01, ha affermato che l'indennità di preavviso ha natura, oltre che indennitaria, retributiva, ed è quindi soggetta al regime di responsabilità solidale che avvince committenti, appaltatori e subappaltatori, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003. Nella medesima pronuncia si statuisce altresì che, ai sensi dell'art. 2118, comma 2, c.c., il datore di lavoro è obbligato a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di risoluzione del rapporto non preceduta da un periodo di preavviso lavorato, sicché, nell'ipotesi di passaggio diretto alle dipendenze dell'impresa subentrante per cambio appalto, l'indennità è dovuta anche ai dipendenti di un'impresa di pulizie e multiservizi, mancando nella contrattazione collettiva di settore una previsione che ne escluda la corresponsione.

- Sez. L, 14712/2024, Panariello, Rv. 671215-02, ha precisato, poi, che alla cessione di ramo d'azienda, seguita da un appalto tra cedente e cessionario e successivamente dichiarata inefficace nei confronti del lavoratore, sono inapplicabili, anche in via analogica, le norme dettate per l'appalto dichiarato illecito, cosicché i pagamenti effettuati dal cessionario ai lavoratori ceduti non hanno effetto liberatorio nei confronti del cedente per le retribuzioni loro dovute.

In tema di interposizione fittizia, si deve, invece, a Sez. L, 19042/2024, Ponterio, Rv. 671922-01, l'affermazione che l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (*recte*, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronuncia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale. In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la messa in mora contenuta nell'atto introduttivo del giudizio.

In ambito affine, si deve ricordare anche che, secondo Sez. L, 10005/2024, Cinque, Rv. 670688-01, in caso di intermediazione vietata di manodopera, la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 va effettuata senza detrazione dell'*aliunde perceptum*, in applicazione sia del criterio ermeneutico letterale, considerato che la decurtazione non è prevista dalla norma citata, sia di quello teleologico, stante la sovrapponibilità della formulazione dell'art. 39 con quella del risarcimento forfettizzato di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.

Sempre in materia di dissociazione fra datore di lavoro formale e sostanziale, due importanti principi di diritto sono enunziati da Sez. L, 11901/2024, Panariello, Rv. 671013-01 e Rv. 671013-02:

- in caso di distacco illecito, il termine di decadenza previsto dall'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, a cui è soggetta la domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro e va individuato, per il distacco a tempo determinato, nella data di scadenza del termine (eventualmente prorogato) stabilito dal distaccante e, per il distacco

a tempo indeterminato o adottato “di fatto”, nella data in cui è intervenuto un qualunque atto gestionale o provvedimento (del distaccatario o del distaccante), in forma scritta, che vi abbia posto fine;

- l'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 - il cui ambito applicativo comprendeva anche la somministrazione fino all'entrata in vigore dell'art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 - prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro.

Sez. L, 21204/2024, Rivero, Rv. 672097-01, quanto alla interposizione illecita di manodopera, ha infine statuito che l'interposizione illecita in un contratto di appalto determina l'instaurazione *ex lege* del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale e l'utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa, anche ai fini dell'efficacia di una polizza assicurativa privata da questi stipulata contro gli infortuni dei propri dipendenti che richieda, per la sua copertura, che il lavoratore infortunato sia addetto all'attività aziendale e che il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi assicurativi sociali, trovando applicazione anche per tale ipotesi gli artt. 29 e 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 e, attualmente, l'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015.

9. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore.

Sul delicato tema delle dimissioni, va senz'altro menzionata **Sez. L, 11236/2024, Rivero, Rv. 671005-01**, la quale ha precisato che le dimissioni della lavoratrice intervenute nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e l'anno dalla sua celebrazione, se non confermate entro un mese davanti alla direzione provinciale del lavoro, sono nulle ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2006, a prescindere dall'individuazione della parte interessata alla conferma o della stessa onerata e dalle ragioni dell'inerzia.

Per la vicinanza al tema qui all'attenzione si ricorda anche **Sez. L, 18263/2024, Ponterio, Rv. 672008-01**, giusta la quale la sospensione unilaterale del rapporto disposta dal datore di lavoro durante il periodo di preavviso per dimissioni può integrare un inadempimento di gravità tale da costituire giusta causa di recesso immediato del lavoratore, se - al di là dalla sua durata - è complessivamente realizzata con modalità tali da rendere impossibile, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che - conferendo rilievo preminente alla breve durata, di cinque giorni lavorativi, della sospensione - aveva escluso la legittimità del recesso immediato del dipendente, consigliere e amministratore delegato di una società di brokeraggio marittimo, sebbene il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione delle dimissioni con preavviso di sei mesi, avesse, contestualmente alla sospensione, ritirato computer, telefono, carte di credito e chiavi dell'ufficio, nonché disabilitato l'*account* di posta elettronica del lavoratore.

10. Le rinunzie e transazioni del lavoratore.

Si deve dar conto in questa sede delle decisioni intervenute sul tema in rubrica che non siano già state esposte nei precedenti paragrafi, perché collegate con i temi ivi trattati.

In generale, **Sez. L, 01975/2024, Panariello, Rv. 669776-01**, ha rimarcato che la sottoscrizione dell'accordo presso la sede di un sindacato, in conformità alle previsioni dell'art. 412-ter c.p.c. e del contratto collettivo applicabile, non costituisce un requisito formale, ma

funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato, con la conseguenza che la stipula in una sede diversa non produce alcun effetto invalidante sulla transazione se il datore di lavoro prova che il dipendente ha avuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte.

Sempre in tema di conciliazione **Sez. L, 10065/2024, Ponterio, Rv. 670870-01**, evidenzia che la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.

11. Il contratto di agenzia.

Il tema classico dei confini fra rapporto di agenzia e mero procacciamento di affari è stato ripercorso con ordinanza da **Sez. L, 23214/2024, Marchese, Rv. 672237-02**, cui si deve la sottolineatura che i caratteri distintivi del contratto di agenzia rispetto a quello del procacciamento di affari.

Caratteri distintivi del contratto di agenzia - evidenzia la S.C. - sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.

In tema di contratto di agenzia, poi, **Sez. L, 23331/2024, Rivero, Rv. 672142-01**, ha affermato che, poiché la naturale onerosità del patto di non concorrenza di cui all'art. 1751-bis c.c. è derogabile dalle parti, sono derogabili *a fortiori* le modalità di liquidazione e pagamento della relativa indennità, che può quindi anche essere erogata, come nel caso di specie, con compensi di natura provvigionale e con anticipi in corso di rapporto, salvo il conguaglio finale.

Un principio consolidato (cfr. ad es. **Sez. L, 10821/2011, Morcavallo, Rv. 617406-01**) è stato invece ribadito da **Sez. L, 23345/2024, Cinque, Rv. 672148-01**, che ha rimarcato che la proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente (nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza, ai fini della prova del diritto alla provvigione, della determina amministrativa di assegnazione al preponente dei lotti di fornitura di presidi medici, in difetto della prova dell'utilità ed essenzialità dell'attività prestata dall'agente e della successiva conclusione dei contratti ad essi relativi).

Quanto allo scioglimento del rapporto contrattuale, **Sez. L, 05281/2024, Ponterio, Rv. 670156-01**, ha affermato che in tema di cessazione del rapporto di agenzia per recesso dell'agente, non viola i canoni legali di ermeneutica contrattuale il giudice che interpreti una clausola del contratto, secondo cui la maturazione di un premio è sospensivamente condizionata ad una durata minima del rapporto ed alla sua mancata cessazione su ini-

ziativa dell'agente, facendo ricorso al criterio interpretativo sussidiario della conservazione degli effetti *ex art.* 1367 c.c., da intendersi nel senso che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni di una clausola contrattuale deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una o più di esse, evitando perciò, senza sostituirsi alla volontà delle parti, di adottare una soluzione che renda improduttiva di effetti la clausola stessa. Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione impugnata che, accertata la giusta causa del recesso dell'agente, aveva interpretato l'espressione adoperata nella clausola contrattuale "cessazione del contratto per sua iniziativa - per qualsiasi ragione o causa" come tale da presupporre una decisione o un atto libero e volontario e non coartato, sia pure indirettamente, dalla condotta illegittima del preponente, facendo leva su uno dei possibili significati del termine "iniziativa", compatibile con il suo significato letterale, respingendo così altra interpretazione che avrebbe condotto a ritenere la nullità della clausola per contrasto con l'art. 1355 c.c.

In tema di indennità suppletiva, da ultimo, **Sez. L, 12113/2024, Garri, Rv. 670929-01**, in relazione all'art. 12 dell'A.E.C. del 16 febbraio 2009, applicabile *ratione temporis*, ha stabilito che l'indennità suppletiva di clientela - emolumento previsto esclusivamente dalla disciplina collettiva (a partire dall'accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974, con previsione reiterata negli accordi successivi) - presuppone soltanto lo scioglimento del contratto ad iniziativa del mandante e per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, trattandosi di compenso che trova fondamento nel principio di equità, sicché per la sua erogazione non occorre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 1571, comma 1, c.c.

Sez. L, 28109/2024, Leone, Rv. 672602-01, ha del resto affermato che l'indennità meritocratica nel contratto di agenzia costituisce, ai sensi dell'art. 13 dell'AEC del 19 febbraio 2009, unitamente a quella di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela, uno dei tre emolumenti che compongono l'indennità di cessazione del rapporto, ne consegue che anche l'indennità meritocratica in applicazione della previsione di cui all'art. 1751 c.c. non è dovuta quando la risoluzione del contratto è provocata da un'inadempienza dell'agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.

CAPITOLO XXI

IL LICENZIAMENTO

(DI LUIGI DI PAOLA)

SOMMARIO: 1. Potere disciplinare. - 2. Licenziamento individuale: i rilevanti interventi della Corte costituzionale. - 2.1. Onere di comunicazione per iscritto. - 2.2. La rinnovazione del licenziamento e la violazione di *bis* in idem. - 2.3. La revoca del licenziamento. - 2.4. Licenziamento ritorsivo e discriminatorio. - 2.5. Giusta causa e giustificato motivo soggettivo di licenziamento. - 2.6. Giustificato motivo oggettivo di licenziamento. - 2.7. Periodo di comportamento e licenziamento. - 2.8. L'impugnazione del licenziamento e le decadenze. - 2.9. Il licenziamento ingiurioso. - 2.10. Applicazioni della legge "Fornero". - 2.11. Le conseguenze del licenziamento illegittimo. - 2.12. Il preavviso. - 2.13. Il licenziamento del dirigente. - 2.14. La risoluzione del rapporto nel lavoro nautico. - 3. Licenziamenti collettivi.

1. Potere disciplinare.

Con riguardo alla delicata tematica della possibile valenza disciplinare dell'esercizio del diritto di critica ad opera del lavoratore, **Sez. I, n. 23850/2024, Michelini, Rv. 672202-01**, ha affermato che il rappresentante sindacale, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trova su un piano paritetico con il datore di lavoro, in quanto l'attività sindacale, tutelata dall'art. 39 Cost. e diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori contrapposti a quelli del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo; ciononostante, l'esercizio da parte del lavoratore sindacalista del diritto di critica, anche aspra, garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., non si sottrae ai limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza di tutela della persona umana assicurata dall'art. 2 della Cost., sicché, qualora tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento assume rilevanza disciplinare.

In tema di illeciti disciplinari del dipendente di istituto di credito, costituisce condotta rilevante la violazione dell'obbligo di identificazione della clientela alla sua presenza fisica previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione applicabile *ratione temporis* (prima della novella di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 90 del 2017), né tale obbligo è derogato dall'art. 20 del medesimo d.lgs., il quale disciplina altri aspetti della valutazione del rischio che presuppongono la già compiuta identificazione del cliente (così **Sez. I, n. 23439/2024, Panariello, Rv. 672150-01**).

In tema di licenziamento disciplinare, l'assenza nella condotta contestata al lavoratore di effettive conseguenze pregiudizievoli per il datore o per terzi, ovvero di concreti vantaggi a favore proprio o di terzi, così come l'eventuale comportamento successivo volto ad eliderne gli effetti dannosi, non valgono di per sé - secondo **Sez. I, n. 23318/2024, Amendola F., Rv. 672196-01** - ad escludere la rilevanza disciplinare del fatto, potendo piuttosto concorrere, unitamente ad ogni altro fattore oggettivo e soggettivo palesato dal caso concreto, nella complessa valutazione giudiziale circa l'idoneità della condotta a giustificare la sanzione espulsiva.

Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, in ragione della ritenuta assenza di offensività, aveva escluso la rilevanza disciplinare di plurime condotte attuate in violazione delle disposizioni aziendali e dei diritti dei clienti da un direttore di filiale di un istituto di credito.

Sez. L, n. 26446/2024, Cinque, Rv. 672591-01, ha evidenziato che la previsione del c.c.n.l. che commina la sanzione espulsiva in caso di commissione di delitti ai sensi di legge non presuppone una pronuncia del giudice penale, la cui inesistenza non impedisce al giudice civile di accertare, *incidenter tantum* secondo la legge penale, la sussistenza del reato e la punibilità in concreto del fatto, anche con riferimento alla ricorrenza della provocazione *ex art. 599 c.p.* (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di annullamento del licenziamento di una lavoratrice che aveva pubblicato su *Facebook* frasi denigratorie della società datrice di lavoro, e del suo amministratore delegato, a breve distanza di tempo dall'avvenuta intossicazione di alcuni lavoratori, fra cui il proprio marito, per la fuoriuscita di sostanze nocive nei locali aziendali).

In tema di contestazione, **Sez. L, n. 14726/2024, Caso, Rv. 671309-01**, ha ribadito, sulla scorta di un orientamento consolidato, che, in tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione stessa va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici.

Nella specie, è stata ritenuta tardiva la contestazione disciplinare intervenuta oltre un anno dopo gli ultimi fatti addebitati al dipendente.

Inoltre, sempre in argomento, è stato puntualizzato - da **Sez. L, n. 00109/2024, Amendola F., Rv. 669691-01** - che il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza.

L'accertamento giudiziale dell'illegittimità o insussistenza di un addebito disciplinare priva la relativa contestazione di ogni effetto, sicché il datore di lavoro non potrà avvalersene per prorogare o sospendere unilateralmente i termini fissati dalla contrattazione collettiva (nella specie, dall'art. 33 CCSL del 7 luglio 2015 per le aziende appartenenti ai gruppi FCA e CNH e per i lavoratori da esse dipendenti) per l'irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione, nell'ambito di procedura in precedenza avviata e per la quale il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni non seguite tempestivamente da provvedimento disciplinare (così **Sez. L, n. 05485/2024, Michellini, Rv. 670159-01**).

In relazione alla questione dell'irrogazione della sanzione comminata oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva, **Sez. L, n. 15324/2024, Ponterio, Rv. 671226-01**, ha precisato che l'art. 227 c.c.n.l. del Terziario del 18/07/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve comunicare il relativo provvedimento conclusivo entro un termine la cui decorrenza, sebbene collegata alla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue difese, non può essere estesa sino al punto da ricomprendere adempimenti di mera natura formale o amministrativa, come la trasmissione da parte del dipendente dell'indice della documentazione già depositata in sede di audizione (nella specie, la S.C. ha affermato che la volontà dichiarata del lavoratore di far pervenire detto indice, senza far riserva di produrre documenti o deduzioni difensive ulteriori, non poteva consentire al datore di lavoro di comunicare il provvedimento conclusivo espulsivo dopo la scadenza del termine a tal fine stabilito dalla norma contrattuale).

Quanto alla questione dei limiti del sindacato di legittimità circa il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato devoluto al giudice di merito, **Sez. L,**

n. 00107/2024, Amendola F., Rv. 669701-01, ha precisato che il giudizio in questione, il quale implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia.

2. Licenziamento individuale: i rilevanti interventi della Corte costituzionale.

Il corrente anno ha fatto registrare molteplici interventi della Corte costituzionale in materia, con impatto significativo sulla disciplina riservata ai lavoratori “nuovi assunti” (per effetto del d.lgs. n. 23 del 2015, c.d. *Jobs Act*), a riprova della complessità dei vari istituti e della difficoltà di contemperare le sopravvenute esigenze ispiratrici delle scelte del legislatore con i vincoli di sistema, integrati, in particolare, dal principio di “ragionevolezza”, che ha giocato un ruolo significativo nell'opera correttiva esercitata dal Giudice delle leggi.

Va menzionata, in primo luogo, la sentenza del 22 febbraio 2024, n. 22, con la quale la Corte - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente» - ha determinato una riconduzione ad unità del regime del licenziamento nullo, il quale è, pertanto, lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l'espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata - che rechi, in modo espresso o no, un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti - salvo che la legge disponga diversamente.

La disciplina delineata dal legislatore, nell'area del *Jobs Act*, per l'ipotesi di licenziamento nullo viene, quindi, in rilievo, all'esito dell'intervento demolitivo, anche nella ricorrenza di casi di nullità “virtuale”, risultando, di conseguenza, la disciplina in questione sovrapponibile a quella contenuta nella cd. legge “Fornero” (riguardante i “vecchi assunti”), imperniata sul riconoscimento della tutela reintegratoria cd. “piena”, comportante il ripristino del rapporto di lavoro con attribuzione di una posta risarcitoria per il periodo intercorrente tra l'intimato licenziamento e l'effettiva reintegrazione.

Con la successiva sentenza del 16 luglio 2024, n. 128, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.

Per effetto di tale pronunzia, il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo per insussistenza del fatto posto a base del licenziamento determina l'operatività della tutela reintegratoria cd. “attenuata” (comportante il ripristino del rapporto con indennità risarcitoria fino ad un massimo di 12 mensilità), al pari di quanto previsto nell'ambito della legge “Fornero”; elemento di diversificazione è, quindi, attualmente costituito dalla tutela spettante nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di *repechage*, che, nel regime del *Jobs Act*, è meno robusta, in quanto integrata dal riconoscimento di una sola indennità, con esclusione della ricostituzione del rapporto di lavoro.

Infine, con la sentenza del 16 luglio 2024, n. 129, la Corte ha, tra l'altro, dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 39 Cost.

In particolare, il Giudice delle leggi, nel fornire una interpretazione "adeguatrice" del predetto articolo - il quale prevede la tutela reintegratoria attenuata per l'ipotesi di illegittimità del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo solo per insussistenza del fatto materiale - ha evidenziato che anche la non proporzionalità "convenzionale" (ovvero quella sancita dai contratti collettivi) conduce al riconoscimento di detta tutela - sul rilievo che una disposizione di legge che si sovrapponesse alla valutazione delle parti sociali circa la sproporzione del licenziamento comprimerebbe ingiustificatamente l'autonomia collettiva -, salva l'ipotesi in cui la contrattazione collettiva faccia riferimento alla proporzionalità con clausola generale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questa richiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o un giustificato motivo e ne definisce la nozione.

Infatti, secondo la Corte, rileva che la finalità della legge di delega è stata non già quella di sovrapporre la legge alla contrattazione collettiva, ma di contrastare una interpretazione di "sproporzione", a tal punto ampia da ritenere sufficiente che la contrattazione collettiva preveda genericamente che il licenziamento possa essere intimato per i fatti "più gravi", per comportare l'applicabilità della tutela reintegratoria.

All'esito di tale percorso argomentativo, solo un licenziamento intimato a fronte di una infrazione per la quale le parti sociali hanno previsto una sanzione conservativa mediante una "puntuale tipizzazione" potrà essere assistito dall'ingiustificatezza cui è correlata la tutela reintegratoria "attenuata".

Per il resto, non tutte le questioni, sul fronte giurisprudenziale, possono ritenersi definite, residuando, ancora, temi - in particolar modo quello della valenza, nell'ambito del sistema, del licenziamento disciplinare illegittimo per scarsa rilevanza del fatto contestato e di quello non tempestivo, in quanto intimato a lunga distanza di tempo dalla contestazione disciplinare, o, ancora, quello delle conseguenze sanzionatorie, nell'ambito del regime del *Jobs Act*, del licenziamento intimato per superamento del comportamento, ma prima dello spirare di questo - meritevoli, attesa la delicatezza delle questioni che vi si ricollegano, di un adeguato approfondimento.

2.1. Onere di comunicazione per iscritto.

Sez. L, n. 10734/2024, Caso, Rv. 670998-01, ha affermato che la comunicazione di licenziamento formulata nel verbale di chiusura della procedura prevista dall'art. 7 della l. n. 604 del 1966, che ha attestato il fallimento del tentativo di conciliazione imposto dalla norma, integra il requisito della forma scritta, purché siano osservate le ulteriori prescrizioni in tema di licenziamento, sicché non è necessario che la comunicazione scritta dello stesso intervenga successivamente, in contesto distinto dal verbale redatto in sede d'incontro davanti alla commissione di conciliazione.

2.2. La rinnovazione del licenziamento e la violazione di *bis in idem*.

Qualora un primo licenziamento, viziato per carenza di forma, sia seguito da un secondo non affetto da vizi formali, ma illegittimo per carenza di giusta causa, la tutela che il lavoratore può invocare per l'assenza del requisito formale è limitata alle retribuzioni relative al periodo compreso tra i due recessi e, qualora non sussista il requisito dimensionale di cui all'art. 18 st.lav., dall'illegittimità del secondo licenziamento deri-

vano unicamente gli effetti di cui alla l. n. 604 del 1966 (così Sez. L, n. 18552/2024, *Riverso*, Rv. 671916-01, conformemente a Sez. L, 03187/2017, Rv. 64308-01).

Sez. L, n. 08745/2024, *Tricomi I.*, Rv. 670677-01, ha precisato - in chiave generale, pur in relazione a vicenda in tema di pubblico impegno contrattualizzato - che l'esercizio del potere disciplinare con l'irrogazione di una sanzione conservativa non preclude la successiva adozione della sanzione espulsiva quando, pur a fronte di addebiti della medesima tipologia e natura, i fatti contestati sono tuttavia diversi perché attinenti a condotte tra loro autonome, non sussistendo in tal caso alcuna violazione del divieto di *bis in idem* sostanziale (nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente *part time* responsabile dell'ufficio condoni edilizi di un comune che, violando le disposizioni in materia di conflitto di interessi, aveva contemporaneamente curato per conto di privati pratiche di condono diverse e non collegate tra loro, in quanto attivate da distinti soggetti richiedenti e per distinte unità immobiliari, circostanze che erano state accertate in tempi diversi e con autonomi procedimenti disciplinari).

2.3. La revoca del licenziamento.

Con una rilevante pronunzia - Sez. L, n. 16630/2024, *Cinque*, Rv. 671306-01 - è stato chiarito che il termine ultimo - di giorni quindici dalla comunicazione dell'impugnativa di licenziamento - per la revoca del licenziamento (ai sensi dell'art. 18, comma 10, della l. n. 300 del 1970, introdotto dalla legge n. 92 del 2012) va individuato nel momento di invio della comunicazione al lavoratore e non in quello della sua acquisita conoscenza, perché l'atto di autotutela del datore costituisce esercizio di un diritto potestativo che produce in via immediata la modifica della sfera giuridica del destinatario.

2.4. Licenziamento ritorsivo e discriminatorio.

In relazione alla rilevanza della natura ritorsiva del licenziamento nell'ambito di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, Sez. L, n. 26238/2024, *Cavallari*, Rv. 672586-01, ha affermato che dalla stessa discende l'abusività, e quindi la nullità del licenziamento, con riferimento a ogni tipologia di contratto di lavoro subordinato, senza esclusione dei contratti a tempo determinato conclusi ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 267 del 2000, non rilevando l'eventuale loro particolare carattere fiduciario, da valutarsi peraltro tenendo conto della specifica attività e delle modalità di svolgimento (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva dichiarato la nullità del licenziamento di un dipendente, assunto *ex art.* 90 del d.lgs. n. 267 del 2000, intimatogli per aver partecipato, in una sola occasione e senza prendere parola, al congresso di un partito politico, condotta ritenuta invece legittima in quanto esercizio di una libertà costituzionalmente garantita).

Con una rilevante pronunzia - Sez. L, n. 18547/2024, *Riverso*, Rv. 672054-01 - è stato chiarito che il licenziamento motivato dall'esigenza di trasformazione del *part-time* in *full-time* o viceversa, illegittimo ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, si distingue dal licenziamento intimato a seguito di rifiuto del *part-time*, nullo perché volto ad eludere - per ritorsione ad un comportamento legittimo del lavoratore - il divieto stabilito da tale disposizione.

Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui la Corte d'appello, accertate l'insussistenza dell'addotta crisi aziendale e la contiguità temporale tra il rifiuto di trasformazione del contratto e la reazione del datore di lavoro, aveva ritenuto che il licenziamento, formalmente intimato per giustificato motivo oggettivo, dovesse considerarsi ritorsivo.

Sulla delicata questione dell'onere della prova circa l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo del licenziamento è stato puntualizzato - da **Sez. L, n. 17266/2024, Patti, Rv. 671589-01** - che detto onere grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni; a tal fine, in caso di licenziamento irrogato per condotta disciplinarmente rilevante in astratto, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito può avere rilievo presuntivo (tenuto conto anche della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva) della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa, fermo restando che tale fattore non è desumibile solo dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa.

In tema di atto espulsivo avente valenza discriminatoria, **Sez. L, n. 14307/2024, Amendola, Rv. 671209-01**, ha affermato che il licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni - se intimato in violazione dell'obbligo di adottare "accomodamenti ragionevoli" (sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003) e, quindi, in violazione di doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono ad una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori - realizza una discriminazione diretta ed è pertanto nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, commi 1 e 2, st.lav.

2.5. Giusta causa e giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

Nel corrente anno vanno segnalate varie pronunzie di indubbio rilievo, con le quali vengono, da un lato, maggiormente definiti determinati profili della locuzione normativa "giusta causa", e, dall'altro, precisata la portata disciplinare delle condotte cd. "extralavorative".

Quanto al primo aspetto, in conformità a **Sez. L, n. 24259/2016, Rv. 641708-01, Sez. L, n. 04458/2024, Amendola F., Rv. 670149-01** ha ribadito che le condotte costituenti reato, sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, possono integrare giusta causa di licenziamento, anche a prescindere da un'apposita previsione contrattuale, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza la relazione lavorativa.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato la rilevanza disciplinare di una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. non solo perché intervenuta prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo e per fatti molto risalenti, ma anche in ragione dell'assenza di qualsivoglia potere decisionale e gerarchico del dipendente.

Analogamente, **Sez. L, n. 08899/2024, Garri F., Rv. 670763-01**, ha affermato che, in tema di licenziamento per giusta causa, solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare *stricto iure* una responsabilità disciplinare del dipendente, diversamente non configurandosi neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà *ex* artt. 2104 e 2105 c.c. la cui violazione sia sanzionabile ai sensi dell'art. 2106 c.c.; tuttavia, condotte costituenti reato realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro possono, anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, integrare giusta causa di licenziamento purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto, e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi

sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che lo caratterizza. Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato per fatti molto risalenti, per i quali era intervenuta condanna irrevocabile addirittura prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo ed il datore di lavoro non aveva indicato specificamente la loro attuale incidenza negativa sulla concretezza del rapporto, limitandosi a prospettare un mero rischio ad essi connesso.

In una vicenda peculiare, **Sez. L, n. 12746/2024, Fedele, Rv. 670937-01**, ha chiarito che l'adozione, da parte di un docente, di reiterati comportamenti minacciosi ed aggressivi verso minori costituisce giusta causa di licenziamento, in quanto il metodo educativo non giustifica il compimento di atti anche solo potenzialmente lesivi dell'integrità psico-fisica dell'individuo e contrastanti con la centralità dei diritti inviolabili dell'uomo nel disegno costituzionale e con le finalità stesse dell'attività educativa, secondo gli *standard* valutativi dell'attuale coscienza sociale. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che - pur considerando antiquato e non condivisibile il metodo educativo della docente - aveva ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva irrogata ad un'insegnante della scuola elementare, che in sede penale era stata condannata per aver maltrattato gli alunni di 6-7 anni, sottoponendoli a ripetuti atti di violenza fisica e psicologica.

Ancora, **Sez. L, n. 18015/2024, Ponterio, Rv. 671849-01**, ha specificato che in tema di personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, integra una giusta causa di licenziamento, data la proporzionalità della sanzione espulsiva, la condotta del dipendente che consapevolmente riceve sul proprio conto pagamenti non dovuti di somme illecitamente sottratte all'amministrazione datrice di lavoro, così commettendo un atto doloso che, a prescindere dai profili di rilevanza penale, integra l'illecito disciplinare tipizzato dall'art. 56, comma 6, lett. d), del c.c.n.l. AFAM. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto del ricorso di una lavoratrice, dipendente di un istituto musicale, licenziata per avere trattenuto consapevolmente - come desumibile dalla circostanza che le somme accreditate sul suo conto corrente nel volgere di un anno e otto mesi superavano l'ammontare dello stipendio corrisposto in un anno - importi non giustificati da provvedimenti motivati, né risultanti dalle buste-paga.

Quanto al secondo aspetto, **Sez. L, n. 00267/2024, De Marinis, Rv. 669703-01**, ha affermato, in perfetta linea con quanto stabilito da Sez. L, n. 28368/2021, Rv. 662522-01, che la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva. Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione operata dalla sentenza di merito di particolare gravità delle condotte poste in essere dal lavoratore - condannato per plurime condotte delittuose di acquisto, detenzione e trasporto a fini di cessione di sostanze stupefacenti - sul rilievo, da un lato, che tali condotte fossero significative di un suo inserimento in un ambiente criminale e, dall'altro lato, che esse, pur se in ambito extralavorativo, fossero state commesse da un dipendente di un'istituzione scolastica, l'Università, per sua natura deputata alla promozione della legalità ed i cui utenti, gli studenti, sono per lo più giovani, destinatari privilegiati dell'attività degli spacciatori, tanto più che trattavasi di dipendente addetto alla segreteria didattica e, dunque, a diretto contatto proprio con gli studenti.

2.6. Giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Negli ultimi anni, come è noto, la S.C. ha riconfigurato, a seguito di un acceso dibattito svoltosi in sede dottrinarie e non ignorato dalla giurisprudenza di merito, la fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nelle pronunzie indicate di seguito è possibile cogliere gli elementi basilari della fattispecie, integrata, da un lato, dalla effettività della scelta datoriale di promuovere il riassetto organizzativo cui è correlata la soppressione del posto di lavoro, e, dall'altro, dall'obbligo di *repêchage*.

Va in primo luogo segnalata **Sez. L, n. 02739/2024, Amendola F., Rv. 669861-01**, nella quale risulta affermato che, nell'ipotesi di soppressione delle mansioni in precedenza prevalentemente esercitate dal lavoratore, al fine di ritenere la possibilità di un utilizzo parziale del predetto lavoratore nella medesima posizione lavorativa, se del caso ridotta con l'adozione del regime di *part-time*, è necessario - affinché non si determini la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa, con indebita alterazione dell'organizzazione produttiva - che le mansioni residuali rivestano, nell'ambito del complesso dell'attività lavorativa svolta, una loro oggettiva autonomia, configurabile ove dette mansioni non risultino intimamente connesse con quelle (prevalenti) sopprese, oppure non abbiano un carattere occasionale, promiscuo e ancillare rispetto ai compiti di altri dipendenti.

Quanto all'obbligo di *repêchage*, **Sez. L, n. 10627/2024, Boghetich, Rv. 670872-01**, ha affermato, con una pronunzia che non fa registrare precedenti in termini, che lo stesso opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili, in concreto attribuibili al lavoratore, non incombendo, anche nella vigenza del novellato art. 2103 c.c., alcun obbligo sul datore di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato.

Analogo principio è stato espresso da **Sez. L, n. 17036/2024, Patti, Rv. 671585-01**, secondo cui l'obbligo datoriale di *repêchage*, anche ai sensi del novellato art. 2103, comma 2, c.c., è limitato alla ricollocazione in mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitano di una specifica formazione.

Sez. L, n. 18094/2024, Amendola F., Rv. 671854-01, ha rilevato che in tema di licenziamento di invalido assunto con il sistema del collocamento obbligatorio, il recesso datoriale per soppressione della posizione lavorativa conseguente a significative variazioni dell'organizzazione del lavoro è legittimo solo se preceduto dall'accertamento, ad opera della commissione integrata di cui all'art. 10, comma 3, della l. n. 68 del 1999, dell'impossibilità di riutilizzazione del lavoratore all'interno dell'azienda - eventualmente all'esito degli opportuni adattamenti - in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute.

Con una significativa pronunzia - **Sez. L, n. 30657/2024, Boghetich, Rv. 673117-01** - resa in tema di contratto di apprendistato professionalizzante, è stato affermato che nel contratto in questione, finalizzato all'acquisizione di una specifica qualificazione professionale, l'inidoneità fisica o psichica dell'apprendista rispetto alle mansioni afferenti a tale qualificazione legittima il datore di lavoro a recedere dal contratto, senza che possa configurarsi un obbligo di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, essendone vietata l'adibizione a mansioni diverse da quelle contrattualmente pattuite e finalizzate all'acquisizione delle specifiche competenze professionali.

Quanto agli oneri di allegazione e prova **Sez. L, n. 02739/2024, Amendola F., Rv. 669861-02**, ha riconfermato il principio - già enunciato da **Sez. L, n. 05592/2016, Rv. 639305-01** - secondo cui spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di *repêchage* del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.

Importante è il principio espresso da Sez. L, n. 19185/2024, Boghetich, Rv. 672003-01, secondo cui il blocco dei licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo previsto dall'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - che ha fondamento nell'esigenza di ordine pubblico di garantire la salvaguardia occupazionale in un particolare momento di emergenza ed evitare l'immediata perdita di capacità reddituale e l'impossibilità di reimpiego dei dipendenti, quale conseguenza generalizzata della pandemia da COVID-19 - è escluso solamente se, nel caso di subentro in un appalto di altra impresa aggiudicatrice, vi sia passaggio effettivo alle dipendenze del nuovo appaltatore e il lavoratore non opponga un rifiuto legittimo alla nuova assunzione.

2.7. Periodo di comportamento e licenziamento.

Molte le pronunzie di interesse intervenute nel corrente anno.

Sez. L, n. 12487/2024, Garri F., Rv. 670892-01, ha puntualizzato che in tema di computo del periodo di comportamento, quando lo stesso è fissato dal contratto collettivo in ventiquattro mesi - e non è possibile attribuire a tale previsione un significato convenzionale diverso da quello desumibile dal calendario comune - la durata di ciascun anno (dodici mesi) deve considerarsi pari a trecentosessantacinque giorni. Nella specie, la S.C. ha escluso che il comportamento fosse pari a trecentosessanta giorni - trenta giorni per ciascun mese moltiplicati per dodici -, non assumendo rilievo la clausola, pure presente nell'accordo collettivo, ma dettata per il diverso ambito retributivo, secondo cui la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile.

Sempre in tema di determinazione del periodo di comportamento, Sez. L, n. 15845/2024, Pontorio, Rv. 671278-01, ha affermato che in tema di malattia del lavoratore, l'art. 70 del c.c.n.l. Carta Industria del 30.11.2016 deve essere interpretato nel senso che i giorni di accesso al pronto soccorso sono esclusi dal computo nel periodo di comportamento.

La richiesta del lavoratore, anteriore alla scadenza del periodo di comportamento, di fruire dell'aspettativa senza stipendio di cui all'art. 51 del c.c.n.l. personale servizi di pulizia del 31 maggio 2011 determina il naturale prolungamento del comportamento oltre il previsto termine di dodici mesi, con la conseguenza che nessun licenziamento può essere validamente intimato in detto periodo (così Sez. L, n. 15568/2024, Panariello, Rv. 671271-01).

Sez. L, n. 24052/2024, Cinque, Rv. 672229-01, ha precisato che la contrattazione collettiva, per sottrarsi al rischio di trattamenti discriminatori a danno dei lavoratori con *handicap*, deve prendere in specifica considerazione la posizione di svantaggio del disabile, poiché non è sufficiente ad elidere detto rischio una disciplina negoziale che tiene conto solo del profilo oggettivo dell'astratta gravità o particolarità delle patologie senza valorizzare anche l'aspetto soggettivo della disabilità, in relazione al quale vanno adottati gli accorgimenti ragionevoli prescritti dalla direttiva 2000/78/CE e dall'art. 3, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 216 del 2006. (Il principio è stato affermato in relazione al c.c.n.l. Associazione nazionale strutture territoriali 2017-2019, che prevede l'esclusione dal computo del comportamento solo dei giorni di ricovero ospedaliero, dei *day hospital*, dei giorni di assenza per malattia dovuti a sclerosi multipla o connessi alla somministrazione di terapie salvavita, e non anche dei giorni di assenza per malattie, anche non gravi, ma cagionate dalla disabilità).

Quanto al profilo del licenziamento, è stato ribadito - sulla scia di SU, n. 12568/2018, Rv. 648651-01 - da Sez. L, n. 15604/2024, Michellini, Rv. 671273-01, che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze del lavoratore per malattia od infortunio, ma prima del superamento del periodo massimo di comportamento, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c., né la riconduzione alla categoria della nullità è impedita dalla collocazione di detta violazione fra quelle a regime reintegratorio attenuato

ex art. 18, comma 7, st.lav. (novellato dalla l. n. 92 del 2012), perché, anche in presenza del medesimo vizio di nullità, il legislatore può graduare diversamente il rimedio ripristinatorio in ragione di un giudizio di minore riprovazione; conseguentemente, la previsione del citato comma 7 è speciale rispetto a quella di cui al comma 1 dello stesso art. 18 st.lav., che disciplina le altre ipotesi di nullità previste dalla legge. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva qualificato come nullo il licenziamento intimato alla lavoratrice che - per evitare il superamento del periodo di comporto - aveva chiesto di fruire di un periodo di ferie, negato senza la sussistenza di ragioni obiettive di carattere organizzativo.

Con una rilevante pronunzia, **Sez. L, n. 14316/2024, Cinque, Rv. 671210-01**, ha chiarito che la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore - o la possibilità di conoscerlo secondo l'ordinaria diligenza - da parte del datore di lavoro fa sorgere l'onere datoriale - a cui non può corrispondere un comportamento ostruzionistico del lavoratore - di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l'eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli imposti dall'art. 3, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 216 del 2003, la cui adozione presuppone l'interlocuzione ed il confronto tra le parti, che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento *de quo*.

2.8. L'impugnazione del licenziamento e le decadenze.

In relazione al rilevante profilo della modalità di comunicazione dell'impugnazione del licenziamento, **Sez. L, n. 18529/2024, Rivero, Rv. 671925-01**, ha affermato che detta impugnazione, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966, può essere effettuata anche con l'invio di una PEC contenente un allegato file in "formato Word", non essendo necessario l'invio della copia informatica di un documento analogico ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, in quanto - in assenza di prescrizioni specifiche - il requisito dell'impugnazione per iscritto è soddisfatto da qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un atto scritto idoneo allo scopo e riferibile con certezza al lavoratore.

Il nuovo termine di decadenza per l'impugnativa dei licenziamenti connesso al deposito del ricorso giudiziale, introdotto dall'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, si applica, secondo **Sez. L, n. 28266/2024, Cinque, Rv. 672680-01**, anche ai licenziamenti intimati ed impugnati stragiudizialmente prima dell'entrata in vigore di tale modifica (24.11.2010), ma solo con decorrenza dal 31.12.2011, in ragione del differimento disposto dal comma 1-*bis* del citato art. 32, successivamente aggiunto dall'art. 2, comma 54, del d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011.

Il licenziamento intimato dall'appaltatore, datore di lavoro formale, non determina l'operatività della decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, con riguardo all'azione, volta alla costituzione o all'accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, essendo l'azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto (così **Sez. L, n. 06266/2024, Boghetich, Rv. 670416-01**).

Sez. L, n. 19740/2024, Pagetta, Rv. 671873-01, ha affermato che la mancata impugnativa dell'atto di recesso nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione, ex art. 6 l. n. 604 del 1966, determina il consolidamento dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro anche quando, in caso di trasferimento d'azienda, l'atto di risoluzione del rapporto sia intimato dal cedente, ma anteriormente alla produzione di effetti di tale trasferimento, dovendosi escludere che il predetto termine decorra dalla cessazione dell'efficacia del rapporto di lavoro.

Sempre in tema, **Sez. L, n. 17470/2024, Panariello, Rv. 671592-01**, ha rilevato che in ipotesi di licenziamento intimato dal cedente prima della cessione dell'azienda, la norma di garanzia di cui all'art. 2112 c.c. può trovare applicazione soltanto se c'è stata la dichiarazione di nullità del recesso datoriale o il suo annullamento, unici atti idonei a produrre effetti ripristinatori *ex tunc*, che presuppongono però l'osservanza da parte del lavoratore del termine di decadenza previsto per impugnare il licenziamento e quindi il tempestivo invio al cedente degli atti impeditivi della stessa.

2.9. Il licenziamento ingiurioso.

In conformità a **Sez. L, n. 23686/2015, Rv. 637788-01, Sez. L, n. 16064/2024, Michelini, Rv. 671436-01**, ha riaffermato che il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso. Nella specie, la S.C. ha negato che fosse ingiurioso il licenziamento intimato per fatti di reato per i quali il datore aveva anche sporto denuncia all'A.G., in assenza di prova circa l'utilizzo di modalità indebite di comunicazione ed attuazione del procedimento disciplinare.

2.10. Applicazioni della legge "Fornero".

Con una rilevante pronunzia - **Sez. L, n. 13491/2024, Boghetich, Rv. 671202-01** - è stato affermato che, in tema di licenziamento per superamento del comportamento, nel regime successivo all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, l'inadempimento dell'obbligo, previsto dal contratto collettivo, di comunicare al lavoratore l'imminente scadenza del periodo di comportamento determina l'illegittimità del licenziamento e l'applicazione del regime sanzionatorio della tutela reintegratoria c.d. debole, secondo l'espressa previsione dei commi 7 e 4 del novellato art. 18 della l. n. 300 del 1970.

In relazione al licenziamento disciplinare, **Sez. L, n. 17306/2024, Ponterio, Rv. 671590-01**, ha ribadito, allineandosi ad un orientamento che va consolidandosi, che in presenza di disposizioni del contratto collettivo che, anche attraverso clausole generali o elastiche, prevedono per la stessa infrazione l'applicazione di una sanzione conservativa e, nei casi di maggiore gravità, della sanzione espulsiva, il giudice di merito deve verificare la sussumibilità del fatto contestato nella previsione collettiva ed individuare gli specifici elementi, di cui dar conto in motivazione, atti ad integrare il dirimente requisito della maggiore gravità.

Quanto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, **Sez. L, n. 18075/2024, Cinque, Rv. 671852-01**, ha chiarito che all'esito della sentenza della Corte cost. n. 125 del 2022 l'accertamento del giudice che prelude all'applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, st.lav. ha ad oggetto la semplice insussistenza del fatto posto a base del recesso datoriale, non essendo più richiesta la verifica di manifesta inesistenza dei presupposti di legittimità dello stesso.

2.11. Le conseguenze del licenziamento illegittimo.

L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporre, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 c.c., salva la dimostrata impossibilità, la cui prova incombe sul datore di lavoro, dovuta a insussistenza di

posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti (così Sez. L, n. 18892/2024, **Riverso**, Rv. 671919-01, in conformità a Sez. L, n. 27844/2009, Rv. 610809-01).

Sez. L, n. 29876/2024, **Caso**, Rv. 673049-01, ha riaffermato - conformemente a Sez. L, n. 03787/2009, Rv. 606627-01 - che, in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore nell'ambito della cd. tutela reale, la retribuzione globale di fatto - a cui fa riferimento l'art. 18 st.lav., quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione - deve includere non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo ricollegato alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, una volta riconosciuto il carattere retributivo, mentre debbono escludersi i soli compensi aventi natura d'indennità o di rimborso spese. In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ricompreso nella retribuzione globale di fatto dovuta ad un assistente di volo anche la voce "rimborso diaria", prevista dalla contrattazione collettiva e sistematicamente indicata nelle buste paga, ma avente natura di mero rimborso delle spese di pernottamento e vitto.

Sez. L, n. 14301/2024, **Caso**, Rv. 671415-01, ha precisato che in ipotesi di nullità del licenziamento cui è applicabile l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, dalla indennità risarcitoria da esso prevista non va detratto l'*aliunde percipiendum*, al pari di quanto stabilito per i licenziamenti nulli dall'art. 18, comma 2, st.lav., più volte modificato, come pure non va detratto quanto percepito a titolo di prestazioni previdenziali, rilevando ai fini dell'*aliunde perceptum* solo i redditi conseguiti attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa.

Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, dichiarata la nullità del licenziamento per causa di matrimonio di una lavoratrice assunta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015, ha escluso la detraibilità dal risarcimento dovutole di quanto percepito a titolo di indennità per congedo di maternità e dell'*aliunde percipiendum*.

Rilevante principio è stato infine ribadito, sulla scorta di Sez. L, n. 16350/2017, Rv. 644863-01, da Sez. L, n. 02694/2024, **Buffa**, Rv. 669853-01, secondo cui, nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia *ex tunc*, poiché rileva la continuità giuridica di quest'ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell'incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro, con la conseguenza che la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia *ex tunc*, esponendo l'interessato all'azione di ripetizione a titolo d'indebito delle relative somme da parte del soggetto erogatore della pensione.

2.12. Il preavviso.

Sez. L, n. 03247/2024, **Riverso**, Rv. 670036-01, ha affermato che la tutela indennitaria-risarcitoria, sancita dall'art. 18, comma 5, st.lav., anche all'esito delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno quelle esigenze, proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione, né autorizzando la lettera e la ratio della disposizione un'opzione ermeneutica restrittiva.

2.13. Il licenziamento del dirigente.

In adesione ad un indirizzo consolidato, **Sez. L, n. 00269/2024, Patti, Rv. 669705-01**, ha ribadito che, in materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedurali dettate dall'art. 7, commi 2 e 3, della l. n. 300 del 1970, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se a base del recesso siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicché la loro violazione preclude le possibilità di valutare le condotte causative del recesso.

In tema di licenziamento individuale del dirigente d'azienda, la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di *repêchage* convenzionalmente assunto configura - secondo **Sez. L, n. 07342/2024, Rivero, Rv. 670450-01** - un inadempimento contrattuale che produce di per sé l'illegittimità del licenziamento, motivato dalla soppressione della posizione lavorativa, sotto il profilo della sua ingiustificatezza, ovvero della mancanza della necessaria giustificazione del recesso, senza che l'accertamento giudiziale sull'effettività di tale soppressione, parametrata sull'intero contesto aziendale e sull'esperienza professionale del lavoratore licenziato, possa comportare una valutazione di merito sulle scelte organizzative, sulle strategie aziendali e sulla professionalità dei dipendenti, lesiva delle prerogative datoriali ex art. 41 Cost.

2.14. La risoluzione del rapporto nel lavoro nautico.

In tema di lavoro nautico, lo sbarco del marittimo per avvicendamento, anche se seguito dalla comunicazione datoriale di cancellazione del lavoratore dal turno particolare, non costituisce necessariamente - secondo **Sez. L, n. 31332/2024, Rivero, Rv. 673119-01** - un atto di risoluzione del rapporto, in quanto il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi, con sospensione, negli intervalli, della prestazione lavorativa. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva ritenuto risolto il rapporto con la comunicazione di cancellazione dal turno particolare, conseguente al rifiuto del marittimo di presentarsi per l'iscrizione nello stesso.

3. Licenziamenti collettivi.

I temi di maggior rilievo affrontati nell'anno vertono, per lo più, sulle questioni dell'identificazione dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi, della esatta definizione degli oneri di procedura, nonché della determinazione della platea dei lavoratori da licenziare e della delimitazione dei criteri di scelta.

La disciplina dell'art. 4, commi 2-12 e 15-*bis*, della l. n. 223 del 1991, dettata per le ipotesi di eccedenza di personale, si applica - secondo **Sez. L, n. 20966/2024, Boghetich, Rv. 672007-01** - anche al caso di cessazione dell'attività aziendale, per il quale, tuttavia, a differenza di quanto previsto per i licenziamenti per riduzione di personale, non è necessario indicare nella prescritta comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali le misure alternative ai licenziamenti che si intendono adottare, essendo sufficiente esporre in modo chiaro le ragioni che sorreggono la decisione di cessare definitivamente e completamente l'attività aziendale e che impediscono l'adozione delle misure alternative.

Sez. L, n. 07695/2024, Caso, Rv. 670533-01, ha precisato che nel caso di trasformazione di enti creditizi pubblici (nella specie, Banco di Napoli) in società per azioni, non può essere esclusa, ex art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1990, l'applicabilità della disciplina sui licenziamenti di cui alla l. n. 223 del 1991, non sopravvivendo alla privatizzazione il regime di stabilità del rapporto di lavoro con un ente pubblico economico, posto che la salvezza dei diritti quesiti riguarda solo le posizioni soggettive già acquisite al patrimonio del prestatore sotto il profilo economico, e non riducibili a mere aspettative sotto il profilo giuridico.

L'art. 7, comma 4-bis, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008 - che esclude l'applicazione delle norme sui licenziamenti collettivi di cui all'art. 24 della l. n. 223 del 1991 ai lavoratori riassunti dall'impresa subentrante in caso di cambio appalto - non si applica, invece, alle ipotesi di subappalto, deponendo in tal senso la lettera e la *ratio* della disposizione, riferita esclusivamente al cambio di appalto e non al subappalto, nel quale non v'è, del resto, né una cessazione dell'appalto, né una sostituzione dell'appaltatore (così Sez. L, n. 26449/2024, *Riverso*, Rv. 672592-01).

Sez. L, n. 21102/2024, *Boghetich*, Rv. 672120-01, ha affermato che, in tema di licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili, l'esclusione dell'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi, prevista dall'art. 24, comma 4, della l. n. 223 del 1991, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente, purché tale fase sia conclusa tutta insieme, poiché se il suo esaurimento è invece graduale occorre comunque applicare le norme sul licenziamento collettivo, al fine di comparare tra loro i dipendenti con la stessa professionalità.

Con una significativa pronunzia - Sez. L, n. 21299/2024, *Michelini*, Rv. 672121-01 - è stato chiarito che le procedure di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori di cui alla Direttiva n. 98/59/CE si applicano anche per i dirigenti in tutti i casi di licenziamento collettivo, non rilevando a tal fine che esso sia stato disposto per riduzione del personale o all'esito di procedura di mobilità.

La sottoscrizione di un accordo sindacale ai sensi dell'art. 4, comma 12, della l. n. 223 del 1991, come integrato dall'art. 1, comma 45, della l. n. 92 del 2012, non ha, di per sé, efficacia sanante di eventuali vizi della procedura di riduzione del personale, occorrendo che le parti abbiano inteso procedere, negli effetti, a detta sanatoria (così Sez. L, n. 18215/2024, *Amendola F.*, Rv. 671858-02). Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'efficacia sanante di un accordo privo di ogni riferimento alla comunicazione e alla verifica congiunta delle ragioni per cui la platea dei lavoratori soggetti a licenziamento era stata limitata ad uno solo dei siti produttivi e le mansioni di tali lavoratori dovevano considerarsi infungibili rispetto a quelle degli altri dipendenti.

Sez. L, n. 18093/2024, *Cinque*, Rv. 671853-02, ha ribadito - in linea con Sez. L, n. 06296/2022, Rv. 664005-01 - che ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l'individuazione di quelli da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salva l'idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui era onere della datrice di lavoro dimostrare l'infungibilità delle mansioni di *supervisor direct sales* svolte in passato dalla lavoratrice licenziata rispetto a quelle di *district supervisor* di altri lavoratori non coinvolti dalla procedura di licenziamento collettivo.

In una vicenda particolare, **Sez. L, n. 24340/2024, Panariello, Rv. 672462-01**, ha puntualizzato che l'obbligo per le fondazioni lirico-sinfoniche, previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c) del d.l. n.91 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 112 del 2013, di provvedere alla razionalizzazione del personale artistico non comporta necessariamente un divieto di licenziamento, ma - con misura più elastica rispetto alla riduzione del personale tecnico-amministrativo, imposta dalla medesima disposizione in via esclusiva - consente il ricorso a vari strumenti, fra i quali pure il licenziamento collettivo, se l'unico idoneo a realizzare il risanamento del conto economico.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, dichiarativa della legittimità del licenziamento collettivo dell'intero corpo di ballo di una fondazione, soppresso a causa degli elevati costi, di produzione e del personale, superiori ai ricavi.

Sez. L, n. 10286/2024, Panariello, Rv. 671196-01 ha precisato che la presunzione relativa, *ex art. 35, comma 3, d.lgs. n. 198 del 2006*, di collegamento fra licenziamento e matrimonio opera anche in caso di licenziamento collettivo e le eccezioni al divieto di licenziamento a causa di matrimonio di cui al comma 5 della citata norma sono insuscetibili di interpretazione estensiva ed analogica, sicché non può ricondursi alla nozione di cessazione dell'attività aziendale (derogatoria rispetto al menzionato divieto) la cessazione di un solo reparto, ancorché autonomo.

CAPITOLO XXII

IL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO PRIVATIZZATO

(DI LUCA D'ADDARIO)

SOMMARIO: 1. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: introduzione. - 2. I principi generali. - 3. La costituzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego privatizzato. - 3.1. Il reclutamento mediante procedure concorsuali: regole ed eccezioni. Le progressioni di carriera. - 3.2. I contratti di lavoro flessibili. - 4. Retribuzione e altri trattamenti economici. - 5. Parità di trattamento - 6. Classificazione del personale: categorie qualifiche e mansioni. - 7. Mobilità. - 7.1. Comando e distacco. - 8. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. - 9. Illeciti disciplinari. - 9.1. Obblighi vaccinali Covid - 10. La cessazione del rapporto di lavoro. - 11. La dirigenza. - 12. Il personale scolastico. - 13. Le azioni di ripetizione del pagamento indebito.

1. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: introduzione.

Le pronunce rese dalla S.C. in materia di pubblico impiego privatizzato saranno esaminate seguendo lo sviluppo del rapporto lavorativo dal momento costitutivo alla sua cessazione, passando per i diritti retributivi, le diverse vicende modificative, la materia disciplinare.

Analogamente alla precedente rassegna annuale si è ritenuto necessario dedicare alla dirigenza ed al personale scolastico un paragrafo *ad hoc*, mentre in relazione alle pronunce in tema di giurisdizione nel pubblico impiego, si fa rinvio, al paragrafo 1 del Capitolo *Il processo previdenziale e del lavoro*.

2. I principi generali.

Nel corrente anno alcune pronunce si segnalano per l'affermazione di alcuni principi di ambito più generale.

Appare dotata di indubbia valenza generale Sez. I, n. 31853/2024, Zuliani, non massimata, la quale ha precisato come nel pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico dei dipendenti non può essere incrementato con compensi incentivanti previsti da un atto amministrativo, essendo interamente demandato alla legge e ai contratti collettivi.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato sul punto il ricorso di alcuni medici dipendenti di un'azienda sanitaria, i quali nei gradi di merito avevano preteso la corrispondenza di emolumenti aggiuntivi invocando unicamente un decreto del Ministro della Sanità.

Appare parimenti significativa anche Sez. I, n. 5744/2024, Cavallari, Rv. 670327-01, con la quale la S.C. ha precisato che in ipotesi di ritardato pagamento di somme di natura risarcitoria ai dipendenti pubblici, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati, a prescindere dalla loro cumulabilità, sugli importi dovuti al netto delle ritenute di legge.

Sez. I, n. 30577/2024, Bellè, Rv. 672941-01, ha affermato che ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni di cui all'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per effetto del richiamo da esso fatto ad altre disposizioni di legge, rileva il requisito dell'incensurabilità della condotta, il quale costituisce un parametro dirimente per l'accesso ad impieghi per i quali è maggiormente sentita l'esigenza di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che devono contraddistinguere le corrispondenti funzioni, ed esprime un giudizio che prescinde dalla commissione di reati, attenendo più in generale alle modalità di comportamento nell'ambito della collettività.

Con la stessa pronuncia sia è inoltre precisato che in tema di assunzione nelle amministrazioni di cui all'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che esercitano competenze istituzionali in materia di polizia e di difesa e sicurezza dello Stato, i requisiti riguardanti le qualità morali e di condotta, afferendo ai rigorosi presupposti comportamentali e di onorabilità connessi alle funzioni svolte ed essendo suscettibili di mutare nel tempo, devono essere comunque posseduti nel momento in cui in concreto si procede all'assunzione, a prescindere dalla loro ricorrenza all'espletamento delle procedure a tal fine indette dalla P.A. (v. Sez. L, n. 30577/2024, Bellè, Rv. 672941-02).

Di valenza generale anche Sez. L, n. 31517/2024, Cavallari, Rv. 673152-01, la quale ha chiarito come in tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese a carico della P.A., incidendo sul costo del personale, sono nulle se adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa e la relativa invalidità va rilevata d'ufficio dal giudice, pure in appello e anche se non prospettata in primo grado o al momento dell'impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente, emergendo dalle prove ritualmente ammesse e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Sez. L, n. 29310/2024, Cavallari, Rv. 673019-01, in tema di *mobbing*, ha precisato che se il responsabile degli atti persecutori è esclusivamente un dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è configurabile un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto l'autore dei comportamenti illeciti è soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro; ne consegue la piena applicazione dello statuto degli illeciti aquiliani con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere della prova ed al regime della prescrizione.

Secondo Sez. L, n. 16036/2024, Di Paolantonio, Rv. 671435-03 nel pubblico impiego privatizzato, il contratto di solidarietà, intervenuto nel corso della procedura di riduzione dell'eccedenza di personale, è applicabile a tutti i dipendenti dell'ente, ma può disporre solo delle situazioni future, non potendo incidere retroattivamente sui diritti già sorti, né sanare i vizi degli atti adottati dal datore in assenza delle condizioni di legge.

La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità secondo Sez. L, n. 11622/2024, Rolfi, Rv. 671038-01, non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza *ex art.* 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun *metus* rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile.

Sez. L, n. 3504/2024, Bellè, Rv. 670039-01, in tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.

Sez. L, n. 23692/2024, Bellè, Rv. 672201-01, in tema di personale operaio assunto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 1 l. n. 124 del 1985, ha precisato che i rapporti di lavoro sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di diritto privato ed

integralmente sottoposti alla disciplina privatistica, sicché è ad essi inapplicabile la previsione dell'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 - e, dunque, inoperante l'effetto disapplicativo della normativa preesistente *ivi* regolato, in ragione della loro estraneità al tipico regime del pubblico impiego contrattualizzato.

Sempre in tema di ambito di applicabilità della disciplina del pubblico impiego, deve segnalarsi **Sez. L, n. 20226/2024, Di Paolantonio, Rv. 672006-01**, la quale ha evidenziato come, nonostante siano sottoposti alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato e salva un'espressa e specifica contraria previsione legislativa, non sono sottratti alle regole generali della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (che costituiscono principi fondamentali *ex art. 117 Cost.*) i rapporti di lavoro con un ente pubblico non economico (nella specie, quelli degli operai agricoli utilizzati dai consorzi di bonifica *ex art. 5 della l.r. Puglia n. 15 del 1994*), ai quali, pertanto, deve applicarsi l'art. 52 del citato d.lgs., secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento non comporta l'acquisizione della qualifica superiore, ma solo il diritto alle differenze retributive.

3. La costituzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego privatizzato.

Il reclutamento del personale avviene, di regola, secondo quanto stabilito dall'art. 97 Cost., mediante concorso pubblico e, almeno per far fronte al fabbisogno ordinario, implica la conclusione di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001).

La conclusione di contratti di lavoro flessibile costituisce una eccezione.

Nei prossimi paragrafi saranno anzitutto passate in rassegna le pronunce della S.C. relative alle procedure selettive, per poi esaminare le decisioni in materia di lavoro flessibile.

3.1. Il reclutamento mediante procedure concorsuali: regole ed eccezioni. Le progressioni di carriera.

Va innanzitutto segnalata **Sez. L, n. 25442/2024, Casciaro, Rv. 672470-01** con la quale, in tema di risarcimento del danno da perdita di *chance* conseguente a procedura concorsuale illegittima, si afferma che esso deriva dall'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno deve assumere connotati prossimi alla certezza, e non può essere quindi desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso.

In relazione alle società *in house*, a cui sia applicabile *ratione temporis* l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, **Sez. L, n. 00420/2024, Leone, Rv. 669693-01**, ha chiarito come il reclutamento del personale avviene con i divieti e le limitazioni previsti per le pubbliche amministrazioni, in applicazione dei criteri pubblicistici di trasparenza, oggettività e imparzialità stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché è inammissibile la conversione di un contratto di collaborazione a progetto illegittimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In tema di accesso al pubblico impiego, **Sez. L, n. 31215/2024, Bellè, Rv. 673150-01**, ha chiarito che sono ostative non solo le condanne penali previste espressamente come tali dalla normativa vigente, ma anche quelle che, a rapporto già esistente, comporterebbero il licenziamento senza preavviso secondo la contrattazione collettiva di riferimento, in questo caso previa valutazione in concreto, da parte della Pubblica Amministrazione, delle circostanze e del rilievo di tali condanne rispetto al rapporto da instaurare (tra cui, in via esemplificativa, distanza nel tempo dell'accaduto e/o concomitanza di altri precedenti e/o relazione tra posto perseguito e tipologia dei reati etc.).

In applicazione di tale principio è stata conseguentemente confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il diniego, da parte della Regione, all'avvio ad assunzione di un soggetto, utilmente collocato nelle graduatorie regionali per tecnico informatico e ragioniere, in ragione della sentenza di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.* per il reato di cui all'art. 3, comma 1, nn. 4 e 8, della L. n. 75 del 1958 e di altri precedenti penali, anche considerando la valutazione in concreto operata dalla Regione con riferimento alla gravità della condotta di cui al capo di imputazione per cui era stata irrogata condanna a due anni di reclusione, e alla vicinanza temporale di quest'ultima, con richiamo anche alla sussistenza di altri precedenti penali minori, circostanze tutte nel loro insieme ritenute tali da realizzare l'incompatibilità con l'assunzione al pubblico impiego.

Sez. L, n. 13957/2024, Tricomi, Rv. 667141-01, ha affermato che nel rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. la riammissione in servizio non dà luogo alla reviviscenza del rapporto di lavoro cessato, ma alla costituzione di uno nuovo, anche se disposizioni di legge - quali l'art. 132 d.P.R. n. 3 del 1957 - o di contratto collettivo, prevedono la riammissione nel ruolo precedentemente ricoperto oppure - come l'art. 115, comma 3, d.P.R. n. 417 del 1974 per il comparto scuola - l'attribuzione dell'anzianità pregressa. In tale occasione la S.C., in applicazione del predetto principio, ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a dipendente della scuola pubblica riammesso in servizio nel 2004, sei anni dopo le dimissioni, aveva escluso la reviviscenza del rapporto di lavoro cessato e applicato la disciplina inderogabile di cui all'art. 2, comma 5, l. n. 335 del 1995, che aveva superato il disposto dell'art. 4 d.P.R. n. 1032 del 1973 in materia di riliquidazione e supplemento dell'indennità di buonuscita.

In tema di procedure concorsuali nel pubblico impiego, **Sez. L, n. 28330/2024, Rolfi, Rv. 672681-01**, ha precisato che, il diniego o ritardo nell'assunzione del vincitore non trova legittima giustificazione nella presenza nel bando di una "clausola di riserva" che consente all'Amministrazione di non procedere comunque all'assunzione, attesa la nullità di tale clausola, attributiva di una mera facoltà discrezionale di annullare o revocare il bando, tale da realizzare un "*contrarius actus*" illegittimo - disapplicabile dal giudice ordinario - poiché privo dei necessari requisiti di forma e integrante una fattispecie di autotutela esercitata in carenza di potere, in virtù dell'insorgere del diritto del vincitore del concorso ad essere assunto e del correlato obbligo dell'Amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 c.c.

Con **Sez. L, n. 20501/2024, Caso, Rv. 672071-01**, si è precisato che, in tema di reclutamento del personale, ai fini dell'estensione alle società a partecipazione pubblica locale dei divieti e limitazioni per le assunzioni a carico delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile *ratione temporis* a seguito dell'introduzione nel citato art. 18 del comma 2-*bis*, rilevano anche le ipotesi in cui la partecipazione dell'ente locale sia svolta in chiave di controllo c.d. indiretto o di secondo grado.

Sez. L, n. 28395/2024, Rolfi, Rv. 672682-01, poi, ha puntualizzato che, in tema di divieto di assunzioni per fini di contenimento della spesa pubblica, la c.d. clausola di salvezza per le procedure concorsuali di cui al periodo conclusivo dell'art. 1, comma 4, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, non impone l'immediata assunzione dei vincitori di concorso, ma la subordina alla conclusione delle procedure di riduzione del personale preesistente ed al raggiungimento della *spending review*, essendo ogni diversa interpretazione della norma incompatibile con la sua finalità di blocco del *turn over*.

Significativa la pronuncia con la quale è stato affermato come in tema di prova di idoneità da parte della P.A. di candidati avviati al lavoro, la prova pratica, di cui all'art. 27 del

d.P.R. n. 487 del 1994, si contrappone a quella teorica, in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto; detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste (v. Sez. L, n. 05653/2024, Buconi, Rv. 670345-01; in senso conforme, v. Sez. L, n. 15223/2016, Di Paolantonio, Rv. 640871-01). In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il test somministrato come prova pratica, nell'ambito di una procedura di stabilizzazione di un LSU come collaboratore amministrativo dell'Ufficio Macchine Agricole - UMA - di un Comune, inadeguato a verificare le reali capacità operative del candidato, in quanto i quesiti attenevano a conoscenze teoriche generali sull'Amministrazione comunale, sulle competenze dell'UMA e sulle tipologie dei relativi atti.

Sez. L, n. 7068/2024, Cavallari, Rv. 670356-02, ha chiarito che, in tema di avviamento a selezione *ex art.* 16 della l. n. 56 del 1987, il diritto soggettivo all'assunzione del lavoratore, ancorché utilmente collocato in graduatoria, sorge all'esito del completamento del procedimento (cioè, dopo la valutazione positiva della prova di idoneità), ma per la costituzione del rapporto è necessaria la stipulazione del contratto e la specificazione dei relativi elementi essenziali; ne consegue che, dopo il completamento della prova, l'indebito annullamento o revoca degli atti della procedura, consente al lavoratore utilmente collocato in graduatoria di ottenere dal giudice, oltre alla condanna al risarcimento dei danni, la pronuncia *ex art.* 2932 c.c. di sentenza costitutiva del rapporto di lavoro con la P.A., sempreché, però, gli elementi essenziali del rapporto di lavoro (qualifica, mansioni e trattamento economico normativo) siano indicati dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Secondo Sez. L, n. 21721/2024, Cavallari, Rv. 672123-01, l'illegittimità, per contrarietà alle norme imperative sul contenimento della spesa pubblica per il personale, della procedura di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, di cui ai protocolli d'intesa conclusi ai sensi della l.r. Lazio n. 21 del 2002, comporta la nullità derivata del contratto di lavoro successivamente stipulato tra P.A. e lavoratore e, nel giudizio da questi instaurato per la prosecuzione del rapporto, il giudice può disapplicare il provvedimento di annullamento in autotutela adottato dalla P.A. solo ove ne ravvisi i vizi di illegittimità propri degli atti amministrativi, trovando altrimenti applicazione soltanto la tutela prevista per i rapporti di lavoro di fatto. In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando l'impugnata sentenza che aveva escluso venisse in rilievo un'ipotesi di licenziamento, profilandosi piuttosto una caducazione *ex tunc* del contratto di lavoro, in quanto affetto da nullità genetica per contrasto della procedura di stabilizzazione con norme imperative di legge.

Sez. L, n. 5309/2024, Rolfi, Rv. 670141-01, ha precisato che, in tema di assunzioni negli enti locali della Regione Sicilia mediante avviamento a selezione al lavoro, l'applicazione degli artt. 25 e 27 del d.P.R. n. 487 del 1994 - che prevedono l'obbligo di richiedere l'avviamento di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire - non è preclusa dalla competenza esclusiva regionale nella materia "ordinamento degli uffici e degli enti regionali" di cui all'art. 14, lettera p), dello Statuto di autonomia, in quanto la Regione stessa, con l'art. 1, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ha optato per un rinvio diretto alla disciplina nazionale sul reclutamento contenuta nel d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, e quindi, per via di tale rinvio "mobile", a quella di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, che all'art. 70, comma 13, richiama, in tema di assunzioni e nelle parti non incompatibili, il d.P.R. n. 487 del 1994.

Sez. L, n. 6335/2024, Tricomi, Rv. 670351-01, ha poi rimarcato come, in tema di procedimento elettorale presupposto per la nomina dei direttori delle accademie di belle arti, l'invalidità delle operazioni elettorali può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui l'atto è preordinato, mentre non può comportare l'annullamento delle predette operazioni la mera irregolarità, concernente i vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto, dovendo le regole formali contenute nella disciplina di settore considerarsi strumentali, in guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato elettorale finale.

Sez. L, n. 14732/2024, Fedele, Rv. 671216-01, precisa come in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta della P.A. di procedere a scorrimento di una graduatoria concorsuale, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, comporta la riattivazione della sequenza concorsuale, ma è soggetta alle condizioni di validità vigenti al momento di tale decisione e, quindi, anche allo *ius superveniens* costituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (nel testo *ratione temporis* applicabile), con la conseguenza che le limitazioni da esso introdotte, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ai concorsi riservati al personale interno non consentono più nemmeno lo scorrimento delle graduatorie relative a procedure per le progressioni verticali riservate interamente agli interni.

Sez. L, n. 05048/2024, Casciaro, Rv. 670163-01, ha chiarito che, in materia di rapporto di pubblico impiego privatizzato, dove la legge e la contrattazione collettiva predeterminano tutti gli elementi essenziali del contratto, come la qualifica, le mansioni, il trattamento economico e normativo e il periodo di prova, non sono ravvisabili ostacoli alla tutela costitutiva ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nel testo *ratione temporis* applicabile - invocata dal lavoratore, iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio e risultato idoneo al collocamento, dovendosi solo valutare, con accertamento di fatto riservato al giudice del merito, se siano o meno praticabili "ragionevoli accomodamenti", nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2000/78/CE, per rendere concretamente compatibile l'ambiente lavorativo con le limitazioni funzionali del lavoratore disabile

In tema di progressione in carriera deve segnalarsi innanzi tutto **Sez. L, n. 01674/2024, Tricomi, Rv. 670028-01**, la quale ha evidenziato come nel pubblico impiego contrattualizzato, le progressioni dei dipendenti tra aree funzionali, con novazione oggettiva del rapporto di lavoro, vanno equiparate alle nuove assunzioni, con la conseguenza che anche per esse è necessaria l'autorizzazione preventiva alla copertura dei posti in applicazione degli artt. 6, 35, comma 4, e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, non novellati *in parte qua* dal d.lgs. n. 150 del 2009.

Ancora in tema di progressione verticale, **Sez. L, n. 18385/2024, Buconi, Rv. 671863-01**, ha precisato come l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - nella parte in cui è previsto che "per, il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" - si applica anche alle progressioni verticali dei dipendenti all'interno della medesima P.A., disposte in seguito a concorsi interni che comportino l'inquadramento dei lavoratori in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro (pronuncia conforme a Sez. L, n. 34724/2023, Cavallari, Rv. 669563-01). In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso il diritto dei lavoratori a percepire, all'esito di procedura selettiva interna, gli adeguamenti stipendiali conseguenti all'attribuzione di un inquadramento

superiore e qualitativamente diverso dal precedente, con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto, ed aveva statuito che sull'originaria previsione contenuta nel bando del 24 luglio 2007 - secondo cui ai vincitori della selezione sarebbe stato corrisposto il trattamento economico della posizione retributiva conseguita, ai sensi della normativa vigente - aveva inciso lo *ius superveniens* costituito dal d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, sul presupposto che la normativa vigente al tempo del bando, salvo che il diritto sopravvenuto non disponga per il passato, non regola lo statuto giuridico ed economico del vincitore della procedura concorsuale, ma la procedura medesima.

In tema di stabilizzazione **Sez. L, n. 18745/2024, Gandini, Rv. 667216-01** ha chiarito come, ai sensi dell'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la P.A. che bandisce la procedura è presupposto indefettibile della stabilizzazione e non è surrogabile con l'ipotesi - non prevista - dello svolgimento di rapporti di lavoro con un'altra P.A., sia perché le ipotesi di stabilizzazione devono considerarsi tassative agli effetti dell'art. 97 Cost., sia perché, in caso di rilevanza del rapporto con altra P.A., resterebbe elusa la *ratio* principale dell'istituto, costituita dalla sanatoria del precariato tramite il consolidamento di esperienze lavorative pregresse.

Sempre in tema di stabilizzazione **Sez. L, n. 12871/2024, Fedele, Rv. 670938-01**, ha precisato che l'art. 3, comma 94, lett. b), della l. n. 244 del 2007 attribuisce il diritto all'assunzione a tempo indeterminato (c.d. stabilizzazione) ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, purché abbiano espletato prestazioni lavorative a tempo determinato per almeno un triennio, anche non continuativo, presso la medesima amministrazione - come desumibile dal rinvio che la disposizione innanzi citata opera all'art. 1, commi 529 e 560, della l. n. 296 del 2006 - e superato una prova selettiva, in conformità al principio costituzionale dell'accesso mediante concorso.

La successiva **Sez. L, n. 25237/2024, Zuliani, Rv. 672469-01**, ha chiarito come la stabilizzazione disciplinata dall'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, non è consentita in favore di dipendenti già in servizio a tempo indeterminato, dovendosi individuare la *ratio* della norma nella previsione di un regime speciale di reclutamento volto a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, che costituisce l'unica ragione di interesse pubblico che possa giustificare, nei casi tassativi individuati dal legislatore, un'assunzione in deroga al concorso pubblico, con esclusione di operazioni di mero reinquadramento migliorativo di soggetti già dipendenti della P.A. In applicazione, di tale principio la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che, in accoglimento dell'impugnazione della ASL, aveva rigettato la domanda del lavoratore - già dipendente dell'Azienda, sia pure con qualifica inferiore - di accertamento della nullità del contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso all'esito di una procedura di stabilizzazione.

Secondo **Sez. L, n. 18568/2024, Sarracino, Rv. 672067-01**, l'illegittima sospensione delle liste di mobilità, a cui consegue il mancato inserimento del lavoratore socialmente utile nel progetto che gli avrebbe consentito l'accesso alla procedura di stabilizzazione, determina un danno da perdita di *chance* pretensiva, che deve essere risarcito rapportando le somme non percepite alla probabilità statistica di verifica dell'occasione perduta. In applicazione di tale principio, la S.C., in parziale accoglimento del ricorso del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha cassato la sentenza della Corte d'appello che, riconoscendo alla lavoratrice tutte le somme dovute a titolo retributivo e contributivo, aveva liquidato il risarcimento del danno da mancata stabilizzazione, anziché da perdita della relativa *chance*.

Sez. L, n. 28579/2024, Rolfi, Rv. 672684-01, in relazione al tema del lavoro nel settore forestale, ha affermato che l'art. 44, comma 7, della l.r. Sicilia n. 14 del 2006 non attribuisce agli operai forestali a tempo determinato inclusi nell'elenco di cui all'art. 43-ter l.r. Sicilia

n. 16 del 1996 (introdotto dalla stessa l.r. Sicilia n. 14 del 2006) un diritto soggettivo pieno ed assoluto all'avviamento al lavoro per 78 giornate lavorative annue (in luogo del precedente regime di garanzia di 51 giornate), poiché detto avviamento resta condizionato alle effettive esigenze del settore, come desumibile dal tenore letterale della disposizione, che menziona un avviamento per 78 giornate lavorative solo "di norma" e che richiama il meccanismo di formazione dei contingenti di lavoratori disciplinato dalla l.r. Sicilia n. 16 del 1996, prevedendo che debbano essere innanzitutto salvaguardate le garanzie occupazionali dei lavoratori inclusi nelle fasce previste dalle lettere b e c dell'art. 46 di tale l.r., aventi diritto a 151 e 101 giornate lavorative.

Secondo **Sez. L, n. 6507/2024, De Marinis, Rv. 670354-01**, l'inquadramento del personale transitato a domanda, ex art. 4, comma 7, l. n. 36 del 2004, dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Sicilia deve essere operato, ai sensi della l.r. n. 9 del 2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base della disciplina all'epoca vigente, a prescindere dall'adozione di tabelle di equiparazione, utilizzando anche i criteri dettati dall'art. 5, l.r. n. 10 del 2000 e dai decreti presidenziali n. 9 e n. 10 del 22 giugno 2001, senza che rilevinò, al contrario, quelli indicati dalla l.r. n. 4 del 2007, entrata in vigore successivamente al realizzarsi delle condizioni richieste dalla legge nazionale e regionale per il transito anzidetto.

Sez. L, n. 5745/2024, Cavallari, Rv. 670328-01, ha precisato che il dipendente ex ITAL-TER e SIRAP, che abbia stipulato contratti a tempo determinato con la Regione Sicilia ai sensi dell'art. 76 della l.r. siciliana n. 25 del 1993 e dell'art. 23-quater del d.l. n. 6 del 1998, conv., con modif., dall'art. 1, comma 1, della l. n. 61 del 1998, non ha diritto a ricevere, con l'integrazione prevista dall'art. 48 della l.r. siciliana n. 21 del 2001, la parte fissa dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti regionali, in assenza di un atto formale di nomina a dirigente al quale si accompagni l'effettivo svolgimento dei relativi compiti con assunzione delle correlate responsabilità.

Con riferimento all'accesso al servizio nel settore scolastico si rinvia al successivo paragrafo 12.

3.2. I contratti di lavoro flessibili.

Nel pubblico impiego, la possibilità di far ricorso a contratti di lavoro flessibile è contemplata dai commi 2 e ss. dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, ma è circondata da molteplici cautele, allo scopo di contenerne gli abusi.

Qualora questi si verifichino, è peraltro noto come la violazione di disposizioni imperative in materia di assunzioni non possa giustificare l'immissione in ruolo, ma, di regola, solo il risarcimento del danno (comma 5).

Nel corrente anno sono intervenute, in materia, alcune pronunzie che hanno puntualizzato alcuni aspetti di significativo rilievo.

Rinviando al paragrafo n.12 per le pronunce rese nel settore scolastico, può in questa sede essere segnalata innanzi tutto **Sez. L, n. 10571/2024, Fedele, Rv. 670691-01**, la quale ha evidenziato come nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di successione di contratti a tempo determinato, trova applicazione il limite di trentasei mesi di durata complessiva, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l'assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici (si tratta di pronuncia conforme a **Sez. L, n. 6089/2021, Spena, Rv. 660963-01**).

Secondo **Sez. L, n. 15814/2024, Marotta, Rv. 671277-01**, in tema di pubblico impiego privatizzato, per i contratti a tempo determinato stipulati prima dell'adozione della direttiva 1999/70/CE è esclusa l'agevolazione probatoria accordata al lavoratore che agisce per il risarcimento del danno.

Sez. L, n. 16778/2024, Tricomi, Rv. 671885-01, ha chiarito che al rapporto di lavoro dei docenti civili assunti a termine dall'Amministrazione della Difesa per l'insegnamento presso le scuole militari di materie non militari si applica la disciplina in materia di risarcimento del danno presunto da precarizzazione conseguente alla successione illegittima o abusiva di contratti a termine, da liquidarsi ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 183 del 2010, in quanto, come affermato dalla CGUE con l'ordinanza 8 gennaio 2024 in causa C-278/23, anche tale rapporto rientra nell'ambito applicativo, da intendersi in senso ampio, dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70 CE, e le esigenze di organizzazione di dette scuole non sono idonee a costituire "ragioni obiettive" che giustificano il rinnovo di siffatti contratti con il personale incaricato dell'insegnamento di materie non militari ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), del medesimo Accordo quadro.

Secondo **Sez. L, n. 02992/2024, Zuliani, Rv. 666994-01**, nel lavoro pubblico contrattualizzato, la tutela del lavoratore precario, come sancita dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del relativo nesso causale, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per difetto di forma scritta, in quanto la mancanza di forma scritta realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale e a garanzia della certezza dell'assetto temporale del rapporto di lavoro a termine, funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

4. Retribuzione e altri trattamenti economici.

Le pronunce del corrente anno in tema di retribuzione e, più in generale, di compensi economici hanno riguardato numerosi aspetti specifici anche disciplinati da normative di settore.

Se, con riferimento al personale scolastico si rinvia al successivo paragrafo specificamente dedicato (v. paragrafo n.12), in questa sede merita di essere segnalata, **Sez. L, n. 17912/2024, Zuliani, Rv. 671599-01**, secondo la quale in tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.

Il tema della rilevanza dell'art. 2126 c.c. nei rapporti di impiego pubblico è altresì indagata in **Sez. L, n. 12868/2024, Buconi, Rv. 671184-01**, nella quale si afferma che la domanda di condanna della P.A. al pagamento delle retribuzioni dovute sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro regolare può condurre, allorché emerga la nullità del contratto o il suo contrasto con divieti inderogabili, alla condanna della parte datoriale *ex art. 2126 c.c.* in ragione della natura non risarcitoria, ma corrispettiva, della retribuzione prevista dalla citata norma, la quale può essere invocata a mezzo di una domanda proposta per la prima volta in grado di appello, ovvero anche essere posta d'ufficio a fondamento della decisione.

Sez. L, n. 26908/2024, Bellè, Rv. 672597-01, ha precisato che i compensi incentivanti, in quanto voci accessorie della retribuzione, non spettano al dipendente pubblico in distacco sindacale a tempo pieno, in applicazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs.

n. 165 del 2001 (disposizione di carattere imperativo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto), come riformulato dal d.lgs. n. 150 del 2009, secondo cui detti emolumenti sono erogati solo a fronte di prestazioni effettivamente rese in relazione al sinallagma contrattuale, nel cui alveo non ricade l'attività sindacale: perciò, devono considerarsi nulle tutte le contrastanti clausole pattizie, dovendosi anche escludere che la citata disposizione costituisca un impedimento all'esercizio della libertà di cui all'art. 39 Cost., in quanto l'impegno rispetto al raggiungimento di una *performance* costituisce ragione obiettiva per negare ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria detta voce della retribuzione.

In tema di indennità di servizio all'estero di cui agli artt. 170 e 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, per il personale dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri, **Sez. L, n. 19681/2024, Cavallari, Rv. 671882-02**, confermando un orientamento già espresso con Sez. L, n. 14112/2016, Di Paolantonio, Rv. 640465-01, ha chiarito che essa non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, sicché la stessa non concorre a determinare il danno patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente richiamato presso la sede centrale.

Secondo **Sez. L, n. 17806/2024, Marotta, Rv. 671598-01**, il diritto al beneficio dell'incremento retributivo (già previsto dall'art. 44 del r.d. n. 1290 del 1922) va riconosciuto ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici invalidi per servizio (ai quali è stato esteso dalla l. n. 474 del 1958 e dagli artt. 1 e 3 della l. n. 539 del 1950) anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. per gli enti pubblici non economici del 16/2/1999 e decorre dalla presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, che ne costituisce il necessario presupposto, in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 26 di detto c.c.n.l., nonché la stessa *ratio* del beneficio, che risiede nella maggiore gravosità del lavoro svolto dal dipendente affetto da invalidità, compensata con una maggiorazione retributiva poiché tale invalidità è conseguenza del rapporto d'ufficio.

Sez. L, n. 14127/2024, Sarracino, Rv. 671206-01, ha precisato che in ipotesi di rapporti di somministrazione di lavoro illegittimi, i lavoratori somministrati che hanno partecipato a specifici progetti realizzati dall'utilizzatore hanno diritto agli ulteriori emolumenti premiali aggiuntivi della retribuzione a tal fine previsti, per il personale dipendente dell'utilizzatore dalla contrattazione collettiva di riferimento, sebbene non in applicazione di quest'ultima ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 4, d.lgs. n. 276 del 2003, *ratione temporis* vigente, ma, stante l'abusività del ricorso alla somministrazione, in forza della norma di chiusura di cui all'art. 2126 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato.

Sez. L, n. 24545/2024, Zuliani, Rv. 672246-01, ha, poi, affermato che, ai sensi dell'art. 9 del c.c.n.l. integrativo del comparto della sanità pubblica del 20 settembre 2001, il dipendente che presta attività lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale ha diritto di scegliere se beneficiare del riposo compensativo o della maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, applicandosi, in caso di mancato esercizio della scelta nei termini fissati, la disciplina di cui all'art. 1287, comma 2, c.c., stante la natura alternativa della corrispondente obbligazione datoriale.

Sez. L, n. 18969/2024, Sarracino, Rv. 672002-01, in conformità con Sez. L, n. 18679/2015, D'Antonio, Rv. 637054-01, ha ricordato che in tema di personale sanitario, l'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l'indennità per l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia

ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale.

In tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, **Sez. L, n. 18962/2024, Cavallari, Rv. 671920-01**, ha poi affermato che le nuove tabelle di corrispondenza previste dall'art. 28 del c.c.n.l. del comparto universitario relativo al quadriennio 2002-2005 non si applicano, per effetto della clausola di salvaguardia di cui al comma 6 della medesima disposizione contrattuale, al personale già in servizio alla data di entrata in vigore del predetto c.c.n.l., con conseguente diritto alla conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche secondo le perequazioni in essere, ivi compresa l'indennità perequativa ("Indennità De Maria") *ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979*.

Numerose pronunzie si sono interessate, poi, delle questioni attinenti le indennità c.d. De Maria che attengono al tema generale della perequazione del personale universitario a quello delle aziende ospedaliere.

Sul punto si ricordano **Sez. L, n. 18963/2024, Cavallari, Rv. 672056-01**, che ha affermato che in tema di personale universitario non docente in servizio presso strutture del Servizio sanitario nazionale, che la domanda giudiziale volta al riconoscimento del diritto all'equiparazione economica al IX livello (dirigente amministrativo), ai fini della corresponsione dell'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cd. indennità De Maria), ha efficacia interruttiva della prescrizione in relazione a tutti i diritti derivanti da detto riconoscimento, *ivi* incluso quello al pagamento dei ratei dell'indennità medesima, senza che occorra che il titolare ne chieda la corresponsione nello stesso o in altro processo, e anche quando la relativa pretesa non possa essere avanzata nel giudizio pendente.

Del pari, in tema di personale dipendente universitario con qualifica non medica impiegato presso il servizio sanitario nazionale, **Sez. L, n. 5056/2024, Cavallari, Rv. 670238-01**, ha precisato che, qualora si controverta della indennità *ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979* (c.d. indennità De Maria), l'appello proposto tempestivamente o dall'azienda ospedaliera universitaria ove il lavoratore presta servizio o dall'università della quale egli è dipendente impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata anche nei confronti dell'altra P.A. che abbia presentato impugnazione incidentale tardiva, in ragione della natura unitaria dell'accertamento della particolare forma di cogestione che vede coinvolte le due pubbliche amministrazioni.

Alla medesima pronuncia si deve l'ulteriore massima, nella quale si è affermato che l'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. De Maria) deve essere determinata - in caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla legge n. 312 del 1980, relativo ai dipendenti dell'Università, e il X livello, relativo al personale ospedaliero - senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione (anche nella sua componente fissa) dei dirigenti del comparto sanità, la quale, essendo strettamente connessa allo svolgimento della loro funzione e all'attribuzione della connessa responsabilità, può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento del relativo incarico, non rilevando che la contrattazione collettiva nazionale successiva al c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 abbia incluso la "retribuzione di posizione minima - parte fissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata al menzionato c.c.n.l., secondo biennio economico 1996-1997" nel trattamento fondamentale di tali dirigenti (v. **Sez. L, n. 5056/2024, Cavallari, Rv. 670238-02**).

Sempre in tema di indennità *ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979*, **Sez. L, n. 5142/2024, Cavallari, Rv. 670154-01**, afferma che in tema di equiparazione tra le qualifiche del perso-

nale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, la corresponsione della predetta indennità perequativa di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cd. indennità De Maria) è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici che, a parità di funzioni, mansioni e anzianità, ed a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale 9 novembre 1982, senza che rilevino, finché detto decreto è rimasto in vigore, previsioni difformi contenute negli accordi di contrattazione integrativa.

In tema di diritto al compenso dei componenti del consiglio di amministrazione di un consorzio di enti locali per lo smaltimento dei rifiuti urbani, **Sez. L, n. 8754/2024, Bellè, Rv. 670678-02**, poi, ha affermato che esso deve ritenersi soppresso dall'art. 5, comma 7, ultimo periodo, d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, norma che non si applica soltanto ai titolari di cariche politiche ed è speciale rispetto all'art. 6, comma 3, del medesimo d.l., il quale prevede la mera riduzione del compenso, anche perché si enuncia il principio di gratuità dell'amministrazione delle forme associate di gestione di servizi e funzioni pubbliche da parte degli enti locali con l'obiettivo di ridurre gli oneri della finanza pubblica.

Secondo **Sez. L, n. 22368/2024, Zuliani, Rv. 672328-01**, la retribuzione contributiva - che costituisce base di calcolo dell'indennità premio di servizio dovuta agli avvocati dipendenti di enti locali, ai sensi art. 4 della l. n. 152 del 1968 - è formata dai soli emolumenti testualmente considerati dall'art. 11, comma 5, della medesima legge, la cui elencazione - in assenza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione - ha carattere tassativo; pertanto, gli importi ricevuti a titolo di riparto degli onorari relativi alle cause in cui il Comune, patrocinato da legali suoi dipendenti, è risultato vittorioso, sebbene assoggettati a contribuzione previdenziale, non vanno computati al fine della quantificazione di tale indennità, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione della base di calcolo dei diversi trattamenti di fine rapporto in modo da realizzarne l'equivalenza.

Vanno poi segnalate una serie di pronunzie che si occupano della retribuzione e più in generale dei trattamenti economici dei dipendenti del Ministero degli esteri.

Sez. L, n. 8680/2024, Fedele, Rv. 671195-01, ha affermato che il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche del Ministero degli Esteri ha diritto ad un adeguamento della retribuzione annua che non è rimesso discrezionalmente all'arbitrio della P.A. datrice di lavoro e che si configura non al solo mutare di uno (o più) dei parametri previsti per la sua determinazione dall'art. 157 del d.P.R. n. 18 del 1967, ma quando ricorre una loro variazione complessiva tale da far venir meno le connotazioni di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost., la cui valutazione giudiziale ha carattere officioso.

Sez. L, n. 28678/2024, Gnani, Rv. 672735-01, ha evidenziato, in relazione ai lavoratori italiani assunti a contratto presso gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri secondo le disposizioni di cui al titolo VI del d.P.R. n. 18 del 1967, che tale ultimo decreto e poi l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 103 del 2000, *ratione temporis* vigente, hanno sempre previsto il regime dell'imponibile contributivo fondato sulla retribuzione convenzionale, dettando una disciplina specifica che prevale e rende inapplicabile la regola generale del minimale contributivo, di cui all'art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, e che non è manifestamente in contrasto con l'art. 3 Cost. laddove stabilisce un trattamento differenziato rispetto ai lavoratori all'estero con retribuzioni inferiori al tetto convenzionale ed a quelli assoggettati al regime previdenziale previsto dalla normativa locale.

Quanto all'ambito del comparto delle Agenzie fiscali, **Sez. L, n. 4154/2024, Casciaro, Rv. 670047-01**, ha chiarito che l'avanzamento economico - connesso alla progressione orizzontale disciplinata dal c.c.n.l. del 28 maggio 2004, come integrato dal c.c.n.l. del 10 aprile 2008 - compete anche ai dipendenti in pensione alla data dell'approvazione della graduatoria, in quanto le parti collettive non hanno previsto la permanenza in servizio quale presupposto necessario ai fini della fruizione del beneficio economico, né detto requisito può dirsi immanente nelle finalità della progressione, corrispettive e premiali, oltre che incentivanti.

Per il personale dipendente dell'Anas trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *ex art. 36*, comma 5, d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, **Sez. L, n. 20955/2024, Di Paolantonio, Rv. 671946-01**, ha affermato che opera il principio di irriducibilità della retribuzione, il quale si applica anche con riferimento alle voci retributive del trattamento economico accessorio purché aventi carattere fisso e continuativo, senza che rilevi il fatto che tali voci esulano dal trattamento economico fondamentale.

Sez. L, n. 3998/2024, Caso, Rv. 670046-01, ha precisato, poi, che la fruizione di permessi retribuiti da parte dei lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche presso le Amministrazioni locali, ai sensi dell'art. 20 l.r. Sicilia n. 30 del 2000, deve essere funzionale all'espletamento del mandato ed adeguatamente giustificata, né a tali regole fanno eccezione i permessi orari di cui al comma 4 del citato art. 20, in relazione ai quali è consentito al datore di controllare che il godimento risponda alle causali autodichiarate dal lavoratore.

Va qui ricordata, in tema di qualificazione come orario di lavoro del tempo di vestizione e svestizione della divisa di lavoro per il personale operante nel comparto della sanità pubblica e del connesso obbligo retributivo, **Sez. L, n. 20784/2024, Bellè, Rv. 671924-01**, in cui si afferma che è irrilevante che il lavoro si svolga su turni o che il medesimo tempo si sommi ai tempi di passaggio delle consegne, necessari a garantire la continuità assistenziale.

Un gruppo di pronunzie dell'anno in corso hanno avuto ad oggetto gli emolumenti retributivi dovuti ai segretari comunali.

Sez. L, n. 02282/2024, Bellè, Rv. 669859-01, poi, ha chiarito che la retribuzione di posizione spettante al titolare di segreteria cd. in convenzione non deve essere calcolata sulla base della popolazione complessiva dei Comuni convenzionati, non trovando un tale criterio rispondenza nella contrattazione collettiva.

Sez. L, n. 02276/2024, Zuliani, Rv. 669865-01, ha precisato che in tema di retribuzione di posizione *ex art. 41* del c.c.n.l. del 2001 nell'ipotesi di conferimento di incarichi aggiuntivi, il diritto alla maggiorazione di cui al quarto comma del menzionato articolo non sorge per effetto del mero svolgimento delle mansioni relative a detti incarichi, essendo necessaria la decisione dell'ente locale di corrispondere la maggiorazione in questione, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa.

Sez. L, n. 30339/2024, Marotta, Rv. 672939-01, del pari in tema di trattamento economico dei segretari comunali, afferma che l'art. 1, comma 458, della l. n. 147 del 2013, che ha sancito l'abolizione del divieto di *reformatio in peius*, non si applica ai segretari in disponibilità nominati in enti di classe inferiore, per i quali vige la specifica previsione contrattuale di cui all'art. 43 del c.c.n.l. 16 maggio 2001, che riprende in toto l'art. 19, comma 7, del d.P.R. n. 465 del 1997, sicché il segretario comunale nominato presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione conserva il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio.

Secondo Sez. L, n. 31003/2024, Cavallari, Rv. 673149-01, il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali non include i diritti di rogito per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante, soppressi dall'art. 10, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, con la sola eccezione prevista dal comma 2-*bis*, le cui disposizioni sono state ritenute dalla Corte costituzionale - con la sentenza n. 200 del 2023 - non contrastanti con gli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost. e non sono manifestamente in contrasto con l'art. 39 Cost., avendo il citato art. 10, comma 1, soppresso, con atto avente forza di legge, un'eccezione al principio di onnicomprensività della retribuzione del trattamento economico dirigenziale ed allineato la normativa concernente i segretari a quella base dei pubblici dipendenti, considerato altresì che l'art. 37 del c.c.n.l. 16/05/2001, modificato dal c.c.n.l. del 2020, stabilisce che i diritti di rogito sono dovuti se spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge.

Sez. L, n. 15451/2024, Bellè, Rv. 671229-01, ha chiarito che, ai fini del rinnovo del contratto collettivo per gli anni 2006-2007, va escluso il diritto alla partecipazione al tavolo negoziale dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP), perché, essendo disciplinata l'attività lavorativa delle predette figure professionali nell'alveo del comparto Regioni ed Enti Locali, il predetto sindacato difetta della necessaria rappresentatività.

Quanto al trattamento economico del personale dell'ISPRA, Sez. L, n. 5583/2024, Rolfi, Rv. 670194-01, ha affermato che il richiamo complessivo all'art. 22 del d.P.R. n. 171 del 1991, operato dall'art. 10 del c.c.n.l. EPR 1994 - 1997 - che regola l'indennità di responsabilità professionale - deve intendersi riferito anche ai criteri di quantificazione contenuti in detta norma, e quindi al limite massimo di determinazione dell'indennità, pari al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale, in quanto si tratta di limite normativo che non prevede alcuna deroga.

In relazione alla disciplina del dottorato di ricerca, Sez. L, n. 14456/2024, Casciaro, Rv. 671212-01, ha evidenziato che nel caso di ammissione del pubblico dipendente a dottorato di ricerca, la disciplina previdenziale applicabile varia a seconda che egli fruisca o meno di borsa di studio, sicché nell'ipotesi di dottorato con borsa, nella quale il pubblico dipendente viene collocato in aspettativa senza retribuzione a carico dell'amministrazione di appartenenza, quest'ultima non è tenuta a contribuzione per tale periodo ed il dipendente deve provvedere autonomamente ad iscriversi alla gestione separata INPS e ad effettuare i versamenti contributivi per la quota a suo carico, ex art. 2 della legge n. 335 del 1995, ferma l'utilità dell'incarico ai fini della progressione di carriera, previdenziali e pensionistici.

Sullo stesso tema dei dottorati di ricerca anche Sez. L, n. 01066/2024, Fedele, Rv. 669771-01, secondo la quale il dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borsa di studio o rinunci alla stessa, non è tenuto alla restituzione delle somme percepite nell'ipotesi di dimissioni dall'amministrazione pubblica di provenienza nei due anni successivi al conseguimento del dottorato, poiché la modifica apportata dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 119 del 2011 all'art. 2, comma 1, della l. n. 476 del 1984 - con cui è stabilita la ripetizione di dette somme ove cessi il rapporto di lavoro o di impiego con "qualsiasi" amministrazione pubblica - assume valenza esplicativa di un significato già insito nella norma originaria, *ratione temporis* applicabile, la quale, deponendo nel senso che l'obbligo di restituzione era ricondotto all'ipotesi di dimissioni dall'amministrazione *tout court*, senza alcuna precisazione, evidenziava la *voluntas legis* di "trattenere" nel settore pubblico risorse qualificate, anche se in amministrazione differente da quella originaria, con l'effetto di collegare l'obbligo di restituzione solo all'ipotesi in cui l'interessato intendesse "disperdere" l'investimento pubblico passando al settore privato.

Sez. L, n. 31089/2024, Cerulo, Rv. 672946-01, esamina il tema della indennità di fine lavoro disciplinata dall'art. 2, comma 130, della l. n. 191 del 2009, prorogata per il 2012 dall'art. 6, comma 1, lettera c), del d.l. n. 216 del 2011, convertito con l. n. 14 del 2012: per un più compiuto esame della pronunzia si rinvia al paragrafo 10 dedicato al Tfr e ai trattamenti affini nel capitolo dedicato alla previdenza.

Quanto ai medici specializzandi, vanno di seguito evidenziati i seguenti approdi del giudice di legittimità, a partire dalle pronunzie delle Sezioni Unite della S.C.

È di significativo interesse **Sez. U, n. 26603/2024, Rossetti, Rv. 672395-01**, la quale, in relazione ai medici che, prima del 1991, avevano iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostrata l'equipollenza di fatto a quelle *ivi* previste, ha affermato che i medesimi non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre 1991.

Analogamente significativa **Sez. U, n. 20006/2024, Iannello, Rv. 671758-01**, la quale, in tema di importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006, ha chiarito che lo stesso non è soggetto né all'incremento annuale in relazione alla variazione del costo della vita né all'adeguamento triennale, previsti dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in virtù del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002.

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi **Sez. L, n. 2913/2024, Cavallari, Rv. 670034-01** ha precisato come il credito concernente la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale dell'importo della borsa di studio spettante *ex art. 6* del d. lgs. n. 257 del 1991, *ratione temporis* applicabile, è soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale, considerato che esso in assenza dei provvedimenti della P.A. che ne stabiliscano l'importo, non è né liquido né esigibile; che la mancata quantificazione, messa a disposizione e corresponsione delle relative somme costituisce inadempimento indiretto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea; che l'importo pagato non è assimilabile alla retribuzione dei pubblici impiegati, non rappresentando un corrispettivo dell'attività svolta.

Sez. L, n. 33596/2024, Casciaro, Rv. 673308-01, ha infine chiarito che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui all'art. 9, comma 1, della l. n. 150 del 2000, ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei c.c.n.l. relativi al triennio 2016-2018, risulta applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, può essere riconosciuta, in quanto destinatari del disposto dell'art. 1, comma 160, della l. n. 160 del 2019, la conservazione del corrispondente trattamento economico già in godimento, se più favorevole e a condizione della previsione, da parte dei predetti c.c.n.l., di un assegno personale riassorbibile.

Sez. L, n. 31350/2024, Sarracino, Rv. 672948-01, ha affermato che il termine per la presentazione delle domande di pagamento dei compensi aggiuntivi dei medici di medicina generale, di cui al punto 4 dell'Allegato D dell'A.C.N. del 2000, fissato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di espletamento delle prestazioni, ha natura meramente acceleratoria e non perentoria.

5. Parità di trattamento.

In tema di parità di trattamento retributivo di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, **Sez. L, n. 24574/2024, Zuliani, Rv. 672464-01**, ha chiarito come il predetto principio vieta differenziazioni, migliorative o peggiorative, a titolo individuale, ma non quelle effettuate dalla contrattazione collettiva, per le quali la disparità trova titolo in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, operanti a un livello istituzionalizzato e paritario sufficiente, salvo divieti di legge, a tutelare il lavoratore. In applicazione di tale principio, la S.C., in relazione all'accorpamento di unità amministrative assoggettate a distinti contratti collettivi integrativi, ha riconosciuto la legittimità delle differenze di trattamento economico accessorio che ne erano derivate, affermando che esse possono dar luogo a una responsabilità solo a titolo risarcitorio della P.A., in caso di suo colpevole ritardo nel provvedere, dopo l'accorpamento, a una nuova graduazione degli incarichi e quantificazione delle relative indennità.

Sez. L, n. 14914/2024, Rolfi, Rv. 671221-02, ha affermato che, per il personale alle dipendenze della P.A., il principio di parità di trattamento contrattuale di cui all'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, non opera nella comparazione tra personale civile e personale militare, poiché il trattamento economico del primo è regolato esclusivamente mediante contratti collettivi, mentre il personale militare risulta tuttora disciplinato da norme di esclusivo diritto pubblico, cosicché non può esservi una completa equiparazione fra personale civile e militare del Ministero della difesa.

Sez. L, n. 30784/2024, Cavallari, Rv. 672944-01, in tema di lavoratori assunti a tempo determinato dalla P.A. e successivamente stabilizzati, ha precisato che la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n. 99/70/CE, impone al datore di lavoro di assicurare loro la parità di trattamento con i dipendenti assunti *ab origine* a tempo indeterminato, anche nel caso di contratti a termine antecedenti all'entrata in vigore della direttiva, sempreché, come precisato dalla giurisprudenza della CGUE, tali contratti siano fatti valere in relazione ad un diritto maturato successivamente a tale momento.

Nella specie, la S.C. ha escluso che il diritto alla parità di trattamento potesse essere invocato da lavoratori assunti a termine prima dell'entrata in vigore della direttiva 99/70/CE per il riconoscimento di differenze retributive relative al servizio preruolo prestato fra il 1978 e il 1986.

Sez. L, n. 5738/2024, Buconi, Rv. 670346-01, ha affermato che l'art. 7 del d.l. n. 344 del 1990, conv., con modif., dalla l. n. 21 del 1991, ha inteso perequare i dipendenti che, alla data del 13 luglio 1980, rivestivano già la qualifica di direttore di sezione o equiparata e che erano stati inquadrati in base all'art. 1 della l. n. 254 del 1988, in sede di prima applicazione e con decorrenza dal 1 gennaio 1987, nella IX qualifica funzionale e coloro che avrebbero conseguito la medesima qualifica in un momento successivo, ma per concorsi indetti anteriormente al 13 luglio 1980. La norma ha, poi, previsto l'estensione del beneficio anche ai dipendenti che precedevano in ruolo i vincitori dei concorsi, ma entro il limite temporale del 31 dicembre 1990, ed ha natura temporanea, in quanto diretta a disciplinare situazioni maturate anteriormente a tale ultima data e non può essere applicata con effetti estensivi, non voluti e non previsti dal legislatore, a situazioni successive.

6. Classificazione del personale: categorie qualifiche e mansioni.

In relazione al tema dell'inquadramento del personale si registrano nell'anno in rassegna, alcune significative pronunce.

Sez. L, n. 01665/2024, Tricomi, Rv. 670027-01, ha chiarito che l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. (pronuncia che si pone nel solco di quanto già affermato dalla S.C. con Sez. L, n. 18817/2018, De Felice, Rv. 649878-01). In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'illegittimità dell'assegnazione ai dipendenti del MIBACT - assunti con il profilo di "assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza" - di mansioni di vigilanza e apertura e chiusura di sale, ambienti, bagni, rientranti nella stessa area di inquadramento del c.c.n.l. 2006-2009 del Comparto Ministeri.

Nello stesso senso anche **Sez. L, n. 26084/2024, Gandini, Rv. 672583-01**, la quale ha precisato che l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare le mansioni cui deve essere adibito il dipendente, assegna esclusivo rilievo al criterio della loro equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, sicché deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma, interpretata nel senso anzidetto, la quale, nel perseguire l'obiettivo della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane e del superamento dell'eccessiva parcellizzazione del sistema di classificazione previgente, non contrasta con il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa, né con il diritto a un lavoro "liberamente intrapreso" contemplato dalla Carta sociale europea, da intendersi come divieto del lavoro coattivo o forzato.

In relazione al diritto al pagamento delle differenze retributive quale conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori **Sez. L, n. 15677/2024, Sarracino, Rv. 671432-01**, con specifico riferimento alle mansioni di autista soccorritore, anziché di autista di Croce Rossa Italiana (C.R.I.), ha precisato che esso consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento, che, nella specie (e con riguardo ai contratti collettivi C.R.I. relativi agli anni 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009) si concretizzano nell'inserimento del solo autista soccorritore (che integra una professionalità che opera in campo medico) - non anche del mero autista - nel processo produttivo tipico dell'attività sanitaria.

Sez. L, n. 22958/2024, Zuliani, Rv. 672337-01, ha precisato che l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori - deve interpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore, ferma la nullità dell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza ed, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

Sez. L, n. 22603/2024, Bellè, Rv. 672333-01, in tema di lavoro universitario, ha statuito che le docenze a contratto - nel regime di cui all'art. 1, comma 32, della l. n. 549 del 1995, e poi del d.m. n. 22 del 1998 e dell'art. 23 della l. n. 240 del 2010 - sono tipici rapporti di lavoro autonomo, coordinato ed eventualmente continuativo, anche quando gli incarichi didattici, che possono comprendere non solo l'insegnamento ma anche le normali attività

ad esso accessorie (esami, assistenza alle tesi di laurea, partecipazioni a riunioni di Ateneo, tutoraggi inerenti alla materia), sono conferiti per l'insegnamento di discipline "ufficiali".

Sez. I, n. 15955/2024, Buconi, Rv. 671279-01, ha affermato che la connotazione intellettuale della prestazione resa da ricercatori e tecnologi e l'autonomia di cui dette figure professionali godono nello svolgimento dell'attività di ricerca comportano che l'eventuale natura subordinata del rapporto di lavoro (come configurato dal c.c.n.l. del comparto degli enti di ricerca relativo al quadriennio 1998-2001, applicabile *ratione temporis*) vada accertata non soltanto alla stregua del principale parametro normativo della soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ma, soprattutto, in base ad una valutazione globale e pregnante di tutti gli indici sussidiari, quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'individuazione di un monte orario settimanale (pur nell'autonoma determinazione del tempo lavoro), il pagamento a scadenze fisse di una retribuzione predeterminata, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo stabilito dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una struttura imprenditoriale.

Per le pronunce aventi a specifico oggetto la tematica delle mansioni nel settore scolastico si rinvia al paragrafo n. 12, ad esso appositamente dedicato.

Per la vicinanza agli argomenti trattati - che si pongono peraltro anche al confine con quelli esaminati nel paragrafo che segue in tema di mobilità - si ricorda qui anche **Sez. I, n. 33355/2024, Fedele, Rv. 673541-01**.

La pronunzia ha affermato che la continuità giuridica dei rapporti del personale già dipendente del soppresso ICE e distribuito tra il MISE e l'Agenzia ICE va invece esclusa - *ex art. 14, comma 22, del d.l. n. 98 del 2022, conv. con legge n. 111 del 2011, come modificato dal d.l. n. 201 del 2011, conv. con l. n. 214 del 2011* - quanto alla posizione del direttore generale, sicché nessuna successione può esservi dalla posizione di direttore generale dell'ICE a quella dell'Agenzia ICE, e ciò in quanto la nuova posizione apicale delineata dal legislatore e dallo statuto dell'ente è specifica e non assimilabile a quella degli altri direttori generali, vieppiù perché la nuova figura di vertice è chiamata ad interagire con la nuova compagine dell'Agenzia su base fiduciaria e per il perseguimento delle finalità istituzionali; conseguentemente il recesso anticipato intimato dall'Agenzia ICE al direttore generale dell'ICE, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, è legittimo.

7. Mobilità.

In tema di mobilità si registrano nell'anno in rassegna numerose pronunce significative.

Secondo **Sez. I, n. 20197/2024, Casciaro, Rv. 672005-01**, in caso di passaggio ad altra amministrazione a seguito delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, al dipendente transitato, pur in epoca successiva al 16 dicembre 2005, compete un assegno *ad personam* a garanzia del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di provenienza, non incidendo sul diritto alla percezione dell'integrazione stipendiale le modifiche apportate al citato art. 30 dall'art. 16, comma 1, lett. c), della l. n. 246 del 2005.

Sempre in tema di passaggio da una amministrazione ad un'altra *ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001*, **Sez. I, n. 13318/2024, Marotta, Rv. 671199-01**, ha precisato che al dipendente transitato si applica il trattamento giuridico ed accessorio previsto dai contratti collettivi del comparto di destinazione, non giustificandosi una disparità tra dipendenti dello stesso ente in ragione della provenienza, salvo che per gli assegni *ad personam*, attribuiti al fine di rispettare il divieto di *reformatio in peius*, riassorbibili in ragione degli incrementi del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell'amministrazione cessionaria, senza che il riconoscimento di voci di retribuzione accessoria previste solo presso l'Ammi-

nistrazione di destinazione (nella specie l'indennità di amministrazione) escluda il raffronto tra i due trattamenti economici di base ai fini della verifica dei presupposti per il riassorbimento.

Sez. L, n. 9370/2024, Zuliani, Rv. 670680-01, ha affermato che al dipendente trasferito dall'Agenzia del demanio al Ministero dell'Economia e Finanze, in virtù dell'esercizio del diritto di opzione di cui all' art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003, prima dell'introduzione del comma 2-*quinquies* nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, compete un assegno *ad personam* riassorbibile tutte le volte in cui il trattamento retributivo fondamentale e accessorio, fisso e continuativo, dovutogli dal Ministero risulti complessivamente inferiore a quello goduto presso l'Agenzia, senza che assuma rilievo che l'effettività del trasferimento sia successiva all'entrata in vigore del citato comma 2-*quinquies*.

Secondo **Sez. L, n. 19613/2024, Cavallari, Rv. 671872-01**, in caso di passaggio ad altra amministrazione in forza di procedura di mobilità volontaria *ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001*, se la P.A. di destinazione, in assenza di tabelle di equiparazione dei livelli, decide di utilizzare come parametro di riferimento per l'inquadramento dei dipendenti trasferiti lo stipendio tabellare già percepito presso la P.A. di provenienza, deve tener conto delle progressioni economiche conseguite alle dipendenze di quest'ultima, e non invece della retribuzione individuale di anzianità ivi maturata.

Sempre in tema di procedura di mobilità *ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001*, **Sez. L, n. 05749/2024, Cavallari, Rv. 670347-01**, ha precisato come la P.A. di appartenenza, una volta prestato il suo consenso al passaggio diretto del dipendente, non possa più revocarlo dopo che questo è giunto a conoscenza della P.A. di destinazione, trovando applicazione il disposto dell'art. 1328, comma 2, c.c., salvo che sia diversamente stabilito in maniera espressa dalla legge o dal bando o che, in presenza di sopravvenienze normative, la procedura anzidetta sia divenuta illegittima.

Sez. L, n. 5749/2024, Cavallari, Rv. 670347-02, ha poi puntualizzato come il dipendente pubblico che abbia preso parte ad una procedura di mobilità *ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001* e che, pur avendo superato la relativa selezione, non sia potuto transitare nella P.A. di destinazione a causa della revoca del consenso già validamente prestato dalla P.A. di appartenenza, avvenuta tardivamente ai sensi dell'art. 1328, comma 2, c.c., può agire contro quest'ultima per chiedere il risarcimento del danno da perdita della *chance* di beneficiare di un migliore trattamento economico, dovendo però dedurre e dimostrare che detta procedura avrebbe avuto esito positivo e che egli, alla luce dei titoli posseduti, avrebbe avuto concrete possibilità di ottenere tale migliore trattamento presso il nuovo datore di lavoro.

In relazione all'attribuzione della qualifica dirigenziale nel caso di passaggio diretto ad altra P.A. mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, **Sez. L, n. 25511/2024, Casciaro, Rv. 672526-01**, ha chiarito che non è sufficiente la mera corrispondenza di fatto tra le mansioni svolte nell'amministrazione di provenienza e quelle proprie del dirigente nell'ente *ad quem*, in quanto l'immissione nei ruoli dirigenziali della P.A. implica una novazione oggettiva del rapporto di impiego del tutto equiparata al reclutamento dall'esterno, sicché presuppone la partecipazione con esito vittorioso ad un'apposita procedura concorsuale, in applicazione dell'art. 97 Cost. e come previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.

In tale occasione, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato il ricorso di un dipendente, transitato all'ARPA Sicilia, che aveva fatto parte della "struttura dirigenziale" della Provincia autonoma di Bolzano, con profilo professionale di esperto in materie tecniche ascrivibile alla nona qualifica funzionale, e non aveva mai ricoperto un incarico dirigenziale ai sensi della l. p. Bolzano n. 10 del 1992.

Sez. L, n. 34058/2024, Gnani, Rv. 673314-01, ha precisato che in caso di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni, il regime giuridico del rapporto di lavoro e di quello previdenziale, ai sensi dell'art.30, comma 2-*quinques*, del d.lgs. n.165 del 2001, *ratione temporis* applicabile, è d'ufficio attratto, in via esclusiva ovverosia anche con riguardo al periodo pregresso al trasferimento, al trattamento previsto per l'ente di destinazione, dovendo ritenersi che l'opzione per la conservazione del regime previdenziale dell'ente di provenienza contemplata dall'art. 6 della l. n. 554 del 1988 opera solo in relazione ai trasferimenti attuati durante la sua vigenza dunque non oltre il 23.4.1998, mentre quella disciplinata dai d.P.c.m. del 26.6.2015 e del 30.11.2023 in attuazione dell'art.29-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 è applicabile solo in caso di mobilità non volontaria.

In relazione alla procedura di mobilità illegittimamente omessa **Sez. L, n. 21931/2024, Cavallari, Rv. 672135-01**, ha evidenziato come il dipendente interessato può chiedere il risarcimento del danno da perdita di *chance*, da liquidarsi tenendo conto - come parametri di riferimento di un giudizio equitativo e in proporzione alla consistenza della probabilità che la procedura avrebbe avuto esito positivo - delle perdite patrimoniali e del mancato guadagno correlati al non conseguimento del transito alla P.A. di destinazione, fra cui deve ricomprendersi anche la perdita dell'indennità di posizione eventualmente spettante presso tale P.A.

Secondo **Sez. L, n. 16036/2024, Di Paolantonio, Rv. 671435-01**, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve essere individuata dalla P.A. con specifico riferimento alla consistenza della dotazione organica degli uffici, tenendo conto dell'area e dei profili professionali del personale in esubero.

Nell'ambito della procedura disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, **Sez. L, n. 16036/2024, Di Paolantonio, Rv. 671435-02**, ha precisato come la ricollocazione totale o parziale del personale in sovrannumero o in eccedenza può essere ottenuta, pur in assenza di intervento della cassa integrazione guadagni, anche mediante il ricorso al contratto di solidarietà, in mancanza del quale il datore di lavoro non può unilateralmente disporre per tutto il personale la riduzione dell'orario e, conseguentemente, del trattamento retributivo.

Sez. L, n. 32773/2024, Cavallari, Rv. 673302-01, ha affermato che nel settore dei servizi idrici integrati, l'art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006 - quanto al personale appartenente alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, del settore idrico - ha previsto una fattispecie legale tipica di passaggio di attività, da ente pubblico a gestore privato, con trasferimento *ope legis* del personale, trasferimento immediato, diretto ed altresì necessitato, per il quale, conseguentemente, è irrilevante il consenso del lavoratore restando l'ente gestore vincolato al rispetto delle garanzie di continuità occupazionale del personale trasferito, con applicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, della disciplina del trasferimento del ramo d'azienda ex art. 2112 c.c.

Quanto al personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito in un ruolo ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente Tabacchi italiano e le società per azioni in cui quest'ultimo è stato trasformato ex art. 1, comma 6, d.lgs. n. 283 del 1998 (e che, in base al disposto del successivo art. 4 del medesimo d.lgs., sia stato dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni), secondo **Sez. L, n. 5092/2024, Cavallari, Rv. 670153-01**, esso non è equiparabile ai dipendenti di ruolo di detto Ministero, in ragione della specialità e della provvisorietà del ruolo di inquadramento, con la conseguenza che tale personale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, a decorrere dal 10 gennaio

2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali prestava servizio alla data di quest'ultimo d.l.

In tema di mobilità relativamente al personale nel settore scolastico si rinvia al paragrafo n. 12, ad esso appositamente dedicato.

7.1. Comando e distacco.

Nell'ambito della più ampia tematica della mobilità nel pubblico impiego, merita segnalare alcune pronunce dedicate all'istituto del comando ed a quello del distacco.

Sez. L, n. 1471/2024, Cavallari, Rv. 669941-04, ha precisato come, qualora, come nel caso previsto dall'art. 23- *bis*, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato d.lgs., dispongano, per singoli progetti di loro interesse specifico e con il consenso dei propri dipendenti interessati, l'assegnazione temporanea presso altri enti pubblici o imprese private in base ad intese tra le parti, ricorre un'ipotesi di comando, caratterizzata, rispetto alla figura generale, dal fatto di essere finalizzata alla realizzazione, quantomeno, di un interesse della comandante. In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che l'assegnazione di un dipendente da parte della datrice Enea alla Sogin S.p.A. - sulla base di una convenzione fra i due enti, stipulata per la messa in sicurezza, lo smantellamento e la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare di proprietà della medesima Enea - integra un'ipotesi di comando, caratterizzata, diversamente dalla regola generale, dall'esecuzione nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza.

Alla medesima pronuncia si deve l'ulteriore massima con la quale la S.C. ha affermato che l'istituto del comando, di natura straordinaria, ricorre quando il dipendente, titolare di un posto di ruolo presso una pubblica amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso differente amministrazione o diverso ente pubblico per esigenze esclusive delle organizzazioni di destinazione, determinandosi una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, cui consegue una modifica del c.d. "rapporto di servizio", in quanto il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (v. **Sez. L, n. 01471/2024, Cavallari, Rv. 669941-01**).

Il cd. "distacco di diritto pubblico" (da non confondere con il "distacco" disciplinato nell'ambito del lavoro privato), secondo **Sez. L, n. 01471/2024, Cavallari, Rv. 669941-02**, è configurabile nell'ipotesi in cui l'impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una P.A., è utilizzato in via temporanea presso un ufficio della medesima P.A. diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio, risultando così assegnato, a differenza delle ipotesi di comando, non ad un'Amministrazione distinta da quella di appartenenza, bensì ad un ufficio, diverso da quello in cui è formalmente incardinato, del medesimo ente datore di lavoro, al fine di soddisfare esigenze esclusivamente di quest'ultimo.

Gli oneri economici per le prestazioni rese da personale comandato, fuori ruolo o in altra analoga posizione, secondo **Sez. L, n. 01471/2024, Cavallari, Rv. 669941-03**, ai sensi dell'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, gravano sull'amministrazione di appartenenza, soggetto, quindi, passivamente legittimato nei relativi giudizi, anche se correlati allo svolgimento di mansioni superiori o ad ipotesi di demansionamento.

Sez. L, n. 04390/2024, Tricomi I., Rv. 670152-01, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione anche al personale in posizione di comando o distacco di voci di salario accessorio trova la sua disciplina nella contrattazione collettiva propria dell'ente

distaccante, in quanto il dipendente comandato o distaccato non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro originario non viene meno, né muta, per effetto del distacco o del comando, la sua regolamentazione a livello legale e contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che ad un dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri, comandato presso altra amministrazione del comparto ministeri, competesse l'indennità cd. di presidenza, voce del salario accessorio, in quanto l'art. 57 del c.c.n.l. P.C.M. del 17.5.2004 dispone che i trattamenti accessori sono a carico dell'amministrazione di destinazione.

Sez. L, n. 05086/2024, Buconi, Rv. 670415-01, ponendosi in conformità con quanto dalla S.C. precisato in Sez. L, n. 30875/2017, Di Paolantonio, Rv. 646562-02, ha chiarito che il dipendente cui sia stata accolta la domanda di mobilità in relazione ad una specifica vacanza nell'ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest'ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare, a passaggio già avvenuto, l'inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell'ente di destinazione con un superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive, non potendo essere alterato il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificate le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze delle PP.AA. mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all'art. 97 Cost.

8. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

Nell'anno corrente alcune significative pronunce hanno riguardato la tematica della incompatibilità.

Sez. L, n. 26928/2024, Zuliani, Rv. 672598-01, ha chiarito che in materia di pubblico impiego privatizzato, il regime delle incompatibilità contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha portata generale, senza distinzioni tra rapporti a tempo determinato e indeterminato, essendo oggetto di separata considerazione soltanto i rapporti a tempo parziale, di cui ai commi 1 e 6 dell'indicata disposizione, da contrapporre ai rapporti a tempo pieno. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la clausola di esclusività riferita al rapporto di pubblico impiego instaurato dal ricorrente, medico psichiatra, con l'ASP di Palermo, previa rinuncia, in virtù di tale esclusività, ad incarichi di lavoro a termine presso due istituti penitenziari.

Significativa la pronuncia resa da **Sez. L, n. 14896/2024, Sarracino, Rv. 671219-02**, la quale ha precisato come nel pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente a cui sia stata rilasciata, da parte di una società di gestione immobiliare, una procura speciale a tempo indeterminato, ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro, pena la violazione dell'art. 53, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 (che prevede l'autorizzazione dell'Amministrazione all'assunzione di incarichi extraistituzionali), al fine di escludere *ab origine* ipotesi di incompatibilità con il principio di esclusività di cui all'art. 98 Cost., senza che possa rilevare la gratuità dell'incarico conferito, poiché occorre in ogni caso verificare, attraverso l'autorizzazione, il rispetto di tale principio.

Si tratta di pronuncia nella quale la S.C. ha valorizzato, ai fini della necessità della preventiva comunicazione del rilascio della procura, l'ampiezza dei poteri gestori con essa conferiti, nonché la natura imprenditoriale dell'ente conferente.

Sez. L, n. 09801/2024, Tricomi I., Rv. 670684-01 ha chiarito che l'accettazione di una carica sociale, nella specie di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, se pur non ricade nelle ipotesi di incompatibilità assoluta di cui all'art. 60 del d.P.R.

n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall'art. 61 del medesimo decreto, costituisce un incarico extraistituzionale il cui svolgimento, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, necessita della preventiva autorizzazione datoriale *ex art.* 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, anche in caso di gratuità, tanto al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Quanto all'ipotesi di trasferimento d'ufficio anche per incompatibilità ambientale, di un componente r.s.u. ad altra sede di lavoro nell'ambito del personale dipendente dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, **Sez. L, n. 31654/2024, Zuliani, Rv. 31654/2024**, ha affermato che lo stesso, per non essere inficiato da presunzione di "antisindacalità", può essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, poiché le ragioni di incompatibilità addotte a giustificazione del provvedimento di trasferimento non possono condizionare l'applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all'espletamento dell'attività sindacale.

Secondo **Sez. L, n. 13490/2024, Di Paolantonio, Rv. 671187-01**, il rapporto di lavoro che si instaura fra l'università e i collaboratori esperti linguistici ha natura privatistica ed è pertanto sottratto all'obbligo di esclusività vigente nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, con la conseguenza che - in caso di violazione dello stesso - non si applica la disciplina della decadenza di cui agli artt. 60 e ss. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (richiamati dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001), fermo restando che il prestatore di lavoro è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

In caso di illegittimità del provvedimento di decadenza per lo svolgimento di attività incompatibili con il pubblico impiego, emesso ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, spetta al lavoratore, secondo **Sez. L, n. 16636/2024, Casciaro, Rv. 671307-01**, il risarcimento del danno, non essendo necessaria, a fini costitutivi del diritto, una formale offerta di prestazione lavorativa.

In relazione all'ambito di operatività della cancellazione dall'elenco dei vigili del fuoco volontari, in ragione dell'incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 76 del 2004, **Sez. L, n. 07366/2024, Cavallari, Rv. 670454-01**, ha chiarito che essa va disposta solo in caso di effettivo svolgimento delle attività espressamente indicate nella citata norma (amministratore di società o titolare di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio; titolare di istituto, ente, studio professionale che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio), restando escluso, in forza di interpretazione necessariamente restrittiva, che possano rilevare anche la potenziale idoneità dell'iscritto all'albo a eseguire lavori in materia antincendio o il semplice esercizio, da parte del medesimo, di un'attività professionale nel cui ambito di svolgimento potrebbero astrattamente rientrare tali lavori.

9. Illeciti disciplinari.

Numerose le pronunce rese, nel corrente anno, in tema di procedimento disciplinare, di illeciti e di sanzioni disciplinari e di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

In relazione alla disciplina del procedimento ed in particolare ai termini in esso previsti, **Sez. L, n. 1867/2024, Marotta, Rv. 669852-01**, ha precisato che la sospensione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale alle dipendenze della P.A. - disposta dall'art. 103, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente prorogata dall'art. 37, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23,

conv. con modif. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40 - si applica a tutti i termini indicati dall'articolo 55-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, *ivi* compresi quelli per la trasmissione all'ufficio procedimenti disciplinari e per la contestazione dell'addebito da parte di quest'ultimo, con la conseguenza che, ai fini della normativa emergenziale, la pendenza del procedimento va riferita al momento in cui è acquisita la notizia di infrazione.

Sez. L, n. 14896/2024, Sarracino, Rv. 671219-01, ha affermato che il termine perentorio di conclusione del medesimo procedimento previsto dall'art. 55-*bis*, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, *ratione temporis* applicabile, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi *ex ante*, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione. In applicazione del menzionato principio la S.C. ha affermato la corretta individuazione da parte del giudice d'appello della decorrenza di detto termine in corrispondenza del compimento non del primo atto istruttorio utile per la contestazione, ma di un ulteriore atto successivo idoneo, in astratto ed *ex ante*, non solo a colorare di maggior disvalore l'illecito contestato, ma anche a verificare ulteriori condotte connesse.

Sez. L, n. 15682/2024, Casciaro, Rv. 671274-01, ponendosi nel solco di quanto già precisato da Sez. L, n. 28928/2019, Bellè, Rv. 655701-01, ha precisato che i termini per lo svolgimento del procedimento disciplinare, così come la distribuzione della competenza tra il responsabile della struttura e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, si definiscono, ai sensi dell'art. 55-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base dei fatti indicati nell'atto di contestazione e delle sanzioni per essi astrattamente stabilite dalla contrattazione collettiva, che si individuano, qualora l'ipotesi rientri tra quelle espressamente enunciate dal c.c.n.l., nella misura massima edittale ovvero qualora si tratti di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della sanzione massima irrogabile (pronuncia conforme a Sez. L, n. 28928 del 2019, Rv. 655701-01).

Sempre in tema di decadenza dall'azione disciplinare ai sensi dell'art. 55 *bis*, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, *ratione temporis* applicabile, **Sez. L, n. 01164/2024, Zuliani, Rv. 669772-01**, ha affermato che la decorrenza del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare resta fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, essendo pertanto irrilevante, ai fini della decorrenza in questione, il tempo necessario al predetto responsabile per completare l'esame della documentazione ricevuta ed esprimere la propria valutazione in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti denunciati.

Quanto alla competenza, **Sez. L, n. 19097/2024, Zuliani, Rv. 671923-01**, ponendosi in linea di continuità con quanto già affermato da Sez. L, n. 30226/2019, Bellè, Rv. 655866-01, ha precisato che l'attribuzione della medesima al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare; la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - nel ritenere legittima la sanzione della sospensione dall'insegnamento per due giorni comminata ad un

docente dal Dirigente scolastico - non aveva tenuto conto dell'entità massima della sanzione applicabile all'illecito disciplinare contestato, ricondotto nella previsione di cui alla lett. b, del comma 2, dell'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994.

Sez. L, n. 26936/2024, Casciaro, Rv. 672599-01, ha chiarito che, ai sensi dell'art. 55-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile *ratione temporis*, il responsabile della struttura, se ritiene che la sanzione da irrogarsi sia più grave di quelle rientranti nella sua competenza, può - senza ritardi tali da rendere eccessivamente difficile il diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'addebito - trasmettere gli atti all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, che - reiterata la contestazione a norma del comma 4 della disposizione citata - deve concludere il procedimento entro centoventi giorni, comunque decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione da parte del responsabile della struttura dove il dipendente presta servizio.

Sullo stesso tema **Sez. L, n. 04280/2024, Bellè, Rv. 670049-01**, ha precisato che, qualora la condotta illecita del dirigente esterno già titolare del rapporto impiegatizio con il medesimo ente si sia protratta durante entrambi i rapporti lavorativi, competente per il procedimento disciplinare, in applicazione dell'art. 55-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, è l'UDP (ufficio procedimenti disciplinari) relativo alle figure dirigenziali, ferma restando la necessità di una conduzione, valutazione e definizione differenziata del procedimento, in relazione ai distinti rapporti impiegatizio e dirigenziale, qualora sia diversa la disciplina ed il catalogo degli illeciti e delle rispettive sanzioni.

Sempre in ottica di disciplina del procedimento disciplinare, **Sez. L, n. 05733/2024, Cavallari, Rv. 670239-01**, ha rimarcato come la partecipazione all'attività e alla decisione conclusiva dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di un componente che, in base alla vigente normativa, si sarebbe dovuto astenere, non rende nullo il provvedimento finale, ove siano stati garantiti la distinzione sul piano organizzativo di tale ufficio rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente e il diritto di difesa di quest'ultimo.

In relazione all'istituto del cd. *whistleblowing*, **Sez. L, n. 17715/2024, Marotta, Rv. 671596-01**, ha affermato come la normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, *ex art. 54-bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 *ratione temporis* applicabile (c.d. "*whistleblowing*"), non può essere estesa fino a comprendere improprie attività investigative poste in essere dal lavoratore, in violazione dei limiti di legge, per raccogliere prove di illeciti nell'ambiente di lavoro, né può riconoscersi efficacia scriminante alle segnalazioni effettuate per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori.

Ancora sullo stesso tema, **Sez. L, n. 09138/2024, Michellini, Rv. 671182-01**, ha precisato come la tutela disciplinare dell'informatore che segnala condotte illecite apprese in ragione del rapporto di lavoro, introdotta dalla direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 e dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della stessa, non è applicabile a fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Nella medesima pronunzia (**Sez. L, n. 09138/2024, Michellini, Rv. 671182-02**) si è precisato come in tema di segnalazione di condotte illecite ai sensi dell'art. 54-*bis* d.lgs. n. 165 del 2001 (*ratione temporis* applicabile), la comunicazione anonima ad organi di stampa dell'avvenuta denuncia all'Autorità nazionale anticorruzione di fatti oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio rientra nell'espressa previsione di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 179 del 2017 (*ratione temporis* applicabile), sicché la loro rivelazione con modalità eccedenti la finalità dell'eliminazione dell'illecito esclude il diritto alla protezione dell'informatore, secondo un bilanciamento di interessi da operare in concreto con il diritto alla libertà di espressione e di critica. Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito

che aveva affermato la fondatezza dell'addebito disciplinare mosso ad un lavoratore per avere reso disponibile ad un giornalista i contenuti di una denuncia, presentata in qualità di whistleblower all'Autorità nazionale anticorruzione, di fatti coperti da segreto aziendale, la cui rivelazione è stata accertata essere avvenuta al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto al fine dell'eliminazione dell'illecito oggetto di segnalazione.

Sempre nell'ambito delle sanzioni disciplinari, **Sez. L, n. 08745/2024, Tricomi I., Rv. 670677-01**, ha precisato che in tema di pubblico impegno contrattualizzato, l'esercizio del potere disciplinare con l'irrogazione di una sanzione conservativa non preclude la successiva adozione della sanzione espulsiva quando, pur a fronte di addebiti della medesima tipologia e natura, i fatti contestati sono tuttavia diversi perché attinenti a condotte tra loro autonome, non sussistendo in tal caso alcuna violazione del divieto di *bis in idem* sostanziale. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente *part time* responsabile dell'ufficio condoni edilizi di un comune che, violando le disposizioni in materia di conflitto di interessi, aveva contemporaneamente curato per conto di privati pratiche di condono diverse e non collegate tra loro, in quanto attivate da distinti soggetti richiedenti e per distinte unità immobiliari, circostanze che erano state accertate in tempi diversi e con autonomi procedimenti disciplinari.

Sez. L, n. 30535/2024, Fedele, Rv. 667295-01, in tema di contratti conclusi per il conferimento di incarichi per le supplenze del personale docente ed educativo della scuola pubblica, ha escluso la natura disciplinare e sanzionatoria della risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato determinata dalla violazione delle disposizioni inerenti all'inserimento nelle graduatorie istituite a tal fine, siccome conseguente alla accertata inosservanza di dette disposizioni, di modo che la successiva irrogazione nei confronti del titolare del contratto risolto di un licenziamento disciplinare, per gli stessi fatti già posti a base della cessazione del rapporto, non contrasta con il principio del *ne bis in idem*.

Alla stessa decisione si deve l'esplicazione del principio secondo il quale, ai fini della valida irrogazione del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, in ragione della peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. rispetto a quello privato, non è necessario, ai sensi dell'art. 55-*bis*, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nella versione *ratione temporis* applicabile), che l'azione disciplinare sia esercitata prima della risoluzione del rapporto di lavoro, perché anche in caso di successivo avvio del procedimento disciplinare perdura l'interesse dell'Amministrazione all'accertamento della responsabilità disciplinare, in ossequio ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (v. **Sez. L, n. 30535/2024, Fedele, Rv. 672952-02**).

Il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-*quater*, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo **Sez. L, n. 8956/2024, Zuliani, Rv. 670600-01**, presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro, omettendo la prestazione dovuta, in un giorno lavorativo e non in un giorno festivo, nel quale non aveva l'obbligo di recarvisi, restando irrilevante la mancanza di valida giustificazione dell'assenza dal servizio nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo.

Secondo **Sez. L, n. 30527/2024, Buconi, Rv. 673048-01**, l'art. 9 l. n. 19 del 1990 - per il quale il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale - deve intendersi riferito alla destituzione adottata quale conseguenza disciplinare della condanna, che necessita, in ogni caso, dell'esperimento del procedimento per l'adozione di sanzioni di carattere disciplinare, e non anche a quella conseguente all'applicazione di misure accessorie di carattere interdittivo, rispetto alle quali la cessazione del rapporto costituisce solo un effetto indiretto, per la fisiologica impossibilità di prosecuzione del rapporto.

Ne consegue che il suddetto intervento normativo non può ritenersi abrogativo dell'art. 85, lett. b), del d.P.R. n. 3 del 1957, atteso che tale norma si riferisce all'ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, che determina la cessazione del rapporto senza la necessità di un procedimento disciplinare, ed è pertanto immune - in conformità dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 286 del 1999 - da censure di legittimità costituzionale.

Secondo Sez. L, n. 21167/2024, Zuliani, Rv. 672075-01, ai fini del rimborso *ex art.* 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997, delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti nei giudizi promossi nei loro confronti per atti commessi nell'espletamento del servizio o nell'assolvimento degli obblighi istituzionali, è indispensabile il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, il quale è però soggetto al vaglio del giudice della causa intentata dal dipendente per ricevere un rimborso maggiore, per il necessario controllo del rispetto dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.

Sez. L, n. 29683/2024, De Marinis, Rv. 673061-01, ha precisato come, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - secondo cui la pubblica amministrazione datrice di lavoro può disporre la sospensione cautelare del dipendente - non contiene una specifica regolamentazione dei presupposti applicativi del provvedimento, che è destinato ad incidere significativamente nella sfera giuridica del lavoratore e, dunque, richiede la previsione di idonee garanzie; perciò, detti presupposti devono essere rinvenuti *aliunde* e, cioè, sia nelle norme speciali che prevedono ipotesi di sospensione obbligatoria, sia nella contrattazione collettiva, a cui l'art. 40 del citato d.lgs. rinvia per la disciplina di aspetti non regolati da specifiche norme di legge. In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia con cui la Corte d'appello aveva annullato il provvedimento di sospensione, in quanto emesso in assenza del previo rinvio a giudizio, previsto dalla contrattazione collettiva.

Sez. L, n. 989/2024, Zuliani, Rv. 669769-01, in tema di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale a carico del pubblico dipendente, ha chiarito come l'art. 27, comma 7, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995, il quale prevede il ripristino dell'obbligo retributivo solo "in caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena", si deve interpretare estensivamente nel senso che il lavoratore sospeso dal servizio in via cautelare ha diritto alla reintegrazione del trattamento economico *ivi* prevista in ogni caso in cui, terminato il processo penale, venga inflitta una sanzione disciplinare che non comporti la cessazione o la sospensione dal servizio, o che comporti una sospensione disciplinare di durata inferiore a quella cautelare, a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo della sospensione cautelare stessa, con la sola eccezione di quella resa necessaria dalla custodia cautelare in carcere o comunque da una misura cautelare personale che renda impossibile la prestazione del lavoratore.

Con riferimento ai professori e ricercatori universitari assegnati per l'esercizio di attività assistenziale alle aziende sanitarie, Sez. L, n. 30752/2024, Buconi, Rv. 672943-01, ha chiarito che il potere del direttore generale di queste di disporre la sospensione e l'allontanamento *ex art.* 5, comma 14, del d.lgs. n. 517 del 1999 non ha carattere disciplinare, ed è esercitato all'esito di un procedimento nel quale, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, devono essere assicurati al destinatario il diritto alla difesa ed al contraddittorio, in modo da consentirgli di conoscere l'iniziativa assunta dall'amministrazione, l'oggetto del provvedimento nonché l'organo investito dell'eventuale attività istruttoria.

9.1. Obblighi vaccinali Covid.

Con specifico riferimento al tema degli obblighi vaccinali si segnalano alcune pronunce.

Sez. L, n. 15697/2024, Bellè, Rv. 671433-01, in tema di obblighi vaccinali anti Covid-19, ha statuito che nella vigenza dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021, al lavoratore che rifiuta di sottoporsi alla somministrazione del vaccino, sospeso illegittimamente, per inottemperanza del datore all'obbligo di *repêchage*, compete il risarcimento del danno, che cessa dal 15 dicembre 2021, in conseguenza dell'abrogazione dell'obbligo datoriale di recupero del prestatore in altre mansioni, conseguente all'introduzione dell'art. 4-ter, commi 2, 3, 5, e 6, ad opera del d.l. n. 172 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 3 del 2022.

Sez. L, n. 12211/2024, Di Paolantonio, Rv. 670986-01, in tema di obbligo vaccinale anti Covid-19, ha precisato che il dipendente ASL il quale, illegittimamente sospeso dal servizio nella vigenza del testo originario dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, perché non ricompreso fra i destinatari dell'obbligo, sia stato successivamente incluso nella cerchia degli obbligati a seguito delle modifiche apportate alla normativa dal d.l. n. 172 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 3 del 2022, ha diritto al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni non corrispostegli, limitatamente al periodo precedente lo *ius superveniens*, il quale non può rendere retroattivamente legittima una sospensione che tale con era al momento della sua adozione, ma dispone, per il periodo successivo, la sopravvenuta irricevibilità della prestazione.

Sez. L, n. 31216/2024, Bellè, Rv. 673151-01, ha chiarito al riguardo come l'obbligo vaccinale previsto per il personale scolastico dall'art. 4-ter, lett. a), d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021, nella versione vigente *ratione temporis*, non viola l'art. 3 reg. CE n. 726 del 2004, poiché il vaccino contro l'infezione da SARS-CoV-2 è stato utilizzato per perseguire il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale, ovvero l'immunizzazione collettiva dal Covid (c.d. effetto gregge) tramite l'immunizzazione individuale.

Con la stessa pronuncia la S.C. ha chiarito come l'art. 4-ter.2, comma 3, d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021, come introdotto dall'art. 8, comma 4, d.l. n. 24 del 2022, conv. dalla l. n. 52 del 2022, *ratione temporis* vigente, che prevede che il personale scolastico inadempiente all'obbligo vaccinale contro l'infezione da SARS-CoV-2 è utilizzato dal dirigente in attività di supporto all'istituzione scolastica (c.d. *repêchage*), è norma speciale e irretroattiva, sicché il lavoratore inadempiente sospeso dal servizio prima della sua entrata in vigore non può dolersi della sua mancata applicazione (v. **Sez. L, n. 31216/2024, Bellè, Rv. 673151-02**).

10. La cessazione del rapporto di lavoro.

Significativa appare, innanzi tutto **Sez. L, n. 04640/2024, Tricomi, Rv. 670127-01**, la quale in tema di esonero dal servizio per inidoneità fisica o psichica del pubblico impiegato, ha precisato come l'art. 23, comma 5, del c.c.n.l. del 4 agosto 1995 impone al datore di lavoro di esperire ogni utile tentativo per il recupero del dipendente al servizio attivo, eventualmente utilizzandolo, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale in mansioni diverse e, in carenza di posti e previo consenso dell'interessato, anche inferiori sicché, anche in assenza dell'iniziativa del lavoratore, non più idoneo alla mansione, la P.A. non è esonerata dal percorrere tutte le strade alternative, previste nello stesso c.c.n.l., prima di adottare il provvedimento di dispensa.

Sez. L, n. 29183/2024, Bellè, Rv. 673018-01, in tema di pensione di vecchiaia, il limite di età cd. ordinamentale (ovverosia il limite anagrafico che la normativa fissa per ciascuna P.A. per

mantenimento al lavoro dei propri dipendenti) può essere derogato solo se la sua applicazione priva il dipendente del diritto alla pensione, come si desume in particolare dall'interpretazione dell'art. 2, comma 5, del d.l. n. 101 del 2013, conv. in l. n. 125 del 2013, che - coniugando le esigenze di risparmio della spesa pensionistica con quelle di "svecchiamento" nel pubblico impiego - afferma che il conseguimento "a qualsiasi titolo" del diritto a pensione costituisce ragione ostativa alla prosecuzione del rapporto oltre i limiti di età cd. ordinamentali.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato il diritto della dipendente, già titolare di pensione, al trattenimento in servizio, richiesto allo scopo di conseguire i versamenti contributivi utili per l'accesso ad un trattamento pensionistico ulteriore rispetto a quello già in godimento.

Per la vicinanza al tema trattato nel presente paragrafo relativo alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, si ricorda qui anche **Sez. L, n. 5667/2024, Rolfi, Rv. 670325-01**, che ha affermato, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, che ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio del dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo (*ex* art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001), va considerato il solo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non anche l'incremento corrisposto in relazione al suddetto incarico, il quale, per la sua temporaneità, non è assimilabile ad un incarico di ruolo.

Quanto invece all'esercizio del potere di recesso datoriale ed ai suoi limiti si rammenta, in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, **Sez. L, n. 24340/2024, Panariello, Rv. 672462-01**.

La pronuncia ha statuito che l'obbligo, per le medesime fondazioni, previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c) del d.l. n.91 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 112 del 2013, di provvedere alla razionalizzazione del personale artistico non comporta necessariamente un divieto di licenziamento, ma - con misura più elastica rispetto alla riduzione del personale tecnico-amministrativo, imposta dalla medesima disposizione in via esclusiva - consente il ricorso a vari strumenti, fra i quali pure il licenziamento collettivo, se l'unico idoneo a realizzare il risanamento del conto economico. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, dichiarativa della legittimità del licenziamento collettivo dell'intero corpo di ballo di una fondazione, soppresso a causa degli elevati costi (di produzione e del personale) superiori ai ricavi.

Alla medesima pronuncia (**Sez. L, n. 24340/2024, Panariello, Rv. 672462-02**) si deve l'affermazione dell'ulteriore principio secondo cui le predette fondazioni sono, di regola, rappresentate e difese in giudizio dall'Avvocatura dello Stato ma, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, possono avvalersi di avvocati del libero foro, previa delibera motivata da sottoporre agli organi di vigilanza, in "casi speciali", i quali non riguardano necessariamente un singolo giudizio, ma possono essere collettivamente individuati per "categorie", ad esempio con riferimento alla materia coinvolta (nella specie, con riferimento alla materia del diritto del lavoro privato).

11. La dirigenza.

In tema di personale dirigente nel corrente anno si sono registrate alcune pronunce significative.

Sez. L, n. 15974/2024, Cavallari, Rv. 671281-01, in tema di incarichi dirigenziale *ex* art. 19, comma 6, d.lgs. n.165 del 2001, ha affermato che sono nulli, per violazione di disposizione imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., sia l'incarico attribuito a soggetto privo dei requisiti *ex* art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo vigente sino al 30 ottobre 2013), sia il contratto individuale che ad esso accede.

Secondo Sez. L, n. 18965/2024, Cavallari, Rv. 672001-01, in seguito alla riforma della dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato - che ha istituito un ruolo unico della dirigenza articolato in due sole fasce (dirigente superiore e dirigente generale) - la valutazione in ordine alla natura dirigenziale delle mansioni svolte dal dipendente va operata con riferimento alle nuove regole, non essendo ammissibile il differimento della loro applicazione, neanche qualora si ritenga che esso trovi giustificazione in una ragione transitoria, come quella concernente il tempo di adeguamento di ciascuna realtà amministrativa ai dettami della riforma (il precedente è conforme a quanto già affermato dalla S.C. con Sez. L, n. 12898/2017, De Felice, Rv. 644508-01).

Sez. L, n. 25537/2024, Gandini, Rv. 672474-01, ha chiarito come negli enti territoriali privi di personale con qualifica dirigenziale, il conferimento di posizioni organizzative non costituisce atto discrezionale e fiduciario del sindaco, in quanto tale interpretazione - contrastando con i principi generali di imparzialità e buon andamento stabiliti dall'art. 97 Cost. e con disposizioni di dettaglio contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001 e nel d.lgs. n. 267/2000 - sottrarrebbe il sindaco all'obbligo di dare conto delle proprie scelte con adeguata motivazione, anche al di fuori di procedure propriamente concorsuali.

Secondo Sez. L, n. 26272/2024, Cavallari, Rv. 672587-03, la domanda d'invalidità della procedura di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Avvocatura generale della Regione Calabria ex art. 10 della l.r. n. 7 del 1996, nel testo precedente all'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), della l.r. Calabria n. 11 del 2015, può essere proposta da chiunque abbia partecipato alla medesima procedura.

Sez. L, n. 27152/2024, Zuliani, Rv. 672665-01, ha affermato che la possibilità di conferire ad un dirigente della P.A. un incarico di valore economico inferiore, ai sensi dell'art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2011, è limitata alle ipotesi di mancato rinnovo in coincidenza con la naturale scadenza dell'incarico, con esclusione dei casi di revoca anticipata, anche se disposta per ragioni organizzative, ipotesi nelle quali, invece, l'art. 1, comma 18, del d.l. n. 138 del 2011, conv. dalla l. n. 148 del 2011, attribuisce al dirigente il diritto di conservare, fino alla scadenza del mandato, il trattamento economico in godimento, con compensazione finanziaria a carico dei fondi della retribuzione di posizione e di risultato o altri fondi analoghi, ove necessario.

Sez. L, n. 25517/2024, Tricomi I., Rv. 672471-01, ha affermato che l'art. 35, comma 1, della l.r. Lazio n. 4 del 2013 ha previsto la cessazione degli organi dell'ASP (Agenzia di sanità pubblica) - tra i quali figura il direttore generale - alla data di insediamento del commissario liquidatore; ne consegue che il contratto di lavoro intervenuto tra il predetto ente e il direttore generale deve considerarsi risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in applicazione dell'art. 1463 c.c.

Nella specie, confermando il rigetto del ricorso proposto dalla lavoratrice, la S.C. ha affermato che la soppressione del posto oggetto dell'incarico consegue alla complessiva ristrutturazione del servizio operata dal legislatore regionale, che ha previsto il trasferimento del solo personale a tempo indeterminato alle Istituzioni subentrate all'ASP.

In relazione al criterio del c.d. *spoil system*, per come previsto e disciplinato dagli artt. 162, comma 12, del regolamento regionale del Lazio n. 1 del 2002 e 53, comma 2, dello statuto della Regione Lazio, Sez. L, n. 25528/2024, Casciaro, Rv. 672473-01, ha precisato che esso non si applica alla figura del direttore regionale, non trattandosi - in quanto formalmente sottoposto ai poteri di direzione e coordinamento del dirigente di dipartimento - di dirigente apicale di nomina politica fiduciaria, sicché la clausola del contratto individuale che prevede la cessazione dell'incarico a fine legislatura è nulla, in quanto contenente una previsione di decadenza automatica che contrasta con i principi desumibili dall'art. 97 Cost.

Sez. L, n. 22518/2024, Bellè, Rv. 672192-01, in materia di dirigenti nell'impiego pubblico regionale, ha precisato che il capo dipartimento (nella specie, dell'urbanistica e governo del territorio) della Regione Calabria, avendo la funzione di organizzare, coordinare e dirigere l'ufficio secondo le direttive generali degli organi di direzione politica che assiste, svolge un incarico rispetto al quale opera il sistema di cd. *spoils system*, rientrando esso nei cd. incarichi dirigenziali apicali che non attengono ad una semplice attività di gestione, ed essendo invece rapportabile alla direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (in senso conforme v. Sez. L, n. 2510/2017, Tricomi, Rv. 643067-01).

Ancora in tema di cd. *spoils system*, **Sez. L, n. 15971/2024, Cavallari, Rv. 671280-01**, ha sottolineato come, ai fini dell'applicazione della normativa ad esso relativa, la natura apicale dell'incarico conferito a un dirigente va valutata tenendo conto della qualificazione formale contenuta nel contratto, che può tuttavia essere superata dalla verifica della preposizione del dirigente a capo di una struttura che, da un punto di vista organizzativo, abbia le stesse caratteristiche di un ufficio apicale.

In relazione agli incarichi alle dipendenze degli enti locali di cui all'art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. uffici di staff), **Sez. L, n. 22325/2024, Marotta, Rv. 672265-01**, ha chiarito come essi hanno una durata rapportata a quella dell'organo politico a cui sono collegati, perché hanno carattere fiduciario e di diretta collaborazione con il vertice istituzionale nell'elaborazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

In tema di dirigenza nel comparto sanitario, **Sez. L, n. 25518/2024, Casciaro, Rv. 672472-01**, ha precisato che il conferimento dell'incarico di responsabile di struttura semplice in luogo di quello già ricoperto di responsabile di struttura complessa, che avvenga nell'ambito di un complessivo riassetto organizzativo aziendale, non comporta di per sé un demansionamento o comunque un danno alla professionalità del dirigente medico, il quale pertanto - nel regime di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - non può rivendicare il conferimento di un incarico di pari valore economico, se il precedente è cessato alla naturale scadenza.

Sez. L, n. 25623/2024, Fedele, Rv. 672476-01, ha affermato che in tema di trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, la riduzione dei compensi, disposta ex art. 61, comma 14, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, non è subordinata all'effettiva riduzione o abolizione del *ticket* per le prestazioni di assistenza specialistica, disposta dal comma 19 della medesima disposizione, come si evince sia dall'interpretazione letterale del citato comma 14, che prevede la decurtazione dei trattamenti economici in via del tutto autonoma, sia dall'esegesi teleologica e sistematica della norma, inserita nel quadro delle disposizioni di coordinamento finanziario e finalizzata al contenimento della spesa sanitaria.

Alla stessa pronuncia si deve l'ulteriore massima (**Sez. L, n. 25623/2024, Fedele, Rv. 672476-02**), secondo la quale il trattamento economico del direttore generale delle aziende sanitarie locali è ancorato ai parametri di cui all'art. 1 del d.P.C.M. n. 319 del 2001, con rinvio all'art. 1 del d.P.C.M. n. 502 del 1999, senza specifici riferimenti alla contrattazione collettiva, mentre quello del direttore sanitario e del direttore amministrativo di dette aziende è agganciato ed adeguato, ex art. 2 del medesimo d.P.C.M., alle retribuzioni delle posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa, pattuite nei contratti collettivi nazionali.

Sez. L, n. 3513/2024, Cavallari, Rv. 669940-01, in tema di dirigenza medica, ha chiarito che la retribuzione di posizione variabile non contrattuale non può essere corrisposta ai dirigenti in assenza di provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli

incarichi; pertanto, ove la P.A. effettui illegittimamente il relativo pagamento in favore di alcuni di tali dirigenti, gli altri, che da tale pagamento siano stati esclusi, non possono dolersi dell'avvenuta disparità di trattamento, dovendo, piuttosto, il datore di lavoro recuperare quanto indebitamente versato a coloro che non ne avevano diritto.

Sez. L, n. 1895/2024, Cavallari, Rv. 669836-01, ha precisato come in tema di dirigenza sanitaria, è nulla - in quanto contrastante con l'art. 97, comma 2, Cost. - la clausola del contratto concluso fra il direttore sanitario e l'azienda sanitaria che prevede lo scioglimento automatico del rapporto in ipotesi di nomina di un nuovo direttore generale; in tale evenienza, il direttore sanitario ha diritto all'integrale risarcimento del danno e non solamente al mero rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera fino a quel momento prestata, non trovando applicazione l'art. 2237 c.c. perché disposizione incompatibile con l'art. 3 *bis* del d.lgs. n. 502 del 1992.

Sez. L, n. 2741/2024, Sarracino, Rv. 669942-01, ha precisato come in tema di assicurazione della responsabilità civile dei dirigenti medici, l'introduzione di un obbligo espresso di "adeguata copertura", ad opera dell'art. 21 del c.c.n.l. del 3 novembre 2005, non ha alcuna valenza innovativa rispetto all'art. 24 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, che già imponeva alle aziende sanitarie di stipulare adeguate polizze assicurative, a copertura dei rischi relativi a tutte le spese di giudizio, e non soltanto di quelle spese che, ricorrendo le più stringenti condizioni di cui al successivo art. 25 del c.c.n.l. 8 giugno 2000, fossero a diretto carico dell'azienda o dalla stessa rimborsabili.

Secondo **Sez. L, n. 2875/2024, Sarracino, Rv. 670033-02**, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituto, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (in senso analogo v. Sez. L, n. 21565/2018, Di Paolantonio, Rv. 650221-01).

Sez. L, n. 31795/2024, Bellè, Rv. 673296-01, ha affermato che l'orario dei medici, fissato dal c.c.n.l. del 3.11.2005 in trentotto ore settimanali, è da intendere come orario minimo, tanto che la predetta soglia può essere superata senza che sia dovuto il pagamento dello straordinario, con la conseguenza che la flessibilità oraria prevista dalla contrattazione collettiva, lungi dall'avere la sola funzione di valorizzare le esigenze personali dei dirigenti medici, ha lo scopo primario di favorire il raggiungimento degli obiettivi da parte della struttura sanitaria, sicché non vi è dubbio che sussistono poteri conformativi dell'orario da parte dei superiori gerarchici, anche con fissazione, per certi ruoli ed attività (come quelli dell'anestesia e degli interventi chirurgici) di orari rigidi. In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato la legittimità dell'indicazione di un orario di lavoro rigido (nello specifico 8.00-14.00) da parte del dirigente della struttura complessa al dirigente della struttura semplice preposto al coordinamento anestesilogico delle sale operatorie.

Il conferimento dell'incarico dirigenziale di un ufficio legale interno della P.A., ad avviso di **Sez. L, n. 24366/2024, Zuliani, Rv. 672245-01**, deve essere il frutto di una procedura comparativa che valuti - nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento ex 97 Cost., oltre che di correttezza e buona fede - i profili specifici e le esperienze professionali

dei singoli candidati, senza che dall'art. 23 della legge professionale n. 247 del 2012 possa desumersi un obbligo per la P.A. di preferire nella procedura valutativa i titoli inerenti all'attività legale rispetto a quelli comprovanti le qualità manageriali. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato che il maggior numero di anni di iscrizione all'albo ed il possesso dell'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di un candidato non comportavano automaticamente la prevalenza dello stesso su altro aspirante con più vasta esperienza manageriale.

Nello stesso senso **Sez. L, n. 01488/2024, Rolfi, Rv. 670024-01**, secondo cui in tema di dirigenza medica, in applicazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 (previsione generale) e dell'art. 15-ter, comma 1, del d.lgs. 502 del 1992 (disciplina speciale), il conferimento dell'incarico di titolare di struttura complessa deve conseguire ad una procedura comparativa dei profili specifici e delle esperienze professionali dei singoli candidati, improntata al rispetto delle regole di correttezza e buona fede e dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., e concludersi con l'adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, che illustri sia i criteri adottati, sia le ragioni giustificative della scelta assunta.

Sempre in tema di dirigenza medica **Sez. L, n. 18204/2024, Fedele, Rv. 671857-01**, ha affermato che nella controversia in cui il dirigente medico contesta la legittimità dei provvedimenti adottati dalla p.a. datrice di lavoro sul mantenimento della retribuzione di posizione "variabile aziendale", prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell'atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell'eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore.

Alla stregua di **Sez. L, n. 14457/2024, Casciaro, Rv. 671213-01**, in tema di dirigenza medica di strutture pubbliche, la normativa speciale di cui all'art. 15-septies d.lgs. n. 502 del 1992, laddove non riconosce un diritto incondizionato all'aspettativa per assumere incarichi in altro Paese dell'U.E., non determina un'ingiustificata restrizione della libertà di stabilimento in contrasto con gli artt. 45-48 del TFUE, in quanto non opera con intenti discriminatori basati sulla cittadinanza, né mira ad attuare una differenziazione con riferimento agli incarichi all'estero, ma soddisfa l'esigenza propria della sanità pubblica di circolazione di professionalità all'interno del SSN, limitando, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito, la possibilità di fruizione dell'aspettativa "senza assegni" a incarichi che realizzano una mobilità in seno al SSN, ed escludendola per quelli conferiti non solo da strutture di Paesi dell'U.E. ma anche da strutture private site nel territorio nazionale.

In relazione alla mobilità tra fasce dirigenziali, **Sez. L, n. 19885/2024, Cavallari, Rv. 667187-01**, ha precisato come, in tema di passaggio dalla seconda alla prima fascia dirigenziale, l'art. 23, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica a tutti i dirigenti dello Stato, ivi compresi quelli appartenenti alle amministrazioni ad ordinamento autonomo come la Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre che a quelli delle amministrazioni non statali di cui all'art. 27 del medesimo decreto, nel rispetto del principio di uniformità di trattamento sul territorio nazionale; ne consegue che il diritto al passaggio di fascia deve riconoscersi anche al dirigente statale di seconda fascia che ha ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti presso un ente locale.

Nell'ordinamento degli enti locali, secondo **Sez. L, n. 12837/2024, Buconi, Rv. 670984-01**, gli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica, conferiti, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, ai sensi dell'art. 110, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, sono di tipo subordinato, perché comportano l'inserimento dei sog-

getti incaricati, adibiti a compiti istituzionali, nell'organizzazione dell'ente, con applicazione della relativa contrattazione collettiva; trattasi di rapporti peculiari, per i quali è consentita, per espressa previsione del legislatore, una deroga alla durata massima di trentasei mesi dei contratti a termine, che non si pone in contrasto con il diritto unionale, stante la temporaneità delle esigenze sottese al ricorso all'istituto e la previsione, comunque, di un limite temporale, benché correlato alla durata del mandato elettorale.

Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta, secondo Sez. L, n. 09982/2024, Buconi, Rv. 670717-01, la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo (la pronuncia si pone nel solco di quanto già affermato dalla S.C. con Sez. L, n. 18140/2022, Bellè, Rv. 664916-01). In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'insufficienza della mera sollecitazione datoriale alla fruizione delle ferie, se il godimento delle stesse è reso impossibile dalle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, come nel caso del susseguirsi di contratti a termine con scadenza molto breve che non consentono la programmazione del periodo di riposo.

L'assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, secondo Sez. L, n. 02695/2024, Sarracino, Rv. 669866-01, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall'assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, la quale assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato (si veda, in senso conforme, Sez. L, n. 30811/2018, Di Paolantonio, Rv. 651752-01).

Sez. L, n. 31653/2024, Zuliani, Rv. 673211-01, ha precisato come ai funzionari regionali di area D del comparto enti locali, iscritti all'albo e che svolgono funzioni di avvocato, non compete, sulla scorta del ccnl Enti locali del 5.10.2001, *ratione temporis* applicabile, la retribuzione di posizione spettante ai dirigenti di *staff*, in quanto la determinazione del trattamento retributivo nel pubblico impiego contrattualizzato è riservata alla contrattazione collettiva che, nella specie, non prevede la spettanza di detto emolumento per le sopraindicate figure professionali; né la retribuzione di posizione può essere riconosciuta invocando la violazione dei parametri costituzionali della sufficienza e proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., sia perché vi è presunzione, ancorché relativa, del rispetto di detti parametri da parte della contrattazione pubblica, sia perché essi sono senz'altro osservati nella fattispecie *de qua*, percependo i funzionari-avvocati, oltre alla retribuzione contrattuale di categoria, una partecipazione alla ripartizione dei compensi incassati dalla Regione a titolo di spese legali per le cause vinte.

Sez. L, n. 31240/2024, Buconi, Rv. 673076-01, in tema di trattamento economico dei dirigenti della Regione Calabria, ha chiarito che l'indennità incentivante all'esodo *ex art. 7* della l.r. Calabria n. 8 del 2005 ha natura retributiva ed è riconducibile alla fase conclusiva del rapporto di lavoro, sicché l'azione volta ad ottenerne il pagamento, quale azione di inesatto adempimento del debito gravante sul datore di lavoro, è assoggettata al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 5 c.c.

Sez. L, n. 14781/2024, Casciaro, Rv. 671228-01, ha affermato che il fondo per la dirigenza *ex art. 26* del c.c.n.l. area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali del 23 dicembre 1999 è determinato tenendo conto delle posizioni dirigenziali effettivamente coperte nell'organico dell'ente e deve essere utilizzato anche per le indennità spettanti

ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, poiché a costoro è applicabile la disciplina normativa e contrattuale dei rapporti a tempo indeterminato compatibile con la natura a termine dell'incarico, per effetto del richiamo di cui all'art. 110 TUEL e del divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine, se non giustificato da ragioni obbiettive, posto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato con la Direttiva 1999/70/CE.

12. Il personale scolastico.

Numerose le pronunce in tema di personale scolastico.

Sez. L, n. 27872/2024, Cavallari, Rv. 672601-01, ha affermato che la c.d. carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015, è una prestazione pecuniaria oggetto di un'obbligazione sui generis, perché condizionata dalla destinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologie di acquisti idonee a soddisfare esigenze formative, e costituisce comunque un beneficio economico, benché atipico, sicché essa compete anche al personale educativo, non solo perché la funzione educativa partecipa al processo di formazione ed educazione nell'ambito della funzione docente, ma anche per l'espressa equiparazione normativa del trattamento economico del personale educativo a quello dei docenti.

Sempre in tema di carta elettronica del docente, **Sez. L, n. 9895/2024, Buconi, Rv. 670685-01**, ha chiarito come la medesima, finalizzata al sostenimento della formazione continua dei docenti al fine di valorizzarne le competenze professionali e prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.

Sez. L, n. 9691/2024, Rolfi, Rv. 670683-01, ha precisato che il diploma di maturità magistrale ad indirizzo linguistico, conseguito al termine del corso sperimentale quinquennale, costituisce titolo idoneo alla ammissione al concorso pubblico per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari che richieda il possesso del diploma magistrale, tale equiparazione riflettendo il nuovo assetto ordinamentale della scuola primaria in cui l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici.

Sez. L, n. 8586/2024, Buconi, Rv. 670538-01, ha poi evidenziato che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie⁷³⁵⁴ di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni *lato sensu* concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.

Sez. L, n. 13684/2024, Cavallari, Rv. 671204-01, in tema di lavoratore inserito nella prima fascia della graduatoria provinciale permanente relativa al personale ATA (nella specie, nel profilo di collaboratore scolastico), ha precisato che lo stesso non ha un diritto soggettivo a stipulare con la P.A. un contratto a tempo determinato avente ad oggetto il conferimento di supplenze annuali in presenza di posti vacanti e quindi non può vantare pretese risarcitorie, neppure in caso di illegittima esternalizzazione da parte della P.A. dei servizi corrispondenti a quelli resi dai collaboratori scolastici.

In tema di mobilità territoriale del personale docente della scuola pubblica **Sez. L, n. 01055/2024, Bellè, Rv. 669770-01**, ha chiarito che l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli.

Ancora, in tema di mobilità, si segnalano le seguenti pronunce.

Sez. L, n. 34602/2024, Cavallari, Rv. 673319-02, ha statuito che i Bollettini ufficiali del MIUR concernenti i trasferimenti provinciali e interprovinciali relativi all'assegnazione ai docenti delle sedi definitive sono atti che svolgono solamente una funzione di pubblicità e che (**Sez. L, n. 34602/2024, Cavallari, Rv. 673319-01**), in tema di mobilità dei docenti di ruolo di scuola pubblica per l'anno 2016/2017 disposta ai sensi dell'art. 1, comma 108, della l. n. 107 del 2015, il c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 (adottato ex artt. 4, comma 2, e 10 del c.c.n.l. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006- 2009) e l'ordinanza ministeriale n. 241/2016 hanno previsto che gli insegnanti provenienti da graduatorie di merito 2012 assunti da fasi B e C del 2015/2016 sono ammessi, a domanda, alla fase B della mobilità 2016/2017, con riferimento alla mobilità endoprovinciale su ambito, con la conseguenza che essi sono preferiti, rispetto all'ambito richiesto, ai docenti delle medesime fasi assunzionali provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (cd. GAE), in quanto questi ultimi sono stati inseriti nella successiva fase C della mobilità 2016/2017, espressamente da svolgersi sui posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti; al contrario, per la mobilità interprovinciale su ambito, gli insegnanti provenienti da graduatorie di merito 2012 sono postergati ai docenti provenienti da GAE assunti nelle fasi B e C del 2015/2016, siccome nella mobilità 2016/2017 i primi docenti sono stati ammessi in fase D, mentre quelli provenienti da GAE hanno partecipato alla fase C.

Sez. L, n. 7354/2024, De Marinis, Rv. 670534-01, in tema di procedure di mobilità del personale docente di fascia C per l'anno scolastico 2016-2017, ha precisato come l'assegnazione delle cattedre avviene, ex art. 6 del c.c.n.i. dell'8 aprile 2016 e del relativo Allegato 1, in considerazione delle preferenze espresse dai candidati, senza che sussista alcuna violazione del criterio meritocratico di cui all'art. 97 Cost., essendosi in una fase successiva a quella del reclutamento: ne consegue che all'assegnazione non si procede seguendo una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale, articolata tenendo conto del punteggio conseguito da ogni insegnante, ma sulla scorta di distinte graduatorie, elaborate sulla base dell'ordine di preferenze espresso dal richiedente in relazione ai vari ambiti territoriali, strutturate al loro interno in considerazione del punteggio conseguito.

Sez. L, n. 18682/2024, Bellè, Rv. 667205-02, ha chiarito che se il docente - al di fuori dell'ipotesi di sostituzione dovuta ad assenza per ferie - è incaricato o svolge di fatto mansioni di supplenza piena del dirigente scolastico o del reggente, con compiti prevalentemente propri di questi ultimi sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, si configura, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'attribuzione di mansioni superiori, per le quali va riconosciuta l'indennità di cui all'art. 69, comma 1, del c.c.n.l. 1994-1997, in tale parte recepito nell'art. 146 del c.c.n.l. comparto scuola del 16 novembre 2007.

Il docente incaricato di specifici compiti consistenti nel coadiuvare il reggente (cioè, il dirigente di un altro istituto che esercita le sue funzioni in più scuole), secondo **Sez. L, n. 18682/2024, Bellè, Rv. 672055-01**, deve considerarsi alla stregua di collaboratore del dirigente scolastico, in applicazione dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, e dev'essere remunerato esclusivamente con compenso a carico dei fondi di istituto, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f), c.c.n.l. comparto scuola del 16 novembre 2007.

Secondo **Sez. L, n. 16715/2024, Cavallari, Rv. 671579-01**, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche. In senso conforme si segnalano, nel corrente anno, **Sez. L, n. 13440/2024, Cavallari, Rv. 671200-01**, nonché la precedente **Sez. L, n. 14268/2022, Spena, Rv. 664850-01**.

Significativa risulta, altresì, **Sez. L, n. 17629/2024, Fedele, Rv. 671594-01**, la quale ha chiarito che la dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento di cui all'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 487 del 1994, *ratione temporis* applicabile, consegue all'accertamento dell'inidoneità, sopravvenuta, assoluta e permanente, allo svolgimento della funzione docente, in conseguenza di obiettive deficienze comportamentali, intellettive o culturali, ed assume inoltre una valenza oggettiva, impeditiva *ex lege*, dell'accesso agli impieghi pubblici; diversamente, il mancato superamento del periodo di prova, di cui all'art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994, esaurisce i suoi effetti nel recesso datoriale dal rapporto contrattuale a cui accede, senza che detti effetti risolutivi possano riverberarsi anche su un nuovo rapporto, posto che la prova è volta solo a verificare la reciproca convenienza del contratto di lavoro nel cui ambito si svolge.

In tema di personale della scuola pubblica, **Sez. L, n. 15198/2024, Di Paolantonio, Rv. 671223-01**, ha affermato che il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi per l'assegnazione delle superiori mansioni di Direttore dei servizi generali ed amministrativi è regolato dall'art. 1, comma 45, l. n. 228 del 2012 che, con una disposizione speciale e derogatoria del principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, stabilisce i criteri di determinazione dell'indennità per lo svolgimento di tali mansioni, la quale dev'essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento (che non può, pertanto, essere assorbita dall'indennità).

Sez. L, n. 8605/2024, Buconi, Rv. 670539-01, ha affermato che, in tema di passaggi di ruolo del personale docente, all'insegnante di scuola materna comunale che transita alla scuola materna statale, spetta il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di

provenienza, in considerazione della piena fungibilità tra i ruoli delle scuole di ogni ordine e grado desumibile dall'interpretazione sistematica della disciplina che regola la materia.

In tema di supplenze temporanee, **Sez. L, n. 7084/2024, Cavallari, Rv. 670357-01**, ha rimarcato che nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie.

Sez. L, n. 12507/2024, Marotta, Rv. 670932-01, ha precisato come nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE (di diretta applicazione) impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, senza che rilevi, ai fini del riconoscimento dell'anzianità, la mancanza del titolo abilitante, dovendosi considerare, ai predetti fini, la sola identità delle mansioni svolte dal docente precario e da quello di ruolo.

In materia di reclutamento a termine del personale scolastico, ai fini dell'accertamento del carattere abusivo o meno di una successione di contratti a termine, **Sez. L, n. 11341/2024, Di Paolantonio, Rv. 671015-01**, ha precisato che l'avvenuta utilizzazione del lavoratore in supplenze presso istituti scolastici diversi non assume alcuna rilevanza per quanto concerne le supplenze conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), mentre è soltanto uno degli indici da apprezzare per la verifica dell'uso distorto di quelle conferite sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Sez. L, n. 17692/2024, Marotta, Rv. 671595-01, ha poi precisato che, in tema di personale da destinare alle scuole statali all'estero, la norma dettata dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 64 del 2017 - secondo la quale tale personale è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero - prevale, in quanto disposizione di natura speciale, su ogni altra, compresa quella di cui al novellato art. 11, comma 14, l. n. 124 del 1999 in materia di valutazione del servizio pre-ruolo e, inoltre, non può essere disapplicata per violazione del diritto unionale, in quanto tesa ad evitare discriminazioni "alla rovescia" nei confronti del personale di ruolo assunto a seguito di un concorso generale, così integrando una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Sez. L, n. 16855/2024, Di Paolantonio, Rv. 671582-01, ha evidenziato che il riconoscimento del titolo di formazione professionale (disposto ex art. 13 d.lgs. n.115 del 1992, *ratione temporis* applicabile) implica il pieno riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'UE, nonché il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, anche ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per l'inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento, determinandosi altrimenti un ingiustificato vantaggio per coloro che hanno concluso in Italia il percorso formativo e una discriminazione indiretta contraria al diritto dell'Unione e, specificamente, all'art. 45 del Trattato UE.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che aveva negato la piena equiparazione di un titolo professionale conseguito presso un'università slovena, riconosciuto con decreto ministeriale *ex art. 13 d.lgs. n.115 del 1992*, alla laurea in scienze della formazione primaria, implicante il diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo utile per la collocazione nella graduatoria ad esaurimento per l'insegnamento nelle scuole primarie nel biennio 2007/2009.

In relazione alla cessazione del rapporto di servizio per collocamento a riposo **Sez. L, n. 34605/2024, Cavallari, Rv. 673320-02**, ha chiarito che il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età del personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorre dal primo settembre dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Alla medesima pronuncia si deve l'ulteriore massima (**Sez. L, n. 34605/2024, Cavallari, Rv. 673320-01**), qui ricordata per ragioni di sistematicità (pur attenendo ad un profilo di confine con la materia processuale), con la quale si è affermato che l'art. 4 della l. n. 260 del 1958, che consente alla difesa erariale di eccepire solo entro la prima udienza l'errata indicazione della persona cui l'atto introduttivo doveva essere notificato, in mancanza non potendo più tale vizio essere prospettato o rilevato dal giudice, trova applicazione anche qualora il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore convenga in giudizio, in luogo del Ministero di appartenenza, l'Istituto scolastico presso il quale presta servizio avanzando pretese concernenti il rapporto di lavoro.

Sez. L, n. 12746/2024, Fedele, Rv. 670937-01, in tema di sanzioni disciplinari, ha affermato che l'adozione, da parte di un docente, di reiterati comportamenti minacciosi ed aggressivi verso minori costituisce giusta causa di licenziamento, in quanto il metodo educativo non giustifica il compimento di atti anche solo potenzialmente lesivi dell'integrità psico-fisica dell'individuo e contrastanti con la centralità dei diritti inviolabili dell'uomo nel disegno costituzionale e con le finalità stesse dell'attività educativa, secondo gli *standard* valutativi dell'attuale coscienza sociale.

Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione d'appello che, pur considerando antiquato e non condivisibile il metodo educativo della docente, aveva ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva irrogata ad un'insegnante della scuola elementare, che in sede penale era stata condannata per aver maltrattato gli alunni di 6-7 anni, sottoponendoli a ripetuti atti di violenza fisica e psicologica.

13. Le azioni di ripetizione del pagamento indebito.

Sez. L, n. 20427/2024, Bellè. Rv. 667207-01, ha affermato che in tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della *causa solvendi* - decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento stesso a seguito di verifiche esperite dalla P.A.

Il principio è stato espresso in relazione ad un'ipotesi nella quale l'emersione dell'indebito veniva riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente.

CAPITOLO XXIII

LE VICENDE DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

(DI MARIO DE IORIS)

SOMMARIO: 1. L'obbligazione contributiva e i soggetti obbligati. - 2. La retribuzione imponibile e il minimale retributivo. - 3. Gli sgravi e i benefici contributivi. - 4. Totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali. - 5. Omissione contributiva e posizione del lavoratore. - 6. Accertamento e riscossione. - 7. La prescrizione dei crediti contributivi. - 8. Gli elenchi dei lavoratori agricoli. - 9. La prosecuzione volontaria del versamento dei contributi.

1. L'obbligazione contributiva e i soggetti obbligati.

Diverse pronunce, nel corso del 2024, hanno fornito importanti chiarimenti in ordine ad incertezze interpretative sorte in relazione ad alcune fattispecie inerenti alla nascita dell'obbligazione contributiva e all'individuazione dei soggetti obbligati al versamento dei contributi previdenziali, finalizzati a fornire agli enti preposti le risorse per l'erogazione delle prestazioni previste dalla legge e per svolgere i compiti loro affidati.

E così, con riferimento al novero dei soggetti tenuti ad assolvere all'obbligazione contributiva nei confronti dell'INPS, **Sez. L, n. 04936/2024, Cerulo, Rv. 670055-01**, ha chiarito che, fino all'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, i soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970 (facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia a terra, a mare, o campestre, polizia, investigazioni private e simili) erano esclusi dalla copertura assicurativa contro la disoccupazione involontaria, con conseguente insussistenza della prestazione previdenziale e della correlativa obbligazione contributiva.

La disciplina da applicare in ordine ad altra tipologia di enti cooperativi, e precisamente le imprese cooperative che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti agricoli o zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dell'allevamento di animali, ha costituito l'oggetto della decisione di **Sez. L, n. 04926/2024, Buffa, Rv. 670054-01**, la quale ha stabilito che, quanto all'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le anzidette imprese cooperative ed i loro consorzi sono inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura allorquando, per l'esercizio di tali attività, non ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

La stessa decisione ha chiarito altresì che non è invece necessario, al medesimo fine, che dette imprese cooperative ed i loro consorzi si costituiscano in società cooperative (a responsabilità limitata o illimitata), non essendo incompatibile con la classificazione nel settore agricolo l'esercizio di tali attività sotto la forma, oltre che di società cooperativa, anche di organismi associativi o cooperativi di fatto, o di società ispirate anche a finalità di cooperazione tra i soci (quali le società civili e le società cooperative irregolari per la mancata iscrizione ex art. 2519 c.c.).

Ai fini dell'accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, rilevante per la sottoposizione ai connessi obblighi contributivi, **Sez. L, n. 33058/2024, Cavallaro,**

Rv. 673305-01, ha preso in esame la disciplina dettata, prima della sua modifica ad opera dell'art. 53 del d.lgs. n. 81 del 2025, dall'art. 2549, comma 2, c.c., introdotto dall'art. 1, comma 28, l. n. 92 del 2012, precisando che tale disposizione codicistica si interpreta nel senso che il limite di tre associati in partecipazione - il superamento del quale comporta la trasformazione di tutti i rapporti di associazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - va riferito non alla singola unità produttiva in cui è eventualmente articolata l'attività d'impresa, ma a ciascun affare o a ciascuna delle attività produttive proprie dell'impresa, indipendentemente dal fatto che ognuna di esse è, a sua volta, articolata in una pluralità di unità produttive, e ciò in ragione dell'interpretazione letterale dell'espressione "medesima attività" utilizzata dal legislatore.

Sez. L, n. 22061/2024, Marchese, Rv. 672264-01, ha invece chiarito che le Autorità portuali non sono tenute alla contribuzione per la disoccupazione involontaria in relazione al periodo di vigenza della disciplina antecedente alla l. n. 92 del 2012, poiché il rapporto di lavoro dei loro dipendenti è caratterizzato dalla stabilità di impiego di cui all'art. 40 del r.d.l. n. 1827 del 1935, sicché tali enti pubblici non economici sono privi del potere datoriale di recedere dal rapporto di lavoro per scelte gestionali di natura economica.

Con riferimento alla categoria dei pubblici dipendenti, in generale, **Sez. L, n. 34058/2024, Gnani, Rv. 673314-01**, ha affermato che, in caso di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni, il regime giuridico del rapporto di lavoro e di quello previdenziale, ai sensi dell'art. 30, comma 2-*quinques*, del d.lgs. n.165 del 2001, *ratione temporis* applicabile, è attratto d'ufficio, in via esclusiva (ovverosia anche con riguardo al periodo pregresso al trasferimento), al trattamento previsto presso l'ente di destinazione, dovendo ritenersi che l'opzione per la conservazione del regime previdenziale dell'ente di provenienza contemplata dall'art. 6 della l. n. 554 del 1988 opera solo in relazione ai trasferimenti attuati durante la sua vigenza, e dunque non oltre il 23.4.1998.

Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi soggetti all'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie - e la delimitazione dei loro obblighi contributivi - **Sez. L, n. 22901/2024, Garri F., Rv. 672335-01**, ha stabilito che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).

Sez. L, n. 08631/2024, Gnani, Rv. 670629-01, si è soffermata invece sulle modalità con la quale verificare il requisito contributivo previsto degli artt. 4, comma 1, 2 l. n. 222 del 1984 e 9, n. 2, lett. b) r.d.l. n. 636 del 1939 ai fini del diritto all'assegno ordinario d'invalidità, e cioè l'iscrizione per almeno 5 anni alla gestione AGO presso l'Inps con versamento di contribuzione pari almeno a 5 anni (260 settimane di contributi).

Al riguardo, l'art. 37, ultimo comma, del d.P.R. n. 818 del 1957, prevede che non si computano nel quinquennio antecedente alla domanda di prestazione richiesta i periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o i periodi di lavoro subordinato per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione, e ciò integra il benefico della cd. "neutralizzazione" dei periodi in questione ai fini del computo del requisito in discorso.

La decisione anzidetta, ha ribadito che tra le forme di previdenza obbligatoria diverse da quelle sostitutive sono ricomprese anche le forme di previdenza obbligatoria erogate in regime di gestione esclusiva ai dipendenti pubblici, ma ha precisato che l'iscrizione ad esse non è sufficiente per consentire l'applicazione del predetto beneficio, occorrendo che detta iscrizione non abbia fatto maturare alcun trattamento previdenziale.

Sez. L, n. 21437/2024, Cavallari, Rv. 672122-01, ha invece affermato che la possibilità per il datore di lavoro di detrarre, nella denuncia contributiva, l'importo dell'indennità corrisposta ai dipendenti beneficiari del congedo straordinario per assistenza a familiari con *handicap* grave ex art. 42, comma 5-ter, d.lgs. n. 151 del 2001, dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente, deve essere riconosciuta anche alle aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto rientranti fra i datori di lavoro privati.

Sez. L, n. 04596/2024, Marchese, Rv. 670150-01, infine, ha preso in esame una forma particolare di contribuzione, e cioè la contribuzione cd. minore per CIGO, CIGS e mobilità, affermando che non sussiste l'obbligo di versamento della stessa in favore dei dipendenti delle società del gruppo di Poste italiane (tra cui Postel S.p.A.) per il periodo anteriore all'istituzione, con d.m. del 24 gennaio 2014, dei fondi di solidarietà bilaterale, in quanto la disciplina applicabile fino all'introduzione di detti fondi disciplinava, in modo autonomo e completo, per tale platea di lavoratori, l'intera materia della previdenza ed assistenza, rendendo per essi inoperante il regime gestito dall'INPS.

2. La retribuzione imponibile e il minimale retributivo.

L'ammontare dei contributi da versare viene calcolato, per quel che concerne il lavoro dipendente, in percentuale sull'importo della retribuzione imponibile; per quel che concerne il lavoro autonomo, in collaborazione o associato, viene invece calcolato in percentuale sull'importo del reddito da lavoro, in misura variabile a seconda dei diversi enti assicuratori.

Quanto al lavoro dipendente, l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, ha fissato il principio secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

A tal proposito **Sez. L, n. 19759/2024, Cavallaro, Rv. 671874-01**, ha precisato che deve farsi riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.

Una particolare ipotesi di non applicabilità del regime del minimale contributivo è stata invece esaminata da **Sez. L, n. 28678/2024, Gnani, Rv. 672735-01**, la quale, con riferimento ai lavoratori italiani assunti a contratto presso gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri secondo le disposizioni di cui al titolo VI del d.P.R. n. 18 del 1967, ha affermato che tale decreto, e poi l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 103 del 2000, *ratione temporis* vigente, hanno sempre previsto il regime dell'imponibile contributivo fondato sulla retribuzione convenzionale, dettando una disciplina specifica che prevale e rende inapplicabile la regola

generale del minimale contributivo, di cui all'art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, e che non è manifestamente in contrasto con l'art. 3 Cost. laddove stabilisce un trattamento differenziato rispetto ai lavoratori all'estero con retribuzioni inferiori al tetto convenzionale ed a quelli assoggettati al regime previdenziale previsto dalla normativa locale.

3. Gli sgravi e i benefici contributivi.

In tema di sgravi contributivi, **Sez. L, n. 22923/2024, Garri F., Rv. 672336-01**, ha enunciato i principi inerenti al riparto degli oneri probatori quando la spettanza degli stessi sia oggetto di contestazione.

A tal proposito, detta decisione ha chiarito che, poiché gli sgravi contributivi costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti la loro fruizione.

Gli artt. 8 e 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 prevedono sgravi contributivi temporanei per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato - o che trasformino in tal senso iniziali contratti a termine - lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

Con riferimento a tale tematica, **Sez. L, n. 34706/2024, Cerulo, Rv. 673321-01**, ha fatto chiarezza in ordine ad alcune questioni circa l'epoca di applicazione delle disposizioni che hanno regolato tale materia, avendo affermato che gli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 2, terzo periodo, della l. n. 223 del 1991, in virtù dell'art. 1, comma 114, della l. n. 190 del 2014, spettano al datore di lavoro che abbia trasformato in contratto a tempo indeterminato il contratto di lavoro a termine stipulato con un lavoratore assunto dalle liste della cd. piccola mobilità, a condizione che tale trasformazione sia intervenuta entro il 31 dicembre 2012 e non in data posteriore, a nulla rilevando che l'originario contratto a termine, presupposto dell'autonomo sgravio disciplinato dall'art. 8, comma 2, secondo periodo, della l. n. 223 del 1991, sia stato concluso prima del 31 dicembre 2012.

Sez. L, n. 12589/2024, Cavallaro, Rv. 670902-01, ha invece affrontato le problematiche connesse all'applicazione dello sgravio di cui all'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223 del 1991, stabilendo che la sua legittima fruizione presuppone, per un verso, l'insussistenza di condotte fraudolentemente preordinate alla creazione di operazioni comportanti il licenziamento di lavoratori da parte di un'impresa e l'assunzione degli stessi lavoratori da parte dell'altra e, per altro verso, l'effettivo incremento dell'occupazione in conseguenza dell'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; pertanto, va esclusa la sussistenza del secondo dei presupposti - e, quindi, il diritto allo sgravio - quando una delle due imprese coinvolte è l'unica committente dell'altra e l'appaltatrice risulta così priva di una reale autonomia economica, perché in tal caso non si realizza un effettivo incremento occupazionale.

Con riferimento, invece, alle agevolazioni contributive di cui all'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375 del 1993, **Sez. L, n. 11762/2024, Cavallaro, Rv. 671010-01**, ha chiarito che detta disposizione si limita ad estendere ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previste dal d. l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 338 del 1989 e, conseguentemente, anche le previsioni dei commi 9 e 10 dell'art. 6 dello stesso d.l., da interpretarsi nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive dev'essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori a cui si riferisce l'inadempimento e le sanzioni da applicare.

In tema di benefici contributivi in generale, **Sez. L, n. 30273/2024, Cavallaro, Rv. 672938-01**, si è soffermata sul presupposto previsto per la loro fruizione dall'art. 1, comma 1175, l.

n. 296 del 2006, e cioè il possesso del cd. DURC (Documento unico di regolarità contributiva), affermando che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell'INPS, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale.

Agevolazioni contributive sono rappresentate anche dai benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni di legge in materia di contratti di riallineamento retributivo, con le quali si è consentito alle imprese collocate in territori disagiati, e che erano inadempienti agli obblighi retributivi, di pervenire ad una graduale regolarizzazione delle loro posizioni contributive attraverso la stipula di accordi e collettivi con le organizzazioni sindacali volti ad allineare i trattamenti retributivi corrisposti ai propri dipendenti ai livelli stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore.

Con riferimento a tale tipo di agevolazioni, **Sez. L, n. 11211/2024, Marchese, Rv. 671003-01**, ha stabilito che in base allo *ius superveniens* di cui all'art. 3-ter del d.l. n. 103 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2021, di interpretazione autentica dell'art. 10 della l. n. 199 del 2016 in tema di accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo, gli accordi aziendali di recepimento di detti accordi provinciali devono intendersi legittimamente stipulati anche in presenza della sottoscrizione della sola associazione imprenditoriale a cui è iscritta l'impresa interessata e firmataria dell'accordo provinciale e, se prevedono un programma di riallineamento graduale, possono essere integrati da intese sottoscritte anche dopo il 17 ottobre 2001, purché prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l.

Sez. L, n. 03976/2024, Gnani, Rv. 670045-01, si è pronunciata con riferimento ai presupposti per poter beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, e cioè l'applicazione del c.c.n.l. del settore produttivo dell'impresa, affermando che il datore di lavoro che intendere fruirne è tenuto ad applicare tale c.c.n.l., poiché la classificazione dei datori di lavoro operata dall'INPS, ai sensi dell'art. 49 della l. n. 88 del 1989, vincola all'applicazione del c.c.n.l. riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l'impresa.

4. Totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali.

Attraverso l'istituto della totalizzazione è possibile acquisire, nonostante il versamento di contributi effettuato in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, il diritto a un unico trattamento pensionistico.

La totalizzazione, ricorrendone i presupposti di legge, è completamente gratuita per l'assicurato che intende beneficiarne, a differenza della ricongiunzione di periodi assicurativi, mirante ad analogo risultato, che è invece onerosa.

Della totalizzazione di contributi si è occupata **Sez. L, n. 18960/2024, Buffa, Rv. 672000-01**, con riferimento ad una fattispecie riguardante una lavoratrice frontaliera residente in Italia e che svolgeva il proprio lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell'indennità di disoccupazione a carico dell'ente previdenziale italiano; la decisione ha affermato che alla lavoratrice spetta l'indennità di maternità alle stesse condizioni di chi ha lavorato in Italia, ai sensi dell'allegato 2, sezione A, del regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione n. 1 del 2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, in quanto - per il principio di parità di trattamento posto dall'art. 4 del regolamento ed in applicazione dell'art. 6 del medesimo, secondo cui deve tenersi conto

dei periodi di assicurazione ed occupazione maturati in base alla disciplina di altro Stato membro (cd. totalizzazione) - è irrilevante il mancato svolgimento di attività lavorativa in Italia.

In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni, **Sez. L, n. 14858/2024, Gnani, Rv. 671304-01**, ha dettato alcuni interessanti chiarimenti in ordine al meccanismo attraverso il quale pervenire a detto risultato, con riferimento alla ricongiunzione presso l'AGO di periodi assicurativi con iscrizione a gestioni previdenziali per i liberi professionisti. A tal riguardo, la predetta decisione ha affermato che l'accettazione, da parte del lavoratore, della proposta formulata dall'ente preposto alla gestione previdenziale accentratrice implica la conclusione di un accordo di natura pubblicistica, che ha ad oggetto anche i costi e le modalità della ricongiunzione e, una volta perfezionato, non è revocabile, salvo il caso di errore. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto irretrattabile l'accordo sull'ammontare dovuto per la costituzione della riserva matematica volta a far fronte alle future prestazioni pensionistiche, conosciuto dal lavoratore, al pari dell'importo del rateo pensionistico da liquidare comunicatogli dall'Inps.

5. Omissione contributiva e posizione del lavoratore.

In materia di omesso versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro, deve registrarsi innanzitutto un'interessante decisione, intervenuta a delineare le implicazioni connesse al principio di automaticità delle prestazioni sancito dall'art. 2116, comma 1, c.c.

Sez. L, n. 00701/2024, Cavallaro, Rv. 669765-01, ha infatti precisato che il principio anzidetto, salvo il caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla l. n. 29 del 1979, e salva altresì la speciale ipotesi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1992, non comporta alcun accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in parte dal datore di lavoro, ma garantisce al lavoratore il diritto alle prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 2114 c.c. anche quando si sia verificato tale inadempimento.

Sempre con riferimento al predetto principio di automaticità delle prestazioni, **Sez. L, n. 15294/2024, Buffa, Rv. 671225-01**, ha affermato che esso non opera per i lavoratori autonomi, con la conseguenza che, in caso di decesso del lavoratore autonomo, il coniuge superstite non ha diritto alla pensione se l'assicurato, al momento del decesso, non poteva far valere il minimo di contribuzione richiesto dalla legge, pur restando impregiudicata la facoltà dei superstiti di versare i contributi omessi dal dante causa, con conseguente maturazione successiva del requisito utile alla pensione stessa.

Detto principio - ha affermato **Sez. L, n. 30474/2024, Cerulo, Rv. 672692-01** - non si applica nemmeno ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015.

Sez. L, n. 00701/2024, Cavallaro, Rv. 669765-02, in precedenza richiamata, ha aggiunto un'ulteriore puntualizzazione sulle conseguenze dell'omissione contributiva, avendo enunciato il principio secondo cui il lavoratore, nel caso in cui il suo datore di lavoro non abbia adempiuto all'obbligo di versamento dei contributi dovuti, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, e ciò nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto al recupero di detti contributi e questi si siano prescritti, potendo egli agire solo nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivato dalla perdita delle prestazioni previdenziali in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo contributivo, o chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962.

La stessa decisione, enunciando altro principio, massimato *sub* n. **Rv. 669765-03**, ha infine chiarito che sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c. (si rinvia al paragrafo 14 del capitolo sul processo del lavoro e previdenziale per l'esame di altre questioni relative al tema del litisconsorzio).

Il diritto alla rendita vitalizia *ex* art. 13 della l. n. 1338 del 1962 ha costituito l'oggetto della pronuncia di **Sez. L, n. 04528/2024, Solaini, Rv. 670051-01**, la quale ha stabilito che la domanda volta alla costituzione di detta rendita non è assoggettabile alla decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, poiché la stessa non concerne una prestazione pensionistica, ma consiste, piuttosto, in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.

In termini generali, **Sez. L, n. 12400/2024, Marchese, Rv. 670931-01**, ha puntualizzato che il *dies a quo* della decadenza prevista dall'art. 47, comma 6, del d.P.R. n. 639 del 1970 decorre dal riconoscimento parziale della prestazione temporanea o del trattamento pensionistico, sicché i termini della procedura amministrativa pregressa sono esclusi dal relativo computo.

Sez. L, n. 28671/2024, Marchese, Rv. 672690-01, al riguardo, ha affermato che la decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell'INPS in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell'INPS, l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

In tema di azione volta alla costituzione della rendita vitalizia, **Sez. L, n. 12833/2024, Cavallaro, Rv. 671183-01**, si è occupata di chiarire la portata della previsione dell'art. 13, commi 4 e 5, l. n. 1338 del 1962, stabilendo che essa va interpretata nel senso che, salvo il caso che si accerti la fittizietà dei documenti, la prova scritta dell'esistenza e durata del rapporto (presupposti per la costituzione della rendita) esime da ogni altra dimostrazione circa il concreto svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto il prestatore è gravato da un'obbligazione di *facere*, i cui tempi e modalità sono decisi dal datore di lavoro, che, *ex* art. 12, l. n. 153 del 1969, resta obbligato a corrispondere la contribuzione dovuta perfino in assenza di una effettiva prestazione, purché il rapporto di lavoro sia giuridicamente esistente.

Problematiche connesse a quelle appena illustrate sono state esaminate da **Sez. L, n. 11730/2024, Riverso, Rv. 671009-01**, la quale ha evidenziato che il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS.

6. Accertamento e riscossione.

Il recupero dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge, o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici a ciò preposti, avviene secondo la procedura di iscrizione a ruolo, disciplinata dal d.lgs. n. 46 del 1999, che detta regole peculiari per i crediti degli enti previdenziali.

In particolare, l'art. 24 del d.lgs. n. 46 cit. dispone che il contribuente può opporsi all'iscrizione per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva entro quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.

L'art. 30 del d. l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, richiamando la procedura prevista dall'art. 24 cit., ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, anziché della cartella di pagamento.

A tal proposito occorre segnalare la decisione pronunciata da **Sez. L, n. 19985/2024, Gnani, Rv. 671884-01**, la quale ha precisato che l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di *litis denuntiatio*, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione.

Sez. L, n. 07285/2024, Gnani, Rv. 670447-01, si è occupata delle ripercussioni che possono avere sui crediti contributivi iscritti a ruolo le procedure di definizione agevolata dei carichi previste da varie norme di legge.

Con riferimento a tale definizione agevolata, la decisione anzidetta ha affermato che la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013 non si applica ai crediti previdenziali dell'INPS, ente pubblico non statale che non rientra tra i soggetti menzionati dall'art. 1, comma 618, della medesima legge, il quale considera i soli enti locali e ed uffici dello Stato come soggetti che possono emettere i ruoli oggetto della definizione agevolata in esso disciplinata.

Altra forma particolare di definizione agevolata, e precisamente quella autorizzata in presenza di calamità naturali per effetto di provvedimenti di protezione civile, è stata presa in esame da **Sez. L, n. 11058 /2024, Mancino, Rv. 671001-01**, la quale in proposito ha chiarito che l'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, *ratione temporis* vigente, ha stabilito una nuova modalità di definizione agevolata del debito contributivo residuo conseguente alla sospensione dei versamenti, e successiva loro rateizzazione a decorrere dal mese di giugno 2004, regolate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2005 n. 3442 e dalle sue successive modifiche, ma non ha ulteriormente prorogato detta sospensione fino al 30 giugno 2007, termine previsto solo per sanare la posizione di quanti avessero già iniziato ad adempiere ai versamenti rateali da giugno 2004 senza avere, tuttavia, completato i pagamenti. In applicazione di tale principio, la S.C. ha quindi confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione a cartella di pagamento proposta da soggetto che, omesso ogni versamento dal giugno 2004, assumeva di poter beneficiare della definizione agevolata mediante pagamento, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2007.

7. La prescrizione dei crediti contributivi.

In ordine alla prescrizione dei crediti contributivi dell'INPS, **Sez. L, n. 30526/2024, Garri F., Rv. 672693-01**, ha affermato che la presentazione del modello EMENS - con il quale

il datore di lavoro dichiara all'INPS le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e i contributi dovuti - costituisce adempimento di un obbligo di legge, che presuppone la consapevolezza da parte dell'imprenditore del contenuto di detto atto, nonché la volontà di manifestarlo, con la conseguenza che, in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto del modello, la dichiarazione in esso riportata è atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

Sez. L, n. 06154/2024, Cavallaro, Rv. 670349-03, si è pronunciata in ordine agli effetti che può produrre sulla prescrizione dei crediti per contributi assicurativi la richiesta di rateazione presentata dall'obbligato successivamente allo spirare del relativo termine prescrizione, affermando che tale richiesta non può configurarsi come rinuncia alla prescrizione per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.

Diverse decisioni hanno preso in esame, invece, la prescrizione dei crediti relativi ai contributi da versare alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995.

A tal proposito, **Sez. L, n. 24186/2024, Marchese, Rv. 672240-01**, ha affermato che la prescrizione di tali contributi decorre non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'obbligato ma dal momento in cui scade il termine, anche eventualmente prorogato - nella specie *ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010* - per il pagamento degli stessi, non rilevando la previsione nelle normative di settore di un ulteriore secondo termine di pagamento, funzionale al solo saldo dei debiti contributivi già scaduti con maggiorazione degli interessi di mora.

Ha ribadito tale principio, con ulteriore precisazione, anche **Sez. L, n. 24584/2024, Mancino, Rv. 672465-01**, la quale ha affermato che la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e si applica anche il differimento previsto dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009, per il quale rileva il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale.

Sez. L, n. 28594/2024, Cerulo, Rv. 672687-01, ha precisato che in relazione alla prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, rilevante ai fini della sospensione della prescrizione, dovendosi invece valutare caso per caso, unitamente ad altri elementi, se attraverso la mancata compilazione di detto quadro si sia effettivamente perseguito l'occultamento in questione.

Con riferimento invece alla prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive per i pubblici dipendenti **Sez. L, n. 31060/2024, Cavallaro, Rv. 672989-01**, ha precisato che l'art. 3, comma 10-*bis*, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019) - che prevede che i termini di prescrizione dei contributi di cui ai precedenti commi 9 e 10 "non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato" - non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni anzidette ma ha previsto, con effetti retroattivi, il differimento della data di entrata in vigore della disciplina concernente la prescrizione dei contributi dovuti a tali gestioni, con la conseguenza che è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma.

8. Gli elenchi dei lavoratori agricoli.

Con riferimento alla tematica degli elenchi nei quali i lavoratori del settore agricolo devono iscriversi per beneficiare delle prestazioni previdenziali ad essi riservate, **Sez. L, n. 07967/2024, Buffa, Rv. 670536-01**, ha affermato che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale inerente all'indennità di disoccupazione agricola, la quale pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.

Lo stesso principio è stato successivamente ribadito anche da **Sez. L, n. 07986/2024, Buffa, Rv. 670536-01**, che ha altresì enunciato l'ulteriore principio, massimato *sub* n. **Rv. 670550-01**, secondo il quale il termine di decadenza di centoventi giorni - previsto dall'art. 22 soprarichiamato, per impugnare in sede giurisdizionale la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli - decorre in ogni caso dalla data in cui il relativo provvedimento amministrativo diviene definitivo, indipendentemente dalla causa per cui si verifica la definitività.

9. La prosecuzione volontaria del versamento dei contributi.

La prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mira ad elidere le conseguenze negative che si producono per l'assicurato, nell'ipotesi di mancata prestazione di un'attività lavorativa soggetta all'obbligo assicurativo; essa costituisce una deroga al principio della corrispondenza della contribuzione all'effettiva attività lavorativa, cosicché si ritiene che essa può avvenire solo entro i confini tracciati dalla legge.

Di tali principi ha fatto applicazione **Sez. L, n. 31403/2024, Cerulo, Rv. 673118-01**, affermando che la prosecuzione volontaria dell'AGO per i lavoratori dipendenti è preclusa nelle sole ipotesi tassative previste dalla legge, come quelle di sovrapposizione tra contribuzione volontaria e contribuzione obbligatoria per l'iscrizione in altra gestione previdenziale sostitutiva o speciale *ex* art. 5 del d.P.R. n. 1432 del 1971, sicché tale prosecuzione non è preclusa dallo svolgimento di lavoro agricolo per un periodo di tempo, corrispondente a quello coperto da contribuzione volontaria, ma inidoneo a far sorgere un valido rapporto obbligatorio previdenziale senza l'integrazione facoltativa del minimo dei contributi di cui all'art. 4 del medesimo d.P.R., la quale non può essere disposta dall'INPS convertendo d'imperio la richiesta di prosecuzione volontaria in quella per detta integrazione (nella specie, la S.C. ha confermato l'illegittimità di tale conversione, che aveva impedito ad una lavoratrice, già autorizzata alla prosecuzione volontaria della contribuzione nell'AGO, a conseguire la pensione secondo il più favorevole regime pro tempore vigente).

Sez. L, n. 13099/2024, Gnani, in corso di massimazione, si è occupata della prosecuzione volontaria quale fattispecie che consente, in forza della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 265, della l. n. 208 del 2015, di fruire dei requisiti di accesso al pensionamento vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, precisando che detta disposizione presuppone l'interruzione del rapporto di lavoro, sicché essa non è applicabile al rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

La materia dell'accesso al trattamento pensionistico in base ai requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 cit., è oggetto più specifico delle decisioni richiamate nel capitolo successivo, *sub* paragrafo n. 2

CAPITOLO XXIV

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

(DI MARIO DE IORIS)

SOMMARIO: 1. La contribuzione figurativa e le maggiorazioni contributive. - 2. Le prestazioni pensionistiche. - 3. Il cumulo dei trattamenti: divieti e facoltà di opzione. - 4. L'indennità di disoccupazione. - 5. L'indennità di mobilità. - 6. L'Assicurazione sociale per l'Impiego (ASpI). - 7. La Nuova Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI). - 8. La Cassa integrazione guadagni. - 9. Il TFR e le altre prestazioni corrisposte dal Fondo di garanzia *ex art. 2* della legge n. 297 del 1982. - 10. Indennità di buonuscita e trattamenti analoghi. - 11. L'indebito previdenziale. 12. La responsabilità per danni degli enti previdenziali e nei loro confronti.

1. La contribuzione figurativa e le maggiorazioni contributive.

La legge prevede casi in cui, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva necessaria per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali, vengono riconosciuti periodi di contribuzione figurativa (mediante l'accredito, sul conto assicurativo del lavoratore, di contributi "fittizi", ossia non versati effettivamente né dal datore di lavoro né dal lavoratore), allo scopo di tutelare il lavoratore qualora si sia verificata una temporanea sospensione o riduzione dell'attività lavorativa oppure la cessazione del rapporto di lavoro.

In altre ipotesi, invece, sono previste maggiorazioni contributive, attraverso il riconoscimento di contributi aggiuntivi rispetto al servizio effettivo prestato, determinandosi quindi una anzianità contributiva convenzionale che si somma a quella effettiva e che consente al lavoratore di raggiungere anticipatamente il requisito contributivo necessario per il conseguimento della prestazione previdenziale o di incrementare, a seconda dei casi, la misura del reddito pensionistico.

Nell'ambito di tali maggiorazioni, particolare rilievo hanno assunto quelle previste in favore dei lavoratori che hanno subito un'esposizione qualificata all'amianto, ad opera di diversi provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo, il cui stratificarsi ha comportato qualche incertezza applicativa in ordine alla individuazione dei destinatari dei benefici in questione nei termini di volta in volta stabiliti dal legislatore.

Sez. L, n. 04729/2024, Buffa, Rv. 670161-01, ha fatto chiarezza in ordine a tali destinatari, stabilendo che la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, commi 7 e 8, della l. n. 257 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 169 del 1993, conv. con l. n. 271 del 1993, a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa della esposizione all'amianto, o che siano stati esposti a detta sostanza nociva per un periodo ultradecennale, non spetta - in virtù di un'interpretazione che la Corte cost., con sentenza n. 434 del 2002, ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38 Cost. - ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità.

La stessa decisione ha precisato che la maggiorazione anzidetta deve invece essere riconosciuta - ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle citate disposizioni - ai lavoratori che, a quella medesima data del 28 aprile 1992 prestavano ancora attività di lavoro dipendente ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero ancora erano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità, essendo anche questi ultimi interessati ad incrementare la posizione assicurativa per conseguire le prestazioni di vecchiaia.

Sez. L, n. 30625/2024, Garri F., Rv. 673148-01, ha invece affermato che detta maggiorazione non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa.

Sez. L, n. 23696/2024, Marchese, Rv. 672228-01, ha operato un'importante puntualizzazione con riferimento alle diverse normative susseguitesi nel tempo, affermando che il fondamento normativo del beneficio della anzidetta rivalutazione contributiva è l'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, che prende in considerazione solo l'esposizione decennale senza identificare un arco temporale di riferimento, cosicché la possibilità di valutare l'esposizione all'amianto per i periodi successivi al 1992 non è ascrivibile alla normativa sopravvenuta dettata dalla l. n. 247 del 2007, il cui art. 1, comma 20, si limita ad introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate.

Analogo rilievo chiarificatore deve attribuirsi a **Sez. L, n. 26092/2024, Marchese, Rv. 672584-01**, la quale ha affermato che, in tema di benefici in materia di amianto ai sensi dell'art. 1, comma 115, della l. n. 190 del 2014, non costituisce presupposto per l'operatività della rivalutazione dell'anzianità contributiva con il più favorevole coefficiente previsto dall'art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 la collocazione in mobilità di tutti i dipendenti dell'impresa, ma soltanto di quelli esposti all'amianto in quanto addetti alla lavorazione poi cessata. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che sia il mantenimento in servizio di un unico lavoratore per custodire l'immobile aziendale, con finalità quindi estranea alla lavorazione dismessa, sia la temporanea riassunzione del richiedente il beneficio per l'effettuazione di opere di mera bonifica del sito non escludono l'applicazione del miglior coefficiente di rivalutazione).

Uno dei presupposti per il riconoscimento della maggiorazione contributiva in esame è che l'INAIL abbia certificato l'esposizione qualificata ad amianto del lavoratore ai sensi dell'art. 13 della l. n. 257 del 1992, e che tale certificazione sia stata allegata alla domanda amministrativa rivolta all'INPS di rivalutazione contributiva.

In proposito si è pronunciata **Sez. L, n. 23552/2024, Buffa, Rv. 672200-01**, enunciando il seguente principio: la domanda amministrativa di una prestazione previdenziale, per la quale costituisce presupposto necessario l'accertamento di un fatto demandato ad un'amministrazione diversa da quella tenuta alla sua erogazione, dev'essere corredata dalla documentazione contenente detto accertamento, risultando altrimenti incompleta nei suoi elementi essenziali, con conseguente improcedibilità della successiva domanda giudiziale (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto il ricorso dell'assicurato in ragione dell'omessa allegazione, alla domanda amministrativa rivolta all'INPS di rivalutazione contributiva per l'esposizione qualificata ad amianto, della certificazione INAIL inerente tale esposizione).

Con riferimento alla procedura per il riconoscimento del beneficio in esame, **Sez. L, n. 34943/2024, Orio, Rv. 673326-01**, ha affermato che la domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente all'erogazione della prestazione, sicché, in mancanza di tale domanda (che ha carattere costitutivo), il relativo diritto, non essendo stato acquisito al patrimonio del lavoratore, neppure è trasmissibile, in caso di decesso, agli eredi.

Sez. L, n. 27149/2024, Marchese, Rv. 672761-01, ha preso in esame la maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto sotto il profilo processuale, affermando che nel giudizio intrapreso dall'assicurato per il riconoscimento contestuale della maggiorazione contributiva e dell'esatta quantificazione dei ratei di pensione così maggiorata, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS in relazione alla quantificazione dei ratei di pensione non si estende al diritto alla rivalutazione contributiva (c.d. diritto stipite); di contro, l'eccezione sollevata con riguardo alla rivalutazione si riverbera sulla quantificazione dei ratei, in quanto la prescrizione del diritto alla rivalutazione esclude, a monte, una diversa misura del trattamento pensionistico.

Sez. L, n. 07382/2024, Cerulo, Rv. 670598-01, ha esaminato, poi, un caso particolare di maggiorazione contributiva, e cioè quella prevista dall'art. 27, comma 2-*bis*, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con l. n. 30 del 1997, affermando, con riferimento al caso di specie (relativo ad una cooperativa di facchinaggio), che essa spetta esclusivamente per gli aumenti contributivi effettivi conseguenti all'applicazione del decreto ministeriale del 21 febbraio 1996, attuativo dell'art. 3, comma 23, della l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto beneficio va riconosciuto quando l'innalzamento dell'aliquota contributiva di finanziamento, dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non è compensata dalla contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della l. n. 88 del 1989, mentre non spetta in relazione alle agevolazioni che, ad altro titolo, siano successivamente riconosciute all'obbligato in ordine ai c.d. contributi minori, come quelle previste dall'art. 120 della l. n. 388 del 2000, in quanto esse si pongono al di fuori del meccanismo compensativo delineato dal citato art. 3, comma 23, l. n. 335 del 1995.

Altra peculiare fattispecie di maggiorazione contributiva è quella prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 1092 del 1973, per la quale **Sez. L, n. 31599/2024, Cerulo, Rv. 673120-01**, ha affermato che essa non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, al dipendente dell'aeronautica militare, transitato in ENAV (Ente nazionale assistenza volo) prima della maturazione del diritto alla pensione, precisando però che i periodi di contribuzione figurativa maturati in aeronautica non restano infruttuosi, dal momento che rilevano ai fini del riconoscimento della indennità *una tantum* prevista dall'art. 124 del medesimo d.P.R., *ratione temporis* applicabile.

Affine alla materia delle maggiorazioni contributive è quella dei benefici "combattentistici" di cui all'art. 2 della l. n. 336 del 1970, sui quali si è soffermata **Sez. L, n. 28433/2024, Garri F., Rv. 672683-01**, la quale ha affermato che tale disposizione prevede un compenso personalizzato e differenziato, collegato alla retribuzione e pensione in godimento ed alle sue modalità di progressione, oltre che riassorbibile, il quale, pertanto, differisce dal beneficio (pur previsto in favore degli *ex* combattenti, ma non rientranti tra le categorie di personale pubblico indicate dall'art. 1 della l. n. 336 del 1970) previsto dall'art. 6, comma 7, della l. n. 140 del 1985, il quale consiste in una maggiorazione del trattamento pensionistico fissa, uguale per tutti, non riassorbibile, che non incide su altri istituti (come il diritto di integrazione al minimo).

Su tali presupposti la stessa decisione ha affermato altro principio, di cui alla massima *sub* n. **Rv. 672683-02**, secondo cui in tema di benefici combattentistici, l'importo da prendere a parametro per la quantificazione dell'incremento della pensione integrativa a carico del Fondo pensionistico integrativo degli *ex* dipendenti INPS, *ex* art. 2 della l. n. 336 del 1970, è quello cristallizzato alla data di soppressione di tale Fondo *ex* art. 64 l. n. 144 del 1999, eventualmente rivalutato alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non potendo, quindi, coincidere con l'importo della retribuzione percepita al momento di detta cessazione.

Quanto alle contribuzioni figurative, l'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede, in favore dei lavoratori affetti da determinate invalidità (fra cui un'invalidità in misura superiore al 74%), il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio.

Con riferimento a tale beneficio, **Sez. L, n. 00716/2024, Cerulo, Rv. 669766-01**, ha precisato che esso rileva ai soli fini del diritto a pensione e della connessa anzianità contributiva, ma non può ritenersi utile al raggiungimento dell'anzianità contributiva, pari o superiore a dieci anni, prescritta per la fruizione dell'indennità disciplinata dall'art. 39, comma 1, della l. n. 448 del 2001, vale a dire una speciale indennità prevista in favore dei lavoratori affetti da talassemia *major* (morbo di *Cooley*) e drepanocitosi, i quali siano titolari di un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni. La S.C., in particolare, ha escluso che il beneficio di cui al citato art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000 possa essere utile al raggiungimento dell'anzianità decennale anzidetta, poiché è espressamente previsto che tale maggiorazione è utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva per esso necessaria, mentre l'indennità sopra richiamata non ha carattere pensionistico.

Sulla stessa contribuzione figurativa prevista dall'art. 80, comma 3, cit., si è pronunciata anche **Sez. L, n. 13102/2024, Gnani, Rv. 670940-01**, affermando che essa è utile ai soli fini dell'anzianità contributiva e della maturazione del diritto alla pensione, ma non per l'incremento del montante contributivo complessivo ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione.

Sempre con riferimento alle tematiche inerenti la contribuzione figurativa, **Sez. L, n. 11336/2024, Solaini, Rv. 671007-01**, ha precisato che non può essere utilizzato come periodo di contribuzione figurativa - utile ai fini sia del sorgere del diritto che della determinazione della misura della pensione - il periodo di godimento della indennità di disoccupazione in mancanza di un anno di contributi obbligatori versati all'INPS nel quinquennio antecedente il verificarsi dell'evento protetto, come espressamente previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 818 del 1957.

2. Le prestazioni pensionistiche.

Come verificatosi nel 2023, anche nel 2024 sono state adottate numerose decisioni riguardanti fattispecie derogatorie dei principi generali fissati dall'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, disposizione volta a perseguire la stabilità economico-finanziaria e rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, in conformità ai principi dell'equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, della flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici e dell'adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita.

La realizzazione di tali obiettivi è stata affidata a diversi strumenti previsti dalla medesima disposizione, fra cui una rivisitazione complessiva delle prestazioni pensionistiche, che ha visto - a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data - il venir meno della pensione di anzianità e l'introduzione di nuovi requisiti e condizioni di accesso per la pensione di vecchiaia, e di vecchiaia anticipata.

Diverse disposizioni di legge, entrate in vigore successivamente, hanno però introdotto misure derogatorie delle norme introdotte dall'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 in tema di requisiti per la maturazione del diritto a pensione e sue decorrenze, consentendo così il pensionamento secondo le regole previgenti, al fine di "salvaguardare" situazioni particolari, ritenute meritevoli di tutela, come ad esempio quella dei lavoratori coinvolti in procedure di mobilità che, secondo la normativa previgente al d.l. n. 201 del 2011, avrebbero

potuto accedere al trattamento pensionistico non appena cessata la fruizione dell'indennità di mobilità e che, viceversa, in considerazione dell'immediato innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione previsti dal citato d.l. n. 201, si sarebbero trovati alla fine del periodo di mobilità non ancora nella possibilità di godere del trattamento pensionistico, restando così privi di occupazione, di sostegno al reddito e di pensione.

Misure di salvaguardia di questo tipo sono state introdotte anche dall'art. 1, comma 194, l. n. 147 del 2013, per varie fattispecie identificate con le lettere da a) ad f).

Sez. L, n. 23414/2024, Cavallaro, Rv. 672143-01, si è pronunciata in ordine a tali fattispecie, stabilendo che la misura di salvaguardia di cui alla norma generale dettata dall'art. 1, comma 194, lett. d), l. n. 147 del 2013, relativa ai lavoratori collocati in mobilità prima del 4 dicembre 2011, si applica anche ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo, il cui collocamento in mobilità sia cessato al 4 dicembre 2011, data di entrata in vigore dell'art. 24, d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, in quanto, in difetto dei presupposti per l'applicazione della salvaguardia di cui alla successiva lett. e), anche il licenziamento collettivo costituisce un'ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Peraltro, misure di salvaguardia erano state approvate già a ridosso dell'entrata in vigore dell'art. 24, d.l. n. 201 del 2011 cit., fra cui quelle disposte dall'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 216 del 2011, conv. dalla l. n. 14 del 2012.

Sez. L, n. 27238/2024, Mancino, Rv. 672666-01, ha affermato che la salvaguardia di cui al citato art. 6, comma 2-ter - che si inserisce nel novero delle previsioni derogatorie di cui all'art. 24, commi 14 e 15, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 - si applica ai soli lavoratori subordinati e non anche a quelli autonomi, in ragione sia della lettera della disposizione, di stretta interpretazione in quanto eccezionale, che si riferisce alla risoluzione dei "rapporti di lavoro" (e quindi ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 e ss. c.c.), sia della *ratio* di tutela sottesa alla norma (impedire che chi ha perso il lavoro si trovi senza stipendio e senza pensione), non ravvisabile in capo ai lavoratori autonomi che non subiscono l'*alea* del recesso datoriale né quella della ricerca di un nuovo impiego.

Norme derogatorie delle disposizioni dettate dall'art. 24, d.l. n. 201 del 2011 cit., sono state introdotte anche successivamente, in più riprese, fra cui anche dall'art. 1, comma 265, l. n. 208 del 2015, per diverse categorie di soggetti che si trovavano in condizioni anch'esse ritenute meritevoli della conservazione del trattamento più favorevole vigente prima del d.l. n. 201 del 2011.

Con riferimento a tale tematica **Sez. L, n. 23411/2024, Cavallaro, Rv. 672198-01**, ha affermato che il regime derogatorio dei requisiti per l'accesso alla pensione di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 - esteso temporalmente, nella ricorrenza dei presupposti di legge, in virtù dell'art. 1, comma 265, lett. c), l. n. 208 del 2015 - si applica ai lavoratori che, dopo la risoluzione del rapporto, non hanno svolto attività riconducibile al paradigma del lavoro dipendente a tempo indeterminato, con la conseguenza che l'assunzione in prova non esclude l'applicazione della deroga nel caso in cui il rapporto venga risolto prima del superamento della stessa.

Sez. L, n. 23419/2024, Cavallaro, Rv. 672144-01, ha precisato che il predetto regime derogatorio di cui all'art. 1, comma 265, lett. a), l. n. 208 del 2015, prevede deroghe solo per i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze, e non riguardo alle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici, sicchè deve escludersi che il ricalcolo delle pensioni in applicazione di tale regime possa effettuarsi sulla base del sistema integralmente retributivo.

Con riferimento alla pensione di vecchiaia, **Sez. L, n. 29768/2024, Cavallaro, Rv. 673021-01**, ha analizzato l'opzione per la liquidazione di tale trattamento pensionistico esclusivamente

con le regole del sistema contributivo, ed ha affermato che se essa è stata esercitata successivamente alla modifica dell'art. 1, comma 23, della l. n. 335 del 1995, ad opera dell'art. 24, comma 7, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, non è consentito all'assicurato di mantenere il più favorevole regime di accesso alla prestazione di vecchiaia prevalgente rispetto alle predette modifiche.

La pensione di vecchiaia prevista per i pubblici dipendenti è stata oggetto di indagine, invece, in **Sez. L, n. 29183/2024, Bellè, Rv. 673018-01**, pronunzia esaminata nel capitolo dedicato al pubblico impiego contrattualizzato al paragrafo n. 10.

In tema di pensione di vecchiaia anticipata, **Sez. L, n. 22227/2024, Buffa, Rv. 671945-01**, ha precisato che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità.

In tema di pensione anticipata **Sez. L, n. 24916/2024, Buffa, Rv. 672467-01**, ha affermato che, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, il presupposto contributivo è integrato anche dal versamento dei contributi figurativi, diversamente da quanto previsto nel sistema di cui al successivo comma 11, il quale - consentendo l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo - richiede, invece, l'effettivo versamento della contribuzione.

Sez. L, n. 24950/2024, Buffa, Rv. 672468-01, si è pronunciata, poi, su una prestazione assimilabile alla pensione anticipata, e cioè il cd. APE sociale (anticipo pensionistico) ex art. 1, comma 179, della l. n. 232 del 2016, stabilendo che, ai fini del riconoscimento del diritto al relativo godimento, il richiedente deve essere disoccupato e non percepire più - quando ne abbia in precedenza beneficiato - l'indennità di disoccupazione.

In ordine alla medesima prestazione **Sez. L, n. 30258/2024, Buffa, Rv. 672937-01**, ha affermato che i requisiti per l'accesso alla provvidenza, ossia lo stato di disoccupazione successivo ad un'occupazione lavorativa dipendente per almeno diciotto mesi nei trentasei precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, vanno riferiti all'ultimo dei rapporti lavorativi - a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi - prima della prestazione, mentre è irrilevante che dopo la cessazione di detto rapporto vi sia stata rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi.

In tema di pensione di anzianità, **Sez. L, n. 23034/2024, Garri F., Rv. 672268-01**, ha chiarito che per il riconoscimento di tale prestazione deve sussistere, al momento della presentazione della domanda amministrativa, la condizione di inoccupazione che, al pari del requisito contributivo, è elemento costitutivo per il suo conseguimento; pertanto, la sussistenza di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato è circostanza ostativa al riconoscimento di tale pensione, trattandosi di contratto di lavoro subordinato che si caratterizza per la peculiare forma di utilizzazione della forza lavoro nell'ambito di un rapporto che, per tutta la sua durata, è in atto con vincoli persistenti per entrambe le parti. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto occupato il ricorrente l'iscritto all'ENPALS e che versava i contributi in relazione a un rapporto di lavoro intermittente, occasionalmente quiescente in coincidenza con la presentazione della domanda amministrativa di pensione di anzianità.

Con riferimento alle prestazioni pensionistiche in favore di cittadini stranieri trasferitisi in Italia, **Sez. L, n. 32121/2024, Cavallaro, Rv. 673298-01**, ha affermato che va applicata la legislazione dello Stato obbligato a corrispondere la prestazione previdenziale, in quanto le prestazioni pensionistiche, stante la loro natura pubblicistica, sono sottratte all'ambito applicativo della l. n. 218 del 1995 e ricadono nella disciplina dell'art. 11 del Regolamento CE n. 883 del 2004, non rilevando, quindi, la residenza del pensionato in altro Stato membro, come pure la maturazione del giudicato interno sulla giurisdizione italiana (principio affermato, in relazione alla richiesta da parte di un notaio tedesco, integralmente soggetto al sistema di sicurezza sociale di quello Stato, stabilitosi in Italia da pensionato, di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione di somme corrispostegli dalla *Notarkasse A.D.O.R.*).

Sez. L, n. 12592/2024, Gnani, Rv. 670985-01, ha esaminato la particolare disciplina previdenziale prevista per i lavoratori dello spettacolo, la quale ha subito diversi mutamenti nel corso nel tempo, anche sotto il profilo dell'ente previdenziale chiamato a curare la relativa gestione ed i procedimenti ad essa connessi.

Detta decisione, si è occupata proprio dei mutamenti anzidetti, affermando che se il rapporto assicurativo dei lavoratori dello spettacolo è iniziato in epoca precedente il d.lgs. n. 182 del 1997 ed è poi proseguito fino al pensionamento nel vigore di esso, per il primo periodo - quello anteriore al d.lgs. innanzi ricordato - l'anzianità contributiva si calcola secondo le norme previgenti, *ratione temporis* applicabili.

La stessa decisione, enunciando altro principio, massimato sub **Rv. 670985-02**, ha affermato, poi, che se il rapporto assicurativo è iniziato in epoca precedente al d.lgs. n. 182 del 1997 e proseguito nel vigore dello stesso, il primo periodo - quello antecedente l'entrata in vigore del citato d.lgs. - non è da inserire in alcuno dei gruppi di cui all'art. 2, comma 1, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva previsto dal comma 4, in quanto opera *ex nunc* la verifica di prevalenza ivi prevista e, cioè, se sia maggiore l'anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del d.m. 10.11.97 (gruppo B) o quella maturata sotto la vigenza del d.m. 15.3.2005 (gruppo A), con conseguente riproporzionamento della contribuzione versata nel gruppo non prevalente, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 3, del menzionato d.lgs.

Sez. L, n. 11553/2024, Mancino, Rv. 671036-01, si è pronunciata con riferimento alle categorie di soggetti beneficiari della pensione di reversibilità, stabilendo che, all'esito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022, il diritto alla pensione di reversibilità previsto dall'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, conv. con modif. dalla l. n. 1272 del 1939, deve essere esteso - alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni previste per i figli - a favore dei nipoti maggiorenni orfani, riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati, precedentemente non inclusi fra i soggetti equiparati ai beneficiari della prestazione.

In ordine alla medesima tematica degli aventi diritto a tale prestazione, ed ai requisiti che gli stessi devono possedere, **Sez. L, n. 15041/2024, Buffa, Rv. 671379-01**, ha chiarito che in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se pure non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato, tuttavia, con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Con riferimento allo stato di inabilità del superstite, **Sez. L, n. 19530/2024, Solaini, Rv. 671871-01**, ha affermato che l'accertamento del requisito della inabilità di cui all'art. 8 l. n. 222 del 1984, richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico.

Sez. L, n. 23204/2024, Buffa, Rv. 672236-01, ha affrontato invece la fattispecie della cessazione della contitolarità della pensione di reversibilità, che si verifica quando viene a mancare la titolarità del trattamento in capo ad uno o più degli originari superstiti cui esso era stato attribuito.

Tale pronuncia ha chiarito che alla cessazione del regime di contitolarità tra i beneficiari del trattamento di reversibilità, la pensione del superstite residuo deve essere rideterminata tenendo conto non già di quanto percepito durante il periodo di titolarità comune, bensì operando un conteggio virtuale, a decorrere dalla data della morte del dante causa, che prenda a riferimento l'ammontare della pensione diretta a questo spettante, nella quale però, se già integrata al trattamento minimo *ex art. 6 d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 638 del 1983*, non possono comprendersi gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica introdotta dall'art. 4 l. n. 140 del 1985, poiché essi devono essere determinati tenendo conto dell'importo "a calcolo" della pensione del titolare e non di quello conseguente all'integrazione al minimo.

Con riferimento all'assegno ordinario di invalidità, **Sez. L, n. 08636/2024, Gnani, Rv. 670599-01**, ha evidenziato che l'accertamento, contenuto nella sentenza passata in giudicato, dell'insussistenza del requisito sanitario in relazione al primo triennio di fruizione di detto assegno estende i suoi effetti anche al triennio successivo, benché l'assegno sia stato riconosciuto in via amministrativa, perché il predetto accertamento non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui il riconoscimento, in sede amministrativa da parte dell'INPS, dell'assegno ordinario d'invalidità per il secondo triennio non faceva venire meno l'interesse dell'ente previdenziale a invocare il definitivo accertamento giudiziale, determinante il travolgimento del predetto riconoscimento, di insussistenza del diritto all'assegno.

Sez. L, n. 03973/2024, Gnani, Rv. 670044-01, si è pronunciata in ordine ai requisiti necessari per l'accesso all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei lavoratori in agricoltura, con particolare riguardo alla categoria dei coltivatori diretti.

Con questa decisione la S.C. ha stabilito che ai fini dell'applicazione della disciplina di tale assicurazione l'appartenente al nucleo familiare del coltivatore diretto, il quale chieda l'affermazione anche nei suoi riguardi di tale qualifica, deve allegare e provare, da un lato, il requisito della abitualità dell'attività manuale nella coltivazione dei terreni o nell'allevamento del bestiame - di modo che l'attività in questione abbia la caratteristica della prevalenza, per essere svolta in misura tale da impegnare il familiare per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca per lui la maggior fonte di reddito - e, dall'altro, che la forza lavoro dell'intero nucleo non sia inferiore ad un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo.

L'art. 2-ter del d.l. n. 30 del 1974, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 1974, *ratione temporis* vigente, prevede che il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati in dette gestioni speciali.

In tal modo viene data la possibilità - a chi ha già conseguito la pensione, per essere stato iscritto in una delle gestioni speciali contemplate dalla norma, e dopo il pensionamento abbia svolto attività di lavoro subordinato con relativa iscrizione alla gestione del Fondo per i lavoratori dipendenti - di conseguire un trattamento pensionistico più favorevole a carico di tale diversa gestione, utilizzando anche i contributi versati alle predette gestioni speciali.

Su tale possibilità si è pronunciata Sez. L, n. 04365/2024, Gnani, Rv. 670050-01, che ha ribadito la natura eccezionale della norma in esame, ed ha precisato che essa si applica solo ove ricorrono i presupposti innanzi evidenziati, cassando così la sentenza di merito con la quale la domanda proposta dall'assicurato - volta ad ottenere il mutamento del titolo della pensione a carico della gestione INPS dei coltivatori diretti in pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti - era stata accolta sul presupposto che, pur in difetto di svolgimento di attività lavorativa dopo il pensionamento ad opera dell'assicurato medesimo, fosse applicabile la sopra menzionata disposizione, conteggiando la maggiorazione contributiva dovuta all'esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa svolta precedentemente al pensionamento ma riconosciuta solo in epoca successiva.

Sez. L, n. 22059/2024, Marchese, Rv. 672327-01, si è occupata invece del trattamento pensionistico dei dirigenti già assicurati presso l'INPDAl e trasferiti, a seguito della soppressione di tale ente, nella gestione previdenziale dell'INPS, affermando in proposito che il principio del *pro rata*, contenuto nell'art. 42, comma 3, della l. n. 289 del 2002, impone di determinare l'ammontare delle quote relative a ciascun periodo di assicurazione secondo tutte le disposizioni vigenti nel corrispondente regime normativo. Ne consegue che, per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l'INPDAl fino alla sua soppressione, il calcolo va operato tenendo conto anche della cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 181 del 1997, che già prima della soppressione dell'INPDAl escludeva che il trattamento pensionistico complessivo degli iscritti a tale ente potesse risultare inferiore a quello previsto dall'assicurazione generale obbligatoria.

3. Il cumulo dei trattamenti: divieti e facoltà di opzione.

In tema di disciplina del cumulo dei trattamenti previdenziali con redditi di altra natura, Sez. L, n. 14447/2024, Cavallaro, Rv. 671211-01, ha escluso che possano costituire reddito rilevante - ai fini del divieto di cumulo con il trattamento pensionistico per i superstiti di cui all'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995 - le somme corrisposte, in forma rateale o in unica soluzione, a titolo di assegno straordinario dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese di credito, di cui al d.m. n. 158 del 2000, in quanto le somme corrisposte a tale titolo hanno natura di incentivo all'esodo.

Sez. L, n. 15453 del 03/06/2024, Gnani, Rv. 671230-01, al medesimo fine di valutare la cumulabilità anzidetta, ha affermato che il trattamento integrativo erogato in forza del Regolamento dei Ministeri della Tavola Valdese è soggetto a tassazione ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a, del TUIR e, dunque, costituisce reddito ai fini dell'art. 1, comma 41, l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che concorre con il trattamento pensionistico ai superstiti erogato dall'INPS ed è cumulabile a questo nei limiti di cui alla tabella F.

In tema di pensione anticipata, **Sez. L, n. 30994/2024, Mancino, Rv. 672990-01**, ha affermato che la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e di lavoro subordinato per la pensione cd. quota cento, di cui all'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019, conv. con l. n. 26 del 2019, comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, ma per tutto l'anno solare di riferimento e ciò in quanto la norma, come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022, esprime una *ratio* solidaristica, ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva.

Sempre in materia di pensione anticipata, **Sez. L, n. 30702/2024, Cavallari, Rv. 673539-01**, ha chiarito che l'art. 25, comma 1, della l. n. 724 del 1994, il quale vieta al personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993 (oggi art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001) di cumulare, successivamente alla cessazione del rapporto, pensione anticipata di anzianità ed incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca conferiti dall'amministrazione di provenienza, o da quelle con cui si sono avuti nei cinque anni precedenti rapporti di lavoro o di impiego, costituisce norma di riforma economico-sociale e si trova pertanto in posizione di preminenza nel regime costituzionale delle fonti, sicché tale divieto riguarda anche l'incarico convenzionale di medicina di base, in quanto prestazione d'opera professionale con i connotati del rapporto di collaborazione continuativa e coordinata.

Sez. L, n. 27290/2024, Mancino, Rv. 672679-01, ha esaminato il divieto di cumulo - previsto dall'art. 23 *bis* della l.r. Toscana n. 3 del 2009, introdotto dall'art. 4 della l.r. Toscana n. 74 del 2015, in relazione al periodo transitorio 31.12.2015-1.6.2019 - tra l'assegno vitalizio spettante per aver ricoperto l'incarico di consigliere regionale della Regione Toscana con quello dovuto in ragione della carica di parlamentare nazionale o europeo, affermando che tale divieto non eccede le competenze legislative regionali né si pone in contrasto con i principi di legittimo affidamento, uguaglianza, ragionevolezza, certezza delle situazioni giuridiche, nonché con la tutela del diritto di proprietà garantita anche dall'ordinamento europeo, in ragione delle motivazioni già spese dalla Corte cost. (in relazione ad analoghe disposizioni regionali) nelle sentenze nn. 136 e 182 del 2022, e neppure confligge con le esigenze di tutela di cui all'art. 38 Cost., in quanto l'assegno vitalizio è emolumento che non ha natura previdenziale.

4. L'indennità di disoccupazione.

Diverse pronunce sono intervenute in materia di trattamenti per la disoccupazione, segno evidente della molteplicità delle problematiche interpretative ed applicative poste dalla relativa disciplina, nelle sue varie forme e fattispecie succedutesi nel tempo.

Sez. L, n. 23039/2024, Garri F., Rv. 672332-01, ha affrontato la tematica della perdita del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria prevista in caso di dimissioni, chiarendo che essa opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro, sicché tale ipotesi ricorre anche nel caso di risoluzione consensuale, non essendovi alcuna differenza fra la dichiarazione unilaterale di recesso e quella manifestata nell'ambito di un accordo consensuale, salvo risulti provato che la sua adesione alla proposta risolutiva, sia intervenuta in presenza di una giusta causa di recesso.

Sez. L, n. 05812/2024, Cerulo, Rv. 670329-01, si è occupata dell'indennità di disoccupazione regolata dall'art. 2, commi 51 e ss., della l. n. 92 del 2012, *ratione temporis* applicabile, riconosciuta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma

1, del d.lgs. n. 276 del 2003; con tale decisione la S.C. ha precisato che detta indennità, poiché la normativa di cui al d.lgs. n. 276 del 2003 (per effetto di quanto disposto dal suo art. 1, comma 2), è inapplicabile alle pubbliche amministrazioni, non può essere attribuita a coloro che abbiano ricevuto dalle pubbliche amministrazioni gli incarichi disciplinati dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Con altra decisione, emessa da **Sez. L, n. 05737/2024, Cerulo, Rv. 670326-01**, è stato chiarito che, nell'ipotesi in cui sia stato adottato legittimamente un decreto ministeriale di esonero del datore di lavoro dall'obbligo assicurativo inerente alla disoccupazione involontaria, non spetta al lavoratore la relativa indennità, in quanto il decreto in questione - i cui effetti si sono prodotti secondo la sequenza individuata dalla legge, che circonda di particolari ed incisive cautele l'accertamento dei presupposti di tale esonero e della stabilità dell'impiego che sola può giustificarlo *ex art. 40, n. 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935* - si riverbera sulla costituzione di un valido rapporto assicurativo ed incide, così, su un requisito imprescindibile e preliminare per accedere alla prestazione.

Sez. L, n. 05912/2024, Cerulo, Rv. 670330-01, ha invece approfondito alcune problematiche insorte con riferimento al requisito contributivo di cui all'art. 74, comma, 1 del r.d.l. n. 1827 del 1935 necessario al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria. Tale pronuncia si è occupata in particolare della fattispecie inerente a periodi di malattia dell'assicurato di durata inferiore all'anno, stabilendo che essi sono riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 56, lettera a), n. 2, di detto r.d.l. per escludere un determinato periodo dal biennio rilevante ai fini del computo del requisito contributivo anzidetto, precisando che l'esclusione è subordinata al fatto che siano stati osservati gli oneri di denuncia imposti dall'art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957, trattandosi di adempimenti funzionali a consentire all'INPS il tempestivo accertamento sancito dalla legge come condizione per tale esclusione.

5. L'indennità di mobilità.

L'indennità di mobilità è stata introdotta dall'art. 7 della l. n. 223 del 1991 quale prestazione previdenziale erogata a favore di chi sia collocato in mobilità ai sensi dell'art. 4 della stessa legge a seguito di procedura di licenziamento collettivo; essa resta regolata, ai sensi dei commi 8 e 12 dell'art. 7 cit., dalla "normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile".

Sez. L, n. 00389/2024, Buffa, Rv. 669656-01, pronunciandosi in ordine all'anticipazione di tale indennità prevista dall'art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991, *ratione temporis* vigente, in favore dei lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere una attività lavorativa autonoma, ha chiarito che essa risponde alla *ratio* di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario destinato a far fronte alle spese iniziali di un'attività svolta in proprio dal lavoratore in mobilità, il quale - in caso di rioccupazione, ancorché temporanea, alle altrui dipendenze entro 24 mesi dall'erogazione - è tenuto alla restituzione delle somme percepite per intero, non soltanto in proporzione alla durata della rioccupazione.

Sez. L, n. 34866/2024, Gandini, Rv. 673542-01, ha invece affermato che ai fini del conseguimento dell'indennità di mobilità è richiesta, ai sensi dell'art. 16, comma 1, l. n. 223 del 1991 *ratione temporis* vigente, la maturazione di una anzianità, non di servizio, ma aziendale presso il datore che ha attivato la procedura, in ragione dell'indissolubile legame

richiesto dalla norma tra anzianità ed azienda, con la conseguenza che sono irrilevanti e non possono essere computate per il compimento del lasso temporale richiesto, le ipotesi di cessione del contratto *ex art. 1406 c.c.*

6. L'Assicurazione sociale per l'Impiego (ASpI).

L'assicurazione sociale per l'impiego (c.d. "ASpI"), è una forma di tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria istituita dall'art. 2 della l. n. 92 del 2012 presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data; essa è volta a fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.

Con tale strumento, destinato a sostituire l'indennità di disoccupazione ordinaria, il legislatore ha cercato di perseguire la graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno al reddito e al reinserimento lavorativo dei disoccupati, senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione d'impresa e tipologia di contratti di lavoro.

Il nuovo trattamento di disoccupazione spetta, a certe condizioni, a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori subordinati di cooperativa, con l'unica esclusione dei dipendenti pubblici contrattualizzati a tempo indeterminato. Ai lavoratori precari compete un trattamento di durata più ridotta, denominato «mini ASpI» (art. 2, comma 20), intendendosi per "precario", nella l. n. 92 del 2012, il lavoratore che non possenga il requisito previsto per godere dell'ASpI (52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni), ma possa far valere almeno 13 settimane di contribuzione effettiva negli ultimi 12 mesi, a condizione che siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria.

Sez. L, n. 34491/2024, Gnani, Rv. 673317-01, si è occupata della transizione dall'una all'altra delle prestazioni anzidette, affermando che l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori che hanno lavorato nell'anno 2012 (disciplinata, quanto ai presupposti, dall'art. 7, comma 3, del d.l. n. 86 del 1988, conv. con modif. con l. n. 160 del 1988) è assorbita, in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 2, comma 24, della l. n. 92 del 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Con riferimento all'ASpI, **Sez. L, n. 11965/2024, Mancino, Rv. 670988-01**, ha chiarito che essa può essere erogata al lavoratore fino alla data del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, e non invece fino alla data di decorrenza in concreto del diritto a pensione, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c, della l. n. 92 del 2012 e l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato, non prevista dalla legge, di determinare il periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito, con la conseguente ripetibilità delle somme percepite a tale titolo dopo che abbia maturato i predetti requisiti.

Su tale principio è tornata anche **Sez. L, n. 22877/2024, Cerulo, Rv. 672299-01**, la quale ha precisato che l'indennità di disoccupazione che costituisce oggetto di tale assicurazione, prevista dall'art. 2, comma 1, della l. n. 92 del 2012, spetta fino alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e - ai sensi dell'art. 2, comma 40, lett. c), della medesima disposizione - il lavoratore decade dal trattamento al raggiungimento di tali requisiti, senza che occorra l'effettiva percezione dell'emolumento, come risulta sia dal dato letterale sia dalla *ratio* della previsione, che attiene - oltre che a esigenze di contenimento della spesa pubblica - a finalità di tutela del lavoratore che non fruisce di un'altra specifica protezione.

Sez. L, n. 22993/2024, Cerulo, Rv. 672303-01, si è pronunciata invece in ordine ai requisiti previsti per il riconoscimento di tale prestazione, affermando che la dichiarazione d'immediata disponibilità all'attività lavorativa, prevista dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 181 del 2000, rappresenta un elemento costitutivo dello stato di disoccupazione rilevante ai fini del conseguimento dell'indennità fornita dall'Assicurazione sociale per l'Impiego (ASpI) e non è incompatibile con lo stato di detenzione, sicché l'erogazione della prestazione decorre dalla sua presentazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto dell'appellante di ottenere il trattamento di disoccupazione ASpI a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, anziché dalla data di rilascio della dichiarazione).

Sempre in materia di ASpI, **Sez. L, n. 23040/2024, Garri F., Rv. 672304-01**, ha affermato che non è consentita la coesistenza di tale prestazione per la disoccupazione e dell'assegno ordinario di invalidità, già in godimento o successivamente riconosciuto, chiarendo però che l'assicurato ha facoltà di optare per uno dei due trattamenti e, stante la mancata previsione di un termine per esercitare l'opzione, di scegliere l'erogazione dell'indennità anche in sede di ricorso amministrativo avverso il rigetto del riconoscimento dell'ASpI, con l'unica conseguenza che il tardato esercizio dell'opzione comporta, a norma dell'art. 2, comma 41, della l. n. 92 del 2012, la ripetibilità delle somme indebitamente erogate a titolo di ASpI.

7. La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI).

La NASpI è un'ulteriore forma di tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria istituita - con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 - dal d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, la quale, con la decorrenza anzidetta, ha sostituito l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e la mini-ASpI).

Come evidenziato da Corte Cost. n. 194 del 14.10.2021, con la NASpI è stata realizzata un'omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi di sostegno dei lavoratori in situazione di disoccupazione involontaria, rapportando la durata degli stessi alla storia contributiva del singolo lavoratore, da realizzare anche attraverso l'incremento della durata massima in caso di anzianità contributive più estese.

L'arco temporale di fruizione della prestazione, consistente in una indennità mensile, non è invece più determinato dalla legge in ragione dell'età del beneficiario, come avveniva per l'ASpI, bensì è rapportato alla storia contributiva del lavoratore: la prestazione può infatti avere una durata massima pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate a favore del lavoratore negli ultimi quattro anni, esclusi gli eventuali periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Pertanto, è venuto meno il tradizionale *favor* per i lavoratori anagraficamente più anziani e si è scelto di agevolare i soggetti con una maggiore posizione contributiva: è stata così eliminata la parte "assistenziale", in quanto non correlata alla contribuzione, del trattamento, precedentemente prevista in favore di soggetti in età "avanzata" che, in quanto tali, avevano maggiori difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro, e si è favorito l'approccio, prettamente economico, secondo il quale la prestazione deve essere parametrata alle somme versate a titolo di contributi, ossia al *quantum* di apporto finanziario all'assicurazione, in base ad un criterio "meritocratico", che incide tanto sulla durata quanto sull'entità del trattamento.

Sez. L, n. 34894/2024, Gnani, Rv. 673324-01, si è occupata di questioni attinenti al transito dall'una all'altra delle prestazioni anzidette, stabilendo che nella vigenza del trattamento ASpI ex art. 2 della l. n. 92 del 2012, qualsiasi nuova occupazione derivante da contratto di lavoro subordinato, ove superiore a sei mesi, determina il venir meno della prestazione per mancanza del requisito della disoccupazione, intesa quale mancanza di

lavoro ex art. 1, d.lgs. n. 181 del 2000 (cui fa rinvio la l. 92 del 2012), a prescindere dal reddito percepito, che diviene invece rilevante, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 22 del 2015, con l'introduzione della NASpI.

In ordine a tale nuova prestazione di disoccupazione, **Sez. L, n. 22922/2024, Marchese, Rv. 672302-01**, si è pronunciata sui requisiti per il relativo riconoscimento, sancendo il principio secondo cui il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, include anche le giornate di ferie e/o riposo retribuito, in quanto costituenti pause essenziali e connaturali del rapporto di lavoro, costituzionalmente garantite. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto il trattamento a una lavoratrice che, nel periodo antecedente alla cessazione del rapporto, aveva goduto di un periodo ininterrotto di ferie, corrispondente a quasi tutto l'anno 2015.

Con la decisione pronunciata da **Sez. L, n. 00846/2024, Gnani, Rv. 669768-01**, la S.C. ha preso in esame alcune questioni connesse alla decadenza dalla fruizione della prestazione prevista dal d.lgs. anzidetto, e precisamente la decadenza prevista dall'art. 11, lett. c), per l'ipotesi in cui il lavoratore cui sia stata riconosciuta l'indennità in questione dia inizio ad un'attività lavorativa, in forma autonoma o di impresa individuale, senza provvedere alla comunicazione all'INPS richiesta dall'articolo 10, comma 1, primo periodo del medesimo d.lgs., nel termine ivi prescritto. La decisione in esame ha stabilito che la decadenza prevista dal citato art. 11, lett. c), si applica anche nel caso in cui la summenzionata attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa, e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa.

La predetta ipotesi di decadenza è stata esaminata anche da **Sez. L, n. 22921/2024, Cavallaro, Rv. 672301-01**, la quale ha affermato che essa non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto.

Sez. L, n. 00396/2024, Rv. 669710-02, ha invece stabilito l'importante principio secondo il quale la NASpI deve essere riconosciuta anche in favore dei detenuti ammessi al lavoro carcerario inframurario, giacché la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 20 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria, rilevante ai fini della tutela previdenziale garantita con la prestazione in esame.

Sez. L, n. 31398/2024, Gandini, Rv. 673182-01, ha affermato che uno dei presupposti per la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento spettante al lavoratore, a titolo di incentivo all'"autoimprenditorialità" ex art.8 del d.lgs. n. 22 del 2015, è costituito dal fatto che il richiedente non goda già del trattamento ordinario NASpI. Ciò sul presupposto, enunciato dalla medesima decisione in precedenza richiamata (**Sez. L, n. 00396/2024, Buffa, Rv. 669710-01**), che detto lavoro è del tutto equiparabile al lavoro ordinario anche ai fini previdenziali, e la relativa tutela non è esclusa dalle peculiarità della regolamentazione normativa del rapporto.

8. La Cassa integrazione guadagni.

Con riferimento a tale ammortizzatore sociale, l'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988 convertito con l. n. 160 del 1988, prevede che il lavoratore ammesso alla fruizione degli interventi di integrazione guadagni straordinaria decade dal beneficio se intraprende un'attività lavorativa subordinata o autonoma senza darne preventiva comunicazione l'INPS.

Sez. L, n. 34861/2024, Gandini, Rv. 673323-01, si è pronunciata su tale decadenza con riferimento ai lavoratori del settore del trasporto aereo, stabilendo che essa è esclusa nei soli casi in cui l'attività svolta presso un nuovo vettore aereo è finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo, applicandosi invece, come nel caso esaminato dalla decisione, ove l'attività svolta sia funzionale, oltre che mantenimento e rinnovo delle licenze e abilitazioni di volo, anche alla conclusione del contratto di lavoro con tale vettore.

Sempre in materia di cassa integrazione guadagni, **Sez. L, n. 33891/2024, Solaini, Rv. 673313-01**, si è occupata delle procedure con le quali il datore di lavoro che abbia anticipato l'importo del trattamento salariale ai lavoratori può compensarlo con i contributi previdenziali dovuti dallo stesso, affermando che ciò è possibile se il conguaglio viene effettuato, *ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148 del 2015*, entro il termine di decadenza coincidente con il giorno sedici del mese successivo alla fine del periodo paga in corso al momento della scadenza del semestre decorrente dal termine di durata di concessione della cassa integrazione o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della stessa. La decisione ha precisato che non si determina alcuna decadenza se il conguaglio viene effettuato entro l'anzidetto termine, ancorché in misura erronea, o se sono comunicate in modo erroneo o tardivo le denunce telematiche mensili previste dall'art. 44, comma 9, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003.

Sez. L, n. 27350/2024, Pagetta, Rv. 672694-01, ha preso in esame l'integrazione salariale relativa alle ipotesi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid 19, di cui all'art. 19 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, precisando che la disciplina così introdotta non ha previsto un procedimento del tutto atipico di accesso al trattamento ordinario, in quanto - pur dovendosi escludere il contenuto vincolato della comunicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 148 del 2015 - il datore di lavoro restava gravato dell'onere di garantire l'effettivo confronto con la controparte sindacale, secondo criteri di congruità ed adeguatezza da valutarsi alla luce dei principi di correttezza e buona fede.

9. Il TFR e le altre prestazioni corrisposte dal Fondo di garanzia *ex art. 2 della legge n. 297 del 1982*.

L'obbligazione di pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, ha natura previdenziale e non va considerata identica all'obbligazione di pagamento del trattamento di fine rapporto a carico del datore di lavoro, avente natura retributiva.

In ordine ai presupposti di tale obbligazione **Sez. L, n. 16740/2024, Gnani, Rv. 671580-01**, ha chiarito che, in caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del predetto Fondo di garanzia per il TFR maturato dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se il relativo credito è stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale, poiché il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui tale credito diviene esigibile, non rilevando in senso

contrario l'accordo sindacale raggiunto *ex art.* 47, comma 5, l. n. 428 del 1990, *ratione temporis* applicabile, per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale di pagare il TFR maturato alle dipendenze del cedente, in quanto tale accordo non è opponibile all'INPS.

Su tali tematiche è tornata anche **Sez. L, n. 23499/2024, Garri F., Rv. 672331-01**, affermando che l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione *ratione temporis* vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando però il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha pertanto confermato l'inopponibilità al Fondo di garanzia gestito dall'INPS di un accordo sindacale, concluso ai sensi del citato art. 47, comma 4-bis, con il quale l'impresa cessionaria era stata esonerata da ogni responsabilità in relazione al TFR maturato presso quella cedente, poiché, nonostante il fallimento di questa intervenuto successivamente alla cessione, il diritto a tale emolumento non era ancora divenuto esigibile per effetto della prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cessionaria stessa).

Sempre con riferimento ai presupposti per l'intervento del predetto Fondo di garanzia, **Sez. L, n. 16833/2024, Gnani, Rv. 671581-01**, ha puntualizzato che il diritto del lavoratore verso tale Fondo, in caso di datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali *ex art.* 2, comma 5, l. n. 297 del 1982, presuppone come fatto costitutivo l'insolvenza di quest'ultimo ed il necessario ed infruttuoso tentativo di esecuzione forzata nei suoi confronti, sicché - dal punto di vista processuale - l'allegazione da parte dell'ente previdenziale del mancato preventivo esperimento di tale esecuzione non è da qualificare come eccezione in senso proprio, bensì come mera difesa, con conseguente inapplicabilità del divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 437 c.p.c.

In tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia dell'Inps, **Sez. L, n. 23474/2024, Buffa, Rv. 672199-01**, ha affermato che spetta al comitato amministratore del predetto ente previdenziale, ai sensi dell'art. 26, lett. b), l. n. 88 del 1989, l'individuazione della documentazione necessaria al fine dell'erogazione delle prestazioni, ma l'esercizio di detto potere va espletato con ragionevolezza, in modo tale da non vanificare o rendere eccessivamente difficile la tutela del diritto e senza deroghe alle disposizioni di legge vigenti in tema di efficacia probatoria dei documenti (in applicazione del principio, la S.C. ha escluso la necessità della produzione dell'originale del titolo esecutivo al fine dell'erogazione della prestazione, ritenendo sufficiente anche la copia conforme o quella fotostatica non disconosciuta).

Sez. L, n. 34283/2024, Cavallaro, Rv. 673315-01, ha preso in considerazione l'ulteriore prestazione prevista a carico del Fondo anzidetto, e cioè l'erogazione delle ultime tre mensilità di retribuzione dovute al lavoratore e non corrispostegli per l'insolvenza del datore di lavoro, precisando in proposito che, ai fini dell'individuazione di tali mensilità, nel computo dei dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata, previsto all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 80 del 1992, non si può tener conto del tempo trascorso tra la richiesta d'intervento ispettivo alla Direzione Territoriale del Lavoro e l'adozione, da parte di quest'ultima, della diffida accertativa di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004.

10. Indennità di buonuscita e trattamenti analoghi.

In tema di indennità di buonuscita da riconoscersi ai dipendenti pubblici ai sensi del d.P.R. n. 1032 del 1973, **Sez. L, n. 09009/2024, Rv. 670601-01**, ha stabilito che, ai fini della sua commisurazione, va presa in considerazione anche l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, la quale, in ragione della sua natura retributiva e dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale *ex art.* 12 l. n. 153 del 1969, deve essere inclusa nel computo della base contributiva di cui agli artt. 3 e 38 del menzionato d.P.R.

In tale prospettiva è possibile stabilire una sorta di parallelismo con **Sez. L, n. 14242/2024, Ponterio, Rv. 671208-01**, (pronunzia ricordata anche nel paragrafo 3.1. del capitolo della presente rassegna dedicato al lavoro privato), che ha affermato la ricomprensibilità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto degli emolumenti incentivanti, proprio in ragione del loro carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e della non occasionalità della loro erogazione, da accertarsi quest'ultima necessariamente *ex post*, senza che rilevi il fatto che l'ammissione al sistema incentivante dipende da una decisione datoriale.

Sez. L, n. 15597/2024, Cavallari, Rv. 671272-01, ha affrontato la disciplina del procedimento per la liquidazione dell'indennità anzidetta, stabilendo che il provvedimento adottato dall'amministrazione del fondo di previdenza può essere revocato, modificato o rettificato dalla stessa nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del successivo provvedimento, con il quale l'amministrazione di appartenenza ricalcoli il trattamento di fine servizio del dipendente per errato riferimento, in un precedente conteggio, alla retribuzione dirigenziale in luogo di quella relativa alla qualifica di funzionario di inquadramento formale, trovando applicazione il disposto dell'art. 26, comma 6, del d.P.R. n. 1032 del 1973, come richiamato dal successivo art. 30, ultimo comma, del medesimo d.P.R.

Su un trattamento previdenziale rispondente ad una analoga funzione, e cioè il trattamento di fine servizio spettante ai dipendenti delle aziende sanitarie locali, si è pronunciata invece **Sez. L, n. 14626/2024, Tricomi, Rv. 671270-01**, con riferimento ad una particolare categoria di personale, quella degli infermieri assunti dall'Università degli Studi di Napoli e destinati ai policlinici universitari *ex art. 1* della l.r. Campania n. 10 del 1978, *ratione temporis* vigente, per i quali detta decisione ha affermato che il successivo transito alle dipendenze delle unità sanitarie locali non ha fatto venire meno la continuità del loro rapporto di lavoro, sicché, ai fini della maturazione del trattamento di fine servizio, deve computarsi, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 761 del 1979, anche il periodo di servizio fuori ruolo presso detti policlinici universitari, e ciò in applicazione del principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. (così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997), che può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge e limitatamente al caso espresso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi.

Altro trattamento rispondente a finalità rapportabili a quelle delle prestazioni in precedenza richiamate è l'indennità di fine lavoro disciplinata dall'art. 2, comma 130, della l. n. 191 del 2009, prorogata per il 2012 dall'art. 6, comma 1, lettera c), del d.l. n. 216 del 2011, convertito con l. n. 14 del 2012, in ordine alla quale **Sez. L, n. 31089/2024, Cerulo, Rv. 672946-01**, ha precisato che essa non spetta ai dottorandi di ricerca universitari, che non svolgono attività riconducibili alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, individuate, invece, ai fini dell'erogazione di detta indennità.

11. L'indebito previdenziale.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 431 del 1993, ha affermato che è venuto via via consolidandosi un principio di settore, secondo il quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) - trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, declinandosi in forme e modalità diverse a seconda delle peculiari discipline di volta in volta dettate dal legislatore.

Ciò premesso in linea generale, va segnalato che **Sez. L, n. 26580/2024, Solaini, Rv. 672656-01**, ha affermato che l'azione di ripetizione di indebito *ex art. 2033 c.c.* non è il solo strumento di cui l'INPS può avvalersi, potendo altresì recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. D), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato *ex art. 21-bis* del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022, i quali rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall'Istituto previdenziale, o quando l'INPS agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive.

I limiti di pignorabilità previsti dal predetto art. 545 c.p.c. sono stati invece ritenuti applicabili da **Sez. L, n. 00357/2024, Garri F., Rv. 669706-01**, con riferimento al credito per TFR maturato da un dipendente di banca, in ordine al quale è stato affermato che esso mantiene, anche nell'ipotesi di trasmissione all'erede, la sua natura di credito di lavoro, poiché non nasce con la cessazione del rapporto, ma si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., sì da costituire un diritto di credito a pagamento differito. Ne consegue che nella predetta ipotesi, conservando il credito in questione autonomia rispetto a quello della banca fondato sul rapporto bancario intrattenuto dal dante causa, la compensazione tra i due crediti è soggetta al limite di cui all'art. 545 c.p.c. Detta disposizione, infatti, prevede limiti di pignorabilità, sia per crediti aventi ad oggetto sussidi erogati da enti di assistenza e prestazioni pensionistiche, sia per crediti aventi ad oggetto indennità relative a rapporti di lavoro o di impiego.

Sez. L, n. 29689/2024, Marchese, Rv. 673062-01, si è soffermata sulla previsione di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, affermando che essa si interpreta nel senso che l'INPS deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito.

Sez. L, n. 03523/2024, Cerulo, Rv. 670041-01, si è pronunciata invece sulla prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dall'INPS, con riferimento alla fattispecie del cumulo della pensione di anzianità con il reddito da lavoro autonomo di cui all'art. 10, comma 6, d.lgs. n. 503 del 1992, laddove tale cumulo abbia comportato il superamento dei limiti di legge entro i quali esso è consentito.

La decisione in esame, nel chiarire che l'esecuzione del pagamento della prestazione in misura eccedente, di volta in volta, i limiti posti dalla legge a tale cumulo concretizza un pagamento indebito, ha precisato che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme non dovute inizia a decorrere da tale esecuzione, e non già dalla presentazione della dichiarazione dei redditi a fini Irpef prevista dall'anzidetto art. 10, identificandosi il fatto costitutivo della pretesa restitutoria nel pagamento in misura superiore ai medesimi limiti di legge.

Una fattispecie di indebito può configurarsi anche nel caso di somme pagate dall'ente previdenziale in esecuzione di una sentenza successivamente riformata o cassata, ai sensi degli artt. 336 e 389 c.p.c.

Per una tale ipotesi **Sez. L, n. 02691/2024, Buffa, Rv. 669860-01**, ha precisato che in caso di riforma della sentenza di condanna dell'ente previdenziale al pagamento di

somme in favore del lavoratore, il predetto ente ha diritto di ripetere quanto il lavoratore medesimo abbia effettivamente percepito, e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

Sez. L, n. 11659/2024, Cerulo, Rv. 671008-01, ha delimitato la portata applicativa delle regole sull'indebito previdenziale e su quello assistenziale, affermando che esse non possono trovare applicazione con riferimento alla ripetizione di somme indebitamente versate a titolo di NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego), la quale è una prestazione previdenziale ma non pensionistica, cosicché detta ripetizione soggiace alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale.

12. La responsabilità per danni degli enti previdenziali e nei loro confronti.

La tematica della responsabilità per danni degli enti previdenziali, invocata dagli assicurati che abbiano subito conseguenze pregiudizievoli in ordine ai trattamenti previdenziali ed assicurativi ad essi spettanti, a causa di comportamenti colposi di tali enti, non è del tutto nuova.

In genere tali fattispecie si sono verificate in caso di errate informazioni contenute negli estratti contributivi rilasciati dall'INPS che avevano indotto l'assicurato a compiere determinate scelte, confidando sull'esattezza di tali estratti e di poter quindi beneficiare di trattamenti previdenziali poi non riconosciuti, o riconosciuti a condizioni meno vantaggiose, a causa della mancanza del necessario requisito contributivo.

Nel corso del 2024 si sono avute due decisioni, di ambito diverso, che hanno dovuto confrontarsi con tale problematica, ma con riferimento a fattispecie nuove.

Sez. L, n. 23325/2024, Cavallaro, Rv. 672197-01, ha precisato che, nell'ipotesi in cui un ente previdenziale abbia fornito all'assicurato un'erronea indicazione sul termine per proporre impugnazione giudiziale, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno conseguente all'omessa impugnazione del provvedimento di reiezione nei termini prescritti dalla legge - che si concretano nell'accertamento dell'erronea comunicazione dell'ente, della natura scusabile dell'errore determinato dalla comunicazione e del rapporto di causalità fra errore e scadenza del termine - costituisce un giudizio di fatto, che compete in via esclusiva al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Sez. L, n. 26620/2024, Solaini, Rv. 672627-01, con riferimento ad adempimenti di competenza dell'INAIL, ha affermato che il rapporto assicurativo che lega tale ente al lavoratore si connota in termini di affidamento e mutua cooperazione, in forza dell'obbligo, gravante sugli enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita; pertanto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per intervenuta maturazione dei requisiti pensionistici in considerazione dei contributi figurativi accreditati per esposizione all'amianto, l'erronea certificazione, con efficacia vincolante, di esposizione all'amianto e la conseguente revoca dell'accredito contributivo danno luogo ad un'ipotesi di responsabilità da contatto sociale, *species* del più ampio *genus* della responsabilità *ex art.* 1218 c.c.

Sez. L, n. 31844/2024, Cavallaro, Rv. 673297-01, si è occupata invece di una diversa fattispecie di responsabilità, e precisamente la responsabilità di un istituto di credito nei confronti dell'INPS, per aver consentito il pagamento di ratei di pensione dopo il decesso del suo titolare a favore del delegato alla riscossione. La sentenza, nell'affermare tale responsabilità, ha precisato che essa, pur in assenza di un contratto tra INPS e banca, è di natura contrattuale, in ragione dello speciale affidamento che chiunque si avvale di un intermediario bancario per effettuare un pagamento è legittimato a riporre nell'adozione, da parte di quest'ultimo, di tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione del beneficiario, soprattutto in considerazione della sua qualità professionale.

CAPITOLO XXV

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

(DI MARIO DE IORIS)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'invalidità civile. - 3. Le misure di sostegno previste per l'emergenza pandemica da Covid-19. - 4. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fruite all'estero. - 5. Le prestazioni a beneficio delle vittime del dovere e di soggetti assimilati. - 6. Le prestazioni in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni o emotrasfusioni. - 7. Le provvidenze a sostegno della natalità.

1. Premessa.

Nell'art. 38, comma 1, Cost. è scolpito il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante a ogni cittadino inabile al lavoro (dunque affetto da incapacità psico-fisica) e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, in ragione del basso (o insussistente) livello di reddito, al di sotto di una certa soglia predeterminata per legge.

L'intervento assistenziale si differenzia da quello previdenziale, essenzialmente perché la relativa spesa è finanziata interamente attraverso la fiscalità generale, in base al principio di solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro che sono riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di minorazioni congenite o acquisite. Le relative prestazioni vengono individualmente erogate ai soggetti che ne hanno diritto, indipendentemente dalla loro iscrizione a gestioni previdenziali e, quindi, dal versamento di una contribuzione.

2. L'invalidità civile.

Diverse leggi speciali riconoscono particolari benefici, non solo economici, ai soggetti che si trovano in condizioni fisiche che li rendono inabili al lavoro e, dunque, in stato di invalidità cosiddetta civile (che si differenzia dall'invalidità legata allo svolgimento di un'attività lavorativa).

Una di tali prestazioni è l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971, riconosciuto in favore di chi ha un'invalidità pari o superiore al 74 % ed è in possesso dei requisiti socio-economici previsti a tal fine dalla legge.

Con riferimento a tale prestazione, **Sez. L, n. 00220/2024, Cerulo, Rv. 669702-01**, ha stabilito che fra i redditi da prendere in considerazione ai fini della verifica del possesso del requisito socio-economico va inclusa, in difetto di previsioni di diverso tenore, anche la remunerazione corrisposta per il sostentamento del clero, ai sensi degli artt. 24, 33, lett. a), e 34, comma 1, della l. n. 222 del 1985, n. 222, in quanto equiparata, a fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

In proposito, **Sez. L, n. 29731/2024, Buffa, Rv. 673063-01**, ha precisato che il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità nel regime previsto, a decorrere dal 1.1.2008, dall'art. 13 della l. n. 118 del 1971 (così come sostituito dell'art. 1, comma 35, della l. n. 247 del 2007), presuppone la dimostrazione dello stato di inoccupazione del richiedente, corrispondente al mancato svolgimento di attività lavorativa, la cui prova può essere assicurata con qualunque mezzo, anche per presunzioni.

Sez. L, n. 28846 del 08/11/2024, Buffa, Rv. 672691-01, si è occupata invece della prestazione di invalidità civile *ex art.* 12 della l. n. 118 del 1971 (pensione di inabilità civile), affermando che la sussistenza del requisito anagrafico per essa previsto deve essere verifi-

cata alla data della domanda amministrativa, sempre che a tale epoca fossero presenti tutti gli altri requisiti di legge, occorrendo altrimenti considerare il requisito anagrafico richiesto dalla normativa vigente al momento della sussistenza di tutte le altre condizioni necessarie per beneficiare della prestazione, tenendo quindi conto delle modifiche apportate a detto requisito dai d.m. 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014.

Con riferimento alla medesima prestazione, **Sez. L, n. 30152/2024, Marchese, Rv. 673067-01**, ha precisato che la domanda relativa alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971 deve essere proposta necessariamente prima del compimento dell'età anagrafica prevista per legge e deve essere accolta (nella ricorrenza degli altri presupposti) se la condizione invalidante si perfeziona entro tale data.

In materia di provvidenze per gli invalidi civili, **Sez. L, n. 30436/2024, Gnani, Rv. 672696-01**, ha affermato che l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, specifica e distinta da quella volta al riconoscimento dell'invalidità civile, in assenza della quale il diritto a detta indennità non può essere fatto valere con l'impugnazione in giudizio dell'esito di una visita di revisione disposta per verificare il requisito sanitario previsto per una prestazione diversa (in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa relativa all'indennità di accompagnamento).

3. Le misure di sostegno previste per l'emergenza pandemica da Covid-19.

La legislazione emergenziale in esame si è caratterizzata anche per l'adozione di diverse misure volte a limitare le ricadute negative sui settori produttivi dei provvedimenti restrittivi approvati per arginare il contagio da Covid-19, fra le quali diverse misure erogate dall'INPS quale sostegno economico a tali settori, aventi natura indennitaria.

Sull'indennità prevista dall'art. 28, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali per il commercio e l'artigianato dell'AGO, si è pronunciata **Sez. L, n. 30820/2024, Cavallaro, Rv. 672991-01**, la quale ha affermato che essa è una prestazione di natura assistenziale che presuppone solo che i suoi beneficiari fossero iscritti a una delle predette gestioni speciali al momento dell'entrata in vigore del citato d.l. (17 marzo 2020) e, al contempo non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla gestione separata. Nella specie, in applicazione del principio *tempus regit actum*, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'INPS, il quale riteneva che, sulla base della previsione secondo cui l'indennità è riconosciuta "per il mese di marzo", questa spettasse solo a chi fosse già iscritto alle gestioni speciali al 1° marzo 2020.

Sez. L, n. 30816/2024, Cavallaro, Rv. 672945-01, pronunciandosi invece in ordine all'indennità per la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, prevista per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali dall'art. 29, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, ha affermato che essa è una prestazione di natura assistenziale a sostegno del reddito personale del lavoratore, sicché ai fini della sua concessione non rileva il settore merceologico in cui risulta inquadrato il datore di lavoro ex art. 49, della l. n. 88 del 1989, poiché la classificazione operata da tale norma vale ai differenti fini della disciplina dei rapporti fra impresa ed ente previdenziale.

4. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fruite all'estero.

Viene considerata prestazione assistenziale anche il rimborso delle prestazioni sanitarie rese in favore di cittadino italiano all'estero, in ordine al quale **Sez. L, n. 30523/2024, Mar-**

chese, Rv. 672940- 01, ha analizzato il requisito della comprovata eccezionale gravità ed urgenza che, *ex art.* 7, comma 2, d.m. 3 novembre 1989, consente di derogare al rilascio della preventiva autorizzazione del Centro regionale di riferimento, affermando che esso è inerente alle cure sanitarie la cui tempestiva erogazione si rende necessaria per tutelare il diritto alla salute, inteso nella sua più ampia accezione voluta dalla Costituzione, e che l'accertamento delle relative condizioni normative deve essere condotto con riferimento allo stato di necessità incombente prima della fruizione del trattamento sanitario, la cui efficacia deve valutarsi *ex ante* in termini di astratta idoneità, non rilevando i risultati da esso concretamente prodotti.

5. Le prestazioni a beneficio delle vittime del dovere e di soggetti assimilati.

Speciali disposizioni prevedono prestazioni economiche ed agevolazioni di altro tipo (lavorativo, sanitario, etc.) a favore di dipendenti pubblici, di altri soggetti equiparati al medesimo fine e dei loro familiari superstiti, i quali abbiano subito infermità con postumi permanenti, o perso la vita, a causa dell'esercizio di funzioni pubbliche o nel corso di azioni terroristiche (cd. vittime del dovere).

Introdotti dalla legge n. 629 del 1973, tali benefici sono stati estesi con successivi interventi normativi alle vittime di fenomeni analoghi quali la criminalità organizzata e di stampo mafioso, le richieste estorsive e l'usura.

Con riferimento alle vittime di reati di criminalità organizzata e dei loro familiari Sez. L, n. 34503/2024, Marchese, Rv. 673318-01, ha affermato che le condizioni, di cui agli artt. 1, comma 2, e 4 l. n. 302 del 1990, per il riconoscimento degli emolumenti ricorrono tutte le volte in cui l'azione delittuosa è commessa dal componente di un sodalizio di tipo mafioso al fine di incrementare la forza del gruppo, nella sua influenza o capacità d'azione e, quindi per realizzare taluno degli obiettivi indicati dall'art. 416-*bis* c.p., tra cui quello, generico, della realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, individuabili nell'apparire e affermarsi come gruppo egemone di una determinata comunità (nella specie, la S.C. ha rinvenuto detti presupposti in relazione ad un omicidio premeditato che, pur avendo quale movente la tutela dell'onore familiare secondo i canoni della subcultura della 'ndrangheta, aveva altresì lo scopo di preservare la posizione di prestigio e preminenza del mandante all'interno dell'organizzazione associativa).

La legge n. 266 del 2005, all'art. 1, comma 564, equipara alle vittime del dovere coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. A tale proposito, Sez. L, n. 00287/2024, Solaini, Rv. 669651-01, ha chiarito che le condizioni particolari anzidette sono quelle che implicano l'esistenza (o anche il sopravvenire) di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.

In relazione al riconoscimento dei benefici spettanti a tali categorie, ed al nesso di causalità necessario a tal fine, Sez. L, n. 12595/2024, Buffa, Rv. 670906-01, ha affermato che in presenza di rischio tipizzato - nella specie da esposizione ad uranio impoverito - e di correlazione concausale con la patologia sofferta dal lavoratore, è onere del datore dimostrare l'efficacia causale esclusiva di fattori patogeni extralavorativi idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale.

Sez. L, n. 16610/2024, Cerulo, Rv. 671305-01, ha invece esaminato i presupposti per il riconoscimento di detti benefici in favore delle vittime del dovere di cui all'art. 1, comma 563, lett. c), l. n. 266 del 2005, affermando che essi sono integrati dalla vigilanza ad infrastrutture civili e militari, alla quale non può ricondursi la sorveglianza dei detenuti da parte della Polizia penitenziaria, la quale non ha come oggetto immediato e precipuo il controllo delle infrastrutture. Nella specie, la S.C. ha escluso che i compiti di sorveglianza dei detenuti ricoverati in infermeria da parte di un agente di polizia penitenziaria siano riconducibili alle attività di vigilanza delle infrastrutture civili e militari.

Sez. L, n. 34299/2024, Cavallaro, Rv. 673316-01, ha precisato che, ai fini del riconoscimento dei benefici spettanti, ai sensi dell'art. 1, comma 563 della l. n. 266 del 2005, alle vittime del dovere, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, comma 563, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività.

Sez. L, n. 34714/2024, Magnanensi, Rv. 673322-01, infine, si è pronunciata in merito ad una delle prestazioni oggetto della legislazione in esame, l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407 del 1998, ed ha chiarito che esso compete, *ex art.* 4, lett. b), del d.P.R. n. 243 del 2006, anche alle vittime del dovere e ai soggetti delle categorie equiparate, dalla data in cui sono maturati i presupposti per la fruizione del beneficio previsti dalla legge, non rilevando a tal fine che all'art. 4, lett. b) di detto d.P.R. è previsto che la provvidenza è corrisposta "a decorrere dal 2006".

6. Le prestazioni in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni o emotrasfusioni.

L'art. 1 della l. n. 210 del 1992 riconosce un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 268 del 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, anche nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazioni cd. raccomandate, affermando che la ragione determinante del diritto all'indennizzo non deriva dalla sottoposizione a un trattamento obbligatorio in quanto tale, ma riposa, piuttosto, sulle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività.

Principi non dissimili sono stati affermati anche da successive decisioni della Corte costituzionale, fra cui la sentenza n. 129 del 2023.

Su tali presupposti, **Sez. L, n. 16875/2024, Marchese, Rv. 671918-01**, ha pertanto affermato che il diritto all'indennizzo disciplinato dalla l. n. 210 del 1992 deve essere riconosciuto, tenuto conto anche della sentenza della Corte cost. da ultimo richiamata, ai soggetti danneggiati dalle vaccinazioni previste dall'art. 1 del d.l. n. 73 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2017, il cui art. 5-*quater* si riferisce tanto alle vaccinazioni obbligatorie quanto a quelle raccomandate, come quella antimeningococcica, e si applica retroattivamente coprendo anche gli eventi verificatisi prima della legge di conversione di detto d.l., se relativi a profilassi valutabili come raccomandate già al momento della loro somministrazione.

Per quanto riguarda le categorie dei soggetti che possono beneficiare di tale misura **Sez. L, n. 31577/2024, Gnani, Rv. 673200-01**, ha affermato che nella categoria degli operatori sanitari, cui compete, *ex art.* 2, comma 1, della l. n. 210 del 1992, l'indennizzo

previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge, non sono ricompresi gli operai specializzati in un settore tecnico e non sanitario e ciò in quanto la tutela indennitaria con scelta discrezionale, insindacabile in quanto non irragionevole, è stata riconosciuta dal legislatore solo agli operatori sanitari che, in ragione della loro attività di cura e assistenza in favore di soggetti a rischio, assumono un rischio specifico, e non solo generico, di contagio (nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'emolumento in capo ad un operario specializzato che aveva contratto infezione da epatite - HCV - durante l'attività di spurgo delle condutture fognarie ospedaliere che lo portava a contatto con sangue e materiale ematico infetto).

Per quanto concerne le modalità di riconoscimento del diritto all'indennizzo di cui all'art. 1, comma 3, della l. n. 210 del 1992, **Sez. L, n. 00620/2024, Buffa, Rv. 669764-01**, ha chiarito che la domanda giudiziale promossa per conseguirlo è relativa alla prestazione (ossia all'accertamento giurisdizionale del relativo diritto soggettivo) e non ha ad oggetto la legittimità dell'azione amministrativa, sicchè l'inerzia della commissione medica ospedaliera, chiamata a valutare in sede amministrativa la ricorrenza dei presupposti di legge, non esclude l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla domanda amministrativa e non preclude poi, la possibilità di promuovere l'azione giudiziale.

Con riferimento alla medesima tematica, **Sez. L, n. 31191/2024, Marchese, Rv. 672947-01**, ha chiarito che nel giudizio proposto nei confronti del Ministero della Salute per conseguire l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992, l'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia effettuato in sede amministrativa dalle Commissioni mediche ospedaliere (CMO) - che sono articolazioni del Ministero della difesa, estranee, quindi, a quello della Salute - non ha valore di prova legale, ma costituisce materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, sicché non è precluso all'amministrazione convenuta contestare la sussistenza di tale nesso, seppure affermato nel verbale della CMO dovendo in tal caso il giudice accertare tutti gli elementi costitutivi della prestazione richiesta, *ivi* compreso il nesso di causalità.

Sez. L, n. 27141/2024, Mancino, Rv. 672636-01, si è pronunciata, invece, con riferimento ad una prestazione diversa, e cioè l'indennizzo aggiuntivo a quello previsto dal citato art. 1 della l. n. 210 del 1992, introdotto e disciplinato dall'art. 1 della l. n. 229 del 2005, affermando che esso deve essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultano già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del d.m. Salute del 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria, come si desume, oltre che dai lavori preparatori, dal dato letterale inequivoco del citato art. 1, comma 4, che preclude ogni altra opzione interpretativa.

7. Le provvidenze a sostegno della natalità.

Al novero delle prestazioni assistenziali sono riconducibili anche varie forme di provvidenze, previste dalla legislazione degli ultimi anni con il fine di dare un sostegno alla natalità, attraverso l'erogazione, per lo più *una tantum*, di somme con le quali contribuire al sostegno dei relativi oneri.

Sez. L, n. 10728/2024, Cavallaro, Rv. 670997-01, si è pronunciata con riferimento ad una di tali provvidenze, e cioè il cd. Premio di natalità previsto dall'art. 1, comma 353, l. n. 232 del 2016, nella formulazione *ratione temporis* vigente, stabilendo che esso spetta alle cittadine extracomunitarie anche se prive di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dovendo ritenersi illegittime le circolari INPS nn. 39 e 61 del 2017 che richiedono tale permesso come presupposto per il riconoscimento del premio.

CAPITOLO XXVI

LA TUTELA INAIL

(DI MARIO DE IORIS)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I soggetti beneficiari dell'assicurazione obbligatoria. - 3. Le prestazioni erogate dall'INAIL ed i requisiti per il loro riconoscimento. - 4. L'azione di regresso dell'INAIL.

1. Premessa.

Attraverso l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), lo Stato - in attuazione del precetto di cui all'art. 38, comma 2, Cost. - assicura al lavoratore che si infortuni sul lavoro, o che contragga una malattia professionale, un adeguato sostegno economico e sanitario durante il periodo nel quale egli è impossibilitato a rendere la prestazione lavorativa e, dunque, a procurarsi un reddito.

Attraverso tale forma di copertura assicurativa è garantita anche la tutela per il danno biologico riportato dai soggetti assicurati per effetto degli infortuni e malattie professionali occorsi in occasione del lavoro prestato.

2. I soggetti beneficiari dell'assicurazione obbligatoria.

L'assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti da costoro, fatta salva l'ipotesi in cui l'evento lesivo si sia verificato per un fatto costituente reato perseguibile d'ufficio, imputabile al datore di lavoro o ai suoi preposti (nel qual caso, l'INAIL può agire in regresso nei confronti del responsabile, nei limiti della prestazione erogata).

L'assicurazione in questione è prevista anche in favore di alcune categorie di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti e collaboratori parasubordinati, come il titolare o il socio dell'impresa artigiana.

A tal riguardo **Sez. L, n. 07225/2024, Riverso, Rv. 670453-01**, ha enunciato il principio secondo cui il ritardo nella denuncia della malattia contratta dal titolare o socio dell'impresa artigiana comporta solo la decurtazione o la perdita dell'indennità temporanea, senza l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 11, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in ragione della parificazione della disciplina della malattia professionale a quella dell'infortunio, desumibile dall'interpretazione letterale e anche logico-sistematica degli artt. 52, 203 e 131 del medesimo d.P.R.

Sez. L, n. 07288/2024, Cavallari, Rv. 670448-01, si è occupata invece dell'attuazione della tutela contro gli infortuni e malattie professionali dei dipendenti dello Stato, per i quali l'art. 127, ultimo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, prescrive che l'assicurazione presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione, la cui disciplina è rimessa ad un decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità".

Il decreto del Ministero del tesoro del 10 ottobre 1985, è intervenuto a dare concreta attuazione e regolamentazione all'assicurazione dei dipendenti statali nella speciale forma di gestione per conto dello Stato.

La decisione in esame ha evidenziato che con tale normativa, lo Stato ha affidato all'INAIL il compito di assicurare i propri dipendenti, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del menzionato Testo Unico, ma nello Stato sono riunite le posizioni sia del datore di lavoro sia dell'assicurazione, cosicché i dipendenti statali vengono a trovarsi per tale motivo in una peculiare posizione, caratterizzata dal fatto che il loro rapporto assicurativo è bilaterale e non trilatero, come avviene invece per gli altri lavoratori, il cui rapporto assicurativo vede coinvolti il datore di lavoro, il dipendente e l'assicurazione.

Sulla base di tali presupposti, la decisione anzidetta ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento ad un infortunio occorso a una dipendente di scuola pubblica, aveva affermato l'inoperatività del contratto di assicurazione stipulato dal Ministero per la copertura del "personale docente e non docente della scuola - non soggetto alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio in occasione di lavoro o di servizio", in quanto la lavoratrice beneficiava di un'assicurazione obbligatoria, restando irrilevante l'identità dell'assicuratore.

3. Le prestazioni erogate dall'INAIL ed i requisiti per il loro riconoscimento.

Con riferimento all'indennizzo per il danno biologico da malattia professionale, o da infortunio sul lavoro, Sez. L, n. 13006/2024, Solaini, Rv. 670939-01, ha precisato che tale danno è indennizzabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, solo se pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore, perché determinerebbe l'accesso alla tutela in difetto dei presupposti di legge.

Con riferimento invece ai presupposti per l'operatività della assicurazione contro le malattie professionali, Sez. L, n. 22592/2024, Garri F., Rv. 671927-01, ribadendo un orientamento consolidato, ha affermato che, nelle ipotesi in cui la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Laddove la prestazione erogata dall'INAIL per l'infortunio sul lavoro o per la malattia professionale da esso riconosciuti assuma la forma della rendita, quest'ultima è suscettibile di revisione nel corso del tempo, in base ai presupposti previsti dalle disposizioni che regolano l'assicurazione obbligatoria.

Con riferimento alla rendita, Sez. L, n. 22897/2024, Garri F., Rv. 672300-01, ha chiarito che il termine per l'esercizio del diritto alla sua revisione stabilito dall'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965 si riferisce esclusivamente all'eventuale aggravamento derivante dalla naturale evoluzione dell'originario stato morboso, mentre, ove il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 80 del d.P.R. cit. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, qualificata la domanda come richiesta di aggravamento degli esiti dell'infortunio *in itinere* avvenuto nel 1975, aveva accertato che la patologia epatica, manifestatasi nel 2010 e diagnosticata nel

2014, era conseguenza delle trasfusioni cui l'assicurato era stato sottoposto in occasione dell'infortunio ed aveva quindi ritenuto che il diritto alla prestazione fosse precluso per effetto del decorso dei dieci anni dall'infortunio).

Presupposto necessario per l'operatività dell'assicurazione obbligatoria è il versamento del relativo premio da parte dei soggetti obbligati.

Per quanto concerne la determinazione del premio da versarsi all'INAIL per l'accensione dell'assicurazione obbligatoria, **Sez. L, n. 16905/2024, Cavallaro, Rv. 671584-01**, ha stabilito che il premio dovuto dalle società cooperative per i soci lavoratori occupati non può calcolarsi in base alla retribuzione effettivamente corrisposta per effetto dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 423 del 2001, poiché tale disposizione non ha comportato l'abrogazione o la deroga della normativa a cui è assoggettata la determinazione del predetto premio e, cioè, la disciplina, di natura speciale rispetto a quella generale dettata dall'art. 41 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dei premi speciali unitari di cui all'art. 42 del medesimo d.P.R., che rinvia a tal fine ad un apposito decreto ministeriale su delibera dell'istituto assicuratore, cosicché la determinazione del premio operata in tal modo è modificabile solo con un nuovo decreto ministeriale.

Con riferimento alla tematica dei premi, **Sez. L, n. 28326/2024, Solaini, Rv. 672734-01**, ha affermato che qualora l'INAIL - per aver pagato un'indennità in seguito ad infortunio *in itinere* al lavoratore assicurato - intenda aumentare il premio assicurativo attraverso il tasso specifico aziendale, ha l'onere di provare un proprio pregiudizio economico, che non sussiste nel caso che abbia conseguito l'integrale rimborso dell'indennizzo agendo in surroga contro il terzo responsabile dell'infortunio.

Di conseguenza, se l'Istituto riceve dal terzo una somma minore per effetto di transazione ha diritto all'aumento del premio, mentre spetta all'assicurante - che tale diritto neghi - provare la manifesta sproporzione nell'accordo transattivo, sfavorevole all'Istituto, tale che possa imputarsi allo stesso il suddetto pregiudizio economico.

In tema di determinazione dei premi dovuti all'INAIL, **Sez. L, n. 30435/2024, Solaini, Rv. 673015-01**, ha precisato che la stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato di rapporti di associazione in partecipazione avvenuta ai sensi dell'art. 7-bis, comma 7, del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. dalla l. 99 del 2013, pur comportando l'estinzione delle pretese contributive, assicurative e per sanzioni conseguenti alle contestazioni connesse a tali rapporti, non è rilevante ai fini della tariffazione assicurativa corrispondente ad una determinata classe di rischio assicurato dall'INAIL, che è questione attinente al profilo delle mansioni svolte dalle posizioni lavorative stabilizzate e non al precedente inquadramento del rapporto.

Sez. L, n. 11218/2024, Mancino, Rv. 671004-01, ha affrontato il tema della prescrizione dei contributi da versare all'INAIL, chiarendo che essi si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, con decorrenza di tale termine, quanto alla prima rata, dall'inizio della lavorazione e, quanto alle rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi degli artt. 28 e 44 del d.P.R. n. 1124 del 1965, posto che alla suddetta data il datore deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il relativo conguaglio.

4. L'azione di regresso dell'INAIL.

Per quanto riguarda tale azione **Sez. L, n. 12777/2024, Buffa, Rv. 670907-01**, ha precisato che il termine triennale previsto per la sua proposizione nei confronti dell'imputato di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 decorre dall'irrevocabilità della sentenza emessa all'esito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, senza che assuma rilevanza l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di altri soggetti per il medesimo infortunio.

Sez. L, n. 13023/2024, Buffa, Rv. 671197-01, ha escluso che l'INAIL possa essere esperire la predetta azione di regresso nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore autonomo, in quanto detta azione presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o ad esso equiparabile, sicché con riferimento a tale fattispecie, l'Istituto può esperire ma soltanto, in presenza di tutti i presupposti, la generale azione di surroga.

La natura del credito oggetto di tale azione è stata evidenziata da **Sez. L, n. 32168/2024, Marchese, Rv. 673220-01**, la quale ha affermato che esso, essendo relativo sin dall'origine ad una prestazione di denaro parametrata all'esborso economico sostenuto dall'ente nei confronti del lavoratore, non configura un credito di lavoro cui applicare l'art. 429 c.p.c. quanto, piuttosto, un'obbligazione di valuta, dovendo pertanto il capitale essere maggiorato di interessi moratori dalla costituzione in mora, salvo il maggior danno, richiesto e dimostrato dal creditore, *ex art. 1224 c.c.*

Sez. 3, n. 29950/2024, Rossetti, Rv. 672910-01, si è pronunciata su una materia affine al regresso, affermando che in materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, quando uno dei danneggiati ha patito un danno biologico indennizzato dall'INAIL, l'Istituto, per le somme pagate a tale titolo, ha diritto di concorrere al riparto proporzionale del massimale incapiente in posizione di parità, atteso che l'assicuratore sociale che agisce in surrogazione nei diritti del danneggiato suo assistito va considerato alla stregua di qualsiasi altro danneggiato-creditore.

CAPITOLO XXVII

LA PREVIDENZA DI CATEGORIA

(DI MARIO DE IORIS)

SOMMARIO: 1. Le Casse professionali. - 2. Geometri. - 3. Dottori commercialisti. - 4. Medici. - 5. Ingegneri e architetti. - 6. Notai. 7. Gli assicurati presso l'ENPAIA.

1. Le Casse professionali.

Al pari dell'INPS per i lavoratori dipendenti (e per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti), le Casse professionali gestiscono la previdenza obbligatoria per i liberi professionisti (ossia per i soggetti iscritti a un ordine professionale o che svolgono attività libero professionale), erogando il loro favore prestazioni finanziate dalla raccolta di contributi versati dagli iscritti. Esse sono state trasformate in enti privati, senza che ciò ne abbia modificato la funzione di interesse pubblico connessa all'esercizio dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza avente appunto carattere pubblicistico.

Ogni Cassa gode di ampi poteri regolamentari, con i quali esercita la sua autonomia gestionale ed organizzativa, a seconda delle peculiarità delle categorie iscritte e della loro professione, ma sempre nei limiti imposti dalla legge.

A tal proposito, **Sez. L, n. 10015/2024, Gnani, Rv. 670689-01**, ha escluso che potesse trovare applicazione alle casse previdenziali dei professionisti l'istituto della definizione agevolata, introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, applicabile soltanto agli enti previdenziali pubblici, in mancanza di un'espressa previsione legislativa che limiti l'autonomia gestionale, contabile e organizzativa degli enti previdenziali di diritto privato e nell'impossibilità di applicare analogicamente l'istituto, disciplinato da norma di stretta interpretazione.

2. Geometri.

Sez. L, n. 30191/2024, Cavallaro, Rv. 673068-01, ha enunciato il principio secondo cui ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti, e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, non rilevando la natura occasionale dell'attività e la mancata produzione di reddito, ed il regolamento della Cassa, disponendo in tal senso, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ponendosi, invece, in linea con l'art. 22 della l. n. 773 del 1982, che già prevedeva il cd. contributo di solidarietà (poi trasformato in contributo soggettivo minimo), e con gli interventi normativi successivi, dal d.lgs. n. 509 del 1994 alla l. n. 335 del 1995.

3. Dottori commercialisti.

Con riferimento alle forme di previdenza gestite dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, **Sez. L, n. 20684/2024, Magnanensi, Rv. 672074-01**, ha esaminato alcune questioni inerenti al potere di tale ente previdenziale di operare, con propri provvedimenti, trattenute su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, a titolo di contributo di solidarietà, quale misura volta ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche.

Con tale decisione, che ha contribuito a consolidare un orientamento già in precedenza espresso dai giudici di legittimità, si è affermato che sono illegittime le previsioni di tale tipo di trattenute stabilite dai regolamenti di disciplina degli enti previdenziali privatizzati in quanto aventi natura di prestazioni patrimoniali sottoposte alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., per cui esse possono andare ad incidere su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti solo se previste in base a disposizioni di legge che autorizzino un tale tipo di prelievo.

Tale principio è stato affermato con riferimento alla previsione di trattenute a titolo di contributo di solidarietà di cui all'art. 22, *ratione temporis* vigente, del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa anzidetta, ma, per le modalità con le quali è stato enunciato, essa è suscettibile di avere rilevanza generale, concernente tutti gli enti previdenziali privati.

Ciò può desumersi anche da altro principio affermato nella stessa decisione, massimato *sub n. Rv. 672074-02*, e riferito alla medesima tematica del contributo di solidarietà, stavolta oggetto di specifica previsione legislativa, e cioè l'art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011; in proposito la decisione in esame ha affermato che tale disposizione consente l'applicazione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati, limitatamente agli anni 2012 e 2013, sia per il caso di inerzia degli enti, alla data del 30 settembre 2012, nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, sia in caso di emissione di parere negativo dei Ministeri vigilanti sulle delibere al riguardo adottate, precisando però che non è possibile equiparare alla predetta inerzia la situazione in cui l'applicazione del contributo in esame sia stata disposta successivamente alla dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di riequilibrio adottati.

Su tali tematiche si è espressa, in senso conforme e in maniera tale da arricchire le ragioni del *decisum* della S.C., anche Sez. I, n. 23257/2024, *Magnanensi*, Rv. 672194-01, affermando che gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del *pro rata* e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel *genus* delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.

La medesima decisione ha altresì affrontato il tema della prescrizione del diritto del pensionato a chiedere la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'ente previdenziale a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione erogatagli, affermando al riguardo che trova applicazione il termine di prescrizione decennale; ha pertanto enunciato il principio così massimato da quest'Ufficio (massima n. Rv. 672194-02): in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando in contrario l'art. 47-bis d.p.r. nr. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione.

L'orientamento in tal modo espresso è stato ulteriormente consolidato, con riferimento alla medesima gestione previdenziale, da Sez. L, n. 29600/2024, Orio, Rv. 673060-02, e da Sez. L, n. 29965/2024, Magnanesi, Rv. 673064-01.

4. Medici.

Con riferimento al Fondo di previdenza generale per gli assicurati ENPAM (Medici ed odontoiatri), Sez. L, n. 34937/2024, Gandini, Rv. 673325-01, ha affermato che l'art. 28 del regolamento di tale Fondo, laddove prevede una specifica modalità formale e temporale di esercizio del diritto per la pensione ai superstiti, costituita dalla presentazione della domanda nel termine di cinque anni dal decesso del *de cuius*, introduce una causa di decadenza convenzionale dal diritto, di modo che, non venendo in rilievo un'ipotesi di prescrizione, non si pone né il problema del rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 2946 c.c. per la prescrizione decennale, né della mancanza di una previsione in tal senso nell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, rilevando, invece, i limiti stabiliti in via generale dall'art. 2965 c.c. per le decadenze convenzionali.

5. Ingegneri e architetti.

Con riferimento alla gestione previdenziale per gli ingegneri e architetti liberi professionisti, Sez. L, n. 18395/2024, Gnani, Rv. 671898-01, ha esaminato la fattispecie della compensazione fra il credito dei professionisti, avente a oggetto ratei della pensione di vecchiaia, e il controcredito per contributi non pagati dell'ente di previdenza, affermando che quest'ultimo, in tale ipotesi di compensazione impropria, resta obbligato, in qualità di sostituto d'imposta, al versamento delle ritenute fiscali sulle somme dovute a titolo di ratei pensionistici, anche se non versate, costituendo la compensazione un mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattivo, che realizza quindi - così come il pagamento - un incremento nella sfera patrimoniale del creditore mediante liberazione da un corrispondente debito.

Sempre in tema di previdenza degli architetti e ingegneri iscritti ad INARCASSA, Sez. L, n. 30315/2024, Garri F., Rv. 673014-01, ha chiarito che il diritto dei superstiti alla pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 6 del 1981, non può essere impedito dalla mancata presentazione della domanda amministrativa del trattamento pensionistico da parte dell'assicurato, se questi ne aveva comunque maturato i requisiti anagrafici e contributivi prima del decesso, non costituendo la domanda presupposto per l'insorgenza del diritto alla prestazione, ma atto d'avvio del procedimento per la sua corresponsione.

Con l'ordinanza Sez. L, n. 22056/2023, Cavallaro, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi ad INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ex art. 21 della l. n. 6 del 1981, e che siano pertanto tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Detta questione è stata ritenuta fondata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024 e, sulla scorta di tale sentenza, Sez. L, n. 28652/2024, Buffa, Rv. 672688-01, ha affermato che gli anzidetti ingegneri e architetti sono esonerati dal pagamento delle san-

zioni civili in favore dell'ente previdenziale per l'omessa iscrizione nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 cit, in applicazione dello *ius superveniens* conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024.

6. Notai.

Sez. L, n. 22903/2024, Cerulo, Rv. 672306-01, si è pronunciata in ordine alla pensione di inabilità prevista per tale categoria di professionisti, stabilendo che l'art. 10, comma 1, lett. b), del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà della Cassa nazionale del notariato costituisce disposizione di carattere negoziale, che si sottrae al sindacato di costituzionalità, e - conformemente alle ragioni che l'ente, nella sua autonomia, ha attribuito alla tutela degli iscritti - deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento della pensione d'inabilità presuppone l'esercizio in atto, o comunque giuridicamente possibile, delle funzioni notarili e l'impossibilità di darvi prosecuzione per una causa di inabilità sopravvenuta (nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato il ricorso di un notaio, costretto a sospendere la propria attività molti anni prima per effetto di un provvedimento disciplinare).

7. Gli assicurati presso l'ENPAIA.

Con riferimento agli assicurati presso l'ENPAIA, l'Ente nazionale (oggi Fondazione di diritto privato) per la previdenza degli addetti ed impiegati in agricoltura - il quale in veste privatistica, ancorché vigilata, continua a gestire le forme di previdenza obbligatoria di cui alla legge n. 1655 del 1962 per i lavoratori anzidetti (Fondo T.F.R., Fondo di previdenza, Assicurazione infortuni) - **Sez. L, n. 28972/2024, Gnani, Rv. 673016-01**, ha affermato che la cessazione del rapporto di lavoro non costituisce il presupposto per la liquidazione del cd. conto individuale, *ex* art. 6 del Regolamento di previdenza approvato con decreto interministeriale del 19.11.1996, in quanto la liquidazione di detto conto non ha funzione di sostegno al reddito. Ne consegue che la liquidazione va operata anche nei casi in cui il rapporto di lavoro continua, ma con passaggio del lavoratore ad altra gestione, mentre va esclusa nelle ipotesi di continuità assistenziale con ENPAIA, in ragione dell'inesigibilità della somma accantonata prima della cessazione del rapporto assicurativo.

CAPITOLO XXVIII

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

(DI MARIO DE IORIS)

SOMMARIO: 1. Finalità della previdenza complementare, natura dei relativi versamenti e mezzi di tutela contro il datore di lavoro insolvente. - 2. Le forme di previdenza integrativa per il personale del pubblico impiego. - 3. Alcuni casi controversi di legittimazione passiva.

1. Finalità della previdenza complementare, natura dei relativi versamenti e mezzi di tutela contro il datore di lavoro insolvente.

Il quadro normativo che governa le forme pensionistiche complementari è stato ricostruito, nei suoi tratti essenziali, da un'articolata sentenza dell'anno precedente a quello in rassegna, Sez. L, n. 18477/2023, Patti, (Rv. 668209-01, 02, 03, 04), ribadendo che esse perseguono la finalità di integrare, appunto in via complementare, i trattamenti erogati dal sistema obbligatorio pubblico, in modo da assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, trovando anch'esse il loro fondamento costituzionale nell'art. 38 Cost.

Sulla scorta di tali premesse, Sez. L, n. 11198/2024, Mancino, Rv. 671002-01, è tornata sulla natura dei versamenti ai fondi pensione complementari, approfondendo anche i profili concernenti il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro e gli effetti del fallimento di quest'ultimo e della cessione dell'azienda datoriale, anche con riferimento al ruolo che può svolgere il Fondo di garanzia per il TFR dell'INPS.

La S.C. ha così affermato che, se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di versare le quote del maturando TFR al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, questi resta creditore nei confronti del datore del corrispondente importo di natura retributiva, e nel relativo debito, in caso di cessione d'azienda, subentra *ex art. 2112 c.c.* il datore di lavoro cessionario, tenuto ad adempiere nei medesimi termini; ciò comporta, però, che non può essere accolta la richiesta del lavoratore di intervento del Fondo di garanzia *ex art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992*, avanzata per il fallimento del cedente dichiarato dopo la cessione dell'azienda, mancando in tal caso il presupposto della sottoposizione del datore di lavoro cessionario ad una delle procedure di cui all'art. 1 del citato d.lgs.

2. Le forme di previdenza integrativa per il personale del pubblico impiego.

Nell'ambito delle forme di previdenza integrativa per il personale del pubblico impiego, già in passato hanno costituito oggetto di ripetuta attenzione giurisprudenziale quelle forme preesistenti alla legge n. 70 del 1975 di riordino degli enti pubblici "parastatali".

Nel corso del 2024 è tornata ad occuparsi di tali forme di previdenza Sez. L, n. 17111/2024, Solaini, Rv. 671587-01, la quale ha affermato che l'espresso divieto di iscriversi ai Fondi di previdenza integrativa, stabilito dall'art. 14 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti pubblici parastatali assunti successivamente all'entrata in vigore della medesima legge, è stato abrogato dall'art. 18, comma 9, del d.lgs. n. 124 del 1993, che ha consentito la facoltà di riscatto dei periodi pregressi, subordinandola però, al pari dell'iscrizione ai Fondi, all'adozione di un decreto ministeriale recante i criteri di calcolo degli oneri di riscatto o ricongiungimento, in mancanza della quale non può configurarsi in capo ai lavoratori già dipendenti dell'E.N.P.I., assunti dopo l'entrata in vigore della l. n. 70 del 1975, un diritto

soggettivo all'iscrizione al Fondo integrativo costituito presso l'ente d'appartenenza, cosicché è legittimo il provvedimento di cancellazione *ex tunc* di tale iscrizione, effettuata in violazione della normativa di riferimento, con restituzione dei contributi versati.

Sez. L, n. 14139/2024, Cavallari, Rv. 671207-01, si è occupata invece del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con l'art. 1 del d.P.R. n. 21 del 1981, e della sua disciplina di attuazione dettata con il d.P.R. n. 1034 del 1984, con riferimento alla sua applicabilità al personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 283 del 1998.

In tale decisione la S.C. ha affermato che nell'ambito del personale di detta Amministrazione autonoma, inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze ed applicato temporaneamente all'Ente tabacchi italiani, i dipendenti che non sono transitati definitivamente nei ruoli di tale Ente hanno diritto all'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 4, n. 1, del citato d.P.R. n. 1034 del 1984 anche per il periodo di servizio, da computarsi *ex art.* 6 del medesimo d.P.R., prestato presso di esso, a differenza dei dipendenti transitati in via definitiva allo stesso Ente, ai quali, per il periodo di lavoro svolto presso di questo dopo il trasferimento, detto diritto non può essere riconosciuto.

3. Alcuni casi controversi di legittimazione passiva.

Sez. L, n. 16878/2024, Solaini, Rv. 671583-01, si è occupata di una peculiare forma di previdenza integrativa, prevista per i dipendenti degli istituti di credito privatizzati, e dei suoi rapporti con la previdenza obbligatoria.

Con tale decisione è stato affermato che l'iscrizione di detti dipendenti, in pensione alla data del 31 dicembre 1990, nella gestione speciale istituita presso l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 357 del 1990, ha comportato l'assunzione a carico di tale gestione solo di una quota del trattamento pensionistico complessivo loro spettante, assoggettata esclusivamente alla disciplina per la perequazione automatica dell'assicurazione generale obbligatoria, sicché l'INPS non ha legittimazione passiva rispetto alla domanda di adeguamento della pensione proposta in ragione della clausola di cui all'art. 24 dello statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane (c.d. "clausola oro"), per la quale unico legittimato è il Fondo stesso, titolare del trattamento pensionistico complementare.

Sez. L, n. 20963/2024, Cinque, Rv. 671948-01, si è occupata invece dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), costituito con la l.r. Sicilia n. 8 del 2012, affermando che ad esso - in qualità di soggetto tenuto, a decorrere dalla chiusura delle operazioni di liquidazione dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI), all'erogazione del trattamento pensionistico integrativo in favore degli *ex* dipendenti di tali enti collocati in quiescenza prima della loro soppressione - spetta la legittimazione passiva per le controversie inerenti a detto trattamento.

PARTE SESTA

I RAPPORTI CON I PUBBLICI POTERI

(coordinata da Alessandro Farolfi e Cecilia Bernardo)

CAPITOLO XXIX

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

(DI GIULIA STANO)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Giurisdizione. - 3. Aspetti processuali - 4. Procedimento espropriativo. - 5. Determinazione delle indennità di espropriazione e occupazione. Altre indennità. - 6. Opposizione alla stima. - 7. Ipotesi diverse di acquisizione in capo alla p.a. - 8. Casi particolari: la facoltà di riacquisizione di aree attribuita ai Consorzi di sviluppo industriale *ex art.* 63 l. n. 448 del 1998; commissariamento dell'Ilva, disposto con il d.l. n. 61 del 2013, convertito in l. n. 89 del 2013.

1. Premessa.

Le pronunce in tema di espropriazione per pubblica utilità emesse nell'anno in rassegna attengono in massima parte a questioni processuali (relative anche al procedimento di opposizione alla stima) e in materia di determinazione delle indennità previste dalla disciplina di settore. Non mancano peraltro decisioni sul procedimento espropriativo, su ipotesi diverse di acquisizione in capo alla p.a. e su casi particolari di acquisto previsto da leggi speciali.

2. Giurisdizione.

In tema di limiti esterni della giurisdizione e in continuità con i principi affermati da Sez. U, n. 32773/2018, *Scaldaferri*, Rv. 651960-01, e Sez. U, n. 27174/2022, *Scarpa*, Rv. 665662-01, la pronuncia Sez. U, n. 30605/2024, *Di Paolantonio*, Rv. 672847-01, ha affermato che l'eccesso di potere giurisdizionale "per arretramento", denunziabile con il ricorso per cassazione *ex art.* 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla base dell'erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non si prospetta in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall'errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in tale ipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza del Consiglio di Stato relativa a un'espropriazione per pubblica utilità, col quale si censurava l'erronea statuizione di avvenuta formazione del giudicato esterno circa l'insussistenza del diritto alla retrocessione dei beni espropriati, la declaratoria di prescrizione della domanda risarcitoria e l'irrelevanza e manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti.

Inoltre, Sez. 1, n. 25027/2024, *Reggiani*, Rv. 672485-01, ha stabilito che nel giudizio per la determinazione dell'indennità di esproprio, il giudice ordinario può valutare la vali-

dità ed efficacia del provvedimento ablativo, senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché egli non procede all'annullamento dell'atto, ma si limita a disapplicarlo, ove invalido o inefficace, per escludere la debenza dell'indennità; tale disapplicazione non involge, infatti, una questione di giurisdizione, ma riguarda l'esercizio di un potere interno alla giurisdizione del g.o., censurabile *ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.*

Infine, la pronuncia **Sez. U, n. 9448/2024, Mercolino, Rv. 670666-02**, in tema di violazione delle distanze, ha affermato che l'adozione, ai sensi dell'art. 42-*bis* del d.P.R. n. 327 del 2001, da parte della Pubblica Amministrazione, di un provvedimento di servitù coattiva con effetto sanante (volta a regolarizzare l'opera realizzata in violazione delle distanze) non determina - in applicazione del principio della *perpetuatio jurisdictionis* - la sottrazione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, ma determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione alle medesime aree, in quanto il sesto comma del predetto art. 42-*bis* dispone che in tale ipotesi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi precedenti, le quali prevedono, per l'ipotesi di emissione del provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, che si determini l'acquisizione del diritto di proprietà da parte dell'amministrazione, precludendo pertanto l'esercizio dell'azione di restituzione del bene da parte del privato ed il mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che, per effetto di tale provvedimento, si converte in quella all'indennizzo previsto dal medesimo art. 42-*bis*.

3. Aspetti processuali.

Sez. 1, n. 8868/2024, D'Orazio, Rv. 671025-01, ha affermato che la Corte di appello, erroneamente adita quale giudice dell'impugnazione, anziché quale giudice competente in unico grado *ex art. 20 della l. n. 865 del 1971*, ove la domanda di determinazione dell'indennizzo sia stata ritualmente formulata in primo grado, deve comunque decidere nel merito, in ossequio ai principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

Sez. T, n. 2640/2024, Paolitto, Rv. 670208-01, ha inoltre affermato che il ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti *ex art. 43 c.p.a.* è soggetto al contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 6-*bis*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo vigente *ratione temporis*, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi, ponendosi così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con l'impugnazione dell'atto originario; al contrario, il ricorso aggiuntivo è esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, poiché non aveva escluso la debenza del contributo unificato sul ricorso aggiuntivo, con il quale era stato impugnato il decreto di proroga del termine per il compimento delle procedure espropriative, non tenendo conto del nesso di presupposizione che lo legava alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, originariamente impugnata, dando luogo ad una connessione cd. forte di cause).

4. Procedimento espropriativo.

In tema di atti del procedimento espropriativo, **Sez. 1, n. 25027/2024, Reggiani, Rv. 672485-02**, ha stabilito che la dichiarazione di pubblica utilità, prorogata anche reiteratamente prima

della scadenza del termine, conserva la sua efficacia ed è valido il decreto di esproprio, se emesso prima dell'ultima scadenza, con conseguente legittimità dell'attività manipolativa del bene del privato, compiuta nel complessivo periodo di efficacia della dichiarazione, non essendo configurabile alcuna carenza del potere amministrativo, né in astratto né in concreto.

Ancora, **Sez. 1, n. 27354/2024, D'Orazio, Rv. 672779-01**, ha affermato che il certificato di destinazione urbanistica, avendo natura di certificazione redatta da un pubblico ufficiale, dal carattere meramente dichiarativo, e non costitutivo, degli effetti giuridici derivanti da precedenti provvedimenti, è privo di efficacia provvedimentale e, non avendo concreta lesività, non è autonomamente impugnabile, potendo gli eventuali errori essere corretti dalla stessa amministrazione, su istanza del privato, ovvero dal giudice amministrativo, dinanzi al quale siano impugnati i successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati sulla base dell'erroneo certificato.

Sez. 1, n. 25109/2024, D'Orazio, Rv. 672484-02, ha stabilito che l'inserimento nel piano regolatore delle opere di grande viabilità, che interessano una parte rilevante del territorio comunale, consistendo in una limitazione di ordine generale, che cade su una pluralità indistinta di beni per finalità di interesse pubblico e che trascende gli interessi dei singoli proprietari delle aree (i quali potranno trarre beneficio dall'esecuzione dell'opera), non è qualificabile come un vincolo preordinato all'esproprio, integrando piuttosto un vincolo di inedificabilità delle zone assoggettate a destinazione viaria, salvo che si tratti di vincolo imposto a titolo particolare su specifici beni, assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno ed a servizio delle singole zone.

5. Determinazione delle indennità di espropriazione e occupazione. Altre indennità.

Nell'importante pronuncia **Sez. 1, n. 28808/2024, Russo, Rv. 672879-01**, è stato affermato che la destinazione del piano regolatore generale a "verde pubblico", pur ordinariamente di carattere conformativo, può rivelarsi, in via eccezionale, come vincolo preordinato all'esproprio - restando quindi irrilevante ai fini della determinazione della citata indennità - al concorrere di tutti i seguenti presupposti: a) che si traduca in un'imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati al precipuo fine della precisa e puntuale localizzazione di un intervento edilizio che, per natura e scopo, sia d'esclusiva appropriazione e fruizione collettiva; b) che la relativa realizzazione risulti incompatibile con la proprietà privata e, perciò, presupponga ineluttabilmente, per il suo compimento, l'espropriazione del bene; c) che l'imposizione determini l'inedificabilità del bene colpito e, dunque, lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul suo godimento, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero da diminuirne in modo significativo il valore di scambio.

In tema di edificabilità legale del suolo espropriato, inoltre, **Sez. 1, n. 23961/2024, D'Orazio, Rv. 672518-01**, ha stabilito che un'area va ritenuta edificabile soltanto quando - e per il solo fatto che - come tale essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, sicché le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui lo strumento urbanistico, vigente all'epoca con riferimento alla quale deve compiersi la ricognizione, abbia destinato la zona, con vincolo conformativo, ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico attrezzato, attrezzature pubbliche, viabilità); conseguentemente, l'edificabilità legale può essere affermata solo se la predetta destinazione è limitata e funzionale all'interno di una zona urbanistica omogenea espressamente classificata come edificabile, a nulla rilevando, in tal caso, vincoli e prescrizioni che vengono ad incidere, nell'ambito di tale zona, su beni determinati, sui quali si localizza la realizzazione dell'opera pubblica.

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, **Sez. 1, n. 25154/2024, Mercolino, Rv. 672405-01**, ha affermato che la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del criterio del VAM (valore agricolo medio), trova applicazione ai rapporti non ancora definitivamente esauriti, con riguardo ai quali l'indennità va stimata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno. Sez. U, n. 17868/2013, Botta, Rv. 627217-01, avevano già stabilito, sul punto, che qualora l'espropriato contesti, anche sotto il profilo della natura non agricola, ma parzialmente edificatoria, del terreno, la quantificazione operata dalla corte di appello con il criterio del VAM (valore agricolo medio), previsto dagli artt. 16 della legge n. 865 del 1971 e 5 *bis*, comma 4, della legge n. 359 del 1992 e dichiarato incostituzionale dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, la stima dell'indennità deve essere effettuata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno, tratto dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, applicandosi la menzionata pronuncia di illegittimità ai rapporti non ancora definitivamente esauriti (come, nella specie, per l'avvenuta impugnazione del credito indennitario per la descritta ragione) ed irrilevante rivelandosi la circostanza che il giudice *a quo*, allo scopo di evitare una *reformatio in pejus* della somma già offerta dall'espropriante, abbia comunque riconosciuto una indennità che, seppure di importo superiore a quella conseguente all'applicazione del VAM, non trovi giustificazione nel predetto valore venale di mercato del terreno ablato.

Inoltre, **Sez. 1, n. 11608/2024, Reggiani, Rv. 671115-01**, ha stabilito che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011 - intervenuta nel corso del procedimento di espropriazione, ma prima dell'atto ablativo - comportando la sopravvenuta invalidità dell'accordo sull'indennità delle aree non edificabili in precedenza raggiunto, consente al proprietario del bene di agire per chiedere, previo accertamento della predetta invalidità, la determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001.

Quanto ai criteri di commisurazione dell'indennità di occupazione, **Sez. 1, n. 25162/2024, Marulli, Rv. 672486-01**, ha poi stabilito che il collegamento procedurale e funzionale tra l'occupazione d'urgenza ed il procedimento espropriativo, del quale la prima costituisce momento prodromico, non viene meno qualora all'occupazione non sopravvenga un tempestivo decreto di esproprio, di modo che è la stessa occupazione che consente il verificarsi dell'effetto acquisitivo della proprietà del bene all'ente pubblico per effetto dell'irreversibile trasformazione di esso: ne consegue che, anche in tale ipotesi, l'indennità di occupazione va liquidata secondo il medesimo criterio adottabile ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio, ovvero con gli interessi legali sulla somma che sarebbe spettata a titolo di esproprio, per ciascun anno di occupazione.

In tema di acquisizione sanante, **Sez. 1, n. 25707/2024, Reggiani, Rv. 672419-02**, ha affermato che il giudizio di determinazione dell'indennizzo *ex art. 42-bis* del d.P.R. n. 327 del 2001 non ha natura di impugnazione dell'atto amministrativo che lo ha determinato, poiché non si esaurisce nel mero controllo delle statuizioni adottate in tale sede, ma è diretto a stabilire il *quantum* effettivamente dovuto, compiendo il giudice la propria valutazione in piena autonomia, seppur nei limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente formulate dalle parti, sicché, ove il privato richieda la corretta determinazione del valore del bene e la liquidazione dell'indennità corrispondente al risarcimento del danno da illegittima occupazione, ai sensi del comma 3 del citato art. 42-*bis*, e l'Amministrazione non eccepisca la prescrizione del credito vantato, l'importo dovuto va calcolato tenendo conto dell'indennità spettante a partire dal momento di inizio dell'occupazione illegittima. La stessa pronuncia ha affermato anche il principio secondo cui il valore venale del bene va

determinato senza considerare quello dell'opera pubblica realizzata dalla P.A., ma tenendo conto della destinazione urbanistica al momento dell'acquisizione dell'area oggetto del procedimento ablatorio, poiché essa connota le attuali caratteristiche giuridiche, in particolare di edificabilità, del bene stesso. Dalla premessa deriva la illegittimità della determinazione basata sul criterio del cd. costo di trasformazione, che, pur epurata la stima dal valore dell'opera pubblica realizzata, consideri le caratteristiche di una sottozona diversa da quella propria del bene al momento dell'acquisizione (recante un indice di edificabilità inferiore a quello effettivo), attribuendo così allo stesso un valore diverso da quello venale effettivo (Rv. 672419-01). Inoltre, Sez. 1, n. 8163/2024, **Parise**, Rv. 670564-01, ha precisato che il valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. "acquisizione sanante" va determinato alla data di adozione del provvedimento acquisitivo, essendo questo volto a ripristinare, ma solo con effetto *ex nunc*, la legalità amministrativa violata.

Ancora, in tema di espropriazione parziale, Sez. 1, n. 24122/2024, **Caiazzo**, Rv. 672479-01, ha statuito che il criterio di stima differenziale, previsto dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001), è rivolto a garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato; tale risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, anziché attraverso tale comparazione diretta, mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.

Sez. 1, n. 25972/2024, **D'Orazio**, Rv. 672748-01, poi, ha affermato che l'indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto o all'imprenditore agricolo professionale *ex* art. 40, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere richiesta necessariamente in modo congiunto all'indennità di espropriazione, trattandosi di determinare la somma complessivamente dovuta dall'espropriante a colui che venga privato del suo diritto reale in uno con l'attività di coltivatore del fondo; diversamente, l'indennità dovuta al terzo coltivatore diretto in forza di un rapporto agrario contrattuale o compartecipativo, prevista dall'art. 42 che rinvia per la liquidazione all'art. 40 cit., può essere oggetto di domanda autonoma, in quanto volta a ristorare l'attività coltivatrice svolta su suolo altrui, interrotta forzatamente per effetto della procedura espropriativa. In argomento, Sez. 1, n. 25203/2024, **Marulli**, Rv. 672410-01, ha affermato che l'indennità aggiuntiva, prevista dall'art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001 in favore del fittavolo, mezzadro e compartecipante, costretti ad abbandonare il fondo da loro direttamente coltivato, non spetta a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma (nella specie, coloro che detengono il fondo in base ad un rapporto derivato da quello di affitto agrario intercorrente tra proprietario ed un diverso soggetto), poiché l'impiego di risorse pubbliche, nell'ottica di un bilanciamento dei valori in gioco, impone una lettura restrittiva della norma, al fine di evitare una dilatazione oltre misura dell'impegno finanziario richiesto.

Sez. 3, n. 19806/2024, **Rubino**, Rv. 671814-01, ha statuito che l'indennizzo di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 - spettante al proprietario dell'immobile che subisce un danno permanente per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità - integra un indennizzo per un'attività lecita che produce una *deminutio* permanente atta a ripercuotersi su una o più delle possibilità di godimento del bene, con la conseguenza che il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrente da quando il privato inizia a subire il pregiudizio ovvero dal momento dell'inizio di operatività dell'opera pubblica.

In applicazione del principio, la S.C. - affermando l'inapplicabilità, ai fini della decorrenza della prescrizione, del diverso termine prescrizionale relativo all'azione di risarcimento dei danni da immissioni e della nozione di illecito permanente, alle stesse collegata - ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva affermato la prescrizione del diritto all'indennizzo del proprietario di un immobile per il pregiudizio subito in conseguenza delle immissioni di rumori prodotti dall'intenso traffico veicolare su una tangenziale, computando la decorrenza del termine decennale dall'apertura della strada al pubblico transito.

A sua volta, **Sez. 2, n. 17585/2024, Grasso, Rv. 671711-01**, ha affermato che il cd. accordo amichevole per determinare l'indennità *ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001*, salva diversa e univoca volontà delle parti, è limitato a ristorare il pregiudizio derivante dall'insorgere di una servitù o dalla permanente diminuzione di valore dell'immobile per la perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.

Quanto alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla realizzazione dell'opera di pubblica utilità sulla porzione di fondo non assoggettata ad esproprio, **Sez. 1, n. 31365/2024, D'Orazio, Rv. 673227-01**, ha affermato che l'istituto dell'espropriazione parziale si applica quando la vicenda espropriativa investe parte di un bene appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da una destinazione economica unitaria, e inoltre implica per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento, presupponendo l'accertamento che la parte residua del fondo sia collegata con quella espropriata da un vincolo tale da conferire all'intero immobile un'unità economica e funzionale, suscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco di una sua parte. Nella medesima pronuncia si è, quindi, stabilito che la disposizione dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - secondo cui è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi - non richiede necessariamente che la situazione contemplata venga a determinarsi in conseguenza di un procedimento espropriativo o di occupazione, ed è diretta alla tutela di soggetti che (quand'anche un procedimento espropriativo vi sia stato) o ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa (c.d. "espropriazione larvata").

Ancora, **Sez. 1, n. 11767/2024, D'Orazio, Rv. 671328-01**, in conformità a **Sez. 1, n. 12468/2018, Lamorgese, Rv. 648780-01**, ha ribadito il principio secondo cui la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell'atto medesimo (quantomeno in via presuntiva), e poi di liquidare, un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata. A tali accertamenti provvede il giudice del merito nei casi in cui la liquidazione sia omessa dalla P.A. o sorgano contestazioni sulla misura dell'indennizzo liquidato in favore del proprietario, ma al privato non si richiede di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A. e non il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito.

Inoltre, Sez. 1, n. 6977/2024, Lamorgese, Rv. 670480-02, ha affermato che l'indennità prevista dall'art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001 non è dovuta nei casi in cui il pregiudizio dedotto in causa non sia riferibile direttamente all'insistenza e alla reiterazione di vincoli scaduti preordinati all'esproprio, che possono essere contenuti nei piani per gli insediamenti produttivi e in piani analoghi, ma sia riferibile alle limitazioni d'uso dei beni insite nelle prescrizioni conformative previste nello stesso piano o nel piano regolatore generale, comportanti limitazioni d'uso coerenti con le specifiche caratteristiche del bene, alla luce dell'art. 17, comma 1, della l. n. 1150 del 1942 che, prevedendo l'ultrattività delle disposizioni del piano scaduto disciplinanti l'edificazione, stabilisce l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona ivi stabiliti.

6. Opposizione alla stima.

Sulla scorta di Sez. U, n. 758/2022, Lamorgese, Rv. 663582-01 (secondo cui “nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, *ex art.* 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo *pro futuro*, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione”), Sez. 1, n. 24000/2024, D'Orazio, Rv. 672478-01, ha affermato che la tempestività dell'opposizione alla stima proposta erroneamente con atto di citazione, piuttosto che con ricorso, deve essere valutata al momento della notifica e non al momento del deposito in giudizio di detto atto introduttivo, senza che assuma rilievo l'omessa pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, in quanto la stessa è destinata ad operare sul rito da seguire all'esito della conversione, senza effetti penalizzanti per quelli comunque collegati alla domanda introdotta secondo un modello difforme da quello legale, ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

Sez. 1, n. 6593/2024, Reggiani, Rv. 670634-01, ha poi affermato che, in assenza di diverse disposizioni normative, al giudizio di opposizione alla stima dell'immobile espropriato si applica la disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001, ove il procedimento espropriativo sia avviato prima dell'entrata in vigore del menzionato d.P.R. ma la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta successivamente a tale data, anche nel caso in cui l'espropriazione sia volta alla realizzazione di opere secondo le procedure straordinarie previste dall'art. 4, comma 4, lett. e) della l. n. 80 del 1984, la cui disciplina, in virtù del richiamo agli artt. 80 e ss. della l. n. 219 del 1981, prevede l'applicazione per la menzionata stima di norme che sono state abrogate per effetto dell'entrata in vigore del richiamato d.P.R. del 2001.

Sez. 1, n. 25246/2024, Marulli, Rv. 672412-01, ha stabilito che l'espropriante che eccepisca la tardività dell'opposizione alla liquidazione giudiziale dell'indennità, in ragione dell'effettuazione della stima amministrativa della stessa e della scadenza del termine di trenta giorni dall'inserzione del relativo avviso di deposito, ha l'onere di provare il fondamento di tale deduzione, vertendosi in tema di eccezione inerente a fatto preclusivo dell'azione.

Sez. 1, n. 25109/2024, D'Orazio, Rv. 672484-01, ha affermato che nel procedimento di opposizione alla stima le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla c.t.u. non sono soggette a preclusioni e possono formularsi anche nelle note conclusionali, depositate in vista della discussione orale, poiché l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella formulazione *ratione temporis* vigente, prevede un rito celere e deformalizzato come il rito sommario.

Sez. 1, n. 6977/2024, Lamorgese, Rv. 670480-01, ha stabilito che il termine di trenta giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, per proporre opposizione alla stima dell'indennità per la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, non è applicabile nel caso in cui l'autorità amministrativa non abbia provveduto sulla domanda di pagamento o abbia provveduto dichiarando che l'indennità non è dovuta.

7. Ipotesi diverse di acquisizione in capo alla p.a.

In tema di occupazione illegittima della P.A. e trasformazione irreversibile del fondo, **Sez. 1, n. 29245/2024, D'Orazio, Rv. 673083-01**, ha affermato che non incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c. il giudice che, a fronte della domanda di reintegrazione nel possesso del proprietario, una volta acclarata l'impossibilità di adempimento da parte dell'amministrazione, per l'intervenuta irreversibile trasformazione del bene a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, pronunci d'ufficio la condanna del convenuto al risarcimento del danno per la perdita del godimento del bene, poiché l'originaria domanda di reintegrazione nel possesso e, quindi, di reintegrazione del danno in forma specifica, già contiene la successiva eventuale domanda di risarcimento del danno per equivalente, ove il bene sia stato irreversibilmente trasformato.

Sulla scorta del precedente conforme di **Sez. 1, n. 12846/2018, Marulli, Rv. 648781-01, Sez. 1, n. 18222/2024, Russo, Rv. 671663-01**, ha precisato che l'occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa sono caratterizzate l'una dall'irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio, e l'altra dalla trasformazione in mancanza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità. Tuttavia, nel caso di proposizione dell'azione di risarcimento del danno in conseguenza di occupazione usurpativa, è ammissibile la riqualificazione della domanda, anche da parte del giudice, come relativa ad una occupazione appropriativa, in quanto entrambe fonte di responsabilità risarcitoria della P.A. secondo i principi di cui all'art. 2043 c.c.

8. Casi particolari: la facoltà di riacquisizione di aree attribuita ai Consorzi di sviluppo industriale ex art. 63 l. n. 448 del 1998.

Tra i casi particolari di attribuzione della facoltà ablatoria, vi è quello dei Consorzi di sviluppo industriali previsto dall'art. 63 della l. n. 448 del 1998. Pronunciando sul punto, **Sez. 1, n. 28423/2024, Marulli, Rv. 672875-02**, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della l. n. 448 del 1998, laddove prevede la facoltà di riacquisizione delle aree in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, esercitabile dai Consorzi di sviluppo industriale tramite la corresponsione del prezzo attualizzato di acquisizione in luogo del prezzo di mercato, atteso che tale potere va qualificato come esplicazione di una potestà ablatoria ad utilità pubblica predefinita, volta cioè a ripristinare, in funzione del superiore interesse pubblico perseguito dal legislatore con l'istituzione del consorzi di sviluppo industriale, uno stato di fatto coerente con le finalità dell'intervento pubblico, e non già come espressione di un generale potere ablatorio in capo alla pubblica amministrazione, sicché non si determina, in forza del suo

esercizio, alcun sacrificio indebito in danno dell'assegnatario, in quanto la sua condizione non è assimilabile a quella del proprietario che si vede espropriato un immobile per la realizzazione di un'opera pubblica. La medesima pronuncia ha espresso anche il principio (Rv. 672875-01) secondo cui la facoltà di "riacquisto" attribuita ai Consorzi di sviluppo industriale dall'art. 63 della l. n. 448 del 1998, nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, non va intesa in senso meramente letterale, cioè quale esercizio di un diritto di riscatto dell'area e degli impianti sulla stessa eventualmente costruiti pattuito al momento dell'inserzione di essa nel perimetro della zona consortile, ma va interpretata in senso più ampio, come esplicazione dell'interesse pubblico al riacquisto dell'area da parte dell'ente consortile, sicché detta pretesa, in presenza dei presupposti previsti dalla citata legge, può essere esercitata prescindendo dalla circostanza che il Consorzio sia stato precedentemente proprietario dei beni oggetto di riacquisizione.

Sez. 1, n. 27137/2024, D'Orazio, Rv. 672768-01, ha stabilito che il provvedimento di riacquisizione, previsto dall'art. 63 della l. n. 448 del 1998, ha ad oggetto tutte le aree comunque sottoposte a vincolo derivante dalla destinazione industriale, anche se acquistate da privati e non cedute dal consorzio, purché incluse nel piano di sviluppo industriale e, dunque, conformate ad esigenze di natura pubblicistica.

Sez. 1, n. 27260/2024, D'Orazio, Rv. 672773-01, inoltre, ha affermato che nel procedimento di riacquisto, ex art. 63 della l. n. 448 del 1998, da parte dei consorzi di sviluppo industriale delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali e degli stabilimenti ivi realizzati, l'effetto traslativo si realizza con l'adozione del provvedimento di riacquisizione delle aree cedute, rappresentando la fase della determinazione del prezzo un mero *post factum*, inidoneo ad integrare il trasferimento della proprietà ma funzionale alla determinazione del *quantum* spettante al proprietario che ha perso la titolarità del bene.

Con riferimento, invece, alla disciplina sul commissariamento dell'Ilva, disposto con il d.l. n. 61 del 2013, convertito in l. n. 89 del 2013, **Sez. 1, n. 10500/2024, Terrusi, Rv. 670972-01**, ha stabilito che, a fronte di tale commissariamento, il soggetto titolare di una partecipazione minoritaria può, in astratto, invocare il diritto a un indennizzo per lesione del valore patrimoniale della quota ai sensi degli artt. 42 Cost. e 1 del Protocollo addizionale della CEDU, rientrando la partecipazione azionaria nella categoria dei "beni" ai quali è dedicata la previsione di salvaguardia dettata dal citato art. 1; spetta però al giudice del merito stabilire se, in concreto, un pregiudizio di tal genere vi sia stato come diretta conseguenza della legge-provvedimento, e la relativa valutazione, se motivata, resta insindacabile in cassazione.

CAPITOLO XXX

APPALTI PUBBLICI

(DI FRANCESCA DELLA VALLE)

SOMMARIO: 1. Il contratto di appalto. - 2. L'esecuzione del contratto. - 3. L'arbitrato negli appalti pubblici. - 4. Il subappalto.

1. Il contratto di appalto.

Svariate sono le pronunce relative al lato soggettivo del contratto di appalto, in particolare in tema di ATI e consorzi.

Sez. 2, n. 27703/2024, Varrone, Rv. 672822-01, ha affermato la nullità del patto parasociale tra i concorrenti riuniti in ATI, che non rispecchi la percentuale di partecipazione ai lavori indicata nel documento presentato in sede di offerta, stante il disposto dell'art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 47 del 2014, secondo cui la mancata corrispondenza tra partecipazione all'ATI ed esecuzione dei lavori determina la nullità del contratto, trattandosi di precetto imperativo non derogabile dall'autonomia delle parti.

In materia di società consortili, **Sez. 1, n. 32676/2024, Reggiani, Rv. 673358-01**, per l'ipotesi di costituzione della società consortile per l'esecuzione del contratto, ha chiarito che il subentro di quest'ultima, costituita tra le imprese riunite in associazione temporanea, alle imprese consorziate aggiudicatrici nell'esecuzione del contratto, non implicando la sussistenza di un subappalto o di una cessione del contratto in capo alla prima, non determina l'applicazione all'impresa cessionaria del disposto dell'art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, ma della disciplina comune prevista per le società consortili di capitali, con la conseguenza che detta impresa non risponde in solido con la società consortile delle obbligazioni da quest'ultima contratte per l'esecuzione dell'appalto. Mentre **Sez. 1, n. 27694/2024, Varotti, Rv. 672788-01**, ha stabilito che il contratto stipulato dalla stazione appaltante direttamente con la società consortile, costituita dalle imprese offerenti che, pur riunite nell'offerta congiunta, non abbiano mai costituito una ATI, non è nullo né inefficace e legittima la società consortile medesima, quale titolare dei diritti e degli obblighi scaturenti dall'accordo, a farli valere in giudizio, tenuto conto che anche i consorzi costituiti in forma di società di capitali o di società consortili possono partecipare alle gare di appalto e rimanere, dunque, aggiudicatari, divenendo parte del relativo contratto.

Sez. 2, n. 02173/2024, Papa, Rv. 669985-01, ha affermato che la parte contraente con la stazione appaltante o con il *general contractor* si identifica nelle imprese che abbiano dato vita all'associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita è responsabile della mera esecuzione dei lavori, laddove la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate, mentre la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Sez. 1, n. 34430/2024, Varotti, Rv. 673364-01, ha chiarito che, dal principio per cui il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario ma unicamente la costituzione di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, deriva che la responsabilità solidale, di cui all'art. 13, l. n. 109 del 1994, sussiste solo ove i coobbligati abbiano partecipato alla gara pubblica, formulando all'interno di essa una specifica offerta.

Sez. 1, n. 24086/2024, Parise, Rv. 672359-02, ha affermato che l'art. 37-*quinquies*, comma 1-*ter*, della legge n. 109 del 1994, laddove stabilisce che l'aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di progetto che subentra nel rapporto di concessione, non ha natura interpretativa, sicché non si applica ai bandi di gara pubblicati anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. L'esecuzione del contratto.

Nel corso del 2024 la Corte ha esaminato diversi profili relativi alla fase dell'esecuzione del contratto di appalto.

Pronunciandosi in tema di collaudo, Sez. 2, n. 03353/2024, Guida, Rv. 670290-01, ha specificato che, in base al d.P.R. n. 554 del 1999, vigente *ratione temporis*, si tratta di un'attività complessa che comprende sia la verifica tecnica che quella relativa agli aspetti amministrativi e contabili dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, il che comporta l'unicità del compenso per tale attività.

Sez. 1, n. 29262/2024, Varotti, Rv. 673084-01, ha chiarito che l'inutile scadenza del termine per il collaudo, conseguente all'inadempimento dell'ente committente, fa sorgere il diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 30, comma 3, del d.m. n. 145 del 2000, stante il ritardo nell'estinzione dell'obbligazione, e gli consente di agire per l'adempimento, senza necessità di mettere in mora l'amministrazione, segnando il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione del credito.

In ordine alla liquidazione dei compensi relativi all'attività di collaudo di opera pubblica, Sez. 2, n. 03318/2024, Fortunato, Rv. 669999-01, ha affermato che la previsione di cui all'art. 7 l. n. 143 del 1949 - secondo cui quando l'incarico è affidato a più professionisti riuniti in collegio a ciascuno dei membri è dovuto l'intero compenso - è derogabile dalle parti.

Pronunciandosi in tema di responsabilità dell'appaltatore, Sez. 1, n. 27830/2024, D'Orazio, Rv. 672791-01, ha statuito che, poiché la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui deve sorgere, l'appaltatore è tenuto al controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente e risponde dei vizi e delle deficienze dell'opera, pur se ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione, eccezion fatta per quelle condizioni geologiche non accertabili con l'ausilio di strumenti e conoscenze normali che costituiscono la c.d. sorpresa geologica.

Sempre in tema di responsabilità, Sez. 3, n. 13157/2024, Tatangelo, Rv. 671145-01, ha chiarito che, in relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrativo (cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione), la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità per inadempimento del progettista-direttore dei lavori che, omettendo di segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l'assenso alle varianti alle opere già autorizzate, ne aveva determinato la responsabilità sul piano amministrativo.

In tema di riserve, **Sez. 1, n. 10603/2024, Mercolino, Rv. 670883-01**, ha stabilito che la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di un atto di sottomissione contenente modifiche all'originaria convenzione ed avente a oggetto una variante e un assestamento del progetto relativo al completamento delle opere non può essere inteso quale rinuncia dell'appaltatore alle riserve avanzate in corso d'opera, per la quale è necessaria un'apposita dichiarazione di volontà del titolare del diritto rinunciato, oppure un comportamento concludente dello stesso idoneo a evidenziare in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà di abdicare al proprio diritto.

Ancora in tema di riserve, **Sez. 1, n. 14522/2024, Fidanzia, Rv. 671465-01**, ha affermato che le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile *ratione temporis*), contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il *quantum* può essere indicato successivamente. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la riserva per l'aumento di volume del materiale di risulta, iscritta nel registro di contabilità anziché nel verbale di consegna dei lavori, attesa la immediata percepibilità del lamentato evento lesivo, essendo evidente che la frantumazione mediante esplosivo avrebbe determinato la formazione di spazi vuoti tra le parti frantumate.

Con riferimento alle opere già ultimate dalla Cassa per il mezzogiorno al tempo della sua soppressione e trasferite ai soggetti destinatari, **Sez. 2, n. 03721/2024, Cavallino, Rv. 670305-01**, ha statuito che l'obbligo del pagamento degli importi, non corrisposti all'appaltatore o al concessionario per le opere completate oppure dovuti per la risoluzione delle controversie insorte nell'esecuzione del contratto verso l'appaltatore, è a carico del Ministero dei LL.PP., legittimato passivo in virtù di un accollo *ex lege* previsto dall'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 96 del 1993.

Diverse pronunce sono intervenute in tema di appalto integrato. **Sez. 1, n. 11904/2024, Mercolino, Rv. 671450-01**, ha chiarito che esso, rispetto ad altri sistemi di realizzazione delle opere pubbliche, si caratterizza per la ripartizione dei compiti relativi alla progettazione dell'opera, ponendo a carico dell'ente committente l'obbligo di redigere il progetto definitivo (che deve raggiungere un livello di definizione tale da contenere, oltre alla compiuta individuazione dei lavori da realizzare, anche l'elaborazione dei calcoli strutturali e lo sviluppo del computo metrico estimativo), ed a carico dell'appaltatore la predisposizione - secondo le indicazioni vincolanti del predetto progetto definitivo e senza poter introdurre variazioni qualitative o quantitative - di un progetto immediatamente cantierabile, cioè non bisognoso di ulteriori specificazioni e tale da contenere la dettagliata indicazione delle lavorazioni necessarie e del relativo costo.

Sempre in tema di appalto integrato, **Sez. 1, n. 11904/2024, Mercolino, Rv. 671450-02**, ha affermato che il recesso dell'ente committente prima dell'inizio dei lavori, per la mancata approvazione del progetto esecutivo, esclude l'operatività della disciplina dettata dall'art. 25, comma 4, della l. n. 109 del 1994, nella parte in cui riconosce all'appaltatore l'indennizzo pari al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, essendo invece applicabile quella di cui all'art. 140, comma 7, del d.P.R. n. 145 del 1999, con conseguente diritto dell'appaltatore al pagamento di quanto previsto dal capitolato generale per l'ipotesi di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Ancora, **Sez. 1, n. 11904/2024, Mercolino, Rv. 671450-03**, ha chiarito che, nell'appalto integrato, che si caratterizza per la ripartizione tra l'ente e l'appaltatore dei compiti relativi alla progettazione dell'opera, l'effettuazione di studi ed indagini preliminari, inserendosi nella fase della progettazione definitiva, grava sull'ente committente non ai sensi

dell'art. 1206 c.c., quale dovere di cooperare in buona fede nell'esecuzione del contratto, bensì quale preciso obbligo previsto dall'art. 16, comma 4, della l. n. 109 del 1994, non trasferibile all'appaltatore, che, ai sensi del successivo comma 5, deve provvedere esclusivamente a studi ed indagini di dettaglio o di verifica, necessari per la specifica individuazione dei lavori da realizzare e per la determinazione dei costi. (Il principio è stato applicato in un appalto integrato, in cui le carenze del progetto esecutivo, determinanti il ritardo nei lavori, erano state addebitate all'ente committente, venuto meno all'obbligo specifico di compiere le indagini per accertare la presenza di reperti archeologici, indipendentemente dagli studi di dettaglio successivamente spettanti all'appaltatore nella fase della progettazione esecutiva).

Quanto al prezzo e alla possibilità di revisione, la compensazione dei prezzi, prevista dall'art. 133, comma 6 *bis*, del d.lgs. n. 163 del 2006, va calcolata non sulla base di una comparazione astratta, bensì sulla scorta dei maggiori costi effettivamente sopportati dall'appaltatore, attesa la chiara finalità della norma di ristorare il predetto dell'aumento, superiore al 10%, del prezzo dei materiali da costruzione, verificatosi per circostanze eccezionali, e non per riconoscere allo stesso un'ingiusta *locupletatio* (così Sez. 1, n. 14522/2024, *Fidanzia*, Rv. 671465-02, che ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui, pur in presenza di una variazione dei prezzi dei materiali superiore al 10% rispetto a quelli rilevati annualmente dal ministero delle infrastrutture, l'appaltatore non poteva limitarsi a presentare domanda di revisione alla direzione dei lavori, dovendo dar prova dei maggiori costi sostenuti).

Sez. 3, n. 34984/2024, *Spaziani*, Rv. 673350-02, ha affermato che quello di cui all'art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F - che attribuisce alla pubblica amministrazione committente il diritto di rescindere autoritativamente il contratto di appalto per frode o grave negligenza dell'appaltatore - non integra un rimedio specifico contro l'inadempimento doloso o gravemente colposo destinato ad operare nell'ipotesi di difetto funzionale della causa del contratto, ma un più ampio potere di autotutela di natura pubblicistica, concretando un'ipotesi di risoluzione che, contrariamente a quella connessa all'inadempimento dell'appaltatore, non è necessariamente collegata alle vicende del singolo contratto di appalto ma alla persona dell'appaltatore medesimo, allorché venga meno il rapporto fiduciario costituitosi fra quest'ultimo e la pubblica amministrazione.

Quanto ai termini di completamento delle opere, Sez. 1, n. 33941/2024, *D'Orazio*, Rv. 673404-01, ha chiarito che le clausole del capitolato generale che prevedono incentivi per l'ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine stabilito contrattualmente non possono in ogni caso giustificare il riconoscimento di un premio superiore al limite legale del dieci per cento dell'ammontare netto dell'appalto, che non può essere superato né per effetto di una singola voce d'incentivazione, né sulla scorta di più voci complessivamente considerate. Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso dell'ente Autostrade e cassato la sentenza impugnata, che aveva sì correttamente ritenuto non cumulabili le due tipologie di premio previste dal contratto, ma aveva liquidato quella relativa al minor tempo d'interferenza dei lavori con il traffico in misura superiore al dieci per cento del valore netto dell'appalto.

3. L'arbitrato negli appalti pubblici.

Sulla competenza arbitrale, Sez. 1, n. 30956/2024, *Caiazza*, Rv. 673510-01, ha chiarito che, in tema di controversie relative ad appalti pubblici, la declinatoria della competenza arbitrale operata dall'ente pubblico ex art. 47 del d.P.R. 1063 del 1962 non consiste in una modifica pattizia, ma in un atto eminentemente processuale che, non comportando alcuna modificazione del compromesso o della clausola compromissoria, integra una mera deci-

sione di natura tecnico-giuridica demandata al procuratore della parte e, per la Pubblica Amministrazione, all'Avvocatura dello Stato, con la conseguente esclusione della necessità di una preventiva deliberazione degli organi cui spettano la formazione della volontà dell'ente pubblico e la rappresentanza dello stesso nei rapporti con i terzi.

4. Il subappalto.

Sez. 1, n. 35053/2024, Zuliani, Rv. 673397-01, ha affermato la validità del contratto di subappalto nell'ipotesi in cui l'impresa appaltatrice sia stata autorizzata dalla stazione appaltante ad affidare ad altra impresa l'esecuzione di parte delle opere, in quanto non è violato il precetto contenuto e penalmente sanzionato nell'art. 21 della legge n. 646/1982, anche se le opere eseguite dal subappaltatore risultano eccedenti la misura prevista nella citata autorizzazione, poiché la funzione del precetto penale è quella di assicurare la qualità soggettiva del subappaltatore, evitando che si tratti di impresa direttamente o indirettamente collegata ad organizzazioni criminali.

CAPITOLO XXXI

LE SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING

(DI GIULIA STANO)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Requisito del cd. controllo analogo congiunto. - 3. Riparto di giurisdizione e violazione dei limiti esterni della giurisdizione. - 4. Contratto di collaborazione a progetto e rapporto di lavoro a tempo indeterminato. - 5. Questioni relative all'affidamento del servizio idrico integrato.

1. Premessa.

Nell'anno in rassegna la S.C. ha emesso, in tema di società *in house providing*, non numerose ma rilevanti decisioni su controllo analogo di ente pluripartecipato, riparto di giurisdizione e violazione dei limiti esterni della giurisdizione, rapporti tra contratto di collaborazione a progetto e rapporto di lavoro a tempo indeterminato, affidamento del servizio idrico integrato.

2. Requisito del cd. controllo analogo congiunto.

SU, n. 18623/2024, Carrato, Rv. 67173-02, Il requisito del cd. "controllo analogo congiunto" - previsto, per le società *"in house"*, dall'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 175 del 2016 - implica la necessaria previsione, da parte dello statuto, di strumenti idonei ad assicurare che ciascun ente partecipante, insieme agli altri, sia in grado di controllare l'attività della società controllata, potendo tale risultato essere raggiunto anche attraverso la costituzione, con apposita convenzione *ex art.* 30 TUEL, di un ufficio comune preposto alla consultazione e coordinamento degli enti locali coinvolti, in vista dell'approvazione degli atti fondamentali della vita sociale. Nella specie, la società ricorrente aveva dedotto la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in relazione alla mancanza, in capo al soggetto interamente pubblico cui era stato affidato unitariamente e totalitariamente il servizio idrico integrato (SII) ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-*bis*, co.1, secondo periodo, e co. 2, secondo periodo, del d. lgs. n. 152/2006, dei requisiti e dei presupposti necessari per la qualificazione come società *in house*, nella specie per difetto del requisito del controllo analogo. La S.C., ritenendo la censura infondata, ha affermato che "come evidenziato dalla conferente giurisprudenza amministrativa sul tema (v., per tutte, Consiglio di Stato, Sez. I, 26 giugno 2018, n. 1645), ai fini dell'individuazione dell'*in house* sono richiesti tre requisiti: 1) controllo analogo; 2) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente controllante; 3) partecipazione totalitaria. Nel caso di specie la difesa di parte appellante pone, in particolare, in discussione la sussistenza del primo, ossia la presenza effettiva di un "controllo analogo" (che, in linea generale, può essere esercitato sia "a cascata", sia in modo "congiunto", ossia con modalità plurifrazionata). Tali definizioni si rinvergono nell'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) la cui lettera c) reca la definizione di controllo "a cascata" (laddove si afferma che: "Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante"), mentre la successiva lettera d) si occupa di

“controllo congiunto” (laddove si prevede che per “controllo analogo congiunto” debba intendersi quella “situazione in cui l’amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”). Nel caso di specie, viene in rilievo il controllo congiunto. Va, in primo luogo, precisato che, quando si afferma che il controllo deve essere congiunto, ciò non implica che debba essere anche necessariamente “paritario”, essendo sufficiente che risulti nello Statuto la presenza di strumenti idonei ad assicurare che ciascuna P.A. controllante, assieme alle altre, sia in grado di controllare l’attività del soggetto controllato (si veda, a titolo esemplificativo, Corte di Giustizia UE, sentenza 29 novembre 2012, C-182/11, la quale ha precisato che, nel caso in cui le amministrazioni pubbliche detengano congiuntamente un soggetto in house cui affidano l’adempimento di una delle proprie missioni di servizio pubblico, il requisito strutturale del controllo analogo può ritenersi sussistente anche in caso di controllo congiunto, a condizione che ciascuno degli enti pubblici affidanti abbia di per sé la possibilità di influire, in maggiore o minore misura, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni rilevanti del soggetto strumentale, possibilità del resto assicurata dalle dinamiche di funzionamento degli organi consortili). Una simile conclusione è inevitabilmente legata alla particolare dimensione naturale, organizzativa e funzionale degli ATO che sono costituiti da plurimi Comuni di varie dimensioni e, dunque, anche di diversa incidenza sull’assetto societario. Occorre, infatti, valorizzare il presupposto di fondo che il servizio idrico implica in sé il concorso di più enti (allo stesso tempo deputati al controllo di eventuali soggetti *in house*). ...”. Quindi la S.C. evidenzia che lo statuto dell’ente *in house* prevede tre modalità di esercizio del controllo analogo, e che detto controllo “deve ritenersi, in ogni caso, assicurato dall’esterno della società, attraverso la conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia prevista dalla convenzione (cfr., al riguardo, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5080 del 2014), alla quale partecipano tutti i Comuni compresi nell’ambito territoriale cuneese”. Sicché nel caso di specie deve escludersi “che ricorra l’ipotesi prevista dalla Corte di Giustizia UE come elusiva dell’ipotesi del “controllo analogo congiunto”, e cioè quella in cui anche una sola amministrazione abbia acquisito nella società *in house* una posizione inidonea a garantirle la benché minima possibilità di partecipare al controllo di tale entità (v. sentenza 29 novembre 2012, Econord, C-182/11 e 183/11)”, considerato che il modello di controllo analogo in caso di *in house* frazionato o pluripartecipato è realizzato secondo le seguenti modalità: “a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”.

3. Riparto di giurisdizione e violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

La S.C. (SU, n. 567/2024, Giusti, Rv. 669892-01) ha affermato che, in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite sono anche giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l’atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione, anche quando tale titolo sia già stato apprezzato col provvedimento impugnato, perché la decisione sulla corretta individuazione del giudice munito di competenza giurisdizionale dipende da quella circostanza fattuale. In applicazione di tale

principio, al fine di verificare la sussistenza del requisito necessario per configurazione di una società *in house*, assoggettata a controllo analogo a quello sui servizi di diretta gestione dell'ente pubblico, la S.C. ha riesaminato lo statuto - già oggetto del precedente apprezzamento della Corte dei conti - di una società interamente partecipata da una ASL, rilevando che l'ente pubblico partecipante aveva il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società, di decidere le strategie aziendali in relazione alle operazioni necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché specifici poteri di ingerenza nella pianificazione, programmazione e controllo dell'attività aziendale, e concludendo così per la giurisdizione del giudice contabile). Il principio affermato nella pronuncia appena menzionata si pone in continuità con l'orientamento stabilito in SU, n. 8074/2015, D'Ascola, Rv. 634938-01, nella quale veniva in questione un contratto di locazione stipulato tra una pubblica amministrazione ed un privato nel contesto temporale di una vicenda espropriativa. Il ricorrente aveva denunciato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, assumendosi pubblico concessionario, sostenendo che la scrittura privata in questione costituiva un accordo sostitutivo di provvedimento "di detenzione di occupazione provvisoria" con effetti di occupazione provvisoria mediante l'utilizzazione dello schema contrattuale. La fattispecie sarebbe quindi rientrata nel modello strumentale degli accordi, con conseguente giurisdizione amministrativa ex art. 11, comma 5, della l. n. 241 del 1990, nella formulazione vigente *ratione temporis*. In quel caso, la S.C. aveva confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto "estranea alla realizzazione dell'opera pubblica la convenzione con la quale il Consorzio si era assicurato la disponibilità del fondo, avendo essa il solo scopo di sovvenire alle esigenze dell'indagine condotta dall'Autorità giudiziaria...", come evidente per la circostanza che l'opera pubblica era già stata eseguita e la locazione si era resa necessaria per esigenze occasionali, derivate da un fatto di rilevanza penale. La Corte di cassazione aveva concluso, quindi, per la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto "detta convenzione non era riconducibile all'ipotesi di "accordo sostitutivo" L. n. 241 del 1990, ex art. 11, nel testo all'epoca vigente", ma ad "un ordinario contratto privatistico al fine di abbreviare i tempi di un'eventuale occupazione temporanea, da chiedere altrimenti ex art. 49 T.U."

Con riferimento ai limiti esterni della giurisdizione ed in tema di giudizi di responsabilità amministrativa, SU, n. 2290/2024, Leone, Rv. 670195-01, ha confermato la decisione della Corte dei conti che, con riferimento a mutui stipulati da una società *in house* costituita da un Comune, e ha ritenuto responsabili gli amministratori dell'ente locale, in quanto organi pubblici privi di competenza, per il danno cagionato all'ente pubblico dal rilascio di lettere di *patronage* in favore delle banche mutuanti, nonostante il successivo avallo del Consiglio comunale, enunciando il principio secondo cui "la Corte dei conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, poiché la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti, secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all'art. 1 della l. n. 241 del 1990, senza che ciò implichi un sindacato sul merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione e, dunque, una violazione dei limiti esterni della giurisdizione ovvero della riserva di amministrazione".

4. Contratto di collaborazione a progetto e rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Conformemente all'orientamento riferito ai contratti a termine di lavoro subordinato (da Sez. L., n. 21378/2018, Torrice, Rv. 650213-01, e Sez. L., n. 13480/2018, De Felice, Rv. 648740-01), Sez. L., n. 420/2024, Leone, Rv. 669693-01, ha affermato che per le

società *in house*, a cui sia applicabile *ratione temporis* l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, il reclutamento del personale avviene con i divieti e le limitazioni previsti per le pubbliche amministrazioni, in applicazione dei criteri pubblicistici di trasparenza, oggettività e imparzialità stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché è inammissibile la conversione di un contratto di collaborazione a progetto illegittimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Sez. L, n. 14751/2024, Panariello, Rv. 671217-01, in tema di reclutamento del personale di società a partecipazione pubblica *in house*, ha stabilito che l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - che, nel testo *ratione temporis* vigente, ha imposto l'osservanza delle procedure selettive pubbliche per le assunzioni, è divenuto applicabile dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo d.l., per consentire a tali società un congruo *spatium temporis* per adeguare i propri sistemi di assunzione alla nuova norma imperativa (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva dichiarato illegittima la "presa d'atto della nullità" di un contratto di lavoro stipulato, senza l'osservanza delle procedure selettive pubbliche, prima del decorso del predetto termine di sessanta giorni). Recentemente, Sez. L, n. 06171/2023, Piccone, Rv. 666949-01, aveva stabilito, difatti, che, nel caso in cui non sia applicabile *ratione temporis* l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008 - con il quale il legislatore ha esteso alle società *in house* le limitazioni imposte alle pubbliche amministrazioni nelle procedure di reclutamento del personale -, è ammissibile la conversione del contratto a progetto illegittimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5. Questioni relative all'affidamento del servizio idrico integrato.

La già menzionata **SU, n. 18623/2024, Carrato**, ha affermato anche il principio (massimato con il n. **Rv. 671743-01**) secondo cui l'esercizio delle attività facenti capo al servizio idrico integrato può essere affidato in via diretta alle società *in house* (interamente partecipate dagli enti pubblici e ricadenti nell'ambito territoriale ottimale), senza che ciò determini violazione del principio comunitario di concorrenza, dal momento che tali società, pur essendo dotate di autonoma personalità giuridica, sono equiparabili a un'articolazione interna dell'ente pubblico che le ha costituite, con la conseguente necessità di rispettare i principi che informano la correttezza e la legittimità dell'attività amministrativa, in vista della tutela del peculiare interesse pubblico a cui sono preposte. Quanto ad una particolare modalità di esercizio del servizio, **Sez. 2, n. 23726/2024, Fortunato, Rv. 672421-01**, ha affermato che una società cd. *In house* può affidare a periti chimici l'attività di rilascio delle certificazioni e i controlli interni tesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti prescritti dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2001, non essendo tale attività riservata ai soli laureati in biologia e chimica, poiché da un lato è lo stesso art. 3 della l. n. 396 del 1967 ad escludere, al secondo comma, che l'elencazione delle attività consentite sia esaustiva o pregiudichi quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti in base a specifiche previsioni di legge o di regolamenti; dall'altro, è ammessa la concorrenza di diverse competenze che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti, dovendosi respingere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica.

CAPITOLO XXXII

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

(DI OLIMPIA MONACO)

SOMMARIO: 1. Principi generali, struttura impugnatoria del giudizio di opposizione e regole processuali. - 2. Giurisdizione. - 3. Competenza ed incompetenza. - 4. Cumulo materiale e concorso di persone. - 5. La responsabilità solidale. - 6. Prescrizione. - 7. Sanzioni in ambito bancario e finanziario: profili procedurali e processuali. - 8. Abuso di informazioni privilegiate - 9. Ulteriori pronunce riguardanti le sanzioni in ambito bancario e finanziario. - 10. Le sanzioni amministrative previste dal codice della strada: modalità di accertamento. - 11. Il verbale di constatazione delle violazioni al codice della strada: natura, requisiti e notificazione. - 12. L'opposizione: il rito, la competenza, l'oggetto e gli effetti. - 13 Le violazioni sanzionate dal codice della strada. - 14. Le altre sanzioni.

1. Principi generali, struttura impugnatoria del giudizio di opposizione e regole processuali.

Nell'ambito processuale la parola opposizione designa, in larga approssimazione, due fattispecie consimili: un'azione d'impugnativa d'un provvedimento autoritativo (il caso di cui ci occupiamo) o un'impugnazione in senso tecnico-giuridico d'un precedente provvedimento del giudice (si pensi, ad esempio, all'opposizione a decreto ingiuntivo o all'opposizione proposta contro il decreto emesso ai sensi dell'art. 28 Statuto dei lavoratori). Nell'un caso come nell'altro, il dato saliente è costituito dal carattere devolutivo dell'opposizione, nel senso che la parte opponente, non essendo costretta da una griglia tassativa di motivi, non incontra limiti di allegazione in fatto ed in diritto.

Venendo più specificamente all'opposizione *ex lege* 24 novembre 1981, n. 689, costituisce *ius receptum* in giurisprudenza, ed affermazione comunemente accolta in dottrina, che essa, esaminata sotto l'aspetto funzionale non mira ad emendare il provvedimento sanzionatorio dei suoi eventuali vizi, per poi restituire il rapporto giuridico sanzionatorio alla medesima P.A., affinché torni ad esercitare il relativo potere in maniera legittima. Al contrario, oggetto dell'opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981 e alle varie leggi speciali che la richiamano è l'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della P.A., sicché la cognizione del giudice dell'opposizione si estende potenzialmente a tutto il rapporto giuridico sanzionatorio.

Pertanto, la struttura del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, ha natura impugnatoria su ricorso e di annullamento di un atto amministrativo, mutuata dal processo amministrativo, rappresentando una delle rare eccezioni ai principi-cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (Sez. 6-2, n. 18158/2020, Tedesco, Rv. 659212-01).

Detto giudizio riguarda - come ricorda Sez. 6-2, n. 21146/2019, Carrato, Rv. 655278-01, in continuità con l'indirizzo nomofilattico (Sez. U, n. 01786/2010, Goldoni, Rv. 611243-01) - il rapporto giuridico sotteso, avente fonte legale in un'obbligazione di tipo sanzionatorio (così già Sez. 2, n. 12503/2018, Carrato, Rv. 648753-01; Sez. 2, n. 09286/2018, Criscuolo, Rv. 648150-01).

Dal punto di vista strutturale, invece, l'opposizione a sanzione amministrativa si configura in senso prettamente impugnatorio, dovendo essere proposta entro un termine di decadenza. Ciò è dovuto al fatto che, nel nostro ordinamento, l'illecito amministrativo,

come è noto, nasce e si struttura nella sua autonomia mediante successive leggi di depenalizzazione di omologhe fattispecie di reato. Nel passaggio dall'ambito penale a quello civile qualcosa si perde e qualcosa si aggiunge. Si perde la formulazione dell'accusa come *thema decidendum* e atto propulsivo del processo, e si sostituisce ad essa la domanda giudiziale dell'opponente, che tra l'altro è l'unica proponibile, non essendo ammissibili né riconvenzionali né domande accessorie. Va da sé che essendo quella dell'opponente l'unica domanda, non può prescindere dalla relativa *causa petendi*, cioè dai fatti su cui si basa l'opposizione e che, dunque, è onere dell'opponente articolare. Essenzialmente due i corollari di tale carattere: il primo è dato dall'impossibilità di formulare, con memorie o altri atti comunque definiti e qualificati, motivi aggiunti a quelli inizialmente proposti con l'opposizione, quanto meno ove ciò avvenga decorso il termine d'impugnazione, la cui perentorietà non è eludibile. Di riflesso, benché per effetto dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 a tale opposizione si applichi il rito del lavoro, pare dubbia la possibilità di discriminare le ipotetiche variazioni della domanda ricorrendo alla consueta alternativa tra *mutatio* o *emendatio libelli*, poiché questa presuppone una domanda che non solo sia a schema libero, ma che possa essere proposta (o se del caso riproposta) al di fuori di cogenti limiti temporali. Simmetricamente, neppure l'amministrazione può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza. Il secondo corollario è costituito dall'impossibilità per il giudice di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza del potere sanzionatorio. Tra queste, vanno annoverate, secondo la giurisprudenza della S.C., le ipotesi di incompetenza assoluta, che ricorre quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene e, in generale, di carenza assoluta di potere, quando, cioè, non è dato cogliere alcun collegamento tra l'atto e le attribuzioni del soggetto che lo ha emesso.

Al descritto paradigma impugnatorio è annesso un rigido sistema preclusivo (Sez. 2, n. 27909/2018, Picaroni, Rv. 651033-01), valevole per ogni soggetto coinvolto nel giudizio di opposizione, sicché tutte le ragioni poste alla base dell'istanza demolitoria di nullità (o di annullamento) dell'atto (*causae petendi*) devono essere prospettate nel ricorso introduttivo entro i termini di legge.

Neppure il giudice può rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi o ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione distinti da quelli dedotti dal ricorrente, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Rientra in quest'ultima eccezione, l'illegittimità del provvedimento opposto per violazione del principio di legalità di cui all'art. 1 della l. n. 689 del 1981, che è rilevabile d'ufficio, trattandosi di principio-cardine dell'intero sistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluti, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.), sicché la sua attuazione non può rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita dall'esercizio della funzione giurisdizionale (Sez. 2, n. 04962/2020, Varrone, Rv. 657117-01).

Non sono mancati arresti che hanno precisato che in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica

della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (**Sez. 2, n. 29315/2024, Varone, Rv. 673034-01**).

Sez. U, n. 20263/2022, Perrino, non massimata, ha delineato i poteri esercitabili dal giudice nel procedimento di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria, disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, riconoscendo al giudice ordinario la competenza giurisdizionale a tutela del diritto soggettivo dell'opponente di non essere sottoposto al pagamento di somme all'infuori dei casi espressamente previsti, in ciò eventualmente restando ricompreso anche il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi che costituiscono presupposto di quell'ordinanza. Pertanto, la cognizione del giudice ordinario si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario.

Con riferimento all'accertamento della eventuale sussistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all'art. 4 della l. n. 689 del 1981, occorre, in mancanza di ulteriori precisazioni, fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità, all'art. 54 c.p. Con particolare riferimento allo stato di necessità, occorre dimostrare che la condotta sia necessitata dall'imminente (ancorché supposto per errore di fatto) pericolo per la vita o l'integrità fisica della persona oggetto del salvataggio: ove tale prova non sia raggiunta, secondo l'apprezzamento di merito del giudice, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, non potrà essere riconosciuta l'esimente. A tale riguardo, Sez. 2, n. 22020/2022, Criscuolo, non massimata, ha precisato che qualora sia invocato uno stato di necessità di carattere medico - sanitario la situazione di pericolo deve avere un carattere di indilazionabilità e cogenza tale da non lasciare all'agente alternativa diversa dalla violazione della legge; ciò perché la moderna organizzazione sociale, venendo incontro, con i mezzi più disparati a coloro che possono trovarsi in pericolo di vita, per il non soddisfacimento dei predetti bisogni, ha modo di evitare il possibile, irreparabile danno alla persona.

In tema di sanzioni amministrative tributarie ed in particolare dell'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, **Sez. T, n. 27651/2024, Rosetti, Rv. 672714-01**, ha, poi, chiarito che la stessa si applica quando il mancato pagamento di un tributo è imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del cit. d.lgs., nemmeno sotto il profilo della *culpa in vigilando*. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto imputabile agli amministratori la mancata tenuta delle scritture contabili e non applicabile la causa di non punibilità derivante dalla condotta omissiva del commercialista al quale era stata affidata la contabilità, trattandosi di violazione talmente macroscopica da non poter sfuggire neanche ad un sommario controllo dei compiti affidati al professionista.

Strettamente connesso a quanto sinora riferito è il principio affermato da Sez. 2, n. 24299/2023, Papa, Rv. 668913-01 laddove si evidenzia che l'amministrato, che abbia agito con la consapevolezza di aver integrato la fattispecie vietata, non può invocare un affida-

mento incolpevole, fondato su una presunta tacita tendenza dell'Autorità a non punire una determinata condotta, poiché l'errore sull'illiceità del fatto, ravvisabile in atti o circostanze tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, non può rinvenirsi nella supposta tolleranza dell'Autorità, essendo irrilevante la convinzione di poter rimanere impuniti.

Nella stessa direzione si pone Sez. 2, n. 24386/2023, Papa, Rv. 668804-02 che ha stabilito che in tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa, senza che rilevi l'eventuale affidamento incolpevole fondato su una presunta tacita tendenza dell'Autorità a non punire una determinata condotta o a punirla con una sanzione più lieve.

Tuttavia, Sez. 2, n. 32082/2024, Falaschi, Rv. 673454-01, ha statuito che, in tema di riparto della responsabilità di ordine sanzionatorio-amministrativo tra organi elettivi e burocratici di un ente pubblico territoriale, alla luce dell'interpretazione sistematica del quadro normativo composto dagli artt. 4, 29 e 30 della l. r. Lombardia n. 14 del 1998, *ratione temporis* applicabile, nonché dagli artt. 50, 7-bis, comma 2 e 107 del TUEL e 17 della l. n. 689 del 1981, non spetta al Sindaco e al Presidente della Provincia qualsiasi compito nell'ambito dell'attività dell'ente, allorché sussista un'apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento di attività non di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il cui dirigente, laddove dotato di autonomia decisionale e di spesa e di tutti i compiti connessi alle sue funzioni, può adottare gli atti che impegnano l'ente all'esterno.

In tema di notifica della violazione, Sez. I, n. 20977/2024, Cinque, Rv. 672095-01, ha affermato che il giudice dell'opposizione dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981, il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.

Secondo Sez. 3, n. 29884/2024, Condello, Rv. 672907-01, la censura concernente l'invalidità della notifica della cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.

In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, Sez. 2, n. 19957/2024, Oliva, Rv. 671781-02 ha affermato che la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione.

Quanto ai poteri decisorii del giudice nel procedimento di opposizione concernente l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione del TUB o del TUF,

Sez. 2, n. 19716/2024, Manna, Rv. 671775-01, ha affermato che il giudice ha il potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi e senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga che, nella determinazione della sanzione, si è tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981.

In materia di residualità della disciplina repressiva prevista dalla L. n. 689/1981, **Sez. 2, n. 21541/2024, Guida, Rv. 671906-01**, ha affermato che in tema di illecito tributario, ivi incluso il contrabbando semplice di tabacchi lavorati, è applicabile il procedimento di irrogazione delle sanzioni, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, e soltanto in maniera residuale la disciplina generale *ex art. 13 e ss. della l. n. 689 del 1981*.

Con riguardo, invece, all'applicazione, nella materia delle sanzioni amministrative, del principio del *ne bis in idem*, **Sez. 2, n. 29801/2024, Besso Marcheis, Rv. 673041-01**, ha rammentato che, in base alla giurisprudenza unionale e della CEDU, non è compatibile con il principio del "*ne bis in idem*" di diritto convenzionale ed euro unitario (e, in particolare, con l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) l'instaurazione di un procedimento amministrativo sanzionatorio o la sua prosecuzione - eventualmente anche in sede di opposizione giurisdizionale - in relazione alla commissione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 187-bis T.U.F. qualora, con riferimento ai medesimi fatti storici, la posizione dell'incolpato sia stata archiviata in sede penale, sulla base di una istruttoria approfondita e con valutazione accurata di un complesso di indizi sufficientemente completo, dovendo in tal caso ritenersi equiparata all'assoluzione la decisione di archiviare il procedimento relativo al delitto previsto dall'art. 184 T.U.F. (fattispecie nella quale la S.C., ai fini dell'operatività del principio del *ne bis in idem* europeo, ha riconosciuto l'efficacia di pronuncia assolutoria al decreto di archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari, quantunque privo di motivazione, in quanto basato su di una richiesta di archiviazione del P.M. ampiamente motivata e nella quale la posizione del ricorrente è stata disposta non sulla base di meri motivi procedurali, bensì con una valutazione nel merito degli elementi di prova acquisiti agli atti).

Da ultimo, **Sez. L, n. 31459/2024, Buffa, Rv 672987-01**, ha affermato che in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, tenuto conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie. Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non applicabile alle sanzioni amministrative in materia di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti, previste dal terzo comma dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, conv. con l. n. 73 del 2002, il più favorevole regime di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione previsto all'art. 20, del d. lgs. n. 472 del 1997, per il quale la prescrizione matura il 31 dicembre del quinto anno successivo all'infrazione, rispetto a quello disciplinato dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981, per il quale la prescrizione quinquennale decorre dalla data dell'ingiunzione.

2. Giurisdizione.

In tema di giurisdizione in materia di sanzioni amministrative, **Sez. U, n. 22891/2024, Giusti, Rv. 672090-01**, ha affermato che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione delle prescrizioni del regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno appartengono alla giurisdizione del giudice tributario allorquando la contestazione involga l'omesso o parziale versamento

(o "riversamento") dell'imposta e, invece, a quella del giudice ordinario nel caso in cui le disposizioni violate siano rivolte ad assicurare l'efficacia del sistema telematico dell'imposta medesima, attraverso la previsione di obblighi procedurali afferenti alle modalità di accreditamento delle strutture e di trasmissione della dichiarazione giornaliera dell'identità di chi vi ha soggiornato.

È stata, inoltre, affermata la giurisdizione del giudice ordinario in tema di mandato relativo alla riscossione di crediti derivanti da sanzioni amministrative previste dal Codice della strada. In particolare, **Sez. U, n. 16031/2024, Scoditti, Rv. 671521-01** ha statuito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la richiesta di rendimento del conto proposta dall'ente territoriale nei confronti della società mandataria, in quanto il *petitum* sostanziale della domanda trova il suo fondamento nelle obbligazioni discendenti dal rapporto privatistico di mandato, rilevando l'emissione di ingiunzione fiscale rivolta all'incasso dei crediti quale mero presupposto esterno del rapporto dedotto in giudizio.

Analogamente - secondo **Sez. 3, n. 2577/2024, Condello, Rv. 670071-01** - sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie aventi ad oggetto i controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private eroganti prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, *ex art. 133, comma 1, lett. c)*, del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora l'oggetto del contendere riguardi esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della struttura rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate, mentre spettano al giudice amministrativo se l'oggetto della contestazione è costituito dalle modalità di esecuzione del controllo o dalla titolarità in capo all'Amministrazione del potere di esercitarlo, poiché in tal caso la domanda investe anche l'esercizio di un potere autoritativo (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo le doglianze relative alle verifiche effettuate dalla Commissione ispettiva, di cui si affermava l'irregolarità per inosservanza delle regole procedurali e di composizione della Commissione stessa).

Da ultimo, in tema di sanzione di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, **Sez. 2, n. 5133/2024, Bertuzzi, Rv. 670379-01**, ha evidenziato che l'opposizione, dopo la declinatoria di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, è proposta in via autonoma dinanzi al giudice competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della predetta pronuncia, essendo irrilevante, ai fini dell'ammissibilità, il deposito di una istanza di riassunzione presso la cancelleria, in ragione della espressa previsione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010; mentre **Sez. 2, n. 10224/2024, Criscuolo, Rv. 670741-01**, ha chiarito che alla tardiva riassunzione davanti al giudice ordinario dell'opposizione alla delibera della Banca d'Italia applicativa di sanzioni amministrative - a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo - consegue l'estinzione del giudizio *ex art. 59, comma 4, della l. n. 69 del 2009*, in assenza di una norma che sanzioni il mancato rispetto del termine per riassumere il giudizio con l'inammissibilità dell'opposizione.

3. Competenza ed incompetenza.

Con riguardo alla competenza per territorio, **Sez. 2, n. 5124/2024, Bertuzzi, Rv. 670319-01**, ha affermato che la competenza ad irrogare la sanzione *ex art. 6, comma 14, del d.lgs. n. 285 del 1992*, spetta a tutti i corpi di polizia municipale dei diversi comuni su cui ricade l'area aeroportuale, in quanto il conferimento alla competente autorità del potere di regolamentare la circolazione stradale per tutta l'estensione dell'area aeroportuale - elevata, dunque, dalla stessa legge a circoscrizione unitaria - ha carattere necessariamente

unitario e coinvolge tutti gli organi e corpi che svolgono servizi di polizia in tale territorio. Di talché la competenza all'accertamento delle violazioni, nel caso in cui la suddetta area comprenda più comuni, è data dalla combinazione dei criteri fondati sul territorio del comune e su quello dell'area aeroportuale, senza che il primo possa prevalere sul secondo.

Sez. 3, n. 29388/2024, Rossi, Rv. 672576-01, ha precisato che se l'opposizione a cartella di pagamento, fondata su sanzione amministrativa pecuniaria, ha natura di opposizione c.d. preventiva all'esecuzione, la mancata elezione di domicilio del creditore nella cartella (atto equiparabile al precetto) comporta la competenza per territorio del giudice del luogo in cui l'atto della riscossione è stato notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.

Relativamente, poi, alla competenza per valore, **Sez. 2, n. 6790/2024, Besso Marcheis, Rv. 670499-01**, ha statuito che il fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche quando disposto in ragione del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente affittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa con atto di opposizione, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, spetta alla competenza per materia del giudice di pace nei limiti di valore di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.

4. Cumulo materiale e concorso di persone.

L'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate - nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione od omissione - non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale (violazioni commesse con più azioni od omissioni), ed è inoltre esclusa la possibilità di invocare l'art. 81 c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché l'art. 8 della l. n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano *tout court* estese alla materia degli illeciti amministrativi (Sez. 6, n. 07704/2022, Fortunato, non massimata).

Sez. T, n. 12722/2024, Crivelli, Rv. 670925-01, ha statuito che il giudice, investito della controversia in ordine alle sanzioni conseguenti a plurime violazioni tributarie avvinte dal vincolo della progressione o continuazione ed accertata la invalidità parziale dell'atto per avere escluso la rilevanza o la sussistenza di alcune condotte, è tenuto a provvedere anche al calcolo della sanzione risultante dal cumulo giuridico, in ossequio al generale principio espresso dall'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, e, in mancanza di detta determinazione, tale compito spetta al giudice adito per l'impugnazione del provvedimento amministrativo esecutivo della precedente pronuncia, non potendo anche quest'ultimo limitarsi a rimettere il calcolo all'autorità amministrativa.

Sez. T, n. 5115/2024, Fracanzani, Rv. 670551-01, sempre in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ha affermato che la recidiva di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, presuppone un definitivo accertamento della violazione antecedente della stessa indole per effetto di una pronuncia giurisdizionale, ovvero della mancata impugnazione della contestazione, con la conseguente compatibilità, ricorrendone i presupposti, con l'istituto del cumulo giuridico.

In tema di circolazione stradale, Sez. 2, n. 4006/2024, Carrato, Rv. 670313-02, ha evidenziato che il cumulo giuridico delle sanzioni, disciplinato per le violazioni al codice della strada dall'art. 198, comma 1, dello stesso codice, non si applica, per quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 198, nel caso in cui, nell'ambito delle ZTL, si violino i divieti di accessi e gli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni, prevedendosi espressamente che, in tale ipotesi, il trasgressore "soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione".

Quanto al concorso di persone, in tema di sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, esso si configura quando viene contestata ad una persona fisica una condotta, materiale o morale, realizzata attraverso azioni od omissioni che, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, rendono possibile o agevolano la consumazione di una violazione tributaria (Sez. T, n. 20823/2024, Caradonna, Rv. 672011-01).

Sez. T, n. 20697/2024, Caradonna, Rv. 672030-01, ha poi affermato che il citato art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 è norma compatibile con l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, sicché è configurabile, nella sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, il concorso di persone terze (nella specie, notaio) nelle violazioni tributarie relative alle società con personalità giuridica e la loro sanzionabilità per il contributo materiale e psicologico offerto nella realizzazione dell'illecito.

Sez. T, n. 21092/2024, Salemme, Rv. 672012-01 ha, infine, specificato che la riferibilità delle sanzioni tributarie alla sola persona giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, non comporta alcuna deroga al principio della responsabilità concorsuale dell'estraneo (segnatamente, quale professionista), ex art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, per l'illecito imputabile alla medesima persona giuridica in conseguenza della condotta materialmente realizzata dall'intraneo, dovendo rispondere l'estraneo, in ragione del concorso, per una condotta sua propria, ancorché atipica, causalmente orientata alla violazione.

5. La responsabilità solidale.

Con riferimento al tema della responsabilità solidale in materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, la previsione della responsabilità solidale in capo alla società di cui al previgente art. 195, comma 9, è norma sostanziale, la cui abrogazione, ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, è operativa soltanto in relazione alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia (ossia dopo l'otto marzo 2016) (Sez. 2, n. 21397/2024, Guida, Rv. 671984-01).

6. Prescrizione.

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa decorre, in ossequio all'art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

In particolare, il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente *ratione temporis*, né al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, operando invece il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'*actio iudicati*, anche ove la definitività della pretesa erariale consegua alla declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente (Sez. T, n. 25222/2024, Lume, Rv. 672377-01). Nello stesso senso vi è anche Sez. T, n. 05577/2019, D'Orazio, Rv. 652721-02.

Quanto al diritto alla riscossione degli interessi sulle sanzioni amministrative pecuniarie, **Sez. T, n. 23572/2024, Gori, Rv. 672151-02**, ha chiarito che detto diritto, sorto a seguito del ritardo nel pagamento dell'imposta principale individuata in una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell'avviso di liquidazione, si prescrive nel termine di dieci anni, in applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina, in via generale, l'*actio iudicati*.

Infine, **Sez. 2, n. 21500/2024, Scarpa, Rv. 671905-01**, ha statuito che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, in caso di illecito permanente, il termine di centottanta giorni per la contestazione degli addebiti nel procedimento delineato dall'art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 decorre dalla data di cessazione della permanenza ovvero, quando non vi sia la prova di tale cessazione, dalla data dell'accertamento dell'infrazione inerente alla condotta specificamente contestata.

7. Sanzioni in ambito bancario e finanziario: profili procedurali e processuali.

Con riferimento ai profili procedurali, **Sez. 2, n. 1154/2024, Amato, Rv. 669969-02**, ha chiarito che, in materia di sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari mobiliari, la previsione di un termine perentorio per la conclusione del procedimento sanzionatorio è incompatibile con il sistema organico di norme di cui alla l. n. 689 del 1981, che delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi che non consentono, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine finale non adattabile alla complessità del caso concreto, con la conseguenza che non ha carattere perentorio il termine di duecento giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento Consob n. 18750 del 2013, al quale rinvia l'art. 24, comma 3, della sopravvenuta l. n. 262 del 2005, poiché, trattandosi di regolamento interno, è inidoneo a modificare le disposizioni della l. n. 689 del 1981, avendo esclusivamente funzione sollecitatoria e ordinatoria dell'attività degli uffici dell'autorità di vigilanza.

In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, **Sez. 2, n. 24401/2024, Amato, Rv. 672289-01**, ha statuito che il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dall'art. 14, comma 6, della l.n. 689 del 1981, decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, e che la sua determinazione spetta all'autorità competente mentre al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'accertamento.

Sez. 2, n. 27009/2024, Carrato, Rv. 672804-01, ha inoltre specificato che, in tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento - dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob - va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni. La stessa pronuncia ha poi affermato che, per il caso di violazioni delle norme sull'intermediazione finanziaria, il giudice dell'opposizione deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'inerzia ingiustificata e protratta durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere anche altri elementi, valevoli a dimostrare la sussistenza di infrazioni ulteriori rispetto a quelle già risultanti dagli atti, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio (**Sez. 2, n. 27009/2024, Carrato, Rv. 672804-02**);

nonché che, ai fini della tempestività della contestazione, il sindacato giurisdizionale sulla completezza degli atti di indagine si limita a un giudizio *ex ante* di evidente superfluità di questi, anche in ragione della possibile connessione con violazioni ancora da accertare, essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in ottica prognostica, si rivelino in concreto inutili (Sez. 2, n. 27009/2024, Carrato, Rv. 672804-03).

Secondo Sez. 2, n. 26766/2024, Guida, Rv. 672801-01, in tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, il termine di decadenza di centottanta giorni per la contestazione al trasgressore decorre non già dalla "constatazione del fatto" (cioè dalla data di acquisizione della notizia dell'illecito, nella sua materialità), ma dal momento dell'"accertamento del fatto", ossia dal giorno in cui l'autorità ha completato l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione. Inoltre, secondo la stessa pronuncia (Sez. 2, n. 26766/2024, Guida, Rv. 672801-05), se una banca, all'esito della verifica ispettiva da parte della Banca d'Italia, viene sottoposta ad amministrazione straordinaria, il termine entro cui la Consob è tenuta a contestare le irregolarità riscontrate in sede ispettiva decorre dal momento in cui essa riceve i rapporti periodici dei commissari straordinari o del comitato di sorveglianza, o da quando le vengono comunicati i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia.

La medesima decisione ha poi affermato che in questa materia l'accertamento dell'illecito amministrativo non si identifica con la fine dell'attività ispettiva o commissariale, ma si colloca in un momento successivo, da valutare a seconda delle particolarità del caso concreto (Sez. 2, n. 26766/2024, Guida, Rv. 672801-02).

Con riferimento ai poteri del giudice, Sez. 2, n. 26766/2024, Guida, Rv. 672801-03, ha affermato che in tema di violazioni delle norme disciplinanti l'intermediazione finanziaria, spetta all'autorità amministrativa il potere di decidere se avviare un'attività di indagine, mentre spetta al giudice controllare se il provvedimento sanzionatorio finale sia stato adottato entro un termine ragionevole, valutando la superfluità *ex ante*, e non la congruità *ex post*, dell'indagine amministrativa prodromica alla sanzione irrogata.

Da ultimo, con riguardo alla questione della decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio in materia di attività di intermediazione finanziaria, Sez. 2, n. 12323/2024, Carrato, Rv. 671491-01, ha statuito che il termine *ex art.* 145 del d.lgs. n. 385 del 1993 (nel testo applicabile *ratione temporis*) non ha natura perentoria e, pertanto, non può comportare alcuna decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio, attesa l'inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, che resta regolato esclusivamente dall'art. 14 l. n. 689 del 1981, ove si prevede un termine perentorio soltanto per la contestazione differita. Sez. 2, n. 10348/2024, Criscuolo, Rv. 670744-01, ha invece affermato che in questi casi trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990, poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere, di modo che quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente.

8. Abuso di informazioni privilegiate.

In tema di sanzioni amministrative a carico degli enti per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Sez. 2, n. 1624/2024, Bertuzzi, Rv. 669977-01, ha statuito che la responsabilità della società per l'abusivo utilizzo di informazione privi-

legiata commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, prevista dall'art. 187 *quinquies* del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione applicabile *ratione temporis* anteriormente alle modifiche *ex* d.lgs. n. 107 del 2018, si configura anche nel caso in cui gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati di altro paese dell'Unione Europea, coprendo la previsione tutte le condotte oggetto dell'illecito di cui all'art. 187 *bis* del medesimo TUF.

9. Ulteriori pronunce riguardanti le sanzioni in ambito bancario e finanziario.

In tema di offerta al pubblico di prodotti finanziari, **Sez. 2, n. 33255/2024, Guida, Rv. 673505-01**, ha chiarito che l'obbligo di pubblicare il prospetto informativo viene meno in presenza dei presupposti di esenzione previsti dall'art. 34-*ter* del Regolamento Emittenti Consob, cioè quando, sotto il profilo soggettivo, i prodotti offerti provengono da soggetti giuridici distinti, non superando per ciascun soggetto la soglia di cinque milioni di euro nell'arco di dodici mesi ed allorché al contempo, sotto il profilo oggettivo, si riscontra una diversità dei prodotti offerti, trattandosi di patrimoni destinati *ex* art. 2447-*bis* c.c., costituiti ciascuno per uno specifico affare.

La stessa pronuncia ha specificato che, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto informativo, ai sensi del citato art. 34-*ter* del Regolamento Emittenti Consob, la locuzione "medesimo prodotto finanziario" non indica strumenti finanziari semplicemente appartenenti al medesimo genere, ma allude a strumenti finanziari omogenei, perché si riferiscono a un medesimo affare o condividono un identico ed unico rischio, connesso all'investimento del capitale (**Sez. 2, n. 33255/2024, Guida, Rv. 673505-02**).

10. Le sanzioni amministrative previste dal codice della strada: modalità di accertamento.

Diverse sono state le pronunce nel corso dell'anno in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione di disposizioni del codice della strada.

Sez. 2, n. 29655/2024, Scarpa, Rv. 673090-01, ha statuito che, qualora il contravventore eccepisca in giudizio la decadenza per decorso del termine di quindici giorni di cui agli artt. 223, comma 3, e 224, comma 2, o del termine triennale di cui all'art. 219, comma 3-*ter* codice della strada, il giudice non può accogliere l'eccezione perché risulta accertato lo spirare del termine di prescrizione di cinque anni dalla violazione, in assenza di atti interruttivi, previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e dall'art. 209 codice della strada, dovendosi limitare a rigettare l'eccezione erroneamente proposta (fattispecie in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità).

Sez. 2, n. 21894/2024, Papa, Rv. 672177-01, ha chiarito, in tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), che, qualora l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico c.d. PARVC (Project Automation Red Violation Control) è illegittima la contestazione differita in assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale, in quanto avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario.

Da ultimo, **Sez. 2, n. 31747/2024, Besso Marcheis, Rv. 673449-01**, ha affermato che sussiste la violazione di cui all'art. 148, comma 12, C.d.S. quando viene ultimata una manovra di sorpasso di un altro veicolo in corrispondenza di un'intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico, ma non nel caso di mero tentativo, non essendo sanzionabile il comportamento del conducente che inizia lo spostamento sull'opposta corsia di marcia, ma non la completa rientrando nella propria corsia.

11. Il verbale di constatazione delle violazioni al codice della strada: natura, requisiti e notificazione.

Per quanto attiene al verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada e alla sua notifica, deve, innanzitutto, essere richiamata Sez. U, n. 02866/2021, Oricchio, Rv. 660403-01, che ha affrontato la questione delle modalità di notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea e, in particolare, quella della idoneità della notifica effettuata a mezzo posta. Discostandosi da una precedente pronuncia del 2018 (Sez. 6-2, n. 22000/2018, Carrato, Rv. 650355-01), le Sezioni unite hanno affermato che, in tale ipotesi, non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal momento che esso esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici poteri). Hanno ritenuto, inoltre, che, nei confronti di un cittadino tedesco, non può procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la l. n. 149 del 1983) - che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa - poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti. In tali ipotesi, pertanto, si deve dunque ricorrere - a pena di nullità (suscettibile di sanatoria) - all'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della citata Convenzione.

In tema di notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario trova applicazione anche nei casi in cui l'amministrazione utilizzi il Servizio integrato di notificazione, trattandosi di un servizio gestito da articolazioni interne di Poste Italiane (Sez. 2, n. 23817/2023, Rolfi, Rv. 668719-01).

Peraltro, l'art. 201 del codice della strada deve essere interpretato nel senso che la notificazione, per ritenersi validamente eseguita, non può fondarsi sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti *ivi* menzionati, essendo necessario l'espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale; da ciò consegue che, anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione, per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario, entro 150 giorni dall'eseguito accertamento (Sez. 2, n. 06722/2023, Carrato, Rv. 667284-01).

Sez. 2, n. 03426/2023, Amato, Rv. 666802-01, ha stabilito che il verbale di accertamento di violazione del codice della strada non può essere notificato, nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania, direttamente a mezzo del servizio postale, necessitando della assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo, la cui assenza comporta, tuttavia, non già l'inesistenza, bensì la nullità della notificazione, suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo *ex art.* 156, comma 3, c.p.c., per effetto della proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204-*bis* del codice della strada.

Sez. 2, n. 30129/2024, Caponi, Rv. 673142-01, ha precisato che nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento e contestazione di una violazione del codice della strada riveste, inoltre, l'efficacia probatoria della fede privilegiata fino a querela di falso nei limiti dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbaliz-

zante, purché privi di margini di apprezzamento. Nella specie, la S.C. ha negato tale valore probatorio al giudizio, contenuto nel verbale, in ordine alla collocazione in postazione “ben visibile” dell’apparecchio rilevatore della velocità.

12. L’opposizione: il rito, la competenza, l’oggetto e gli effetti.

In forza del d.lgs. n. 150 del 2011, sia ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione sia a quelli di opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo il 6 ottobre 2011, si applica il rito del lavoro e, in particolare, l’art. 434 c.p.c.

Per tale ragione, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, la produzione di documenti da parte dell’Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all’accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il comma 3 dell’art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l’udienza di discussione (Sez. 2, n. 32226/2022, Dongiacomo, non massimata).

In tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della l. n. 689 del 1981 *ratione temporis* vigente (oggi, art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011), non è necessaria la formale costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace della Pubblica Amministrazione, essendo sufficiente il solo deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento da parte dell’autorità emittente (Sez. 2, n. 16772/2023, Caponi, Rv. 668051-01).

Sez. 2, n. 07364/2022, Cavallari, Rv. 664208-01, ha precisato che il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada (ma il principio deve ritenersi esteso a tutte le sanzioni amministrative, salvo non vi sia una diversa disciplina di legge), instaurato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l’appello sia stato irrualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest’ultima. Inoltre, deve rilevarsi che il termine cd. lungo di impugnazione della sentenza, previsto dall’art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, vale a dire, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale soltanto può proporsi l’impugnazione, salvo il caso particolare dell’appello con riserva di motivi, di cui all’art. 433 c.p.c., comma 2.

In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la cognizione dell’opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione (di competenza del giudice di pace), deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità (Sez. 6-2, n. 14304/2022, Varrone, Rv. 664915-01).

Sez. 3, n. 29383/2024, Rossi, Rv. 672575-01, ha precisato che se l’opposizione, proposta nei confronti di una cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, prospetta il difetto di legittimazione passiva dell’opponente, va qualificata come opposizione preventiva all’esecuzione *ex art.* 615, comma 1, c.p.c., essendo diretta a contestare la direzione soggettiva dell’azione esecutiva - in quanto rivolta nei confronti di soggetto

diverso da quello individuato come obbligato nel sotteso verbale - minacciata con un atto (la cartella) che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolve *uno actu* la funzione che nell'espropriazione codicistica, è rivestita dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto. In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la competenza per materia, *ex art.* 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, del giudice di pace sull'opposizione *ex art.* 615, comma 1, c.p.c..

In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, Sez. 3, n. 13304/2024, Tatangelo, Rv. 671147-01, ha affermato che la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica della cartella costituisce un motivo di opposizione all'esecuzione, in quanto con essa si contesta in radice il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito, con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità, è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella la quale in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell'atto successivo della procedura.

Nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, *ex art.* 14 della stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (Sez. 2, n. 01056/2022, Besso Marcheis, Rv. 663569-01).

Per Sez. 6-2, n. 00922/2022, Dongiacomo, Rv. 663809-01, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità.

Per Sez. 6-3, n. 03582/2022, Rossetti, Rv. 664072-01, l'opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella *ex artt.* 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.. Nella fattispecie giunta al suo esame, la S.C. - qualificata come opposizione agli atti esecutivi la contestazione riguardante l'irregolare notificazione della cartella, in quanto eseguita da un indirizzo PEC non inserito in pubblici elenchi - ha accolto il regolamento di competenza dell'opponente avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza in favore del giudice di pace del luogo in cui era stata commessa la violazione del c.d.s.

Sez. 6-2, n. 37999/2021, Varrone, Rv. 663087-01, ha riaffermato il principio (già affermato da Sez. U, n. 20544/2008, Carbone, Rv. 604645-01) per cui l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, dal momento che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo l'art. 202 codice della strada, non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, comportando soltanto un'incompatibilità,

oltre che un'implicita rinuncia, a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata, sia alla violazione contestata che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico.

Pertanto, l'interessato potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come, ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata.

13. Le violazioni sanzionate dal codice della strada.

In tema di violazioni al codice della strada, l'art. 218, comma 6, c.d.s., che punisce chiunque circola abusivamente nel periodo di sospensione della patente, prevede, a garanzia dell'interesse alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela della vita umana, un illecito istantaneo il cui perfezionamento non richiede la previa definizione del ricorso, amministrativo o giurisdizionale, avverso l'ordinanza di sospensione della patente (**Sez. 2, n. 29652/2024, Guida, Rv. 673036-01**).

Secondo **Sez. 2, n. 10505/2024, Carrato, Rv. 670887-01**, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.

In tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, **Sez. 2, n. 4187/2024, Amato, Rv. 670317-01**, ha ritenuto che il periodo di protrazione della violazione, che, ai sensi del comma 15 dell'art. 7 del nuovo codice della strada, consente la reiterazione della sanzione nel caso di superamento dei tempi consentiti della sosta regolamentata o limitata, si individua in base alla fascia di vigenza giornaliera - o infragiornaliera - della sosta (e non già in base al periodo determinato dal pagamento effettuato dall'utente o indicato nel disco orario esposto), con la conseguenza che la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore e la sanzione relativa alla sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, le cosiddette "*microcars*" sono qualificabili come "motoveicoli", ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. h), cod. strada, non essendo equiparabili, ai sensi dell'art. 52 cod. strada, ai cicli e ai motocicli, con la conseguenza che non possono legittimamente sostare negli spazi predisposti per questi ultimi (**Sez. 2, n. 03432/2023, Carrato, Rv. 667568-01**).

14. Le altre sanzioni.

Nell'anno di riferimento la S.C. ha precisato presupposti e ambito di applicazione anche di altre sanzioni amministrative.

Sez. 2, n. 32079/2024, Falaschi, Rv. 673453-01, in tema di sicurezza ed etichettatura dei prodotti, ha evidenziato che gli obblighi informativi previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 206 del 2005 gravano su tutti gli operatori della filiera economica, stante la definizione di "distributore" di cui all'art. 2, lett. f), del d.lgs. n. 172 del 2004, che lo identifica con qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Quanto alle sanzioni in materia di gestione e raccolta di rifiuti, **Sez. 2, n. 25905/2024, Falaschi, Rv. 672813-01**, ha chiarito che le relative sanzioni amministrative pecuniarie previste dal regolamento comunale sono legittime spettando al Comune il potere di controllare il rispetto delle prescrizioni normative relative alla raccolta dei rifiuti attraverso la regolamentazione del servizio di nettezza urbana, e, quindi, attraverso la previsione di specifiche sanzioni nei limiti di cui all'art. 7-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000. Nella specie, la S.C. ha giudicato legittima la comminatoria del regolamento comunale di Roma Capitale di una sanzione da 50 a 300 euro, a fronte di un minimo e un massimo legali rispettivamente di 25 e 500 euro.

In tema di violazione della disciplina antiriciclaggio per omessa segnalazione di operazioni sospette, **Sez. 2, n. 26793/2024, Guida, Rv. 672802-01**, ha statuito che la facoltà di richiedere il pagamento in misura ridotta pertiene alla fase del procedimento amministrativo, sicché anche per godere della definizione agevolata *ex art.* 68, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007, l'interessato deve procedere con istanza da proporre al Ministero dell'economia e delle finanze, il cui esito è irrilevante nel procedimento giurisdizionale, salvo che, in caso di accoglimento, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Nella stessa materia, **Sez. 2, n. 24396/2024, Amato, Rv. 672288-01**, ha sottolineato l'obbligo, per il responsabile della dipendenza, di segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che il relativo oggetto possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, effettuando un'ampia ed approfondita valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano l'anomalia dell'operazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l'ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all'effettiva qualità e capacità economica dell'autore delle operazioni, non essendo sufficiente la mera liceità dell'operazione finale ai fini del superamento della presunzione di irregolarità derivante dalla presenza degli indici di anomalia dettati dalla Banca d'Italia.

CAPITOLO XXXIII

ELEZIONI E GIUDIZI ELETTORALI

(DI GIULIA STANO)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Diritto di elettorato passivo. - 3. Diritto di elettorato passivo e appartenenza di genere. - 4. Spese elettorali.

1. Premessa.

Nel corso dell'anno in rassegna le pronunce in materia elettorale non sono numerose. Significativi, comunque, sono stati gli interventi concernenti i temi dell'elettorato passivo e del contenzioso elettorale.

2. Diritto di elettorato passivo.

Sez. 1, n. 26375/2024, *Tricomi L.*, Rv. 672751-01, ha affermato che la dichiarazione d'incandidabilità degli amministratori non consegue automaticamente al provvedimento di scioglimento dell'amministrazione comunale, così come, del resto, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità *ex art.* 143, comma 11, TUEL deve ritenersi autonomo rispetto a quello penale, in quanto la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio, anche attraverso elementi di collegamento fra l'amministratore e l'oggetto dell'addebito, ritenuti idonei ad influenzare e condizionare la formazione della volontà dell'ente pubblico. La pronuncia si pone nel solco di SU, n. 1747/2015, *Giusti*, Rv. 634130-01, secondo cui lo speciale procedimento di cui all'art. 143 del TUEL scaturisce dalla proposta di scioglimento del Ministro dell'interno, che "non solo indica le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico, ma contiene anche la menzione degli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento: di qui l'idoneità di detta proposta del Ministro, in quanto recante i nominativi degli amministratori responsabili e le ragioni della loro dedotta responsabilità, a fungere, una volta inviata al tribunale competente ai fini della dichiarazione d'incandidabilità di detti amministratori, da atto di impulso del relativo procedimento giurisdizionale"; inoltre, "occorre considerare che l'incandidabilità temporanea e territorialmente delimitata rappresenta una misura interdittiva volta a rimediare al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali. Nel disegno normativo, pertanto, l'attitudine postulatoria della proposta proveniente direttamente dalla parte sostanziale e la non necessità per l'Amministrazione dell'interno, ai fini dell'introduzione del procedimento, di versare gli elementi già contenuti in quella proposta in un atto di ricorso, si giustificano con l'esigenza di apprestare forme procedurali essenziali, in grado di permettere una

risposta giurisdizionale il più possibile ravvicinata nel tempo. Risponde ad una logica di effettività del rimedio prefigurato dal legislatore il riservare alla stessa Autorità cui sono demandate le funzioni di formalizzare la proposta di scioglimento dell'organo elettivo dell'ente esposto a infiltrazioni della criminalità organizzata ovvero dalla stessa condizionato nel suo funzionamento, il compito anche di introdurre direttamente, con l'invio della proposta e dei relativi allegati, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità dei componenti degli organi politici che abbiano provocato o concorso a provocare lo scioglimento dell'ente". Ritenendo la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 11, del TUEL per contrasto con gli artt. 27 e 51 Cost., inoltre, le Sezioni Unite avevano affermato che "la misura interdittiva della incandidabilità dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o simile nel tessuto istituzionale locale, privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi nell'ambito di competizioni elettorali destinate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di *extrema ratio* volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare, e a salvaguardare così beni primari dell'intera collettività nazionale - accanto alla sicurezza pubblica, la trasparenza e il buon andamento delle amministrazioni comunali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, capaci di alimentare la "credibilità" delle amministrazioni locali presso il pubblico e il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni -, beni compromessi o messi in pericolo, non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento".

Sez. 1, n. 26094/2024, Tricomi L., Rv. 672749-01, da parte sua ha stabilito che l'art. 60, comma 1, del d. lgs. n. 267 del 2000 - il quale, al fine di prevenire una possibile incidenza sulla libertà di voto, individua nella funzione di Commissario di governo una causa di ineleggibilità nel territorio in cui detto soggetto esercita le proprie funzioni - non può riguardare la carica di Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'art. 1 del d.l. n. 109 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 130 del 2018 (ricostruzione del c.d. "Ponte Morandi"), in quanto, trattandosi di disposizione intesa a limitare il diritto di elettorato passivo, la stessa riveste natura eccezionale ed è insuscettibile di applicazione analogica. In motivazione si fa menzione dell'orientamento in materia della Corte costituzionale, che afferma la "preminenza del diritto di elettorato passivo, che l'art. 51 della Costituzione assicura in via generale", riconducendolo "alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione (sentenze nn. 571 del 1989, 235 del 1988, 141 del 1996)"; si evidenzia, inoltre, che la Corte costituzionale ha sottolineato "che la verifica di legittimità costituzionale deve effettuarsi innanzitutto alla luce dell'art. 51 Cost., senza dimenticare che "l'eleggibilità è la regola, e l'ineleggibilità l'eccezione" e che le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (v. già la sentenza n. 46 del 1969, indi la sentenza n. 166 del 1972, fino alle sentenze nn. 571 del 1989, 344 del 1993, 141 del 1996), per cui si richiede che il limite sia effettivamente indispensabile". Si afferma, ancora, che la S.C. ha statuito che "anche che le disposizioni che sanciscono l'ineleggibilità sono norme a carattere eccezionale e non possono

essere applicate analogicamente a casi diversi anche ove emerga una posizione simile (Cass. n. 1949/2016; Cass. 626/2008); le restrizioni per il diritto di elettorato passivo sono ammissibili soltanto nei limiti necessari alla tutela di altri interessi di rango costituzionale pari o superiore (Cass. n. 1073/2001)".

Ancora, in continuità con Sez. 1, n. 27832/2011, Di Palma, Rv. 620923-01, **Sez. 1, n. 29277/2024, Campese, Rv. 673129-01**, in tema di elezioni del consiglio regionale siciliano, ha affermato che l'art. 10-*bis* della l.reg. n. 29 del 1951, introdotto dalla l.reg. n. 7 del 2005, nel prevedere il termine entro il quale devono essere rimosse le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale, richiede che la cessazione delle funzioni incompatibili sia effettiva, incombendo sul candidato l'onere di provare l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, poiché solo in tal caso si evita il rischio che egli possa approfittare del prestigio connesso a tale ufficio per captare il consenso degli elettori, con conseguente lesione della *par condicio* rispetto agli altri candidati.

3. Diritto di elettorato attivo e appartenenza di genere.

Sez. 1, n. 9428/2024, Tricomi L., Rv. 670721-01 ha affermato che le norme relative alla disciplina dell'elettorato attivo, alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali, distinte per appartenenza di genere, non incidono sull'esercizio del diritto di voto ma solo sulle attività propedeutiche alla sua attuazione concreta, con la conseguenza che si deve escludere la rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle norme stesse rispetto alla invocata lesione del diritto di voto, dovendosi, al riguardo, accertare l'esistenza di un nesso di strumentalità tra la definizione del giudizio principale e la risoluzione della questione afferente al bene della vita per il quale si agisce. Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da ricorrenti che, in qualità di persone non binarie, lamentavano che il mancato riconoscimento della propria identità ed il disagio a dover attendere la chiamata alle urne nella fila corrispondente al genere assegnato dalla nascita incidessero sull'esercizio del diritto di voto. Si legge nella motivazione, in particolare, che le norme sospettate di incostituzionalità "stabiliscono che: le liste elettorali sono distinte per uomini e donne e sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, con l'indicazione di una serie di elementi identificativi degli elettori (art. 5 del d.P.R. n. 223/1967 e art. 4 della l. n. 1058/1947); devono essere aggiornate annualmente dal sindaco con i nominati di coloro che hanno raggiunto la maggiore età, in base ai registri dello stato civile (art.8 del d.P.R. n. 223/1967 e art. 6 della l. n. 1058/1947); semestralmente devono essere compilati due elenchi separati, ciascuno distinto per uomini e donne, per la revisione delle liste elettorali, cui provvede la Commissione elettorale (art.16 del d.P.R. n. 223/1967 e art. 13 della l. n. 1058/1947); anche le liste di sezione devono essere compilate, sulla scorta delle liste elettorali, distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori (art. 37 del d.P.R. n. 223/1967 e art. 29 della l. n. 1058/1947). ... e le norme dedotte e la lamentata distinzione per appartenenza di genere concernono esclusivamente l'esecuzione e lo svolgimento delle attività di carattere amministrativo propedeutiche all'esercizio del diritto di voto, realizzate mediante la predisposizione e l'aggiornamento delle liste elettorali, ma non incidono sull'esercizio del diritto di voto che è oggetto della tutela richiesta. 5.3.- Il diritto di voto, che si fonda sul principio del suffragio universale sancito dalla Costituzione, è, ben vero, autonomamente regolato, senza alcun vincolo o condizione, dall'art.57 del d.P.R. 361/1957 (che al primo comma stabilisce che «Dichiarata aperta la votazione, gli elettori

sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.», di guisa che la prospettazione circa la prassi dell'incolonnamento in fila per genere, in attesa dell'accesso alle urne, di cui i ricorrenti si dolgono (e come notoriamente è dato riscontrare nella realtà dell'esercizio del diritto politico), appare riconducibile ad una impropria evenienza fattuale - peraltro, atta ad incidere sul principio dell'esercizio del diritto di voto secondo l'ordine di presentazione, stabilito dalla norma in esame - e non già ad una disposizione normativa della cui legittimità costituzionale si possa dubitare. ... nessun pregiudizio sul diritto di voto può ipotizzarsi o è previsto da una qualche norma quale conseguenza della suddetta mancata immedesimazione di genere. Parimenti, il senso di disagio e di imbarazzo lamentato dai ricorrenti nel corso delle operazioni elettorali non si vede a quale previsione normativa sia ricollegabile, visto che lo svolgimento di tali operazioni, che ben potrebbe essere diversamente organizzato, non prevede in alcun modo una ostensione o distinzione, fisica o visibile, degli elettori in base al genere risultante dalle liste elettorali...».

4. Spese elettorali.

Alla violazione degli adempimenti in materia di spese elettorali, gravanti sui candidati ai sensi dell'art. 7 della l. n. 515 del 1993 (contenente *Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*), conseguono le sanzioni amministrative previste dal successivo art. 15, di competenza del Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 della medesima legge.

È incontroversa, peraltro, l'applicabilità della disciplina generale contenuta nella l. n. 689 del 1981 alle sanzioni previste in materia elettorale (cf. Sez. 2, n. 3879/2008, Piccialli, Rv. 602202-01; Sez. 2, n. 21249/2007, Trombetta, Rv. 599154-01; Sez. 1, n. 11893/2006, Spagna Musso, Rv. 589161-01; Sez. 2, n. 24790/2005, Cioffi, Rv. 585543-01; Sez. 1, n. 10582/2003, Macioce, Rv. 564810-01; Sez. 1, n. 9935/2001, Forte, Rv. 548373-01; Sez. 3, n. 1855/2000, Varrone, Rv. 534073-01; Sez. 1, n. 477/1998, Catalano, Rv. 512029-01. Presuppone detto principio Sez. 1, n. 9263/1994, Senofonte, Rv. 488434-01).

Nel periodo in rassegna, e a specificazione della disciplina applicabile, Sez. 2, n. 3984/2024, Amato, Rv. 670310-01, ha avuto modo tuttavia di affermare che la diffida con la quale il Collegio regionale di garanzia invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e nel contempo di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio; ne consegue che non è necessaria la notificazione di un nuovo atto di contestazione, ex art. 14 della l. n. 689 del 1981, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessario l'invio della contestazione ex art. 14 cit., da inviarsi a seguito dell'avvenuto inadempimento alla suindicata diffida). Il principio si pone in continuità con Sez. 6-2, n. 8263/2021, Falaschi, Rv. 660825-01, cui è a sua volta conforme Sez. 1, n. 27148/2024, Caiazza, Rv. 672770-01, secondo cui l'obbligo stabilito dall'art. 2, comma 1, n. 3, della l. n. 441 del 1982, richiamato dall'art. 7, comma 6, della l. n. 515 del 1993, di attestare, in alternativa alla dichiarazione concernente le spese sostenute per la campagna elettorale, di essersi avvalso esclusivamente di

materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione del partito, mirando ad assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento e gli eventuali controlli, grava su tutti i candidati che abbiano partecipato alla competizione elettorale, i quali devono rendere la dichiarazione autocertificativa, pur in forma negativa, anche nei casi limite, in cui, oltre a non aver sostenuto personalmente oneri o ricevuto contributi, neppure si siano avvalsi di strutture e mezzi messi a disposizione dal partito, onde, in caso di omissione, è legittima la sanzione irrogata dal Collegio di garanzia elettorale.

CAPITOLO XXXIV

I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

(DI OLIMPIA MONACO - LUCA D'ADDARIO)¹

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La responsabilità disciplinare dei magistrati. - 2.1. Gli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni. - 2.2. Concorso formale tra illeciti funzionali. - 3. Il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio. - 4. Il giudizio disciplinare. - 4.1. Revoca del provvedimento di archiviazione disposto ai sensi dell'art. 16, comma 5-*bis*, del d. lgs. n. 109 del 2006. - 4.2. La sospensione dei termini del procedimento disciplinare. - 4.3. La revoca della misura cautelare e la sospensione cautelare. - 4.4. Cessazione del rapporto di servizio e cessazione della materia del contendere. - 4.5. L'utilizzo di intercettazioni. - 4.6. La sanzione della rimozione a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006. - 4.7. La revisione della sentenza. - 5. La responsabilità disciplinare degli avvocati. - 5.1. Gli illeciti disciplinari. - 5.2. La concreta individuazione delle condotte illecite. - 5.3. Il Consiglio distrettuale di disciplina, elezione dei componenti e natura del giudizio disciplinare dinanzi al medesimo. - 5.4. Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione resa dal Consiglio distrettuale di disciplina. - 5.5. L'impugnazione dinanzi alle Sezioni Unite della decisione del Consiglio Nazionale Forense. - 5.6. La riassunzione del giudizio disciplinare a seguito di cassazione con rinvio della decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense. - 6. La responsabilità disciplinare dei notai. - 6.1. Gli illeciti disciplinari. - 6.2. Il ravvedimento.

1. Premessa.

La rassegna sulla responsabilità disciplinare racchiude le pronunce rese in tale ambito dalla S.C. nei riguardi dei magistrati, degli avvocati e dei notai.

2. La responsabilità disciplinare dei magistrati.

Sul tema della responsabilità disciplinare degli appartenenti all'ordine giudiziario, nell'anno di riferimento, sono state reperite delle pronunce rese solo con riferimento agli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni, nonché alcune decisioni che hanno affrontato temi legati ai profili procedurali del giudizio disciplinare.

2.1. Gli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni.

Nell'ambito degli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni ricadono le fattispecie dei comportamenti che, violando i doveri del magistrato, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nell'ambito dell'ufficio giudiziario ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; la sottrazione abituale ed ingiustificata all'attività di servizio e la condotta scorretta nei confronti di altri magistrati.

In particolare, Sez. U, n. 7616/2024, De Masi, Rv. 670522-01, ha affermato che la configurazione dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, richiede

(1) Paragrafi dal n. 1 al n. 2.4 a cura di Olimpia Monaco; Paragrafi da n. 2.5 a n. 7.2 a cura di Luca D'addario.

che il magistrato, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante la violazione dei doveri di diligenza, laboriosità e correttezza, abbia procurato ad una delle parti un indebito vantaggio.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Sezione disciplinare del CSM aveva sanzionato un Pubblico Ministero - che aveva fornito un'informazione, non riservata *ex art.* 116 c.p.p. e di per sé ininfluyente sull'esito del procedimento considerato nel capo d'incolpazione, sull'esistenza o meno di un provvedimento dell'autorità giudiziaria -, ravvisando il vantaggio indebito nell'agevolazione della parte nell'acquisizione di informazioni di suo interesse, pur non ricorrendo alcuna ipotesi di divulgazione preferenziale della strategia investigativa o comunque di determinazioni sensibili inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Con riferimento, invece, alla configurabilità dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, le Sezioni Unite hanno sottolineato che non è richiesto che la condotta scorretta del magistrato sia, al contempo, grave ed abituale, essendo sufficiente - alla stregua del tenore testuale della disposizione, nella quale i due aggettivi sono separati da una congiunzione disgiuntiva - che ricorra uno solo di tali requisiti, sicché anche una singola condotta, se grave, consente di ravvisare la violazione (**Sez. U, n. 16682/2024, Garri, Rv. 671388-01**).

Quanto all'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, **Sez. U, n. 7838/2024, Criscuolo, Rv. 670508-01**, hanno precisato che esso si configura in presenza dei presupposti della reiterazione e della gravità del ritardo, che è giustificabile solo se, nel lasso temporale interessato, sia inesigibile una diversa organizzazione del lavoro per evitarlo o almeno per ridurre l'abnorme dilatazione, potendo le condizioni personali dell'interessato solo concorrere, ove eccezionali e transitorie. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità disciplinare del magistrato per una pluralità di gravi ritardi ultrannuali nel deposito di sentenze in ragione dell'elevato numero e della durata dei ritardi stessi, non giustificati da situazioni lavorative e da situazioni personali, e per avere omesso ogni iniziativa concreta ai fini dello smaltimento dell'arretrato.

Quantunque non specificatamente riferita alla tematica degli illeciti disciplinari funzionali, appare nondimeno opportuno il richiamo in questa sede a **Sez. U, n. 16784/2024, Giusti, Rv. 671523-01**, la quale, in sede di riparto della giurisdizione, ha chiarito che gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario. In applicazione del predetto principio la S.C. ha ritenuto tali atti insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).

2.2. Concorso formale tra illeciti funzionali.

Le Sezioni Unite hanno chiarito come, tra gli illeciti disciplinari “funzionali” di cui agli artt. 2, comma 1, lett. a), g) e q), d.lgs. n. 109 del 2006 e tra questi e l’illecito *ex art. 4*, lett. d), del citato decreto, ricorre un concorso formale, dal momento che nei primi si affianca a una parte comune - rappresentata dalla violazione dei doveri del magistrato - un elemento di specificazione (costituito, rispettivamente, dal danno ingiusto o dall’indebito vantaggio procurato ad una delle parti; dalla gravità della violazione di legge, che dev’essere determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; dalla pluralità di condotte omissive nel compimento degli atti d’ufficio), mentre l’ultimo - come tutti quelli conseguenti a reato - si caratterizza per una maggiore gravità ed integra la compromissione di beni giuridici diversi rispetto agli altri, relativi all’osservanza dei doveri professionali, la cui lesione costituisce fondamento degli illeciti funzionali o extra-funzionali di cui agli artt. 2 e 3 della disciplina legislativa (Sez. U, n. 31016/2024, Iofrida, Rv. 672861-01). In applicazione del predetto principio, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM che aveva riscontrato un concorso formale tra gli illeciti sopra elencati - contestati ad un pubblico ministero in relazione all’inerzia nella gestione di diversi procedimenti penali -, escludendo che potesse configurarsi una violazione del principio del *ne bis in idem*, dal momento che non si poneva un problema di nuovo esercizio dell’azione disciplinare per il medesimo fatto, bensì di verifica della sussistenza di un’unità o pluralità di illeciti, alla stregua dei criteri relativi al rapporto strutturale tra norme.

3. Il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio.

In relazione all’applicazione della misura cautelare del trasferimento d’ufficio del magistrato, Sez. U, n. 24283/2024, Falabella, Rv. 672093-01 ha precisato che il giudice del merito deve verificare che ricorrano, accanto ai gravi elementi di fondatezza dell’incolpazione (*fumus*), motivi di particolare urgenza che impongono il trasferimento in via cautelare, valutando sia l’esigenza di carattere soggettivo di allontanare il magistrato da un ambiente in cui, in pendenza del giudizio disciplinare, non potrebbe continuare ad esercitare le funzioni con la serenità e il distacco necessari, sia la finalità di carattere oggettivo, avente un peso preponderante, di evitare che la permanenza del magistrato nell’ufficio o nelle funzioni esercitate incida negativamente sul buon andamento dell’amministrazione della giustizia, anche sotto il profilo della visibilità all’esterno (in senso conforme Sez. U., n. 33017/2018, Cirillo, Rv. 652078-03). In applicazione di tale principio è stata, pertanto, confermata la decisione impugnata che aveva fondato il provvedimento di trasferimento cautelare ad altra sede e con diverse funzioni sul rilievo che l’incolpato non avrebbe potuto continuare a esercitare con serenità e distacco le funzioni requirenti nella medesima sede, in ragione delle piccole dimensioni dell’ufficio e del fatto che il magistrato era originario della stessa città in cui era svolta l’attività giurisdizionale, risultando così integrato in un tessuto sociale che, proprio per le gravi vicende oggetto dei procedimenti penale e disciplinare pendenti nei suoi confronti, poteva rivelarsi in futuro ostile o comunque fortemente critico nei suoi confronti.

4. Il giudizio disciplinare.

In relazione al più ampio tema del giudizio disciplinare, si riportano di seguito le decisioni concernenti prevalentemente questioni procedurali ed attinenti alle misure cautelari.

4.1. Revoca del provvedimento di archiviazione disposto ai sensi dell'art. 16, comma 5-bis, del d. lgs. n. 109 del 2006.

Le Sezioni Unite hanno osservato come il fatto nuovo - che giustifica la revoca del provvedimento di archiviazione di cui all'art. 16, comma 5-bis, del d.lgs. n. 109 del 2006 - è integrato dall'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'incolpato, trattandosi di un fatto oggettivo rilevante quale elemento discreitivo tra i titoli di incolpazione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 del citato d.lgs. e quello di cui alla lett. d) della medesima disposizione (Sez. U, n. 26371/2024, Rossetti, Rv. 672394-01). In applicazione di tale principio, le Sezioni Unite hanno escluso che l'iniziale archiviazione di un procedimento cd. "predisciplinare" - motivata, tra l'altro, dalla ritenuta implausibilità che il procedimento penale pendente nei confronti dell'incolpato potesse concludersi con una condanna - precludesse l'avvio di un nuovo procedimento disciplinare, in ragione del rinvio a giudizio successivamente intervenuto.

4.2. La sospensione dei termini del procedimento disciplinare.

In tema di sospensione *ex lege* dei termini del procedimento disciplinare per esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 109 del 2006, Sez. U, n. 9716/2024, Patti, Rv. 670668-01, hanno precisato che essa consegue alla necessaria emanazione di un provvedimento della Sezione disciplinare del CSM - avente natura dichiarativa ed effetti retroattivi alla data di esercizio dell'azione penale - che presuppone, a comune fondamento di entrambi i procedimenti, la sussistenza del "medesimo fatto".

4.3. La revoca della misura cautelare e la sospensione cautelare.

Sez. U, n. 9375/2024, Fuochi Tinarelli, Rv. 670665-01 hanno precisato che una volta formatosi il c.d. "giudicato cautelare" in ordine ai fatti contestati e alla loro gravità, la revoca della misura cautelare inflitta al magistrato presuppone l'esplicita considerazione di elementi caratterizzati da novità, che non siano già stati oggetto di apprezzamento, neppure su un piano di derivazione logica da quelli già esaminati in sede di applicazione della misura o di sua impugnazione, e che, valutati unitariamente, siano idonei a suffragare l'affievolimento delle esigenze cautelari, non rilevando *ex se* il mero decorso del tempo.

Con riferimento, invece, alla sospensione cautelare facoltativa, prevista dall'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, Sez. U, n. 3657/2024, Mercolino, Rv. 670008-01, hanno specificato che la sua applicazione in relazione al caso del magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, impone al giudice disciplinare di valutare la gravità dei fatti ascritti in sede penale, tenendo conto del titolo dei delitti e di tutte le circostanze del caso concreto, ai fini del giudizio circa l'esistenza di una lesione del prestigio e della credibilità dell'incolpato tale da non essere compatibile con l'esercizio delle funzioni, restando escluso che detto organo possa altresì formulare una prognosi circa l'esito del procedimento penale, non essendo dotato del potere di negare, nella sostanza, lo stesso presupposto previsto dalla legge - ossia la sottoposizione a procedimento penale - per l'applicazione della sospensione cautelare in tale ipotesi. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di rigetto dell'istanza di revoca della sospensione cautelare facoltativa di un magistrato, imputato per il delitto di tentata concussione, avendo rilevato che i fatti emersi dall'istruttoria penale e disciplinare erano stati oggetto di autonoma valutazione ai fini della verifica della sussistenza del *fumus* del reato contestato, ritenuto di gravità tale da compromettere l'immagine del magistrato ed incompatibile con la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni, anche in una diversa sede.

4.4. Cessazione del rapporto di servizio e cessazione della materia del contendere.

Le Sezioni Unite hanno precisato come il venire meno del rapporto di servizio nel corso del procedimento innanzi alla Sezione disciplinare comporta, nell'ambito del giudizio disciplinare a carico di magistrati, la declaratoria, da parte di quest'ultima, dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, a meno che non risulti la perduranza di un concreto interesse dell'incolpato, diverso da quello latamente "morale", alla prosecuzione del giudizio (Sez. U, 28697/2024, Terrusi, 672743-01). Con tale pronuncia, rilevando la mancata prospettazione nel giudizio di un concreto interesse dell'incolpato alla sua prosecuzione, le Sezioni Unite hanno annullato senza rinvio la sentenza disciplinare, dando atto del venire meno, in epoca precedente alla decisione, del rapporto di servizio del magistrato.

Sez. U, n. 13319/2024, Di Paolantonio, Rv. 671516-01, hanno precisato che il transito alla magistratura speciale tributaria, disposto nelle more del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 1 della l. n. 130 del 2022, è inidoneo a determinare l'estinzione del potere e dell'azione disciplinare, in quanto, non avendo carattere di definitività, non fa venir meno l'interesse dell'amministrazione all'accertamento della responsabilità, che potrebbe assumere rilievo in caso di successiva riammissione nei ruoli della magistratura ordinaria.

4.5. L'utilizzo di intercettazioni.

In tema di intercettazioni, Sez. U, n. 8492/2024, Graziosi, Rv. 670757-01, ha affermato che l'utilizzazione, nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico di magistrati, di captazioni ritualmente disposte nell'ambito di un procedimento penale, non confligge - pure alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2023 - con gli artt. 8 della CEDU e 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, poiché quest'ultima, nel dettare i presupposti ed i limiti della cosiddetta "*data retention*", ha ad oggetto i dati, provenienti dagli utenti, già acquisiti e temporaneamente conservati dai fornitori del servizio di comunicazione, mentre oggetto della *translatio* dal procedimento penale a quello disciplinare sono le conversazioni telefoniche o ambientali, non potendosi dilatare il perimetro della citata direttiva fino a ricomprendervi situazioni da essa non regolate, perché altrimenti il diritto dell'individuo alla riservatezza prevarrebbe automaticamente, oltre i limiti della proporzionalità e ragionevolezza, sull'imparzialità e correttezza della funzione giudiziaria.

Sulla stessa linea si pone Sez. U, n. 13319/2024, Di Paolantonio, Rv. 671516-02, decisione con la quale è stato precisato che, nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'utilizzo di captazioni disposte in un procedimento penale non contrasta con l'art. 8 CEDU, né con l'art. 15, par. 1, Direttiva 2002/58/CE, poiché il diritto eurounitario, al pari di quello interno e convenzionale, non esclude in assoluto qualsivoglia limitazione del diritto alla riservatezza, ma richiede un suo bilanciamento con le finalità di interesse generale che possono venire in rilievo e che legittimano lo Stato membro a ritenere, con atto normativo, quel diritto subvalente, qualora la sua compressione sia proporzionata allo scopo e sia giustificata dalla necessità di tutelare altri valori, come, nella specie, il prestigio dell'ordine giudiziario e dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, i quali rientrano tra i beni protetti di maggiore rilevanza nell'assetto costituzionale italiano.

Con la medesima pronuncia si è inoltre precisato che l'utilizzo delle intercettazioni non viola l'art. 268, comma 3, c.p.p., ove l'attività di registrazione, consistente nell'immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata, avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo degli impianti ivi esistenti, mentre non è necessaria

l'immediata trasmissione degli stessi al *server* finale di destinazione, essendo rilevante che, attraverso l'obiettivo utilizzazione di impianti posti sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, la fase decisiva della registrazione sia effettuata al riparo da ingerenze esterne (Sez. U, n. 13319/2024, Di Paolantonio, Rv. 671516-03).

4.6. La sanzione della rimozione a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006.

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 (Corte cost., sentenza n.51 del 2024) le Sezioni Unite hanno chiarito come la sanzione della rimozione non è più automaticamente applicabile al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p., o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168 c.p., riespandendosi la disciplina generale di cui all'art. 4 (illeciti disciplinari conseguenti a reato), comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs., così restituendo alla Sezione disciplinare del CSM la possibilità di comminare, secondo il proprio discrezionale apprezzamento, una delle sanzioni previste dall'art. 5 (Sez. U, n. 25975/2024, Marotta, Rv. 672322-01).

4.7. La revisione della sentenza.

In tema di revisione della sentenza, Sez. U, n. 9156/2024, Crucitti, Rv. 670664-01, ha evidenziato che in ragione della natura straordinaria dell'impugnazione per revisione della sentenza disciplinare irrevocabile di condanna, anche nella fase rescindente, la valutazione degli elementi addotti al fine di capovolgere la decisione di condanna non può essere superficiale, ancorché sommaria, dovendosi necessariamente compiere una verifica preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza o, di contro, sulla non decisività delle allegazioni poste a sostegno dell'istanza. Conseguentemente, il giudizio preliminare di ammissibilità ha il medesimo ambito della fase di revisione, differenziandosene, tuttavia, per essere caratterizzato da un vaglio prognostico che non necessita di scandaglio approfondito ed è limitato alla valutazione dell'attitudine astratta dei nuovi elementi, apprezzati insieme ai pregressi, a scardinare la statuizione di colpevolezza.

5. La responsabilità disciplinare degli avvocati.

Riguardo alla responsabilità disciplinare degli avvocati vanno richiamate le pronunce riguardanti talune ipotesi di illecito disciplinare e quelle dedicate ad alcuni aspetti del conseguente giudizio.

5.1. Gli illeciti disciplinari.

Le Sezioni Unite hanno chiarito come, in tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, il dovere di astensione previsto dall'art. 24, comma 5, del codice deontologico - qualora le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale - trova applicazione anche nelle ipotesi contenute nel comma 4 dell'art. 68 dello stesso codice (secondo cui l'assistenza del minore in controversie familiari impone all'avvocato di astenersi dal prestare la propria assistenza in successive controversie familiari), in quanto l'esigenza d'impedire - soprattutto nella delicata materia della famiglia - il conflitto di interessi, anche solo potenziale, resterebbe radicalmente vanificata se fosse permessa la sua agevole elusione in caso di strette e continuative collabo-

razioni professionali tra avvocati (Sez. U, 20881/2024, Grasso, Rv. 671763-01). In applicazione di tale principio, le Sezioni Unite hanno conseguentemente confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense con la quale era stata ravvisata un'ipotesi di conflitto d'interessi - potenziale, ma comunque rilevante - nella condotta di un difensore che aveva accettato il mandato conferito per il procedimento volto ad ottenere il riconoscimento di *status* di una minore, sebbene il curatore di quest'ultima, che in concreto aveva aderito alla domanda di riconoscimento, fosse un avvocato facente parte della medesima associazione professionale.

5.2. La concreta individuazione delle condotte illecite.

Le Sezioni Unite, in relazione al caso di un legale giudicato colpevole, in via definitiva, del reato di cui all'art. 609-*bis*, comma 3, c.p., hanno chiarito che nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (nella specie, atti lesivi del decoro e della dignità professionali) è rimessa all'ordine professionale, essendosi altresì chiarito che il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla S.C., se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense, tramite una riformulazione o ridefinizione delle condotte esaminate, nell'enunciazione delle ipotesi di illecito (V. Sez. U, n.26369/2024, Rossetti, Rv. 672372-01).

Nella medesima pronuncia le Sezioni Unite, data la possibilità per il giudice disciplinare, di individuare, entro il limite della ragionevolezza, l'esatta configurazione della violazione in relazione a clausole generali oppure in norme deontologiche speciali, hanno altresì considerato non irragionevole il ravvisare in un comportamento integrante una violenza sessuale a danno di terzi l'illecito, di carattere generale, di cui all'art. 9, comma 2, del codice deontologico (violazione dei doveri di probità, dignità e decoro al di fuori dell'attività professionale), punito più severamente di quello, più specifico, di cui all'art. 63 dello stesso codice (rapporti con i terzi), sanzionato con il semplice avvertimento (Sez. U, n. 26369/2024, Rossetti, Rv. 672372-02).

5.3 Il Consiglio distrettuale di disciplina, elezione dei componenti e natura del giudizio disciplinare dinanzi al medesimo.

In tema di elezione dei componenti del consiglio distrettuale di disciplina, le Sezioni Unite hanno chiarito come la decorrenza del termine per l'impugnazione del procedimento elettorale va individuata nell'atto conclusivo della proclamazione degli eletti, applicando analogicamente, in assenza di norme specifiche, il criterio dettato dall'art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 per il procedimento di elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (Sez. U, 09749/2024, Sestini, Rv. 670758-01).

Quanto alla natura della fase del giudizio disciplinare dinanzi al medesimo consiglio distrettuale forense, Sez. U, 24285/2024, Falabella, Rv. 672189-02, hanno escluso l'ammissibilità dell'accompagnamento coattivo dei testimoni chiarendo che, stante la natura amministrativa di tale organo, lo stesso non gode delle speciali prerogative di tipo coercitivo che sono generalmente riconosciute alle autorità giurisdizionali per fini di giustizia (il carattere amministrativo del procedimento davanti al consiglio distrettuale di disciplina era già stato affermato da Sez. U., 19030/2021, Criscuolo, Rv. 661739-01, la quale aveva conseguentemente escluso l'applicabilità al medesimo procedimento delle disposizioni in tema di astensione del giudice contenute nei codici di procedura civile e penale).

5.4. Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione resa dal Consiglio distrettuale di disciplina.

In relazione alla natura del ricorso al Consiglio Nazionale Forense, le Sezioni Unite hanno precisato che, mentre la prima fase avanti al consiglio distrettuale di disciplina ha carattere amministrativo (si vedano al riguardo le pronunce citate nel precedente paragrafo 5.3), il successivo ricorso al Consiglio Nazionale Forense assume natura e funzione propriamente giurisdizionali e l'atto deve contenere la specifica indicazione dei motivi sui quali si fonda, con la conseguenza che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili anche d'ufficio (Sez. U, 09949/2024, Tedesco, Rv. 670759-01).

Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito come l'avvocato stabilito, secondo la definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs n. 96 del 2001, non possa proporre in proprio, *ex art. 86 c.p.c.*, l'impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense della sanzione disciplinare irrogatagli, in quanto deve ritenersi privo, nel nostro ordinamento, di un autonomo *ius postulandi* e, in base all'art. 8 del d.lgs. n. 96 del 2001, può svolgere, anche in materia disciplinare, attività di rappresentanza, assistenza e difesa soltanto d'intesa con un professionista abilitato (Sez. U, n. 24279/2024, Falabella, Rv. 672188-01).

5.5. L'impugnazione dinanzi alle Sezioni Unite della decisione del Consiglio Nazionale Forense.

In alcune pronunce le Sezioni Unite hanno definito alcuni aspetti della fase di impugnazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense.

In relazione alla censurabilità in sede di gravame di legittimità della scelta della sanzione da adottare, le Sezioni Unite hanno chiarito come le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle medesime Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salvo il caso di sviamento di potere e nei limiti della ragionevolezza, la correttezza nella scelta della sanzione da applicare non è di per sé censurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 26369/2024, Rossetti, 672372-03).

In relazione all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza del Consiglio Nazionale Forense, Sez. U, n. 20877/2024, Grasso, Rv. 671762-01, ha chiarito come la medesima può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso la stessa, alle medesime Sezioni Unite, purché abbia una propria autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, atteso che l'art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012, limitandosi a prevedere che le Sezioni unite possano sospendere l'esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso.

5.6. La riassunzione del giudizio disciplinare a seguito di cassazione con rinvio della decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense.

In relazione al rapporto tra giudizio disciplinare e pronuncia della Corte di cassazione, Sez. U, n. 30886/2024, Tricomi, Rv. 672859-01, ha chiarito che, a seguito della cassazione con rinvio della decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense, la riassunzione del giudizio dinanzi a quest'ultimo organo deve avvenire su impulso di parte, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., con la conseguenza che un'eventuale riassunzione disposta d'ufficio dal medesimo Consiglio non impedisce l'estinzione del processo, secondo i principi civilistici e dispositivi

che regolano questa materia, mentre - aggiunge la S.C. - non possono trarsi argomenti in senso contrario dall'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, il cui art. 59 fissa i principi che regolano il procedimento disciplinare nelle diverse fasi che si succedono dalla formulazione del capo di incolpazione al deposito della motivazione del provvedimento adottato, nonché alle relative notifiche. In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione di inammissibilità emessa dal Consiglio Nazionale Forense rispetto all'impugnazione proposta dal legale che, in precedenza, aveva ommesso di riassumere il giudizio dopo la cassazione con rinvio della decisione del medesimo Consiglio, seguita dalla delibera di radiazione dell'ordine di appartenenza.

6. La responsabilità disciplinare dei notai.

In via generale, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, **Sez. 2, n. 27588/2024, Mondini, Rv. 672820-01**, ha statuito che il giudizio sulla sussistenza di un concorso apparente tra più norme applicabili ad un medesimo fatto si fonda sul raffronto tra gli interessi che esse sono chiamate a proteggere, anziché sulla comparazione tra gli elementi strutturali delle fattispecie, in particolare ove si tratti di illeciti disciplinari a condotta libera, diretti a esercitare un ruolo preventivo a tutela dell'etica professionale della categoria.

6.1. Gli illeciti disciplinari.

Secondo **Sez. 2, n. 27709/2024, Criscuolo, Rv. 672824-01**, sussiste la responsabilità disciplinare del notaio che proceda alla stipula di atti di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, senza eseguire le visure ipotecarie e catastali, ancorché nell'atto si assuma la provenienza del bene in capo all'alienante da un acquisto a titolo originario (privo di accertamento giudiziale), e che ometta altresì di dare avviso all'acquirente del potenziale pericolo sotteso all'acquisto, mentre la stipula dell'atto presso la sede di una delle parti non concreta violazione del divieto di ricorrenti prestazioni presso terzi, o organizzazioni, o studi professionali, previsto dal combinato disposto degli artt. 147, comma 1, lett. b), l. n. 89 del 1913 e 31, comma 2, lett. f), del codice deontologico, atteso che la nozione di terzo è da riferire a soggetti privi di collegamento diretto con la stipulazione (**Sez. 2, n. 27563/2024, Criscuolo, Rv. 672819-02**).

Circa la possibilità di un spostamento degli atti fuori dello studio, **Sez. 2, n. 27563/2024, Criscuolo, Rv. 672819-01**, dopo avere chiarito che la contemporanea previsione, nella legge professionale e nel codice deontologico, di condotte analoghe non crea dubbi interpretativi ove nella fonte sovraordinata sia contenuta tutta la disciplina sanzionatoria - trovando applicazione solo la legge professionale, mentre l'analoga previsione del codice deontologico non assume valore di precetto autonomamente sanzionabile - ha accolto il ricorso affermando che il divieto di spostamento degli atti fuori dello studio, previsto dall'art. 13 del codice deontologico, si ricava già dal combinato disposto degli artt. 26 e 61 l. n. 89 del 1913, cosicché la condotta violativa va sanzionata solo in base alla norma primaria, che prevede, *ex art.* 137 della legge notarile, la sanzione pecuniaria e non la censura.

Sempre in tema di responsabilità disciplinare dei notai, **Sez. 2, n. 30906/2024, Picaro, Rv. 673044-01**, ha affermato che l'art. 147, comma 1, lett. b) della l. n. 89 del 2013, che sanziona la violazione ripetuta dei principi del codice deontologico dei notai, attraverso la sua considerazione in astratto, non tutela un unico interesse alla correttezza del comportamento dei notai, comunque diverso dall'interesse, presidiato dall'art. 147, comma 1, lett. a) della medesima legge, alla tutela della dignità e reputazione del notaio o del decoro e prestigio della classe notarile; sicché, ai fini della sussistenza di un concorso apparente tra

le due norme, occorre individuare e comparare, col suddetto interesse tutelato dall'art. 147 lett. a), i variabili interessi protetti dai singoli articoli del codice deontologico dei notai che sono stati ripetutamente violati.

6.2. Il ravvedimento.

Sez. 2, n. 29707/2024, Criscuolo, Rv. 673039-01, ha affermato che, in tema di responsabilità disciplinare del notaio, la doverosità dell'adempimento non esclude il riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso, *ex art.* 144 l. n. 89 del 1913, purché tale doverosità non sia stata acclarata in un giudizio che abbia già coinvolto il professionista, poiché in tal caso, l'adempimento del notaio, soprattutto se scaturente da un'esecuzione già iniziata, perde il carattere della resipiscenza e della consapevolezza della contrarietà della condotta ai doveri giuridici e deontologici, finendo col perseguire la finalità di far cessare l'aggressione coattiva del proprio patrimonio.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2025
a cura di

IPZS
ISTITUTO
POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO

